REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO *Universidad Francisco Marroquín*

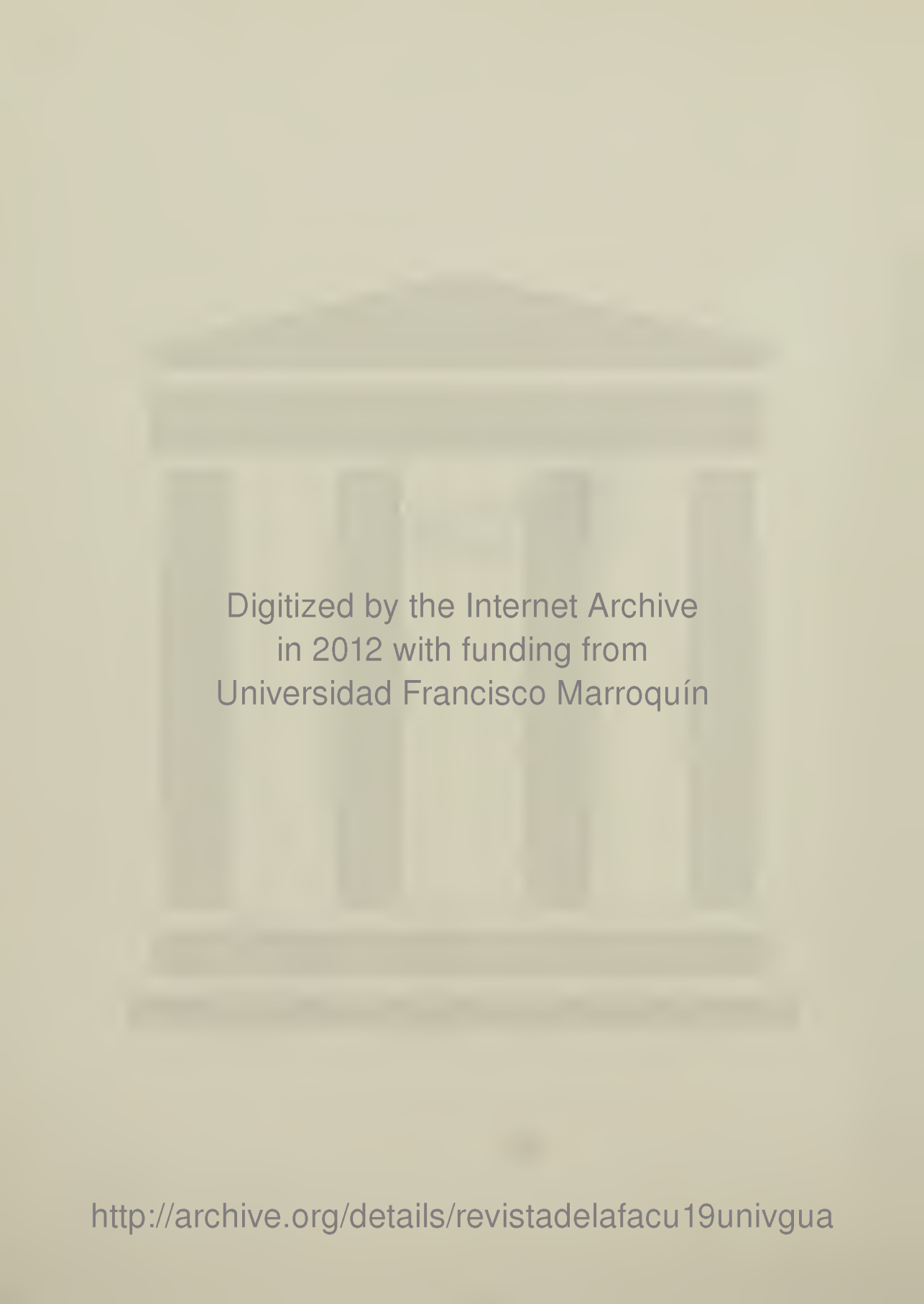
AÑO XI - Nº 19
Marzo de 2001
Segunda época
ISSN 1562-2576



0.05
4r
11 #19
.2001

Portada: Biblioteca Ludwig van Mises, situadas en el campus central de la Universidad Francisco Marroquín.
Fotógrafo: Carlos Rafael Pellecer

BIBLIOTECA
LUDWIG VON MISES
UFM GUATEMALA


Digitized by the Internet Archive
in 2012 with funding from
Universidad Francisco Marroquín

http://archive.org/details/revistadelafacu19univgua

AÑO XI - Nº 19
Marzo de 2001
Segunda época
ISSN 1562-2576

La misión de la *Universidad Francisco Marroquín* es la enseñanza y difusión de los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables.

CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD

Fernando Monterroso
Rector
Giancarlo Ibargüen
Secretario
Ramón Parellada Cuadrado
Tesorero
Vocales
Conrad Losen
Max Holzheu
Jorge Molina-Sinibaldi
William Olyslager V.
Luis Fernando Samayoa

CONSEJO DE LA FACULTAD DE DERECHO

Milton Estuardo Argueta Pinto
Decano

Ana Gisela Castillo de Andrade
Secretario

María Luisa Beltranena de Padilla
Representante docente

Luis Pedro del Valle H.
Representante estudiantil

DIRECTORIO DE LA REVISTA

María Ximena Ordóñez Orellana
Directora
Ana Cristina Garita
Subdirectora

Evaluación y revisión de contenido
Luis Pedro del Valle (*Coordinador*), Fernando Argueta, Mariana Gabriela Barillas, Vivian Cruz, Fernando de la Cerda, Sandra Iriarte, Kristine Klanderud, Vivian Morales, José Enrique Pensabene, Noelle Rivera, Ana Cristina Rodríguez, Javier Ruata.
Distribución y promoción
Vivian Cruz (*Coordinadora*), Fernando Argueta, Ana Lucía Barrios, Fernando de la Cerda, Luis Pedro del Valle, Ana Cristina Garita, Sandra Iriarte, Kristine Klanderud, Vivian Morales, José Enrique Pensabene, Noelle Rivera, Ana Cristina Rodríguez, Javier Ruata, Daniela Sierra.
Fotografía
Carlos Rafael Pellecer

91994

Copyright ©2001 Facultad de Derecho, Universidad Francisco Marroquín, Guatemala.
ISSN 1562-2576

Contenido

Editorial

James M. Buchanan en Guatemala *(Carroll Ríos de Rodríguez)* 7

Derecho

La copropiedad en el derecho tributario (*Guillermo Andrés Castillo Ruiz*) 11

¿Reducir la carga fiscal? *(Luis René Pellecer López)* 15

Importancia de la actividad notarial y registral en el Derecho guatemalteco *(Jorge Andrés Wyld de Nes)* 21

Algunos antecedentes históricos y legislativos del mercado de telecomunicaciones en Guatemala *(Gloria Rodríguez Natareno)* 41

Nueva regulación del mercado de telecomunicaciones en Guatemala *(Gloria Rodríguez Natareno)* 51

Efectos de la exhibición personal al dar cumplimiento a garantías constitucionales procesales *(Luis Pedro Alvarez Morales)* 61

La aplicación de la clonación en la producción ganadera: propuesta de una fórmula jurídica para establecer el vínculo contractual *(Jary Leticia Méndez Maddaleno)* 67

Derecho y Economía

Patentes: costos y beneficios *(Julio H. Cole)* 75

El conflicto entre Marcas y Nombres de Dominio en Internet *(Ada Lissette Redondo Aguilera)* 87

Filosofía

Adiós muchachos (Y no olviden la lección) *(Milton Estuardo Argueta Pinto)* 99

Mil años, cien obras *(Armando de la Torre)* 113

La ley natural, la cooperación social y el orden espontáneo *(Gabriel J. Zanotti)* 117

Etica y mundo de los negocios *(Rafael Termes)* 123

Sección Estudiantil

Contradicciones al Artículo 4º de la Constitución contenidas en los Acuerdos de Paz *(Ana Cristina Rodríguez)* 135

Indice 155



Editorial

CARROLL RÍOS DE RODRÍGUEZ[1]

James M. Buchanan en Guatemala

¿Cuál es la relevancia de la visita que hizo el Dr. James M. Buchanan, Premio Nobel de Economía (1986), a Guatemala del 18 al 21 de enero de 2001?

Esta pregunta tiene dos respuestas. Por un lado, es de considerar la relevancia de la visita para la Universidad Francisco Marroquín como institución. Brindó prestigio a nuestra casa de estudios la venida de otro Premio Nobel (la Universidad recibió hace años a científicos sociales galardonados, como Friedrich Hayek y Milton Friedman), particularmente porque el riguroso trabajo que ha realizado el Dr. Buchanan en el transcurso de su carrera goza de una intachable reputación. Además, las ideas elaboradas por el Dr. Buchanan y sus colegas, que ahora se conocen como la escuela de Opción Pública (*Public Choice*), son también pilares filosóficos de la universidad de la cual fue huésped. El Dr. James Buchanan externó públicamente la grata impresión que le causó la Universidad Francisco Marroquín, no sólo con palabras sino aceptando el Doctorado Honoris Causa que le otorgó dicha institución. Su venida a nuestro país causó un revuelo inusual. Su conferencia magistral del 19 de enero, titulada 'Mi peregrinaje intelectual', fue escuchada por más de 600 personas y despertó el interés no sólo de economistas y miembros de la familia marroquiniana, sino el de un público más amplio y diverso, el cual incluye a periodistas, editorialistas, empresarios, funcionarios públicos y más.

Parte de esta primera respuesta debe abarcar el hecho de que la visita de James Buchanan sirvió tres objetivos. Clausuró dos seminarios que se llevaron a cabo durante las primeras semanas del año, el 'Diplomado Avanzado sobre el Proceso Económico' y el seminario 'Introducción a la Escuela de Opción Pública', e inauguró el Centro de Opción Pública del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, el cual se encargará de hacer crecer la semilla que dejó sembrada el Dr. Buchanan con su presencia.

La visión del Centro de Opción Pública es proporcionar a profesionales guatemaltecos las herramientas de análisis de la escuela de Opción Pública que les permitan aportar y apoyar soluciones políticas para una sociedad de personas libres. Esta meta será alcanzada organizando seminarios y conferencias, publicando documentos, tesis y artículos, acudiendo a programas radiales, instalando el sitio de Internet y realizando otras actividades. En otras palabras, muchas personas en la Universidad se esforzaron por construir algo que cosecharía beneficios a más largo plazo y con repercusiones más permanentes de lo que pueden lograr con una única conferencia aislada.

Por otra parte, la visita de James M. Buchanan es relevante porque sus ideas son pertinentes a la realidad guatemalteca actual. En esta encrucijada histórica buscamos cimentar las instituciones políticas de la paz, la democracia participativa y el crecimiento económico.

James Buchanan y sus colegas explican porqué algunas instituciones democráticas fracasan y otras no. Proveen un diagnóstico realista de los incentivos que imperan sobre los políticos, los burócratas y los votantes -y de cómo estos incentivos nos suelen lle-

1 B.A. en Economía y Ciencias Políticas; M.A. en Estudios Latinoamericanos; y Directora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales y del Centro de Opción Pública en la Universidad Francisco Marroquín.

var a tomar decisiones erradas o ineficientes. Este es un discernimiento novedoso y aplicable a las discusiones políticas en nuestro país. Según la teoría de Opción Pública, el fracaso, entendido como la ineficiente asignación de los escasos recursos a disposición de la sociedad, se da por varias razones. Puede ocurrir porque los grupos de presión más vociferantes logran desviar recursos para satisfacer sus necesidades, que realmente no son prioritarias para el resto de la sociedad, que acarrea con el costo de las mismas. También ocurre porque los políticos no son omniscientes, y pueden tomar decisiones con base en información parcial o irreal. Muchos políticos ponderarán sus intereses profesionales y personales a la hora de decidir, en lugar de concentrarse desinteresada y exclusivamente en el 'bien común'. Tenderán a optar por obtener beneficios de corto plazo, según la longitud de su período en el poder, y postergar los costos en el tiempo, para que éstos no los perjudiquen. Adicionalmente, los mecanismos mediante los cuales consultamos a la población sus demandas, como por ejemplo las votaciones por mayoría simple o el sistema de gobierno por representación, no necesariamente reflejarán correctamente las preferencias de los votantes. Por ello, estos mecanismos también contribuyen al fracaso gubernamental.

No estamos acostumbrados a pensar en estos términos. Tradicionalmente, las ciencias sociales asumen que el gobierno logra resultados positivos. No solemos cuestionar su capacidad de planificación ni de ejecución. Tampoco percibimos que es posible escoger las reglas del juego para disminuir los costos y las ineficiencias. Algunas de las soluciones para hacer más eficiente la gestión pública que son congruentes con el enfoque de Opción Pública incluyen la desregulación, la descentralización y la privatización.

Pero quizás la propuesta de solución más ambiciosa, y la que más inquieta a James Buchanan desde mediados de los años setenta, es la propuesta constitucionalista. Buchanan enfatiza la importancia de contar con una buena *Constitución*, que ponga límites razonables al ejercicio del poder por parte de los gobernantes de turno y que plasme las reglas abstractas y de aplicación general, las cuales deberán gozar de un apoyo casi unánime entre los ciudadanos.

Se podría aducir que los discernimientos de la Opción Pública son aún más relevantes en países en vías de desarrollo, como Guatemala, que en los países desarrollados, porque en los primeros una gran parte de la población es pobre y no se puede dar el lujo de despilfarrar los recursos económicos escasos en fracasos gubernamentales diversos. Estamos a tiempo. Debemos acatar las recomendaciones y las advertencias de la escuela de Opción Pública. Podemos utilizar la Opción Pública como una herramienta, o una forma de pensar, que nos permite escudriñar eventos de la vida pública actual. Este diagnóstico permite, a su vez, formular propuestas de solución.

La visita de James Buchanan a nuestro país marcó el principio de una sana discusión que beneficiará a todos los guatemaltecos.

Lo que ha hecho siempre del Estado
un infierno sobre la tierra es precisamente que
el hombre ha intentado hacer de él su paraíso.

F. Hölderlin

Derecho

GUILLERMO ANDRES CASTILLO RUIZ[1]

La copropiedad en el derecho tributario



El *Código Civil* en su artículo 485, dispone que hay copropiedad cuando dos o más personas son propietarias o tienen dominio, en iguales o desiguales partes, de un mismo bien o de un mismo derecho (proindiviso).

Las fuentes de la copropiedad son semejantes a las que dan origen al derecho de propiedad, ya que se adquieren por los mismos títulos y modos admitidos por el derecho positivo. Pero la copropiedad además presenta particularidades propias como lo son la pluralidad de sujetos y la indivisión de la cosa común, pero con fines de obtener la división futura del bien, para dar la parte correspondiente a cada uno de los copropietarios. Esta parte puede ser en formas iguales o proporcionales a su participación. La prueba clara y evidente de que la copropiedad persigue como fin la división del bien entre los comuneros, es la prohibición que la misma ley establece al pacto de indivisión y la forma en que favorece la legislación la división como cuando establece que en caso de no poderse dar cómoda división, se opta a la venta del bien y su precio se reparte entre los comuneros.

En la copropiedad existe lo que se conoce como una propiedad ideal del todo, es decir, el copropietario no tiene la propiedad exclusiva sobre una parte determinada del bien, sino que su derecho de propiedad se extiende en proporción sobre el todo y no sobre una parte. Se tiene el título de propietario del bien común, pero no el lugar o parte de cada uno.

Como ya se había mencionado anteriormente la copropiedad se distingue esencialmente por la pluralidad de sujetos y su unidad de objeto. Es indispensable la existencia de varias personas dueñas del mismo bien o derecho generalmente denominados copropietarios.[2] Debido a que el bien o derecho debe ser uno y a la vez pertenecer a varias personas, se produce el derecho de usar el bien. Este uso común implica que cada copropietario puede servirse de la cosa, siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad ni impida a los copropietarios usarla según su derecho.[3] Hoy por hoy esta facultad de usar la cosa común debe ejercitarse conforme a lo acordado en un convenio escrito entre los copropietarios. En la práctica este convenio se encuentra manifestado en un reglamento de observancia general para los copropietarios. En defecto de reglamento escrito, suple la ley.

Otra implicación referente al mismo bien proindiviso, es que ninguno de los copropietarios debe tener una parte materialmente determinada en el objeto, por eso se dice que a cada comunero le corresponde una parte alícuota del bien.[4] A raíz de esta situación existente de diversos propietarios sobre un todo indiviso los mismos están sujetos a participar tanto en los beneficios como en las cargas que se generen, siempre y cuando sea de manera proporcional a sus respectivas cuotas. Así como pueden obtener rentas o productos,

1 Abogado y Notario.

2 También se les conoce como condueños, comuneros, copartícipes o condóminos.

3 Artículo 487 del *Código Civil*.

4 En principio las cuotas de los partícipes se presumen iguales. Esa presunción legal (artículo 486) admite prueba en contrario, debe entenderse que a falta de convenio las cuotas de los copartícipes se presumen iguales, las cuotas conllevan una división ideal o abstracto. Surgen varias consecuencias de esa división ideal de la cosa común.

también deben contribuir tanto con los gastos necesarios para la conservación de la cosa común como con el pago de los respectivos impuestos generados en la copropiedad.

Todos los copropietarios tienen derecho a gozar de la cosa, sus derechos y obligaciones son iguales, pero se puede dar el caso que sus obligaciones sean distintas, inclusive a las de los demás copropietarios, como se da en el caso de un acotamiento, es decir la explotación de una parte de la cosa a un copropietario en particular.

Es importante diferenciar la copropiedad de una sociedad. Tratar de explicar la copropiedad como una sociedad obliga a forzar mucho los conceptos. La copropiedad supone un dominio común y ejercido sobre cada una de las unidades indivisas, antes de la partición. Concebirla como una sociedad, implica imponer a los copropietarios y a la figura una distorsión de la misma que no está en su ánimo ni en la esencia de la institución. Al pretender equipararlas, se alienta la disolución de la copropiedad por las ventajas de gestiones económicas del dominio privado. Las sociedades se planean para larga duración. Su personalidad abstracta predomina sobre la de los integrantes, en la copropiedad la personalidad de cada uno de los partícipes aparece definida. Existen marcadas diferencias respecto a la constitución, duración y extinción de ambas.

En materia fiscal la copropiedad es considerada como una figura particular con obligaciones propias. Esta afirmación no es fácil ni nueva, ya que en la doctrina se ha discutido si, además de las personas, pueden ser sujetos pasivos de la obligación fiscal las agrupaciones que constituyen una unidad económica diversa de sus miembros y que carecen de personalidad jurídica. Sobre este problema la doctrina ha aceptado la posibilidad de que las unidades económicas[5] sean capaces de ser sujetos de derecho en materia tributaria y, por lo tanto, pueden reunir la calidad de sujeto pasivo de la obligación fiscal. Se sostiene que al aceptar que el sujeto de derecho se define como un centro de imputación de derechos y obligaciones, resulta que es estrecha la dicotomía tradicional de personas físicas y personas jurídicas, por lo tanto siempre que se esté frente a un hecho imputable de derechos y obligaciones se estará frente a un sujeto de derecho, independientemente del tratamiento que les dé el Derecho Privado.

La organización y funcionamiento del Estado necesariamente implica la realización de gastos y la procura de los recursos económicos indispensables para cubrirlos, lo cual origina la actividad financiera del Estado. Para esto el Estado puede adoptar el criterio de vinculación que consiste en el señalamiento por la ley de cómo, cuándo, dónde, y por qué surge el nexo entre el sujeto activo y el sujeto pasivo de la obligación tributaria. En la legislación guatemalteca, los diferentes cuerpos legales imponen obligaciones fiscales para las copropiedades.[6] Por esta razón se considera lógico y jurídicamente posible que los ordenamientos tributarios permitan que las unidades económicas carentes de personalidad jurídica, es decir las copropiedades, operen como elemento personal configurador del hecho imponible. Las copropiedades constituyen un hecho diferente a los miembros que la forman y debido a la posibilidad de la existencia de obligaciones ajenas (en caso de acotamiento de la cosa) se convierten, en sí mismas, en un centro de imputación de derechos y obligaciones, reconociéndoseles así el carácter de sujeto pasivo de la obligación fiscal.

Para Dino Jarach,[7] la capacidad de ser contribuyente consiste en la posibilidad de hecho de ser titular de las relaciones económicas que constituyen los hechos imponibles. Una contribución es un concepto genérico que engloba a todo lo que auxilia a subvencionar los gastos del Estado, de ahí el término 'contribuyente'. Nuestra legislación distingue dos clases de sujetos pasivos.[8] Por un lado están los contribuyentes y por otro

5 Procedo a aclarar que la copropiedad no es más que un hecho y no se refiere más que a la posición que los copropietarios tienen sobre los bienes o derechos.

6 Artículo 3 *Ley del Impuesto sobre la Renta*. Contribuyentes [...] Para los efectos de esta ley los entes, patrimonios o bienes que se refieren a continuación se consideran como sujetos del ISR: [...] las copropiedades [...] Artículo 2 numeral (7) del *Reglamento del ISR*. [...] las copropiedades deben inscribirse como contribuyentes [...] Artículo 3 del *Reglamento del ISR*. Obligación de tener un número de identificación tributaria (NIT). El artículo 2 y 6 de la *Ley del IVA*: [...] serán contribuyentes o sujetos pasivos [...] las copropiedades. Entre otras.

7 Dino Jarach, 1943.

8 El sujeto pasivo de la obligación fiscal es la persona que conforme a la ley debe satisfacer una prestación determinada en favor del fisco, ya sea propia o de un tercero.

los responsables. El artículo 21 del Código Tributario tipifica a los *contribuyentes* como las personas individuales o jurídicas, que realizan o respecto de las cuales se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Pero a la vez considera como *responsables* en situaciones especiales como la copropiedad a los mismos copropietarios, porque en virtud de lo abstracto de la situación debe existir alguien físicamente que se haga responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Por lo tanto la copropiedad tiene sus deudas propias y es considerada un contribuyente, pero para evitar problemas por carencia de personalidad y como consecuencia de la abstracción que implica la copropiedad entonces, por razones prácticas de cobro, la ley atribuye a una persona ajena a la relación fiscal la responsabilidad del pago, en caso se presente cualquier dificultad para cobrar al titular de la deuda. Esta circunstancia no exonera, ni debe hacerlo, de su responsabilidad originaria al contribuyente titular de la deuda.

Estas cargas denominadas impuestos no son tributos establecidos en virtud de decisiones arbitrarias, sino una contribución que se basa en las cargas de la vida social. Los impuestos deben ser proporcionales a las posibilidades económicas de los contribuyentes, a las rentas o al capital. Por lo tanto una vez que se ha realizado el hecho previsto por la ley impositiva, o sea que se ha realizado lo que se llama hecho generador, surge la obligación tributaria, y por lo tanto, hay un sujeto activo y un sujeto pasivo de la obligación, siendo siempre el sujeto activo el Estado. Y en este caso como ya se discutió, las copropiedades son sujetos pasivos con responsabilidad parcialmente directa y parcialmente solidaria. Ya que a cada copropietario se le puede exigir el total del adeudo y no sólo la parte que le corresponde.

Ahora surge la interrogante de cómo opera esta tributación en la práctica. No podemos concebir a la copropiedad presentándose ante la Administración Tributaria y solicitando por si misma su número de NIT.[9] Y en términos amplios no podemos considerar a la copropiedad ejerciendo ningún acto de manifestación de voluntad por sí misma, ya que no tiene ni capacidad ni personalidad. Por lo tanto la ley manda a los responsables a solicitar a la Administración Tributaria la inscripción correspondiente. Si bien es cierto que la costumbre no es una fuente formal de derecho en nuestra legislación, en el caso del procedimiento para la tramitación de éstos asuntos en la esfera administrativa, sí cabe esta posibilidad, porque ante la falta de regulación detallada en este campo se originan las 'prácticas' que son seguidas puntualmente por el personal de la Administración, cuya continua repetición y concepto de ser obligatorias han llegado a crear normas de procedimiento. Cuando uno solicita su número de identificación tributaria, sólo existen dos opciones para llenar el formulario, ya sea como persona individual o como persona jurídica. Esto presenta un problema porque la copropiedad no es ninguna de las dos, es sólo una situación de hecho, y en este campo del derecho tributario, resulta una situación especial sujeta al pago de impuestos. Por lo tanto para poder solicitar el NIT, la Administración Tributaria requiere de una patente de comercio. Esto nos puede parecer contradictorio a primera vista e inclusive dificultoso. Cuando nos presentamos ante el Registro Mercantil y deseamos solicitar una patente de comercio para una copropiedad, el formulario tampoco nos da esa opción, sino que los datos se llenan según sea una persona individual o empresa. Una vez más la copropiedad tampoco encaja ahí. Por lo tanto lo que se hace es que cada copropietario llena un formulario como persona individual debiendo, además, presentar sus documentos de identificación y en un mismo expediente lo entregan haciendo la salvedad que se unen las solicitudes en virtud que el prestador de servicios será la copropiedad. Pero aún así falta otro elemento. En principio para la administración del bien común son obligatorios los acuerdos de la mayoría de los partícipes. Este precepto legal también permite que los copartícipes firmen un convenio (reglamento) de administración evitándose así el requerir en cada oportunidad la opinión de todos los condueños. Por lo tanto, cuando solicitamos, ya sea, la patente de comercio o el NIT ante la Administración Tributaria, es indispensable indicar a un administrador. Pero el Registro Mercantil en los casos de copropiedad pide que sea un factor.[10] El factor debe ser constituido mediante mandato con representación.

9 La Administración Tributaria es la encargada de asignar un número de identificación (NIT), el cual deberá indicarse en toda actuación que se realice ante dicha Administración en las facturas y recibos que emitan.

10 Artículo 263 *Código de Comercio*: Son factores, quienes sin ser comerciantes tiene la dirección de una empresa o de un establecimiento.

Una vez extendida la patente de comercio cualquier copropietario puede solicitar el NIT presentando también el formulario y demás requisitos establecidos por la Administración Tributaria. Lo único que se debe hacer constar es qué tipo de organización es, todos los datos de la patente y quién es el factor. Estos datos se llenan en el espacio indicado para personas jurídicas, y el factor se indica en el espacio para representante legal. La copropiedad no adquiere la calidad de tal por el simple hecho de plasmar sus datos en la sección de persona jurídica, ni el factor se vuelve representante legal, es sólo una formalidad que carece de efectos constitutivos.

El hecho que la copropiedad sea contribuyente, no implica que los copropietarios no puedan serlo, al contrario cada quien individualmente es contribuyente, lo único es que la doble o múltiple tributación no es permitido. Y es por eso que la ley es la que debe indicar qué ingresos o bienes serán imponibles. De la realización del presupuesto legal conocido como hecho imponible surge una relación jurídica que tiene la naturaleza de una obligación. En esta obligación tributaria[11] la calidad de deudor o sujeto pasivo puede adquirirla una agrupación económica distinta a sus miembros y que a la vez carezca de personalidad jurídica. Sin olvidar que dependiendo de las actividades que se realicen en la copropiedad así llegarán a ser o no objeto del gravamen, estas actividades consisten en una realidad económica sujeta a imposición y como ejemplos podemos citar la renta obtenida, la circulación de riqueza, el consumo de bienes o servicios entre otros.

En conclusión parece interesante analizar la dicotomía existente entre derecho público y derecho privado y cómo cambian las concepciones dependiendo del campo en el que nos encontremos. El derecho tributario no se interesa por los problemas del derecho privado, al tratarse de impuestos, la obligación tributaria nace en el momento en que se realiza el hecho jurídico previsto por la ley, siendo ese el único requisito requerido desde el momento en que se actualiza el supuesto. Y con respecto a la facturación en la copropiedad, es interpretación no sólo del Ministerio de Finanzas, sino también de la *Ley al Impuesto al Valor Agregado* (IVA), que son responsables del pago del IVA, todos los copropietarios con respecto a su parte proporcional, y en donde paga el factor por todos los comuneros en nombre de la copropiedad sin tener representación legal. Se emite una sola factura a favor de la copropiedad y no varias facturas a cada uno de los copropietarios, por lo que se emite la factura sin que nadie de ellos pueda aprovechar el crédito fiscal sino que se absorba como consumidor final.

Bibliografía

Cabanellas, Guillermo
1994 *Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.* 7 tomos. Buenos Aires: Editorial Heliasta.

Carrillo Marroquín, Ana Lucía
1992 *Condominios urbanizados, necesidad de su regulación legal.* Trabajo de Tesis. Guatemala: Universidad Francisco Marroquín.

Códigos
1964 *Código Civil.* Decreto ley 107.
1991 *Código Tributario.* Decreto ley 6-91.

Espín Cánovas, Diego
1968 *Manual de Derecho Civil.* 2 volúmenes. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado.

González Mijangos, Vilma Consuelo
1996 *El condominio como nueva forma de copropiedad.* Trabajo de Tesis. Guatemala: Universidad de San Carlos.

Jarach, Dino
1943 *El hecho imponible.* Buenos Aires: Edición de la Revista de Jurisprudencia Argentina S.A.

Leyes
1992 *Ley del Impuesto Sobre la Renta.* Decreto ley 26-92.
1992 *Ley del Impuesto al Valor Agregado.* Decreto 27-92.

Reglamento
1997 *Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.* Acuerdo Gubernativo Número 596-97.

Rodríguez Lobato, Raúl
1983 *Derecho Fiscal.* México: Editorial Harla.

11 En el artículo 14 del *Código Tributario* la obligación tributaria se define como un vínculo jurídico de carácter personal, entre la Administración Tributaria y otros entes públicos acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. Tiene por objeto la prestación de un tributo, surge al realizarse el presupuesto del hecho generador prevista en la ley [...]

LUIS RENE PELLECER LOPEZ[1]

¿Reducir la carga fiscal?



Sumario

Introducción
1- Análisis: subir o bajar los impuestos
2- Efectos de una reducción de impuestos
Conclusión
Bibliografía

Introducción

> *'Cabe imputar a posteriores economistas no poca responsabilidad por el confusionismo en estas materias imperantes. También es verdad que hay buenas razones para creer que cuantas inquietudes experimenta el gobernante de intervenir en el ámbito económico son sospechosas y que, sobre todo, existe una fuerte prevención contra la directa participación estatal en la actividad mercantil. Ahora bien, tales razones en absoluto difieren de las generales a favor de la libertad y se apoyan en el hecho de que una buena parte de las medidas que propugna el poder público en este campo son de hecho ineficientes, bien porque se traducen en un fracaso o porque su coste sobrepasa a los beneficios logrados'.* [2]

Los impuestos son necesarios para el desarrollo en sociedad. Éstos son la fuente principal de ingresos del Estado y sin éstos, sería muy difícil que el gobierno lleve a cabo sus funciones. Sin embargo, ¿cuál es el efecto del impuesto en una sociedad? Ya se sabe la importancia de establecer las funciones del Estado para que su actuar no sobrepase e interfiera más allá de lo que le corresponde. El monto de impuesto que ha de ser recaudado tiene un estrecha relación con las funciones que el Estado realiza. El determinar cuánto impuesto ha de recaudarse no es una tarea sencilla, más bien es de gran trascendencia, por ello la Constitución Política de la República[3] ha encomendado tal función al organismo más representativo de la voluntad de sus habitantes, el Legislativo.

El propósito del presente trabajo es presentar un análisis sencillo en el cual se pretende hacer notar la importante relación que se da entre el derecho y la economía con relación a la carga fiscal. Se incluirá dentro del mismo un razonamiento que supone ser similar al utilizado por el Congreso de la República, al decidir sobre impuestos. Asimismo, se examina y analiza la función constitucional que se le ha encomendado en materia tributaria a dicho órgano y los posibles efectos de incrementar o disminuir la carga tributaria.

La Constitución Política de la República establece en el artículo dos que es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Sobre esta disposición, el Congreso de la República, por ser parte integral del Estado, está obligado a velar por que sus actuaciones estén encausadas dentro de esta norma constitucional.

'En efecto, la influencia del positivismo jurídico ha consolidado nociones contrarias a la permanencia

1 Abogado y Notario.

2 Friedrich A. Hayek, 1975:306-307.

3 *'La virtud de la Constitución no es de carácter instrumental. No sirve para lograr fines u objetivos específicos sino, simplemente y llanamente, para asegurar el mantenimiento de ciertos principios elementales de la acción legítima del Estado. Su máxima virtud, por tanto, es la de ser estable y duradera, de manera que se convierta en fuente de estabilidad institucional'* (Carlos Boloña Behr, 1995:153).

de normas generales y no discriminatorias. Mientras se creía que la ley podía hacerlo todo y que todo lo que emanaba de la autoridad era ley, independiente de sus características cualitativas, se favorecía cualesquiera posiciones políticas contrarias al Estado de Derecho y la Economía de Mercado.

No se puede proteger los derechos para que la gente se fije fines y establezca medios materiales libremente si es que el Estado tiene una idea preconcebida sobre lo que debe ser el orden social. Concebido el derecho como un instrumento de 'corrección' del orden social, cuando no de creación y diseño del mismo, obviamente no cabe proteger de manera uniforme y no discriminatoria los derechos de las personas'.[4]

Al Congreso de la República dentro de sus atribuciones, se le presentan varias opciones con relación a los tributos. El artículo 171 de la Constitución Política de la República establece que el Congreso de la República está facultado para: *'a) Decretar, reformar y derogar las leyes; c) Decretar impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a las necesidades del Estado y determinar las bases de su recaudación'.* Por otro lado, el artículo 239 del mismo cuerpo legal indica que: *'Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes: a) El hecho generador de la relación tributaria; b) Las exenciones; c) El sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria; d) La base imponible y el tipo impositivo; e) las deducciones, los descuentos, reducciones y recargos; y f) Las infracciones y sanciones tributarias'.* De lo anterior se puede inferir que la misma Constitución Política de la República le autoriza al Congreso de la República para hacer todo lo relativo a los impuestos, pero debe hacerlo de conformidad con las necesidades y beneficios del Estado.

Sobre este punto se puede dar una disyuntiva, por un lado, el Congreso de la República tiene que brindar al Estado los medios necesarios para poder cumplir sus funciones, y por otro, tiene la obligación con los habitantes de garantizarles su libertad, paz, seguridad, justicia y desarrollo integral. Esta disyuntiva se daría si es que los intereses del Estado se encuentran en contradicción con los de los habitantes. En teoría, los intereses del Estado van encaminados en la misma dirección que la de sus habitantes, pero se puede dar que quienes ejercen el poder en nombre del Estado, en algunas ocasiones actúen por intereses propios en vez de actuar por el interés colectivo.[5] Por lo que de esta forma es posible que se dé una dualidad de intereses. Las posibilidades de este supuesto acontecer, se podría limitar al tener bien definidas las funciones y rol del Estado, ya que ayudaría a prevenir que los gobernantes se extralimiten de sus facultades.

Al Congreso de la República, en materia tributaria, en términos generales se le presentan tres opciones. La primera, sería no modificar nada; la segunda, subir la carga tributaria; y por último, bajar los impuestos. ¿Cuál de ellas ha de adoptar? En la práctica, esta pregunta la responde la política económica del gobierno de turno. Son los gobernantes quienes poseen el poder para decidir qué ha de hacerse. Ellos son los que tienen de su lado el poder de la infraestructura del Estado. Estas personas, estando o no conscientes de la responsabilidad de su decisión, debieran saber que cualquier cosa que decidan tiene consecuencias, por lo que se debiera elegir la que conlleve a menos resultados negativos y beneficie a más personas.

1- Análisis: subir o bajar los impuestos[6]

A continuación se verán posibles efectos como consecuencias de subir o bajar la carga fiscal.[7] Es por eso que se dan dos posturas: en primer lugar, la que indica

4 Carlos Boloña Behr, 1995:152.

5 *'El ejercicio del poder público es entonces, tal vez, inexorable y compulsivo. Creer que los titulares del poder público -quien quiera que sea- son capaces de autolimitarse sistemáticamente, de abstenerse de mandar, aún teniendo el poder para hacerlo, sería un costoso y lamentable error. Es casi una máxima que nunca se propende a ejercitar menos poder del que se tiene, sino que por el contrario, la propensión natural es que el ejercicio del poder propenda a excederse de los límites predeterminados'* (Eduardo Mayora Alvarado, 1997:71).

6 En este análisis, al tratar la reducción, se entiende que tiene que ser en la medida en que puedan pagar los gastos del Estado, por lo que en la medida que el Estado intervenga menos, en esa medida, se podrá reducir en algún porcentaje la carga fiscal.

7 En el presente trabajo se desarrolla el análisis en base a la reducción o incremento de la carga fiscal. No se analiza la opción en

que bajar los impuestos perjudica el presupuesto balanceado provocando problemas aún peores que los existentes en relación a la deuda nacional que se tiene, y en segundo lugar se encuentran los que sostienen que la reducción de impuestos estimularía la economía y provocaría un incremento en las ganancias y por ende en el poder adquisitivo de los individuos (salario real).

La tesis por quienes abocan la reducción, sostiene que se debe reducir el impuesto en relación a cada ganancia de unidad monetaria (quetzal). Esto tendría como consecuencia el incremento en la producción, debido a que los contribuyentes poseen más recursos para disponer de ellos a su libre elección, a tal grado que los ingresos percibidos por el Estado se mantendrían estables o posiblemente se incrementen debido al aumento sobre lo cual recae el impuesto.

A diferencia de la mayoría de políticos, a los economistas les parece muy lógico que reduciendo los impuestos, el ingreso total percibido por parte del Estado al final del ejercicio fiscal sea mayor. Por lo que su propósito es incrementar la recaudación fiscal mediante la reducción de impuestos. El punto en cuestión es ¿cómo es posible que sea mayor lo recaudado al bajar los impuestos que teniendo los impuestos a un nivel más alto?

Los ingresos fiscales por el incremento en la producción dependen especialmente de dos aspectos. Primero, ¿qué tan grande es el incremento en la producción en comparación con la reducción de impuestos?; y segundo, ¿qué tan grande es el incremento en la producción con relación a cada quetzal invertido?, esto viene a ser la productividad marginal del capital.

Es evidente que la decisión de reducir los impuestos es compleja, ya que el resultado en el incremento en la producción de estos cambios ha de ser enorme para mantener el total de ingresos por parte del Estado y evitar que se tenga una baja. A simple vista pareciera que la mejor opción es reducir los impuestos, sin embargo, la historia ha demostrado que como resultado de la baja en la carga tributaria, los Estados tienden a incrementar su déficit ya que el gasto se mantiene pero el ingreso se reduce. Esto es posible debido a que la simple reducción no reacciona en el mismo grado que el de la inversión, por lo que en vez de tener un superávit, el gobierno se endeuda y de esta forma, se perjudica a todos. Esto fue lo que sucedió cuando el Presidente Ronald Reagan trató de reactivar la economía.[8]

Dentro de este esquema se da una situación condicional la cual consiste en que la reducción de la carga tributaria traería beneficio si y tan sólo si de tal reducción se lleva a cabo un incremento bastante alto en las inversiones. La mayoría de economistas, a diferencia de la evidencia, creen que la reducción de impuestos en realidad estimularía la inversión hasta cierto grado. Sin embargo, reduciendo la carga fiscal para incrementar lo que se recauda, parece ser algo de poca probabilidad debido a que la inversión y producción que se requiere dar, produzca dicho efecto que es de alto nivel.[9]

Los críticos[10] sostienen que la tesis por quienes promueven la reducción de la carga fiscal, traería como resultado el incremento en el déficit del gobierno. Como respuesta a lo anterior, los promotores de dicha tesis sostienen que eso no es factible que suceda, ya que la reducción de la carga fiscal sería recaudada en una producción más grande. '*Y, con una cierta capacidad para hacer tales predicciones, los individuos pueden anticipar y planear sus propias respuestas de ajuste. Si la asignación de la base impositiva se hizo con cuidado, los individuos estarán protegidos de la explotación fiscal indebida sin necesidad de restricciones más complejas sobre la autoridad fiscal*'.[11] A largo plazo es posible que esto suceda pero la historia ha mostrado lo distinto. Nadie duda que la reducción de los impuestos estimularía, hasta cierto grado, la inversión e incrementaría la productividad. Para mantener los ingresos fiscales, de darse la reducción, el incremento en la inversión tendría que ser demasiado grande, tan grande que la probabilidad de tener éxito

donde los impuestos no varían, ya que es cuestión de tiempo para que sea modificado y de no cambiar, la sociedad se encuentra en términos generales, en igualdad de circunstancias, por lo que no varían sus efectos.

8 http://william-king.www.drexel.edu/top/prin/txt/ASapp/cider4.html.

9 En términos de oferta y demanda, la opción de reducir impuestos con el fin de incrementar lo recaudado pareciera que sí podría funcionar, pero en realidad es muy difícil que suceda.

10 http://william-king.www.drexel.edu/top/prin/txt/ASapp/cider4.html.

11 Greoffrey Brennan y James M. Buchanan, 1987:249.

es casi nula. Lo que más parece ser, es que la reducción de cargas tributarias acarrean consigo un aumento en el déficit, provocando incrementos en los intereses que han de pagar las generaciones futuras.[12]

Posiblemente el tema propuesto por la oferta sobre la reducción de los impuestos, es una proposición que parece ser que viene y se va con cierta regularidad en las políticas económicas. Esta sugerencia puede ser analizada en términos de oferta y demanda. Aquellos que discuten los distintos puntos de vista sobre la proposición de la oferta (reducción de impuestos), posiblemente aprenderán varias lecciones del análisis antes descrito. Por una parte los que favorecen la disminución de la carga fiscal posiblemente aprenderán que sí es posible el éxito de tal política económica. Por otra parte, los que se oponen a tal política, aprenderán que es poco probable que esto en realidad tenga éxito. Sin embargo, ambos estarían correctos.

Como se puede observar, la decisión por parte del Congreso de la República en cuanto a disminuir o no la tasa impositiva lleva consecuencias que pueden llegar a hacer más positivas que negativas según la situación del Estado. La decisión de elevar la carga impositiva tendría entre sus consecuencias una baja en la producción del Estado, como resultado de empobrecer a los contribuyentes quienes poseerían menos recursos para destinarlos como consideren más conveniente para su interés. Incluso podría darse el caso en el cual se provoque una recesión en la economía nacional, en detrimento del interés del Estado y de sus recursos económicos. Por el contrario si se decide bajar la carga fiscal, es cierto que los contribuyentes tienen más recursos para disponer de ellos e incluso aumentaría la inversión, sin embargo, el sector público se vería afectado en cuanto a los ingresos a corto plazo.

Por lo anterior, la medida a tomar no es fácil desde ningún punto de vista, sin embargo se considera que lo más beneficioso sería que hubiera una reducción en la carga fiscal. Es muy probable que el Estado disminuya su caudal de recursos recaudados, pero es importante establecer que aunque no se invierta lo necesario para mantener la misma recaudación, en algo ayuda a los contribuyentes, ya que éstos son los mejores administradores de sus recursos, por lo que el Estado se beneficiaría.[13]

2- Efectos de una reducción de impuestos

A continuación se estudia la ventaja económica de la reducción de impuestos. Anteriormente se aclaró que es posible que la reducción traiga más problemas que soluciones, sin embargo, la experiencia nos ha enseñado que la simple reducción tiene sus beneficios. Es imposible poder abarcar todo el ámbito en el cual puede llegar a influir. Aquí se trata de resolver el dilema de si la reducción es positiva o no.

El Congreso de la República juega un papel de suma importancia ya que de éste dependerá algunos de los efectos que se verán a continuación. La ley, el medio de imposición más efectivo en sociedades modernas, se hace responsable del desarrollo de cada sociedad en particular. Es difícil imaginar cómo es posible que una norma jurídica tenga tanto impacto en la sociedad, en especial cuando ésta invade el ámbito de la moral, la propiedad o limita la libertad. Al emitirse normas en relación a los impuestos que ha de hacer efectivo cada contribuyente en particular, la ley se ha introducido en todas las mencionadas esferas de interacción humana. El resultado es sorprendente, y dependerá con relación a la aceptación de la ley por la sociedad. Es así que lo más sensato a hacer es apoyar un reducción no sólo en el presupuesto nacional sino en la cantidad de recursos recaudados por el Estado.

Dentro de los posibles efectos de una legislación que tienda a reducir la carga tributaria, es posible que se logre una inversión más intensa o con mayor magnitud; esto hasta cierta medida, provocaría una constante recaudación en los tributos, o su posible aumento. Por lo tanto, las reservas en el presupuesto nacional son muy posibles que aumenten. Como consecuencia de esto, la reducción en la carga fiscal, provocaría que el Estado se encuentre en una situación más sana con relación a sí misma en comparación al caso de incrementar los impuestos.

Así, en cuanto a la calificación de los bonos emitidos por el Estado, por estar respaldados con sus ingre-

12 En los Estados Unidos de Norte América esto fue lo que pasó en los años de 1960's y los 1980's.
13 Este es un cálculo económico, donde lo que traiga mayor beneficio contable, se debiera de hacer.

sos por el derecho que posee de tributar, se ha dicho y analizado que si hay una reducción en los impuestos, se da un deterioro fiscal, por lo que la calificación de los bonos se deprecia. Sin embargo, en la práctica y en países que han reducido impuestos, el resultado es contrario, se ha observado que en los lugares donde ha habido una disminución en la carga impositiva, los bonos tienden a tener una mejor calificación, contrario a lo que usualmente se ha dicho.[14]

Comúnmente se ha empleado en política la idea de reducir los impuestos con el fin de conseguir votos; sin embargo, lo ofrecido no siempre se cumple. A las personas les gusta, como es natural, que le quiten menos de sus ganancias, es por ello que como resultado, se ha visto que en los lugares donde ha habido una reducción en la carga tributaria, la población (natural y de inversión o jurídica) tiende a aumentar. Siendo los pobladores quienes en definitiva mueven la economía de dicho Estado.

Las empresas, compañías, trabajos, entre otros, emigran a los lugares donde los impuestos son más bajos. La historia nos ha enseñando que en los lugares donde se han subido los impuestos, el crecimiento de empleos o se ha mantenido igual o ha disminuido; mientras que en los lugares donde los han bajado el crecimiento de nuevos empleos se ha incrementado notablemente.[15] Esto va muy relacionado con la tasa de desempleo. Se ha dado a tal punto que a los políticos les interesaba que hubiera desempleo para que así ellos tuvieran algo de que hablar y poder componer. Sin embargo en los últimos años esta tendencia ha cambiado, ahora pareciera ser que en realidad se trata de hacer lo posible para que disminuya el desempleo. Lo que se ha visto en otros Estados es que en lugares donde se aumenta la carga fiscal, el índice de desempleo aumenta, contrario a lo que sucede en Estados donde se ha disminuido, logrando mayor progreso. Un ejemplo claro de esto era Hong Kong hace unos años, considerado el lugar más libre de toda la tierra; prácticamente no había desempleo y el nivel de progreso era altísimo. Esto está sucediendo ahora en Nueva Zelandia.

En los Estados donde se ha reducido la carga tributaria, se ha comprobado que los ingresos han aumentado, a diferencia de lo que sucede en Estados con política de incrementar la carga fiscal.[16] En el caso de los ingresos per capita, sucede lo mismo, en los lugares donde se reducen los impuestos, se incrementa el nivel de vida de las personas.

La economía de un Estado no es independiente. Esta se relaciona con otro tipo de circunstancias o hechos que transcurren alrededor de una sociedad. La reducción en la carga fiscal, no garantiza que el nivel de vida de sus habitantes va a mejorar ya que mucho de los resultados dependen de la política del gobierno de turno. Probablemente mejore la economía, tanto del Estado como la de sus ciudadanos, pero esto también depende de muchos otros factores.

Conclusión

Lo que se ha pretendido establecer en este trabajo es determinar la importante labor que tiene el Congreso

14 Esto es posible ya que la misma legislación ha restringido su ámbito de aplicación por lo que en términos generales, los contribuyentes son más libres de hacer lo que consideren que tiene más beneficio. Por el contrario, el estudio que se hace es que por la misma reducción tributaria, el Estado estará en una posición de poca liquidez o desajustado a su presupuesto, por lo que los bonos estarán afectados por la economía del Estado. El resultado es contrario, donde más libertad, más opciones y mejores resultados. Esto fue lo que publicó un artículo de la organización CATO lo cual ocurrió en algunos de los Estados del los Estados Unidos de América.

15 Esto es posible de apreciarse con bastante claridad en el caso de los Estados Unidos de América, en el cual se ha visto que hay una fuerte tendencia a que en los Estados se reduzcan impuestos. Como consecuencia de esto, actualmente, los Estados Unidos se encuentra con una economía bastante fuerte y sólida, y los índices de desempleo se encuentran en uno de los puntos más bajos de su historia. Esto en comparación con Europa, donde se tiene una política impositiva contraria a la ya mencionada, es posible apreciar que sus economías están hasta cierto punto en malas condiciones. Este fenómeno ha llegado a tal extremo, que Europa en lugar de crecer (población), se ha contraído con el paso de cada año. El resultado es sorprendente, ya que se logra visualizar los efectos hasta cierta medida, de un tipo de legislación que tiende a restringir a sus contribuyentes y decidir que hacer con sus recursos.

16 *'a) actividad financiera de finanza clásicas, en la que dadas determinadas necesidades económicas de la sociedad la actividad financiera debe satisfacerlas sólo mediante determinados ingresos públicos; b) actividad financiera de finanza moderna, en la que tiende a lograrse determinadas utilidades a través de ciertas medidas de política económica y fiscal; podría concluirse que la primera acoge la postura de un Estado liberal de corte abstencionista en su actividad económica, mientras que la segunda obedece más bien a la postura de un Estado intervencionista, beligerante en la vida económica'* (Francisco José Carrera Raya, 1993-1:28-29).

de la República al legislar sobre impuestos. La legislación no está separada de otros factores que conforman la sociedad, como lo es la economía. Pareciera ser que el Congreso de la República tiene el poder de hacer con la ley lo que crea más conveniente, pero tiene que tener claro que sus efectos, de no estar correctamente dirigidos, pueden tener consecuencias nocivas al desarrollo de la sociedad. Por eso la misma Constitución Política de la República debiera tener bien delimitada la función del Estado.

El tema de los impuestos es muy amplio, lo que se intenta hacer notar con el presente trabajo es que una decisión del Congreso de la República, como la de subir o bajar la carga fiscal, trae consigo efectos más serios de lo que aparenta para el desarrollo de una nación. Sobre las ideas de reducir impuestos, la primera impresión es que la reducción tiene beneficios a tal extremo que el presupuesto del Estado no se vería afectado por lo que no habría inflación. La realidad es distinta, por lo general, una decisión de este tipo tiene efectos negativos en el presupuesto del Estado y por ende a la sociedad mientras se ajusta el gasto público al nuevo nivel de recaudación. Por otro lado se ha notado que, no importando la velocidad de reacción de la inversión para mantener balanceado el presupuesto del Estado, el simple hecho de reducirlo tiene beneficios.

La posición que se apoya es que lo más conveniente para el desarrollo de la sociedad es bajar los impuestos. Cada contribuyente sabrá qué debe hacer para obtener mayores beneficios de sus recursos. Lo más recomendable sería la reducción de la carga fiscal, sabiendo de antemano que es posible que la inversión en la producción no se dé al mismo nivel que la misma reducción. Sin embargo, lo más sensato es que se dé una reducción en el tamaño del Estado, en la medida que pueda ser subvencionado por el nuevo presupuesto que tiene. De ser así, no sólo se mejora por la decisión de reducción de impuestos sino que el Estado acapara menos recursos de sus habitantes, pudiendo llegar a ser más eficiente.

Bibliografía

Boloña Behr, Carlos

1995 *Cambio de Rumbo.* Lima: Instituto de Economía de Libre Mercado.

Brennan, Greoffrey [Buchanan, James M.]

1987 *El Poder Fiscal. Fundamentos analíticos de una constitución fiscal.* Madrid.

Buchanan, James M.

1987 [Brennan, Greoffrey; -]

Carrera Raya, Francisco José

1993 *Manual de Derecho Financiero. Volumen I Derecho Financiero y Teoría de los Ingresos Públicos.* Madrid: Editorial Tecnos.

Hayek, Friedrich A.

1975 *Los Fundamentos de la Libertad.* Madrid: Héroes S.A.

Mayora Alvarado, Eduardo

1997 *Teoría Constitucional para una Sociedad Libre (El caso de Guatemala).* Buenos Aires.

JORGE ANDRES WYLD DE NES[1]

Importancia de la actividad notarial y registral en el Derecho guatemalteco

Sumario

Introducción
1- La seguridad jurídica
2- Efectos del acto fedatario notarial
3- Efectos de los actos registrales
4- Extinción de la calidad de documento público
Conclusión
Bibliografía

Introducción

Resulta de mucho provecho tanto para los juristas, como para los profesionales del Derecho, entender los efectos y aplicar las consecuencias de la actividad notarial y registral en Guatemala. Ambos surgen de la necesidad de seguridad jurídica respecto de la interacción social. Los actos notariales y registrales se relacionan con los más variados aspectos del Derecho, en algunos casos dándoles la vida misma. El interés al profesional práctico es que al saber estos temas a profundidad, podrán planificar mejor su estrategia en procesos judiciales o en la estructuración de una negociación. Asimismo, podrán encontrar más fácilmente fallas o errores que hagan nulos muchos actos que sin saberlo podrían dejar pasar oportunidades de ganar un juicio. Todo esto no en afán de rendir culto al formulismo o formalismo innecesario, como tantos ignorantemente creen. Al mismo tiempo se resalta lo importante que resulta que el notariado y la actividad registral se realicen conforme a la ley; de otra manera se estaría socavando el mismo fundamento del Derecho: la justicia.

1- La seguridad jurídica

1.1 Consideraciones de la Corte de Constitucionalidad

Sin tomar en cuenta los peligros que trae un sistema positivista y de constitución escrita -como el nuestro-, cabe decir que la Constitución establece que es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.[2] Esto se debe a que es natural que los hombres se organicen para proveerse de seguridad mutua; en un principio, la seguridad física, y una vez esa se ha logrado, la seguridad de sus derechos, que es una derivación de su propia vida.

1 Abogado y Notario.

2 Art. 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En la historia constitucional de Guatemala, esta disposición se encuentra en: el art. 4 de la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812 (Constitución dictada por las Cortes en Cádiz); art. 1 de las Bases para la Constitución Federal de 1823; el preámbulo y el art. 2 de la Constitución Federal de 1824; el art. 28 (también arts. 16 y 20) de la Constitución del Estado de Guatemala de 1825; el art. 4 del Decreto 67 de la Asamblea Constituyente del Estado de Guatemala, Ley Constitutiva del Supremo Poder Ejecutivo del Estado de Guatemala de 1839; art. 4 de la Declaración de los Derechos del Estado y sus Habitantes de 1839 (normativa muy interesante y poco conocido en la Historia del Derecho guatemalteco); el art. 16 de la Ley Constitutiva de la República de Guatemala de 1879; el art. 23 de la Constitución de la República de Guatemala de 1945; el art. 1 de la Constitución de la República de Guatemala de 1956; el art. 1 de la Constitución de la República de Guatemala de 1965. De todo esto se colige que se ha considerado importante, cuando menos formalmente, el hecho que el Estado provea de seguridad a los individuos.

La Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado respecto de la seguridad jurídica en varias sentencias, especialmente en las de amparo.[3] Por ejemplo, en su primera sentencia de inconstitucionalidad general,[4] consideró que el Estado de Derecho requiere que exista seguridad jurídica para la convivencia pacífica. Además ha dispuesto que una de las funciones de la ley es crear seguridad jurídica, cuyo propósito es, entre otros, el de prevenir conflictos. Las leyes existen para regular instituciones con normas precisas; las que dan certeza y seguridad jurídica a las personas, a modo de evitar controversias innecesarias.[5] La Corte sostiene claramente que la seguridad es uno de los principios contenidos en el artículo segundo de la Constitución.[6] Este órgano jurisdiccional también considera un punto interesante, -piedra angular de todo sistema jurídico, y posiblemente de vivir en sociedad-, cual es que 'la veracidad [...] es base de la seguridad jurídica de la colectividad'.[7] En un voto razonado de Edmundo Quiñones Solórzano de la sentencia del 26 de octubre de 1988,[8] éste consideró que la Corte de Constitucionalidad debe defender el principio de seguridad jurídica que garantiza la Constitución.

Es de suma importancia que la Corte de Constitucionalidad considere la seguridad jurídica con un alcance tan amplio en nuestro ordenamiento normativo. La seguridad jurídica es un elemento estructural de la urdimbre de nuestro sistema legal; porque en un sistema donde rige el positivismo legislativo (contrapuesto a un sistema de precedentes judiciales), es a través de la legislación que la seguridad toma vida. Si las leyes son ambiguas o no contemplan instituciones que causan seguridad, no habrá seguridad, formalmente hablando. De aquí que el análisis que se hace adelante sea mayoritariamente de normas legales y de exposiciones doctrinarias.

2- Efectos del acto fedatario notarial

Como se ha visto, la Corte de Constitucionalidad considera la seguridad jurídica como un valor o elemento indispensable del Estado de Derecho. Ésta da certeza a los actos y negocios jurídicos, con lo cual las relaciones humanas se pueden dar en paz, haciendo más eficiente todo tipo de empresa que desarrollan los hombres en libertad. Una de las manifestaciones precisas de la seguridad jurídica se evidencia en la actuación notarial, siempre y cuando ésta cumpla con los requisitos legales, y sea fiel reproductora de la verdad. Los efectos de la actividad notarial son muy variados desde los que afectan los derechos a la personalidad, hasta efectos sobre las relaciones con otras personas contractual y políticamente,[9] debido al alcance (como plena prueba) que le otorga la legislación procesal. Así todo, los notarios intervienen en casi todos los acontecimientos jurídicos de los individuos.

2.1 Efectos sobre los derechos a la personalidad

Uno de los principales efectos de la actividad notarial, respecto de los derechos de la personalidad, es la posibilidad de efectuar el acto del matrimonio y unión de hecho[10] de un hombre y una mujer. Esta función ha quedado plasmada en la Constitución, y ha permitido una inherencia íntima en la vida de las personas, ya que muchas de ellas se casan ante notario. Después

3 Tal requisito, como se ha externado [sic] en anteriores decisiones, obedece en nuestro sistema al valor seguridad jurídica que consagra la Constitución Política de la República y no a un mero detalle procesal, a fin de dar certidumbre a los actos jurídicos [...]' Sentencia del 2 de agosto de 1990 en Gaceta Jurisprudencial Nº 17. Apelaciones de Sentencias de Amparos. Expediente Nº 164-190.

4 Sentencia del 17 de septiembre de 1986 en Gaceta Jurisprudencial Nº 1. Inconstitucionalidades Generales. Expediente Nº 12-86, p. 1 y ss.

5 Sentencia del 24 de junio de 1992 en Gaceta Jurisprudencial Nº 28, p. 29 y ss. Expediente Nº 84-92.

6 Sentencia del 25 de enero de 1996 en Gaceta Jurisprudencial Nº 39. Inconstitucionalidades en Caso Concreto. Expediente Nº 617-695.

7 Sentencia del 20 de enero de 1989 en Gaceta Jurisprudencial Nº 11. Inconstitucionalidades Generales. Expediente Nº 309-388, p. 1 y ss. Este principio es importante recordarlo en el proceso de faccionamiento de los documentos notariales, ya que sin él todo el edificio jurídico se derrumba.

8 Gaceta Jurisprudencial Nº 10. Inconstitucionalidades Generales. Expedientes acumulados Nos. 4-88 y 22-88, p. 13 y ss.

9 La Ley Electoral y de Partidos Políticos da un papel preponderante a la actividad notarial.

10 Resulta interesante notar que la declaración de cesación de la unión de hecho por mutuo consentimiento la puede declarar un notario (art. 183 Código Civil), misma idea que se trató de seguir en el proyecto de la Ley reguladora de la tramitación notarial

que el matrimonio civil quedó permanentemente instituido en Guatemala, por el triunfo de la Revolución Liberal en el siglo XIX,[11] sólo los alcaldes podían realizar el acto del matrimonio. Afortunadamente, la legislación permitió que los notarios lo pudieran celebrar también, abriendo así la posibilidad de la desconcentración de la actividad administrativa. En todo caso, los notarios autorizan la escritura pública donde constan las capitulaciones matrimoniales y sus modificaciones. El notario también puede participar en el proceso de divorcio por mutuo consentimiento, ya que la reconciliación se puede hacer constar en un memorial con autenticación de firma o por testimonio de la escritura pública donde conste (artículo 432 del Código Procesal civil y mercantil). La identificación de personas puede hacerse ante notario, así como el reconocimiento de hijos, y otros procedimientos que se tramitan según la *Ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria*, Decreto 54-77 del Congreso. La adopción en sede judicial también se establece por escritura pública (art. 239 Código Civil), previa aprobación de las diligencias respectivas por el juez de Primera Instancia competente, quien manda que ésta se otorgue.

2.2 Efectos en la constitución de derechos reales

Los artículos 531 y 559 del Código Civil establecen que necesariamente se debe otorgar escritura pública para la constitución del régimen de propiedad horizontal y el de su administración. El artículo 808 del Código Civil dispone que la falta de títulos constitutivos de las servidumbres que no pueden adquirirse por prescripción, únicamente se puede suplir por confesión judicial o reconocimiento hecho en escritura pública por el dueño del predio sirviente, o por sentencia firme que declare existir la servidumbre. Por otra parte, los artículos 859 y 865 del mismo código establecen la necesidad de que se haga constar el contrato respectivo con garantía hipotecaria, en escritura pública. Lo mismo ocurre con la constitución o cesión de todos los demás derechos reales, en tanto éstos se deban inscribir en el Registro de la Propiedad.

2.3 Efectos respecto de la contratación

La actuación notarial en la vida de los contratos es actualmente de importancia significativa, ya que además de los efectos adjetivos (probatorios), supone, en ciertos casos, la existencia misma del contrato. El documento notarial cumple el papel de presupuesto de la existencia y, por consiguiente, de la validez del contrato. Tal es el caso de los contratos solemnes, pues sólo cuando el documento ha sido otorgado, redactado y firmado puede decirse que el contrato ha nacido a la vida jurídica y se perfeccionó. Entonces, el acuerdo de voluntades que no se documente notarialmente, será nulo.[12] Así se puede ver la importancia toral que tiene el hecho que el notario cumpla con los requisitos que manda la ley notarial, porque si no lo hace, provoca que el negocio jurídico nunca exista.

Los contratos solemnes son de dos clases:[13] la legal, cuando la propia ley manda que exista una forma específica,[14] y la consensual, cuando las partes se obligan a otorgar el documento notarial. Ejemplos de la primera son: los diversos contratos de

de asuntos de jurisdicción voluntaria, pero no se consiguió; probablemente porque se creía que resultaría muy fácil disolver el matrimonio si se hiciere más expedito el trámite para conseguirlo (lo cual es una idea equivocada, ya que no se promoverían mas problemas en una relación fallida).

11 La reglamentación de las formalidades de la ceremonia del matrimonio civil data del 21 de noviembre de 1879, segun el Decreto gubernativo 250, substituido por el número 272 de 20 febrero de 1882. Dicho reglamento probablemente esta vigente y, aunque no se aplica en la práctica, sería conveniente hacerlo positivo porque sus elementos formales darían mucha solemnidad al acto.

12 No es anulable, porque el art. 1518 del Código Civil manda taxativamente que: 'Los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez'. Esta norma se debe interpretar e integrar con el art. 1,577 del mismo Código, donde se dispone que la propia validez de los contratos solemnes depende del otorgamiento de escritura pública. También se debe contraponer a la norma del art. 1,576, en la cual se establece que en los contratos consensuales o reales que se deban inscribir en el registro son válidos y las partes se pueden compeler recíprocamente al otorgamiento de escritura pública, si se establecen sus requisitos esenciales por confesión judicial o por otro medio de prueba escrita.

13 Santos Cifuentes, 1994:200.

14 El art. 1,577 del Código Civil imperativamente dispone que: 'Deberán constar en escritura pública los contratos calificados expresamente como solemnes, sin cuyo requisito esencial no tendrán validez'. En general las formas de contratación en nuestra

sociedad mercantil (art. 16 Código de Comercio), el contrato de fideicomiso (art. 771 Código de Comercio), el contrato de mandato (art.1687 Código Civil), el contrato de sociedad (1,729 Código Civil), contrato de donación[15] de inmuebles (art. 1,862 Código Civil), el contrato de renta vitalicia (art. 2,122 Código Civil) el contrato de transacción (art. 2,169 Código Civil), y el contrato de promesa cuando el contrato prometido deba constar en escritura pública (arts. 1,674 y 1,680 Código Civil).

El derecho a la libre asociación también tiene relación con la actuación notarial, ya que la llamada 'persona jurídica' se tiene que hacer constar en escritura pública (art. 16 Código Civil). Las fundaciones también se constituyen por escritura pública (art. 20 Código Civil). Una obligación accesoria, como la expuesta en el artículo 1,683 del Código, relativa a la obligación de escriturar también implica la actuación del notario, y en la doctrina se considera de suyo como negocio jurídico.[16] La consecuencia de que el contrato no conste en escritura pública, bien sea por culpa del notario o de hecho, en el caso de una escritura constitutiva de sociedad mercantil, resulta en que la responsabilidad de los socios es como la de una sociedad colectiva.

2.3.1 Renovatio contractus

Resulta también interesante escudriñar los efectos que tiene el otorgamiento de escritura pública respecto de los contratos que ya se habían perfeccionado con el mero consentimiento de las partes, esto es de los contratos consensuales. Este tema fue abordado por el *procesalista* alemán Degenkolb hace poco más de cien años en su *Die Vertragsvollziehung als Vertagsreproduktion*, en el cual asevera: 'El estado corriente actual puede resumirse en que se considera el documento de perfección reproductiva como documento probatorio, *in thesi*, y como documento dispositivo *in praxi*'.[17] Y es que el problema se suscita cuando existe una manifiesta contradicción entre el primer convenio y el documento notarial. La jurisprudencia alemana de entonces dispuso que la falta de concordancia era insólita, así como las omisiones en dicho documento, pues las partes sólo querían lo que constaba en el documento otorgado. De lo contrario, había que probar que la discordancia quiso mantenerse viva en el momento del otorgamiento, y que tuviera valor junto con éste. Por lo tanto, el documento notarial no posee meros efectos probatorios (*ad probationem*) y el acuerdo preliminar es a posteriori un pacto *in contrahendo*: el convenio preliminar y el otorgamiento del contrato son lo mismo que obligación y pago, respectivamente. Nuñez Lagos concluye de lo dicho por Degenkolb que existe una *renovatio contractus* (aproximado a la novación), cuando el notario redacta la escritura pública, porque moldea la voluntad de las partes de conformidad con la tipicidad que la ley manda y que, además, las partes tienen que prestar su consentimiento de nuevo ante éste.

Existen autores como Meyer que adoptaron una posición ecléctica en cuanto a la construcción antes dicha. Para éste, 'el documento reproductivo es probatorio en cuanto coincida con los acuerdos primarios; dispositivo, en cuanto diverja'. Para Carnelutti[18] la pregunta está mal formulada, lo que se debería preguntar es si la declaración sucesiva es una declaración de voluntad o es una declaración de verdad,

legislación según el art. 1,574 del Código Civil: 'Toda persona puede contratar y obligarse: 1o.- Por escritura pública; 2o.-Por documento privado o por acta levantada ante el alcalde del lugar; 3o.- Por correspondencia; y 4o.-Verbalmente'. La modalidad del acta levantada ante el alcalde es una de las más acostumbradas en los pueblos alejados de la Ciudad de Guatemala, donde no haya notarios, lo cual se viene dando desde tiempos coloniales. Otra formalidad poco conocida es la del contrato de mandato, el cual se puede hacer constar ante el juez local, quien también levanta el acta respectiva, según el art. 1683 del Código Civil. El art. 1575 del Código establece que el contrato cuyo valor exceda de trescientos quetzales, debe constar por escrito; y si el contrato fuere mercantil puede hacerse verbalmente si no pasa de mil quetzales; sin embargo, este es un requisito ad probationem, no un elemento ad solemnitatem (Vea Federico Ojeda Salazar, s.f.:150).

15 Ernesto Viteri (1992:249-250) no considera que este sea un contrato solemne, sino que la escritura es parte de la forma del contrato. La Exposición de motivos del Código Civil si considera al contrato de donación de inmuebles como un contrato solemne. Históricamente el contrato de donación de inmuebles siempre ha requerido de más formalidades que otros contratos. La Exposición también considera contratos solemnes los de hipoteca y prenda registrable (Federico Ojeda Salazar, s.f.:150).

16 Rafael Núñez Lagos, 1945:28-33.

17 Citado por Rafael Nuñez Lagos, 1945:16.

18 Citados por Rafael Nuñez Lagos, 1945:19-23.

pues pueden darse los dos casos; de esta manera, si los documentos son redactados por las mismas partes, la contratación sucesiva del mismo contenido sólo varía en cuanto a la forma, y su eficacia es sólo probatoria. Sin embargo, estas ideas de Carnelutti cuadran perfectamente respecto del documento privado, no así del documento notarial.

Nuñez Lagos apunta que, en el derecho español, el acuerdo primario se puede tomar como la causa del negocio de cumplimiento: la escritura pública (todo visto *a posteriori*, por supuesto). Este autor lo resume así: 'El otorgamiento de la escritura pública no supone, en cuanto a la substancia contractual, un *novum*, sino un *idem* contractual, porque son las mismas obligaciones del acuerdo primario que se absorben y embeben en un negocio de ejecución como en el río confluente los afluídos [*sic*]'.[19] En el otorgamiento no se anula la primera obligación, sino que se consume como pago; pues no se recogen los dos momentos (a lo que a lo sumo se alude o se supone), y sólo se evidencia el otorgamiento como una unidad, de efectos únicos y no alternativos.

Díez Picaso también encuentra consecuencias prácticas para este problema doctrinal, especialmente cuando no existe absoluta concordancia entre el primer acuerdo y el documento redactado posteriormente. Menciona este autor español, en concordancia con el sector mayoritario de la doctrina, que:

> *El problema de la renovatio contractus debe ser examinado, al menos desde dos puntos de vista. El primero lo constituye la hipótesis de redacción de un documento en el que plasma un anterior contrato verbal no documentado. En este caso entendemos que la documentación constituye un nuevo contrato que asume respecto del anterior un papel novatorio. La anterior reglamentación de intereses que quedó establecida verbalmente, queda sustituida por la reglamentación de intereses plasmada en el documento. El documento nova el acuerdo verbal. Si el contenido de uno y otro son idénticos, la documentación constituiría un contrato meramente declarativo o un contrato de fijación. Si la documentación modifica el acuerdo anterior nos encontraremos en presencia de un negocio dispositivo respecto de la situación reglamentada.*[20]

El mismo autor comenta una sentencia del Tribunal Supremo español de 3 de noviembre de 1982,[21] en la cual los actores primeramente habían suscrito un contrato de compraventa de viviendas en documento privado. Luego, cuando se constituyó el régimen de propiedad horizontal, el vendedor y los compradores otorgaron escrituras públicas de compraventa. Sin embargo, había notables discrepancias entre lo que constaba en los documentos privados y en las escrituras públicas. El Juzgado de Primera Instancia falló en contra del demandado, pero la Audiencia revocó la sentencia, y lo absolvió. El Tribunal Supremo consideró que las escrituras públicas deberían prevalecer por haber ocurrido novación expresamente pactada de lo consentido originalmente en los documentos privados. De tal forma que resulta muy importante la intervención del notario en la fase de captación de la voluntad de las partes para la redacción del instrumento, porque éste será considerado como el contrato vinculante entre ellas, y no el contrato primigenio.

2.4 Efectos extraterritoriales

2.4.1 Actuación de notarios en el extranjero

Los notarios guatemaltecos pueden realizar ciertos actos notariales en el extranjero. Éstos también realizan actos relativos a los documentos provenientes del extranjero, tales como la protocolización de los documentos legalizados que deban ser presentados ante los registros públicos y los mandatos o poderes (así como cualquier otro documento que se desee). Parece ser que la posibilidad jurídica de cartular en el extranjero no la contemplan muchos otros sistemas de Notariado.[22] La rapidez y la cantidad de negocios que se llevan a cabo en la actualidad, y su diversidad; ha causado una explosión en esta actividad que otrora no

19 Rafael Nuñez Lagos, 1945:37.
20 Luis Díez Picaso, 1993:260.
21 Luis Díez Picaso, 1993:261.
22 Luis Díez Picaso, 1993:261.

fuera tan frecuentemente realizada. La certeza de la realización de los actos que las partes requieren (para protegerse en un juicio, por ejemplo) y que la ley manda, han causado que más y más notarios viajen al extranjero para dar fe en los casos permitidos por la legislación guatemalteca.

La historia de esta institución resulta interesante y da luz para entender algunos puntos confusos del régimen actual. La primera vez que se reguló la actuación notarial en el extranjero (aparte de la de los agentes diplomáticos o consulares) fue en el Decreto 1762 del Congreso de la República,[23] Ley del Organismo Judicial, en el artículo diecinueve. Preceptuaba esta ley que las formas o solemnidades externas de cualquier documento en que se establecieran derechos u obligaciones se regirían por las leyes del país donde se hubieren de otorgar. Sin embargo, los guatemaltecos o extranjeros residentes fuera de Guatemala, podrían sujetarse a los requisitos externos prescritos por las leyes guatemaltecas, en los casos en que los actos o contratos se debieran ejecutar en este país. Actualmente se regula en el artículo 43 de la Ley del Organismo Judicial, la cual no hace mención de las formalidades de los actos notariales. Comparada con la ley anterior, fue peor cómo quedó regulada la forma en que se protocolizan los documentos faccionados por el notario en el extranjero; ya que antes la protocolización se efectuaba por medio de la fórmula 'Por mí y ante mí', y ahora no queda claro si se tiene que usar ésta o las específicas que dispone el Código de Notariado en el artículo 63.[24] La protocolación del documento faccionado por el notario podrá ser efectuada por cualquier otro notario, no necesariamente por el notario que autorizó el documento en el extranjero.[25]

2.4.2 Notarios que no sean cónsules o agentes diplomáticos

La Ley del Organismo Judicial vigente dispone que toda la actividad notarial en el extranjero se hará en papel simple, y que los actos notariales ejecutados fuera del país surten sus efectos desde que se protocolicen en Guatemala. La ley sólo les permite hacer constar hechos que presencien y circunstancias que les consten y autorizar actos y contratos. Por ende, los únicos documentos notariales (el medio exclusivo con que pueden actuar los notarios) que podrán autorizar en el extranjero serán: actas notariales, legalización de firmas (en el caso de contratos y otros actos), fotocopias, fotostáticas, y otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, siempre que éstas sean procesadas, copiadas o reproducidas del original, en presencia del notario. No podrán redactar escrituras públicas en el extranjero, porque éstas se plasman sobre papel especial para protocolos (la ley dice que solo se usará papel simple); ni hacer constar contratos en acta notarial (ya que el acta tiene otros efectos). Respecto de las firmas legalizadas, el notario deberá tomar razón en su propio protocolo dentro del término de ocho días de haber realizado el acto. En cuanto a los documentos legalizados, se deberá pro-

23 La Ley del Organismo Judicial anterior a la actualmente vigente es de fecha 2 de julio de 1968. Fue publicada en el Diario Oficial el 26 de julio del mismo año, tomo CLXXXIII, Nº 14. También fue publicada en la Recopilación de Leyes de la República de Guatemala, Tomo LXXXVII, p. 98.

24 El acta de protocolación tendrá el número del instrumento, el lugar y la fecha en que se hizo la protocolización, los nombres de los solicitantes, la mención del documento proveniente del extranjero, y el lugar en el orden del protocolo; y deberá ser firmada por sí y ante sí, por el notario en el caso de la protocolación del documento legalizado, según el art. 63 del Código de Notariado, inciso primero, ya que la Ley del Organismo Judicial art. 38, establece que se debe protocolizar y cómo se debe hacerlo. Lo mismo se ha de hacer cuando sea un acta notarial o una legalización de fotocopia, por virtud de que el art. 43 remite al art. 38 de la Ley. Otra interpretación es que, en el caso de la legalización de firmas bastará con que se haga la toma de razón dentro de los ocho días después del acto notarial. Sería diferente en el supuesto de los documentos privados con firmas autenticadas o legalizadas donde consten contratos, ya que en el acta de protocolación deberá comparecer la persona a cuyo favor se suscribió el documento (inciso segundo del art. 63 del Código de Notariado). El testimonio que se extienda será del acta de protocolación, la cual tendrá un número correlativo como el de las demás escrituras públicas o razones de legalización. Los documentos protocolados se considerarán como parte de las escrituras respectivas (art. 71 del Código de Notariado), supliendo así la necesidad de la escritura pública en los casos que la legislación guatemalteco así lo exija para su validez (mandatos, sociedades, sociedades mercantiles).

25 Esto según el dictamen emitido por el licenciado Jaime A. Valencia, aprobada por la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Guatemala, en sesión de fecha 9 de noviembre de 1971. Dicho dictamen, por cierto muy interesante, tiene relación con la materia tributaria-notarial que se trata más abajo (Registro, 1971-3(1):19-20).

ceder a su protocolización, lo antes posible, para que surta los efectos que las partes deseaban que tuviere.

La actuación en el extranjero no deja de tener sus peculiaridades, y provoca dudas, las cuales serán resueltas con la investigación y por la jurisprudencia. Parecería bastar que el notario sea hábil y colegiado activo, y que lleve su sello registrado ante la Corte Suprema de Justicia para cartular en el extranjero. Se debe cumplir con lo que el Código de Notariado en general manda respecto de las actas, tal como la identificación de quienes intervengan con su pasaporte -bien fueren guatemaltecos[26] o extranjeros-;[27] el uso del idioma español (juntamente con intérpretes, si fuere necesario); y la asociación de testigos instrumentales que llenen los requisitos que manda la ley.[28] Respecto de los contratos que la ley en Guatemala manda que sean otorgados en escritura pública, bastará con que se plasmen en papel simple, las firmas sean legalizadas o reconocidas y luego las hojas sean protocolizadas, de tal manera que se deba entender que se ha cumplido con la obligación de que consten en escritura pública, ya que la protocolación sustituye el defecto del papel simple, lográndose cumplir con la solemnidad y asegurando su validez. Sin embargo, el notario debe ser cuidadoso en que sus clientes redacten apropiadamente el contrato en documento privado para cumplir con los juramentos que la ley manda. El notario no debe tomar en cuenta las reglas para formalidades del lugar donde autoriza el acto o contrato, y deberá consignar los datos de identificación, así como las representaciones que se ejerzan, como si estuviera en Guatemala.[29] Es importante notar que el estado civil que se consigne será establecido según el estatuto personal de las personas respectivas.[30]

Nótese que la obligación tributaria establecida por la *Ley del Impuesto al Papel Sellado y Papel Especial para Protocolos*, Decreto 37-92 del Congreso y sus modificaciones, se genera al momento de que los documentos provenientes del extranjero ingresan en el territorio de Guatemala, y se debe liquidar y pagar antes de la protocolización. En el caso de todos los documentos notariales autorizados en el extranjero, la situación es un tanto más compleja, ya que la obligación tributaria es territorial, y -aunque el hecho generador se dé en el extranjero-, ésta sólo nace hasta que el documento llega a Guatemala, por lo que se podría decir que la obligación tributaria queda en suspenso. Por ende, los notarios no deben llevar ni timbres notariales ni fiscales o papel especial para protocolos (los medios de pago del impuesto documentario) al extranjero, cuando autoricen actos fuera de Guatemala. Es posible que no se haya requerido el uso de papel sellado especial para protocolos, el

26 La Ley de Migración, Decreto 95-98 del Congreso, en su art. 50 establece que el pasaporte constituye, en el extranjero, el documento de identidad de los guatemaltecos. Sin embargo, este extremo es discutible, ya que la ley específica es la de Notariado, para la aplicación de las formalidades del acto notarial, por lo que también se podría utilizar la cédula de vecindad como documento de identificación (no 'identidad' como equivocadamente dispuso el legislador en la Ley de Migración).

27 Es importante mencionar que el art. 1 del Convenio de Munich de 5 de septiembre de 1980 dispone que el nombre y apellidos de una persona se determinan por la ley del Estado del cual dicha persona sea nacional. Esto tiene importancia no solo para la actuación notarial en el extranjero, sino que también para su actuación en Guatemala. Por ende, si en el pasaporte sólo consta un apellido, éste será el que se consignará en el documento notarial.

28 Vea arts. 51, 52, 53 del Código de Notariado.

29 Esto es una excepción atrevida del principio de locus regit actum, y del de lex loci celebrationis (arts. 28 y 29 de la Ley del Organismo Judicial), en la Ley del Organismo Judicial anterior (Decreto 1762 del Congreso) hacía mas claro la excepcion a este principio. Vea Corte de Constitucionalidad, Gaceta Jurisprudencial No. 5. Amparos en Unica Instancia. Expediente No. 121 87. De Erice y O'shea (1954-II:167) considera que en el caso del cónsul-notario se sigue el principio locus regit actum, ya que la actividad notarial se realiza en la sede del consulado, la cual se considera como parte del territorio nacional. Sin embargo, en el caso de los notarios que no cartulen en el consulado, también deben seguir las formalidades que establecen las leyes de Guatemala, rompiendo con el principio al cual se ha hecho alusión. Todo así, se debe tomar en cuenta que dichos actos notariales sólo serán válidos en Guatemala, y esta es la razón para hacer la excepción al principio.

30 El estado y la capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio (art. 25 de la Ley del Organismo Judicial), la cual aquí sí se aplica a diferencia de los dos principios antes mencionados (vea anterior llamada) porque la propia Ley del Organismo Judicial así lo dispone. Esta norma es aplicable tanto para la actividad notarial en el territorio de Guatemala, como para la actividad notarial en el extranjero. Es pues, un ejemplo de la aplicacion del Derecho extranjero por parte del notario guatemalteco, un juicio que éste tiene que hacer lo podrá realizar siguiendo el procedimiento establecido en el art. 35 de la Ley del Organismo Judicial, por integración (ya que no hay otra norma específica o especial respecto del Derecho extranjero y la administración pública o la actuación notarial).

antiguo papel sellado o el uso de timbres fiscales (ni el uso de timbres notariales),[31] porque existe la duda si este acto tributario que ejerce el Estado, por medio de su poder de imperio,[32] viola o no viola la soberanía del Estado donde se ejecuta el acto notarial que genera la obligación tributaria. Este problema no ha sido resuelto aún por la jurisprudencia, ni la doctrina.[33]

Lo mismo cabe preguntarse respecto de la propia actividad notarial en el extranjero, si se considera a los notarios como funcionarios públicos, ya que son los facultados por el Estado para ejercerla. ¿Será esta actividad una intervención ilegítima del Estado de Guatemala respecto de otros Estados? Una posible forma de analizar el asunto es que la actividad notarial es una extensión de las facultades de los agentes diplomáticos o consulares (funcionarios públicos de un Estado que actúan legítimamente en otro), en cuanto a la posibilidad que el Derecho internacional público les da para legalizar actos y documentos en el extranjero. Otro planteamiento es que los notarios son profesionales particulares, que actúan por su propia cuenta y no por la del Estado. Sin embargo, esta idea podría colisionar con normas de orden público existentes en casi todo Estado, tales como las que requieren de colegiación antes del ejercicio de la actividad fedataria.[34] Independientemente de estas consideraciones, en Guatemala los documentos públicos autorizados por notario en el extranjero surten efectos como si hubieran sido faccionados aquí. Se puede entonces concluir que la actividad fedataria del notario tiene serias implicaciones aún en le ámbito internacional, y que urge su fiscalización.

2.5 Efectos en el derecho administrativo: el ejercicio notarial por funcionarios del Estado

2.5.1 El Escribano de Cámara y de Gobierno

El cargo de Escribano de Cámara y de Gobierno es el más antiguo que todavía existe en el ámbito de las instituciones notariales en Guatemala, continuamente desde la época de la Colonia. Es posible que se le haya dado este nombre porque era el escribano de la Cámara de Hacienda, la que se encargaba de los contratos con particulares, especialmente los de las adjudicaciones de tierras, objeto que aún hoy en día cumple función similar, al estar íntimamente ligada esta oficina a la Sección de Tierras. Según Solombrino Orozco, el Escribano Nacional y de Cámara de Hacienda del Supremo Gobierno de la República actúa desde 1772, como consta en la colección de autos acordados y providencias

31 Según Carlos Giuliani Fonrouge (1993-I:402) los colegios profesionales carecen de potestad tributaria, pero son sujetos de las obligaciones tributarias (sí son de naturaleza tributaria) de las cuales son titulares por autorización estatal, por virtud de ley; y se les denomina sujetos parafiscales. De igual forma los identifica Fernando Pérez de Hoyo (1996:114), quien también les reconoce calidad de tributos.

32 Carlos Giuliani Fonrouge, 1993-I:283, 297.

33 No se trata de una discusión de lo que es llamado Derecho tributario internacional, el cual trata de la doble imposición o los tratados comerciales (Héctor B. Villegas, 1995:481), sino más bien del ámbito espacial de aplicación de la ley tributaria. Vea también en Francisco José Carrera y Raya, 1994-II:23. El principio general en nuestra legislación tributaria es el de la territorialidad (caso del Impuesto Sobre la Renta ('fuente guatemalteca') y el Impuesto al Valor Agregado ('la internación' y 'la exportación'), principio respaldado por Giuliani Fonrouge; el cual Martín y Rodríguez Usé creen que va evolucionando, de tal forma que dicho principio resulta alterado (José María Martín y Guillermo F. Rodríguez Usé, (1995:73-86.) por tres criterios de imposición: el de la ubicación territorial de la fuente productora, el del domicilio o residencia del beneficiario de las utilidades, y el de la nacionalidad de éste. Ninguno de estos criterios casa cuadradamente respecto de nuestro tributo documentario. En el procedimiento de legalización de documentos provenientes del extranjero, el hecho generador es la internación del dicho documento en el territorio nacional. De esta forma, el hecho generador sí ocurre en Guatemala y debe liquidarse y pagarse aquí, en el tiempo requerido para no caer en mora y acreditarse una multa. Un caso un tanto más complejo es la actividad notarial en el extranjero, porque el hecho generador es la existencia del documento notarial creado por la propia actividad notarial (art. 5, numerales 5, 6 y 7). La Ley del Organismo Judicial dispone que el escrito de los notarios surte sus efectos (qua documento notarial) desde su protocolización en Guatemala. La Ley del Timbre, Decreto 37-92 del Congreso (art. 16, numeral 2) manda a que se pague el tributo antes que éstos se les protocolice (aunque cabe decir que esta norma estaba realmente dedicada para el proceso de legalización de documentos). Se podría decir entonces que el efecto de la actuación notarial queda en suspenso hasta que el documento llega a Guatemala, y que el tributo se debe pagar en el proceso por el cual éste se convierte en documento notarial. Lo mismo ocurre en el caso del timbre notarial. Tal vez la única excepción al principio de territorialidad es el numeral 2 del art. 5 de la Ley del Timbre, ya que tanto el hecho generador como el momento de pago ocurren en el extranjero. También vea un dictamen interesante sobre esta materia en el boletín denominado Registro (1971:19-20).

34 Antonio Boggiano, 1993:248. También vea Mario Aguirre Godoy, 1993-I:221.

generales del antiguo Juzgado Privativo de Tierras, y cuyo protocolo empieza en 1784.[35] Un decreto[36] de la época de Vicente Cerna, justo antes de la Revolución Liberal, sobre el presupuesto de la Secretaría de Gobernación, se tiene una partida para el Escribano de Cámara y Hacienda, quien ganaba $480 al año.

Actualmente es la única instancia en que a un notario se le denomina 'escribano', ya que este nombre cambió definitivamente por el de 'notario' a finales del siglo pasado. Su regulación se encuentra dispersa, aunque sí se menciona como órgano del Ministerio de Gobernación.[37] Leyes como la de contrataciones del Estado[38] y otras especiales[39] le atribuyen el faccionamiento de escrituras públicas cuando otorguen contratos el Estado u otras entidades de Derecho público, salvo que el interesado sufrague los gastos de un notario público. La Escribanía de Gobierno siempre ha estado íntimamente ligada a los asuntos agrarios, aún en épocas pretéritas, por lo que hasta el día de hoy la oficina queda en el mismo sitio que la Sección de Tierras, en el edificio antiguo de la Corte Suprema de Justicia (donde hoy se localiza el Registro General de la Propiedad).

2.5.2 Cónsules o agentes diplomáticos

El Código de Notariado[40] permite la actuación de los cónsules y agentes diplomáticos que sean notarios para que ejercieran el Notariado en el extranjero. Se ha de suponer que están facultados para hacerlo sólo en el ámbito territorial de su competencia (distrito consular), ya que en otro sitio no tendrían la calidad de cónsul o agentes diplomáticos. No se debe confundir esta facultad con los actos que desempeñan los cónsules o funcionarios diplomáticos respecto de la legalización de documentos provenientes del extranjero, porque ni el cónsul, ni el funcionario diplomático que no sea notario, podrá cartular en el extranjero. La *Convención de Viena sobre Asuntos Consulares*[41] prevé que los cónsules ejerzan el Notariado como una función permitida.

La actividad notarial de los cónsules-notarios resulta interesante, ya que son los únicos notarios que puedan escriturar en el extranjero, pues el Código de Notariado ampliamente los faculta para cartular.[42] El mismo código[43] dispone que el protocolo (lo cual implica escrituración) de los agentes diplomáticos y consulares, y los testimonios e índices respectivos, se

35 Vincenzo Solombrino Orozco, 1977:192-193.

36 Recopilación de Pineda de Mont, Tomo II, p. 263.

37 Decreto gubernativo 1728 emitido por Jorge Ubico el 24 de junio de 1935, art. 1, literal j), luego por el art. 23, literal h) del Decreto 47 de la Junta Revolucionaria de Gobierno el 27 de diciembre de 1944; el Decreto 93 del Congreso de la República de 25 de abril de 1945, art. 19, inciso 1, literal g). Últimamente quedó regulado en la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97 del Congreso de la República, art. 36, literal f).

38 Decreto 57-92 del Congreso de la República, reformado por el Decreto 20-97, arts. 49 y 93.

39 Art. 76 del Decreto 100-97 del Congreso de la República; art. 26 del Decreto 25-74 del Congreso de la República (lo llama 'Escribano de Cámara'); art. 29 de la Ley de Expropiación, Decreto 529 del Congreso de la República; art. 103 de la Ley de Transformación Agraria Decreto 1551 del Congreso de la República; art. 2 del Decreto-Ley 141-85, y el art. 2 del Acuerdo Gubernativo 694-93 (lo llama 'Escribano de Cámara del Gobierno').

40 Inciso 2 del art. 6, el cual es una excepción al principio general de que los funcionarios y empleados del Organismo Ejecutivo que devengan sueldo del Estado tienen prohibido ejercer el Notariado; en el caso de los cónsules ad honorem, tampoco aplica esta restricción, ya que no reciben salario del Estado, y son cónsules. La norma anteriormente citada se complementa con el art. 43 de la Ley del Organismo Judicial en cuanto a la facultad de autorizar contratos, y se apoya en el art. 976 del Código civil. El art. 9 de la Ley de Notariado (antecesora del Código de Notariado), también permitía que cartularen los cónsules y agentes diplomáticos que fueran notarios.

41 Art. 5, Convención sobre Relaciones Consulares, suscrita en Viena el 26 de abril de 1963. Es interesante notar que el Reglamento para las Misiones Diplomáticas guatemaltecas no dispone nada respecto de la actividad notarial en el extranjero.

42 Todo lo referente a la legalización de documentos provenientes del extranjero está regulado en la Ley del Organismo Judicial, algo que ahora resulta de mala técnica legislativa, ya que realmente su naturaleza es materia del de Notariado, que por ser código, debe estar todo recopilado allí. Puede ser que se le haya dejado allí debido a que antiguamente el procedimiento de legalización contemplaba el 'pase de ley' por la Corte Suprema de Justicia, el cual fue suprimido en los años sesenta (Decreto Ley 268), de cuenta que hoy en día es incorrecto referirse al procedimiento antes descrito como 'pases de ley', porque lo que existe en la actualidad es una 'cadena de legalización'. Este es otro ejemplo de la intromisión ahora corregida del Organismo Judicial en el ámbito constitucional del Ejecutivo.

43 Según el art. 10 del Código de Notariado, sin perjuicio del impuesto fiscal correspondiente, adhiriendo timbres. En las actas notariales y demás documentos que no sean escrituras públicas también se adherirán timbres notariales, ya que la exención a este tributo sólo aplica a los contratos autorizados por el Escribano de Gobierno (art. 1 del Decreto 82-96 del Congreso de la República).

extenderán en papel de lino o similar.[44] El cónsul notario abre el protocolo cada año y cartula como si estuviera en Guatemala[45] y que tales escrituras surten sus efectos inmediatamente; por lo que no se aplica lo relativo a la actuación notarial en el extranjero que dispone la Ley del Organismo Judicial. Cabe recalcar que el protocolo se debe entender que es del consulado (protocolo consular),[46] y que ahí debe permanecer, hasta que la misión o agencia sea suprimida, o que por su antigüedad se deba enviar al Archivo de Protocolos en Guatemala. El cónsul tendrá que enviar los testimonios especiales por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el tiempo que manda la ley, y llenar los demás requisitos[47] de los notarios del país.

2.5.3 Función registral de los cónsules

Además de las funciones notariales, los cónsules también están facultados[48] para llevar un registro de los nacimientos, matrimonios, cambios de nacionalidad y defunciones de los guatemaltecos residentes o transeúntes en los países en que ejerzan sus funciones. Sin embargo, deben enviar una copia de las partidas que asienten al Registro Civil en la capital de Guatemala, para que aquí se hagan las inscripciones que correspondan. Esto último se puede interpretar de dos formas: la primera es que los cónsules sólo hacen una anotación 'preventiva' del acto registrable en los libros del consulado, y que luego éstos mandan copia al Registro Civil para que formalmente se inscriba el hecho; otra posibilidad es que los registros consulares son delegaciones del Registro Civil en el extranjero y que la inscripción queda asentada efectivamente desde que se inscribe el hecho en el libro del registro del consulado; la copia sólo se envía al Registro Civil de la capital para hacer las anotaciones marginales en otras partidas por parte de cualquier registrador, cuando corresponda (*v. gr.* defunción o matrimonio en la partida de nacimiento). Lo más probable es que la intención del legislador fue que todos los actos susceptibles de registro que ocurran en el extranjero se concentren en el Registro Civil del Municipio de Guatemala. La actuación registral en el extranjero demuestra la afinidad natural que existe entre el Notariado y los registros públicos.

2.6 Efectos jurisdiccionales

El documento público se considera entre los medios de prueba de índole privilegiada. Una de las ideas más importantes de esta investigación es el hecho de recalcar que el documento notarial es una suerte de prueba preconstituida o anticipada.[49] Existen dos clases de documento público: los documentos notariales y los hechos por funcionario o empleado público.[50] La cali-

44 Norma que se acarrea de la Ley de Notariado de 1934, Decreto presidencial Nº 1563, arts. 63 y 64.

45 Para De Erice y O'shea (1954-II:167) el cónsul-notario debe seguir el principio locus regit actum (modificado), porque la actividad notarial se realiza en la sede del consulado, la cual se considera por algunas tendencias del Derecho internacional público como parte del territorio nacional.

46 Queda la duda de qué ocurre cuando en el consulado no haya ningún notario para que extienda los testimonios de las escrituras públicas que conformen el protocolo consular, ya que sería extraño que cualquier funcionario público, sin conocimiento del Derecho notarial, ni habilitación, los pudiere compulsar. También pudiera ser que el protocolo sea el del notario, y que éste se lleve los tomos consigo a donde resida.

47 Laudelino Moreno, 1946: 287-354. Un libro sumamente interesante, muestra del nivel de los guatemaltecos estudiosos de hace cincuenta años, infortunadamente la legislación notarial cambió luego de haberse publicado la obra, por lo que muchas de sus nociones no son aplicables actualmente.

48 Art. 374 del Código Civil.

49 La investidura de la fe pública que ejercen los notarios posiblemente se dio por la íntima relación profesional que tenían antiguamente los notarios en los tribunales, en donde probablemente acompañaban al juez cuando judicaba ciertos actos. La evolución posterior segregó, por efectos de la versatilidad y funcionalidad, al notario del tribunal, pero este salió llevándose la fe pública investida en el juez. Es importante notar que los actos notariales se deben conformar a la solemnidad y rigor de un proceso judicial, especialmente en cuanto al acto de la identificación de los intervinientes, tal y como sucede en el proceso. Un ejemplo para confirmar esta propuesta es la norma del art. 1,576 (y el art. 808) del Código civil, en la cual se establece que en los contratos consensuales o reales que se deban inscribir en el Registro de la Propiedad son válidos y las partes se pueden compeler recíprocamente al otorgamiento de escritura pública, si se establecen sus requisitos esenciales por confesión judicial o por otro medio de prueba escrita. Esta idea también la patentiza Nuñez Lagos (1945) en su Estudios sobre el valor jurídico del documento notarial. Algunos de los primeros notarialistas fueron procesalistas.

50 Anteriormente, el Código de Enjuiciamiento distinguía entre los instrumentos notariales (que les llamaba documentos públicos), y los documentos auténticos, los que eran hechos por funcionarios públicos.

dad de documento público con que gozan los documentos notariales son un ejemplo de una prueba tasada, ya que producen fe y hacen plena prueba[51] en juicio, salvo el derecho de las partes a redargüirlos de nulidad o de falsedad. El juez debe apreciar este medio de prueba como que es verdad lo que en ellos está plasmado. Sin embargo, se debe entender en cuanto a qué es lo que hace plena prueba, ya que se debe distinguir entre el documento en sí mismo, su materialidad, y, por otra parte, respecto de su contenido.[52] Es en cuanto al documento en sí mismo que se debe considerar dos elementos esenciales: que sea un notario en el ejercicio de la profesión quien autorice, y que el notario siga las solemnidades que la ley manda, en este caso el Código de Notariado.[53]

En cuanto al contenido del documento notarial -respecto del tema que interesa ahora- sólo cabe dar valor de plena prueba las declaraciones del notario respecto de actos ejecutados por sí mismo o que hubieran ocurrido en su presencia. Se tendrá por auténtico lo relativo al lugar y fecha del otorgamiento, quiénes son las partes,[54] si son de su anterior conocimiento o no, el hecho que las partes dijeron, reconocieron o manifestaron algo, y que se tuvo a la vista algún hecho o documento, la literalidad de las transcripciones que se hayan hecho. Resulta probado el hecho de que alguien declaró un asunto específico, pero no que lo declarado sea verídico.

Es importante hacer ver que el contenido de las declaraciones hechas por las partes en un documento público no tiene la calidad de plena prueba en sí mismo. Por eso es que Aguirre Godoy cita[55] a Gómez Orbaneja y Herce Quemada, quienes apuntan que los documentos públicos prueban, *erga omnes*, el contenido de la percepción del fedatario, que aparece consignada en ellos, pero no el contenido de las declaraciones que él ha recogido (por ejemplo, en el caso de la simulación). Respecto de las escrituras públicas donde se plasma un contrato, 'prueba contra los contratantes en cuanto a las *declaraciones* que hubiesen hecho éstos, y prueba contra terceros lo que el Notario consigna como saber propio: el hecho que motiva su otorgamiento y la fecha de este. En cambio, el documento privado en que se incorpore el contrato, no prueba contra terceros, ni siquiera por lo que hace a su fecha', por lo que sólo prueba contra su autor.

Los documentos notariales se pueden presentar en original, en copia fotográfica, fotostática, o fotocopia o mediante cualquier otro proceso similar. Cuando se trate de escrituras públicas, el notario puede extender copia simple legalizada, por lo que no tiene que expedir testimonio, a menos que la ley así lo requiera. Estas copias, si son fácilmente legibles, se tendrán como fidedignas, salvo prueba en contrario. Sin embargo, el juez o el adversario en un juicio pueden solicitar que se exhiba el documento original. En cualquier momento de un proceso el juez puede, de oficio o a petición de parte, disponer que la copia se coteje con el original, ya sea por el propio juez o por peritos. El Código procesal, como caso excepcional, permite al juez ordenar que se lleven a su presencia los registros, archivos o protocolos. No obstante esto, el Código de Notariado expresamente prohíbe al Director del Archivo General de Protocolos que éstos sean extraídos, aun con orden de autoridad judicial, los protocolos, -testimonios y documentos del Archivo, porque cualquier autoridad, tuviere que practicar alguna diligencia, la tendría que verificar en el propio Archivo, en presencia del Director, quien firmaría el acta que se levantare.[56] Un caso similar[57] es el de la prohibición de sacar los libros de la oficina del Registro de la Propiedad, aunque sea por motivos de diligencias judiciales. En cuanto a los notarios queda la duda si deben llevar el protocolo al juez o no, ya que el Código de Notariado no se los permite

51 Plena prueba quiere decir que no hay necesidad de probarlo en el proceso, sin embargo, no quiere decir que al ser el documento público apreciado por el juez, éste lo tiene que aceptar en vista de otros medios de prueba más contundentes, y destruir su eficacia probatoria, ya que en nuestro sistema no existe preeminencia entre éstos. Vea Mario Aguirre Godoy, 1993-1:723.

52 Oscar A. Salas, s.f.:228-233.

53 Arts. 29 y 31 del Código de Notariado.

54 No es técnicamente apropiado mencionar en las escrituras públicas que el otorgante 'dice ser de las generales', porque es labor (y responsabilidad) del notario precisamente identificar plenamente a las personas, como en un juicio. Vea cita al pie número 47.

55 Aguirre Godoy, 1993-1:703-704.

56 Art. 81 Código de Notariado, inciso 10.

57 Art. 1,222 del Código Civil.

expresamente, dado que los notarios guardan el protocolo en calidad de depositarios,[58] y sólo pueden ser desposeídos de él en circunstancias calificadas.

2.6.1 Auxiliares del juez

Los notarios pueden actuar como auxiliares[59] del juez dentro de los procesos, directamente. De hecho, antiguamente había un escribano en cada tribunal como parte de los empleados judiciales. Actualmente, existe la posibilidad de que los notarios notifiquen actos judiciales a las partes interesadas en un juicio. El contenido de la cédula de notificación y el modo en que debe procederse es de suma importancia, ya el acto de la notificación está vinculado con la disposición constitucional del debido proceso (citación a juicio). Respecto de la fase probatoria de un juicio, el notario interviene personalmente en el discernimiento del cargo de expertos, lo cual en la práctica forense resulta difícil de llevar a cabo, con lo cual el notario puede ayudar para agilizar las diligencias. Con motivo de la prueba de documentos, los notarios también pueden actuar autorizando una transcripción de documentos en poder de terceros, sin necesidad de que éstos comparezcan personalmente al juicio. Intervienen en la producción de medios de prueba al poder certificar en actas la autenticidad de los medios científicos usados para probar algún extremo. Sólo los notarios pueden ser partidores en los juicios de división de la cosa común. En la sustanciación del proceso ejecutivo el notario puede ejecutar el embargo y el secuestro de bienes, y en la fase final del proceso, efectúa la escrituración de la traslación de dominio del bien rematado. Dentro de las ejecuciones especiales se encuentra la de escriturar, en la cual necesariamente interviene un notario. En el proceso de ejecución colectiva también participa el notario, documentando en escritura pública los acuerdos del concurso; así como en la quiebra, donde el notario ejerce funciones importantes como la de ocupación de bienes, y la redacción de inventario (y en cualquier otro caso que se requiera redactar un inventario) y avalúo de éstos. Finalmente, el notario por medio de una autenticación de firmas interviene en el desistimiento a juicio de la parte que así lo desee.

2.6.2 Títulos ejecutivos

Otra función muy importante de los notarios es su intervención en la creación de títulos ejecutivos para los procesos de ejecución. Este es otro ejemplo de cómo existe un vínculo estrecho entre la actividad notarial y la procesal. En materia procesal mercantil, son títulos ejecutivos las copias legalizadas de las actas de protocolación de protestos de documentos mercantiles y bancarios. Asimismo son títulos ejecutivos en la vía de apremio los testimonios de escrituras públicas donde se plasme el contrato de transacción, hipoteca o prenda, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar una cantidad de dinero líquida y exigible. También interviene el notario en la escrituración después que se dicta el auto que aprueba la liquidación en los procesos de ejecución. En el proceso ejecutivo[60] los testimonios de escrituras públicas, actas de protocolización y actas notariales son títulos ejecutivos. Este efecto se debe probablemente a que en sus orígenes el documento notarial provenía del juez, y que en cierta forma dicho documento es una forma de prueba preconstituida.

2.7 Efectos cuasiprocesales: subastas, loterías, protestos

Según el Acuerdo Gubernativo del 9 de agosto de 1968 se requiere de un notario para hacer constar en[61] acta notarial lo acontecido en loterías, rifas y eventos similares. El notario también interviene en

58 La función depositaria implica el guardar y custodiar los documentos que componen el registro notarial que el notario forme, el cual no le pertenece, ni a él, ni a las partes o sujetos que intervengan en su creación, sino al Estado, quien es su propietario por ser bien nacional de uso no común, al estar al servicio de éste y formar parte de su patrimonio. Un caso similar es el de los expedientes judiciales, ya que ni las partes ni el abogado se pueden quedar con los autos. La función de depositario se manifiesta en varias ocasiones; v.g. art. 86 Código de Notariado, y en sentido amplio, el art. 27 del mismo código.

59 La actividad de auxiliar del juez y, en cierta forma también de las partes de un proceso; se tiene, por ejemplo, en los siguientes artículos: 71, 72, 33, 181, párrafo primero; 192, párrafo primero; 220, 298, 324, 349, 381, párrafo final; 396, 382, 384, 555 a 567, 585. Vea Mario Aguirre Godoy, 1993-I:223-227. Esta tradición judicial proviene de la época colonial, cuando había un escribano en cada juzgado.

60 El notario también crea títulos ejecutivos según la Ley de Bancos arts. 51 y 112.

61 El acuerdo de la Corte Suprema de Justicia número 202 del 19 de julio de 1968 prohibió a los jueces de paz asistir a legalizar la

las subastas voluntarias, según el artículo 449 del Código procesal civil y mercantil, según las condiciones que libremente fijen las partes. El artículo 791 del Código de Comercio autoriza que en los fideicomisos de garantía, el fiduciario puede promover la venta de los bienes fideicometidos en pública subasta ante notario, en caso de incumplimiento del deudor, siendo nulo todo pacto que autorice al fiduciario a entregar los bienes al acreedor en forma distinta. Se ha considerado que este artículo puede adolecer de inconstitucionalidad, pues viola el derecho (que algunos consideran irrenunciable) al debido proceso ante tribunal competente; pues el deudor es desposeído de su derecho de propiedad sin haber sido citado, oído ni vencido en juicio. La Corte de Constitucionalidad así lo consideró en el caso del artículo 243 del Código Procesal civil y mercantil.[62] En un tema relacionado con el proceso ejecutivo, cual es el protesto en los títulos de crédito, el notario también tiene una participación primordial, precisamente levantando el acta notarial de protesto (art. 480 Código de Comercio).

2.8 Efectos tributarios

El Código tributario[63] faculta a los notarios designados por la Administración Tributaria para notificar personalmente a los contribuyentes o responsables ante ésta. También podrán hacerse estas notificaciones entregando la cédula en manos del destinatario donde quiera que se le encuentre, inclusive en el extranjero, debido a que los notarios pueden actuar en el extranjero. La Ley del impuesto de timbres fiscales[64] considera que los notarios por su 'condición' de tales, gozan de los *privilegios* de los patentados, lo cual resulta un ingreso de dudosa constitucionalidad.

2.9 Efectos registrales

El documento auténtico tiene un importante afecto en el área registral. Prácticamente todos los documentos que se ingresan a los Registros de la Propiedad y al Mercantil tienen que haber pasado ante los oficios de un notario. El artículo 1,576 del Código Civil manda que los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberán constar en escritura pública. Tal es el caso de las compraventas de inmuebles, ya que para que se inscriba el título sobre el derecho real de propiedad adquirido por la compraventa se requiere de escritura pública.[65] Sin embargo, los contratos que no se otorguen en escritura pública (si no fueren contratos solemnes como el caso del fideicomiso) serán válidos y las partes pueden compelerse recíprocamente al otorgamiento de ésta, si se establecieren sus requisitos esenciales por confesión judicial del obligado o por otro medio de prueba escrita, lo que implica un juicio. En el caso del Registro General de la Propiedad, los documentos aceptables son los testimonios de escrituras públicas, lo mismo ocurre en el caso del Registro Mercantil y el Registro de Poderes, así como los documentos que provienen del extranjero, cuando tienen que ser presentados ante los registros. Este acto previo de parte del notario ayuda a que el procedimiento registral sea más rápido y descentralizado, ya que de cierta forma, éste empieza desde que las partes concurren ante el notario que autoriza el documento, de tal forma que los interesados no tengan que ir personal-

realización de loterías, rifas, remates o subastas, pues su actuación en esas actividades era ajena a la función jurisdiccional. Además, vea arts. 2 y 5 del Decreto número 1610 del Congreso, y art. 8 del Acuerdo Gubernativo del 18 de mayo de 1956 de Castillo Armas.

62 Ida Rebeca Permuth Ostrowiak, 1998:21-67.

63 Arts. 133 y 134 del Código tributario, Decreto 6-91 del Congreso según fue aquél reformado por el art. 34 del Decreto 58-96 de Congreso, vigente a partir del 15 de agosto de 1996.

64 Art. 27 del Decreto 37-92 del Congreso, cuya redacción es equívoca, ya que considera al Notariado como una 'condición', y además les otorga 'privilegios', cuando la Constitución los prohibe expresamente en el art. 130. Hay personas que creen que cuando la Ley del impuesto al valor agregado menciona que ese tributo se puede pagar adhiriendo timbres fiscales, que es un acto tributario que se rige por la Ley de timbres fiscales. Esta postura es incorrecta, ya que lo que se permite es que en vez de pagar en efectivo se pague con timbres fiscales, lo cual es permitido por el propio Código tributario en el art. 9: 'Tributos son las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder tributario, con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines'. Por ende, en el caso de pagar el impuesto al valor agregado con timbres, el acto no se debe regir por la Ley del timbre fiscal, sino por la Ley al impuesto al valor agregado.

65 Una normativa, -de las más antiguas respecto de este tema para Guatemala- es la Real Cédula del 1 de noviembre de 1591

mente ante un funcionario del registro y hacer su trámite ante él.

Es de suma importancia que los documentos que se presenten sean faccionados con cuidado, ya que pueden causar que las inscripciones no surtan efectos si se probare que éstos son nulos o falsos. La Corte de Constitucionalidad considera que los documentos falsos que den vida a un asiento registral no pueden ser motivo para violar el derecho de propiedad del dueño; así se pronunció:

> [...] está [*sic*] Corte en sentencia del veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y tres, Gaceta veintinueve, página ciento noventa y dos, consideró: '[...] estando probada la falsedad e inexistencia de los títulos conque se operó la cuarta inscripción de dominio sobre la finca relacionada, ésta resulta nula y jurídicamente inexistente, deviniendo, en consecuencia también nula la quinta inscripción de dominio y cualquiera otra posterior. De ahí se establece que, en el presente caso, se violó a la postulante su derecho de propiedad pues la autoridad impugnada operó la cuarta inscripción de dominio y subsiguientes con documentos falsos y de autenticidad aparente, contrariando el principio de que las inscripciones registrales se operan sobre la base de la presunción de autenticidad legítima de los documentos públicos que se presentan al Registro, con ello se afectó a la postulante su derecho de propiedad garantizado por la Constitución y las leyes [...]' Tomando este fallo como premisa, esta Corte concluye que, en el presente caso, también ha quedado demostrada la falsedad del documento que sirvió de base para las inscripciones que se impugnan, especialmente con lo manifestado por el Notario [...] y con el acta notarial autorizada en esta ciudad por el Notario [...], el quince de octubre de mil novecientos noventa y tres; por lo que la protección que se solicita deviene procedente, toda vez que se ha establecido la violación al derecho de propiedad como se denuncia y así debe declararse.[66]

Como se puede ver, la actuación notarial en los asuntos registrales puede ser la diferencia entre la existencia o inexistencia de las inscripciones.

3- Efectos de los actos registrales

Así como el ejercicio del Notariado tiene efectos en muchos aspectos de los actos y negocios jurídicos, también los actos registrales tienen sus propios efectos encaminados a ofrecer seguridad jurídica. En la mayoría de los casos, nuestro sistema registral no tiene efectos constitutivos[67] (el sistema que más seguridad jurídica provee), sino declarativos; en parte porque las fuentes del Derecho civil guatemalteco no confían los derechos a actos registrales. Otra fuente histórica del porqué los registro en Guatemala no han evolucionado hacia mayor protección de los derechos es que la Administración Pública nunca ha podido servir a la mayoría de los administrados. El acceso a los registros está, de hecho, limitado a las personas que tienen conocimiento de su existencia y, en muchas instancias, recursos económicos para asumir el elevado costo del proceso registral.

Existe otra fuente, tal vez la más digna de discutirse, de la razón porqué algunas personas no aceptan que el acto registral tenga un efecto constitutivo, o que éste sea necesario para la existencia de los derechos: la libertad. Tal vez este problema se pueda solucionar con acotar que no se trata de que los derechos registrados existan porque el Estado los constituye, sino que frente a éste sólo se debe reconocer los derechos registrados. Esto quiere decir que

donde obligaba a que las ventas, trueques, empañamientos que se hicieren de cualquier bien raíz, mueble o semoviente se hiciera ante escribano del número. AGCA, A3.5. Exp. 1,295. Leg. 67. Fol. 5, la cual no apareció cuando la busqué físicamente en el Archivo. Después de la Independencia, por disposiciones del 14 de enero y 28 de agosto de 1832 exigían la escritura pública para acreditar las convenciones sobre enajenación de bienes raíces. Todo esto cambió por virtud del decreto de 28 de octubre de 1843, en es cual se dispensaba de la obligación de la escritura pública. Este decreto a su vez fue derogado por el art. 2066 del Código Civil de 1877, según se coligue de lo informado por la comisión de reforma hipotecaria llevada a cabo por Manuel Ubico a finales del siglo XIX. (Informe, 1932:70).

66 Sentencia del 15 de junio de 1994 en la Gaceta Jurisprudencial Nº 32. Apelaciones de Sentencias de Amparos. Exp. Nº 561-593.

67 El art. 24 del Decreto 100-97 del Congreso, Ley de Aviación Civil, establece un registro aeronáutico nacional, el cual dispone expresamente que: 'no tendrá carácter constitutivo de derecho'.

en cualquier tribunal u órgano administrativo se considerará válido y existente sólo el derecho que esté inscrito. Y esto por lo mismo que la mayoría ha acordado que se maneje por el lado derecho de las calles, o que debemos parar cuando el semáforo está en rojo; porque proporciona seguridad.

3.1 Efectos respecto de los contratantes

El artículo 1,808 del Código Civil establece una norma que apoya el sistema registral de carácter constitutivo, ya que si la cosa vendida es inmueble o derecho real sobre inmueble, prevalece la venta que primero se inscriba en el Registro. Adicionalmente, el artículo 1,885 del Código Civil establece que cuando una misma cosa se ha arrendado a dos o más personas, tiene la preferencia el primer contratante, y si los contratos son de la misma fecha, en que tenga la cosa en su poder; pero, si el arrendamiento se debe inscribir en el Registro de la Propiedad, la preferencia corresponderá al que primero que inscriba su derecho. Estas dos normas se apartan de la tendencia general del Derecho guatemalteco, ya que el Código hace nulo uno de los dos contratos coexistentes, desatando el vínculo creado por la manifestación de voluntad de quienes no hayan sido prudentes y rápidamente hayan inscrito su derecho.

Como una excepción al principio general de los efectos que tiene el acto registral, porque generalmente los tiene sólo declarativos, el artículo dieciocho del Código Civil,[68] recientemente reformado, dispone que: '[...] la personalidad jurídica de las asociaciones civiles es efecto del acto de su inscripción en el registro del municipio donde se constituyan. [...]. Aunque se menciona el concepto de la personalidad jurídica, realmente lo que se indica es que el contrato de asociación será válido hasta que éste sea inscrito en el Registro Civil.

3.2 Efectos frente a terceros

En el Derecho registral inmobiliario un tercero es la persona que no interviene como parte en un acto o contrato determinado. En el sistema registral guatemalteco, únicamente perjudica a tercero lo que aparezca inscrito o anotado en el Registro y lo que conste en certificación expedida por el registrador.[69] Los títulos inscritos o anotados surten efectos contra tercero y aun contra los acreedores singularmente privilegiados, desde la fecha de su presentación ('entrega' dice el Código) ante el Registro.[70] Este tema es discutido extensamente por la doctrina, y resultó (en el caso de Guatemala) de haber seguido al Derecho español y, más aún, al Derecho civil francés, al cual repugna la noción de la obligatoriedad de registro para constituir derechos. Existen ejemplos del carácter declarativo que tiene casi todo el sistema registral, tal como lo es el artículo 1,704 del Código Civil, que dice: 'El testimonio de la escritura pública del mandato y el de la revocación debe presentarse al Registro de Poderes'. El contrato de poder es válido entre las partes contratantes, pero sólo afecta a terceros desde que queda inscrito en el Registro de Poderes y en el Registro Mercantil,[71] en algunos casos. Lo mismo se puede decir del artículo 1,680, porque cuando la promesa se refiere a enajenación de bienes inmuebles o derechos reales sobre éstos, el contrato debe inscribirse en el Registro de la Propiedad, y sólo así será oponible frente a terceros. La Corte de Constitucionalidad[72] ha considerado que: '[...] es jurisprudencia reiteradamente sostenida por esta Corte que las inscripciones en el Registro de la Propiedad no tienen carácter de notifica-

68 Reformado por el artículo 53 del Decreto 114-97 del Congreso, vigente desde el 20 de diciembre de 1997.

69 El art. 1,181 del Código Civil obliga al registrador a que haga mérito en la certificación de cualquier título que estuviere presentado solamente, pero que tenga relación con el asiento certificado. Se debe deducir entonces que si se tiene a la vista una certificación en la cual no se ha hecho mérito de la presentación de otros títulos, si éstos de hecho se hubieran presentado, no afectarán a tercero, pues no constarían en la certificación. Esta consideración es importante hacerla, ya que actualmente los registradores se tardan mucho en hacer las inscripciones.

70 Art. 1,148 del Código Civil.

71 El art. 338 del Código de Comercio establece que: 'Aparte de los hechos y relaciones jurídicas que especifiquen las leyes, es obligatorio el registro de los siguientes: 1o. El nombramiento de administradores de sociedades, de factores y el otorgamiento de mandatos por cualquier comerciante, para operaciones de su empresa'. Esta es la razón por la cual los poderes especiales judiciales no deben ser inscritos en el Registro mercantil, ya que éstos no son necesarios para la operación de la empresa, ya que la comparecencia a juicio nunca podrá ser el giro ordinario ni extraordinario de una empresa mercantil, sino el ejercicio del derecho al debido proceso.

72 Sentencia del 11 de febrero de 1992 en Gaceta Jurisprudencial Nº 23, Apelaciones de Sentencias de Amparos, Exp. 287-291.

ción a las partes interesadas [...]'; lo cual resulta interesante, pues pone un límite a lo que debe entenderse por la publicidad registral, y cómo los administrados se notician de la información que consta en el Registro. Aún frente al Estado el registro de derechos es de trascendencia porque si los derechos que se tengan sobre un inmueble localizado en las áreas de reserva de la Nación no están registradas con anterioridad al primero de marzo de 1956,[73] éstos se consideran inexistentes.

3.3 Efectos procesales del acto registral

El artículo 1,129 del Código Civil dispone que en ningún tribunal ni oficina pública se debe admitirán escrituras ni documentos sujetos a inscripción, que no hubieran sido razonados por el registrador. Esta norma resulta importante para analizar cuidadosamente todos los documentos que se presentan ante el Registro, especialmente cuando se incluye documentos como medio de prueba (testimonios de arrendamientos por más de tres años, promesas sobre inmuebles) y los testimonios de poderes. También el artículo 45 del Código procesal civil y mercantil establece que no se admitirá en los tribunales credencial de representación que no esté debidamente registrada en la oficina respectiva. Entre los efectos del emplazamiento[74] está el efecto material de hacer anulables la enajenación y gravámenes constituidos sobre inmuebles objeto del proceso, con posterioridad al emplazamiento, el cual sólo se producirá si se hubiera anotado la demanda en el Registro de la Propiedad. En cuanto embargo[75] de bienes inmuebles o derechos reales, éste se debe anotar en el respectivo Registro de la Propiedad para surtir su efecto procesal; así como cuando un crédito embargado esté garantizado con hipoteca.

3.3.1 Medio de prueba tasado

El documento público registral es uno de los medios de prueba tasados por la ley procesal, ya que producen fe y hacen plena prueba en juicio, salvo el derecho de las partes a redargüirlos de nulidad o de falsedad. El juez debe apreciar este medio de prueba como que es verdad lo que en ellos está plasmado. Sin embargo, se debe distinguir entre el documento en sí mismo, su materialidad, y, por otra parte, su contenido. Respecto de la materialidad, los libros y certificados no deben tener alteraciones, cortaduras ni raspaduras, lo cual causaría la nulidad del asiento que así apareciere. En cuanto al contenido de los asientos se ha de tener en cuenta: que sea el registrador quien haga el asiento, y que éste contenga los requisitos que el Código Civil o el Código de Comercio, en su caso, manda.

El documento público expedido por el Registrador de la Propiedad se denomina 'certificación' (o 'copia fotográfica legalizada por el Registrador'),[76] la cual se tendrán como fidedigna, salvo prueba en contrario.[77] Sin embargo, el juez o el adversario en un juicio pueden solicitar que se exhiba el documento original, en este caso los libros del registro. Aunque el Código Procesal civil y mercantil, permite excepcionalmente al juez ordenar que se lleven a su presencia los registros o archivos, hay prohibición expresa de sacar los libros de la oficina del Registro de la Propiedad, aunque sea por motivos de diligencias judiciales; de tal forma que se debe hacer en éste lugar.[78]

4- Extinción de la calidad de documento público

El documento notarial y los documentos públicos emitidos por el Registrador de la Propiedad tienen una gran trascendencia en el Derecho. El legislador procesal les ha dado calidad de plena prueba, en tanto no se pruebe que son falsos o nulos. Sin embargo, estos extremos son difíciles de probar en muchos casos, por lo que es importante que dichos documentos producto de la fe pública que ostentan tanto notarios, como funcionarios

73 Art. 122 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
74 Literal 'e' del art. 112 del Código procesal civil y mercantil.
75 Art. 308 y 304 del Código procesal civil y mercantil.
76 Arts. 1,183 y 1,179 del Código Civil.
77 El art. 1,184 del Código Civil dispone que cuando las certificaciones que expida el registrador no fueren conformes con los asientos a que se refieren, se estará a lo que de éstos resulte, salvo la acción del perjudicado por aquéllas para exigir la indemnización correspondiente del registrador que hubiere cometido la falta.
78 Art. 1,222 del Código Civil.

públicos, representen fielmente la verdad. Adelante se examina los procesos mediante los cuales se desnuda a los documentos notariales y públicos de su autenticidad para mostrar cuanto el legislador los protegió en pro de la fe pública y la celeridad en la contratación.

4.1 Documentos deteriorados

Los documentos notariales que han sufrido algún desperfecto material no gozan de la presunción de plena prueba, esto para protección del público, porque se duda de la integridad del documento. Es interesante notar, como lo hace Aguirre Godoy,[79] que en el antiguo Código procesal, se disponía que no producirían plena prueba el testimonio de testimonio, a no ser en los casos de reposición de protocolo, disposición que ahora ya no existe; el documento referente, si no se comprobaba existencia del referido, fuera nulo o fuera falso o del documento que en su parte esencial estuviera roto, raído, con borrones o testaduras no salvadas. Las normas procesales vigentes establecen que no hacen fe en juicio los documentos públicos rotos, cancelados, quemados, o raspados en su parte sustancial. Desgraciadamente, el Código actual utiliza el término 'sustancial', en vez de 'esencial', que lo hace más extenso, pero más impreciso, ya que no se sabe exactamente qué es 'sustancial'. El Código de Enjuiciamiento sí disponía cuáles eran las partes esenciales del documento: los nombres y apellidos de los otorgantes, testigos, y Notarios; la cosa o materia del documento; las cláusulas indispensables para conocer su naturaleza y efectos; el lugar y fecha del otorgamiento; la suscripción de los que intervienen en el acto, y el sello del Notario, cuando así fuera requerido por la ley. Por otra parte, el Código de Notariado en el artículo 31 explica cuáles son los elementos esenciales del instrumento notarial; por lo que al hacer una interpretación usando la historia fidedigna de la institución e integrando con esta norma, se puede saber qué es un elemento 'sustancial'.

4.2 La redargución de falsedad o nulidad de un documento público

La redargución es el procedimiento mediante el cual se desnuda a un acto, plasmado en un documento, en el que intervino un agente fedatario, de la cualidad de plena prueba. Si el documento fuere redargüido y se considerare que existen indicios de criminalidad, lo deberán denunciar al Ministerio Público y entregar dicho documento a las autoridades que realicen la investigación criminalística.[80] El documento público notarial podría ser redargüido por dos razones: por la nulidad del documento o por su falsedad. Cuando en juicio civil se declare que un documento faccionado o autorizado por notario no es un documento público, por el propio acto de desvanecimiento o denudación, ningún otro tribunal o entidad pública podrá considerarlo como tal; *contrario sensu* del caso de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la cual se estableció que un documento privado reconocido en juicio produce prueba en otro.[81] La declaratoria de nulidad o falsedad de un documento notarial podría acarrear varias consecuencias: en el ámbito registral,[82] podría caber la nulidad de las inscripciones hechas con motivo de la presentación del testimonio de la escritura pública redargüida en juicio, por ejemplo el caso de un contrato de sociedad mercantil o de donación de bienes inmuebles. Y en el ámbito contractual causaría que no existiera contrato de mandato, si la escritura pública en que se plasmó el poder fuere declarada nula o falsa por un juez. La nulidad que se declara en este juicio es absoluta, por lo que nunca nace a la vida jurídica el acto notarial o fedatario.

4.3 Indemnización por mal faccionamiento de un documento notarial: responsabilidad civil de los notarios

Existirá culpa de parte del notario que haya autorizado el documento notarial que fuera declarado nulo o falso

79 Mario Aguirre Godoy, 1993-I:705-706.

80 El documento se convertiría en el objeto material del delito, el cual tendría que pasar a formar parte de los medios de prueba en el juicio penal correspondiente.

81 Mario Aguirre Godoy, 1993-I:707, nota al pie número 17.

82 La calificación que hace el registrador mercantil no impide ni perjudica el juicio que pueda seguirse en los tribunales sobre la nulidad de un documento notarial presentado en el Registro Mercantil, pues se entiende limitada para el efecto de negar o admitir su inscripción o anotación; siguiendo el principio que el asiento registral no convalida los actos nulos. Art. 346 del Código de Comercio.

en un proceso civil. La indemnización compensatoria responderá por el incumplimiento del contrato de obra que requirieron sus clientes. El notario deberá responder por el daño emergente y el lucro cesante que ocasione a las partes, dado que habrá incumplido con el contrato de obra (no el de un contrato de servicios profesionales[83]), que le obligaba a producir un documento que fuera perfecto desde el punto de vista, cuando menos, técnico. La culpa sería fácil de probar; ya que difícilmente el notario no sabría el lugar o la fecha en la cual autoriza un documento notarial, por ejemplo. La culpa de un notario que: no lleve a cabo las formalidades esenciales y especiales que las leyes le exigen, no se haga las advertencias pertinentes, o no esté presente cuando firmen las personas que intervengan en un acto notarial, es inexcusable. Podrá existir culpa (impericia, imprudencia o negligencia) en cuanto a la identificación de las partes o quienes intervengan en el acto, si el notario no toma la precaución de verificar que los documentos de identificación que le presenten son auténticos. Cuando un notario se da cuenta que ha cometido un error en cuanto a asuntos enmendables de forma contemplados en el artículo 93 del Código de Notariado, debe proceder a corregir su falta lo antes posible ante juez de primera instancia, a sazón de que no incurrir en responsabilidad por su negligencia, prueba de lo delicado que resulta cometer errores en el ejercicio del Notariado.

Conclusión

Como se ha podido ver en el transcurso del presente trabajo, la actuación del notario al producir el documento notarial y los actos registrales derivados de la actuación del Registrador, tienen efectos fundamentales en el Derecho guatemalteco. En muchos casos el propio derecho existe legalmente sólo si el documento notarial ha sido otorgado. Los efectos declarativos de los actos registrales no son menos elementales, aunque no sean constitutivos de derechos. Ambos actos jurídicos están investidos de una fuerza probatoria inusual, similar a la prueba anticipada, gracias a la confianza que el pueblo ha delegado en los profesionales y funcionarios para hacer viable la seguridad jurídica que el Estado debe proveer. Desgraciadamente, la falta de conocimiento -entre los notarios, los funcionarios y empleados públicos y los usuarios- sobre sistema de fe pública registral y notarial, aunado a la casi total falta de fiscalización de estas actividades, han causado el desplome y desprestigio de dichas instituciones de la seguridad jurídica. Se espera que esta breve introducción al tema despierte más interés entre los que en la práctica o desde la cátedra se encuentren con estas instituciones, y les den el valor que les corresponde.

Bibliografía

Aguirre Godoy, Mario
1993 *Derecho procesal civil.* Guatemala: Centro Editorial VILE.

Azurdia Alfaro, Roberto (recopilador)
1981 *Leyes vigentes de gobernación.* Guatemala: Tipografía Nacional.

Bejarano Sánchez, Manuel
1984 *Obligaciones civiles.* México: Harla, S.A.

Boggiano, Antonio
1993 *Curso de Derecho internacional privado.* Buenos Aires: Abeledo-Perrot, S.A.

Carrera Raya, Francisco José
1994 *Manual de Derecho financiero.* Madrid: Editorial Tecnos.

Cifuentes, Santos
1994 *Negocio jurídico.* Buenos Aires: Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma S.R.L.

83 Hay quienes consideran -equivocadamente- que el contrato por el cual el notario presta sus servicios es el de servicios profesionales. La realidad es que el contrato de obra, un contrato de fines, y no uno de medios, como lo es el de servicios profesionales, obliga al notario a producir un documento por el cual se protege la seguridad jurídica de quien lo contrata o de las partes que se ven afectadas por el documento notarial (en este caso la responsabilidad del notario frente a la parte que no pagó los servicios notariales es de naturaleza extracontractual). Si el documento faccionado no produce esa seguridad jurídica, habrá responsabilidad del notario, y se le podrá exigir el pago de daños y perjuicios. La diferencia entre un contrato de medios y uno de fines es que, en éste sólo se exige que el deudor haga sus mejores esfuerzos con el conocimiento que ha adquirido, razonablemente, tanto en la universidad, como en la vida profesional; mientras que en aquél lo importante es que la cosa sirva al acreedor para lo que ordinaria y legalmente ésta sirviere.

De Erice y O'shea, José Sebastián
1954 *Derecho diplomático.* Madrid: Instituto de Estudios Políticos.

Díez Picaso, Luis
1993 *Fundamentos del Derecho civil patrimonial.* Madrid: Editorial Civitas.

Fernández Rozas, José Carlos [Sánchez Lorenzo, Sixto]
1993 *Curso de Derecho internacional privado.* Madrid: Editorial Civitas.

Giuliani Fonrouge, Carlos M.
1993 *Derecho financiero.* Buenos Aires: Ediciones Depalma.

Informe
1932 *Informe y Proyecto de Ley.* Guatemala: Tipografía Nacional.

Martín, José María [Rodríguez Usé, Guillermo F.]
1995 *Derecho tributario general.* Buenos Aires: Ediciones Depalma.

Méndez Montenegro, Julio César
1960 '444 años de legislación agraria'. *Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala.* VI-9 al 12. Guatemala: Universidad de San Carlos.

Méndez, Rosendo P. (recopilador)
1927 *Leyes vigentes recopiladas por la Secretaría de Gobernación y Justicia, y apéndice de reglamentos.* Guatemala: Tipografía Nacional.
1937 *Leyes vigentes de Gobernación y Justicia.* Guatemala: Tipografía Nacional.

Moreno, Laudelino
1946 *Derecho consular guatemalteco.* Guatemala: Tipografía Nacional.

Nuñez Lagos, Rafael
1945 *Estudios sobre el valor jurídico del documento notarial.* Alcalá de Henares: Imprenta Talleres Penitenciarios.

Ojeda Salazar, Federico
s.f. *Exposición de motivos del Código Civil.* Guatemala: Casa editora Gomes Robles.

Pérez de Hoyo, Fernando
1996 *Derecho financiero y tributario, parte general.* Madrid: Editorial Civitas.

Permuth Ostrowiak, Ida Rebeca
1998 'El subarrendamiento y el debido proceso'. *Revista de la Facultad de Derecho,* VIII-15. Guatemala: Universidad Francisco Marroquín.

Registro
1971 *Registro.* Órgano oficial del Registro de la Propiedad de Guatemala. Segunda época. No. 3. Volumen I.

Rodríguez Usé, Guillermo F.
1995 [Martín, José María; -]

Salas, Oscar A.
Derecho notarial de Centroamérica y Panamá. San José: Editorial Costa Rica.

Sánchez Lorenzo, Sixto
1993 [Fernández Rozas, José Carlos; -]

Solombrino Orozco, Vincenzo
1977 *El Ministerio de Gobernación de Guatemala.* Guatemala: Tipografía Nacional.

Ubico, Manuel
1932 *Informe y Proyecto de Ley.* Guatemala: Tipografía Nacional.

Villegas, Héctor B.
1995 *Curso de finanzas, derecho financiero y tributario.* Buenos Aires: Ediciones Depalma.

Viteri, Ernesto R.
1992 *Los contratos en el Derecho civil guatemalteco (Parte especial).* Guatemala: Serviprensa Centroamericana.

Libertad es libertad, no igualdad,
ni equidad ni justicia ni felicidad,
ni una conciencia tranquila.

Sir Isaiah Berlin

GLORIA RODRÍGUEZ NATARENO[1]

Algunos antecedentes históricos y legislativos del mercado de telecomunicaciones en Guatemala[2]

Sumario

Introducción
1- Las primeras telecomunicaciones
2- Primeras manifestaciones del intervencionismo estatal
3- Telecomunicaciones: *servicio público*
4- Creación de órganos administrativos específicos
5- Desarrollo del tráfico internacional
6- Aparece GUATEL
7- Desmonopolización de GUATEL
8- Consideraciones finales
Bibliografía

Introducción

La experiencia internacional demuestra que el mercado de telecomunicaciones ha mejorado considerablemente a raíz de su desmonopolización, y ello no puede ser de otra manera, ya que cuando existe sólo un operador de telecomunicaciones, sus recursos -limitados, por muchos que sean- no se dirigen a satisfacer las necesidades del mercado sino solamente aquéllas que su capacidad le permite. Con base en esta circunstancia es que ya son más de 70 países los que han liberalizado su mercado de telecomunicaciones, permitiendo la libre entrada y permanencia de competidores dentro de éste. Siguiendo esta acertada tendencia, Guatemala, a partir de 1996, cambió la legislación aplicable a la prestación del servicio de telecomunicaciones y redefinió considerablemente la función de la administración pública respecto del mismo.

A continuación se presentará una investigación sobre el marco legal que regula el mercado de telecomunicaciones en Guatemala a efecto de dar a conocer sus rasgos característicos así como los innovadores servicios que contempla. Para la justa apreciación de esta investigación, cabe mencionar que si bien la legislación que regula el mercado de telecomunicaciones en Guatemala tiene ya casi 4 años de vigencia, en nuestro país el tema ha sido muy poco estudiado desde la perspectiva de sus connotaciones legales -no así de las técnicas y económicas-. Fuera de un artículo de revista publicado por un jurista guatemalteco, no existe bibliografía sobre el particular. A ello se suma el hecho que esta materia también ha sido poco examinada en las aulas de la Facultades de Derecho, quizá por la complejidad derivada de sus implicaciones técnicas.

Estas son algunas de las circunstancias que nos motivaron para la elaboración de este estudio, el que -por la ausencia de bibliografía ya comentada- se basa principalmente en el análisis directo del texto de la legislación aplicable en concordancia con los principios constitucionales y los generales del Derecho, en entrevistas con abogados expertos en la materia, en investigación de campo y en alguna experiencia adquirida a raíz del trabajo directo en el mercado en cuestión.

Finalmente, es necesario aclarar desde ya al lector que dentro de esta investigación no se incluye lo relativo al proceso por el cual la empresa que hasta hace poco tiempo prestaba los servicios de telecomunicaciones en Guatemala -en calidad de monopolio- pasó a manos de particulares. Este hecho simplemente se mencionará como parte del desarrollo his-

1 Abogada y Notaria.

2 Capítulo primero del trabajo equiparado a tesis de graduación, intitulado *Estudio sobre la legislación aplicable al mercado de telecomunicaciones en Guatemala*, conformado por cuatro ensayos.

tórico de las telecomunicaciones en Guatemala, pero sus detalles se han omitido por apartarse del objeto inicialmente trazado para la elaboración de este trabajo. La extensión y complejidad del caso ameritarían una investigación especialmente dedicada a ello.

1- Las primeras telecomunicaciones

En Guatemala el primer servicio de telecomunicaciones que se conoció fue el telégrafo. A iniciativa del francés Oscar Du Teil y con el auxilio de los guatemaltecos Salvador Cobos y Francisco Alvarez, en 1867 se instaló la primera línea telegráfica entre Amatitlán y la ciudad capital.[3]

Teniendo como antecedente al telégrafo, las primeras comunicaciones telefónicas aparecieron en Guatemala en 1881, de Guatemala a la Antigua, y fueron prestadas por una empresa privada,[4] propiedad del guatemalteco Roderico Toledo. Posteriormente, este servicio se extendió a Quetzaltenango,[5] llegando a tener 400 aparatos en funcionamiento. El servicio telefónico de la capital fue formalmente organizado en 1884[6] por Toledo, con base en una concesión gubernativa de 23 de septiembre de ese año[7] que le autorizaba para ello. Esta concesión fue otorgada durante el régimen presidencial del General Justo Rufino Barrios. El documento que la formalizó establecía, entre otras cosas, que:

> '[*sic*] Traída á la vista la exposición en que Don Roderico Toledo, deseando organizar en esta capital un *exchange* ó servicio de teléfonos tal como lo poseen las principales ciudades de los Estados Unidos del Norte, solicita del Gobierno las concesiones que para tal objeto conceptúa necesarias y creyendo conveniente deferir á esa solicitud, ya que será notoriamente ventajosa, así para las autoridades como para el público, la realización de tan útil proyecto en las favorables condiciones que Toledo ofrece, y ya también que al solicitante le son indispensables el privilegio y demás exenciones que demanda, para compensar así las erogaciones que exigirán la instalación y mantenimiento del servicio indicado; por tanto, el General Presidente acuerda: 1º. Se concede á Don Roderico Toledo, por el término de cinco años, que se contará desde la fecha, privilegio para establecer en la capital de la República el servicio de teléfonos [...]'

Como lo establece la disposición administrativa citada, esta concesión le fue otorgada a Toledo por el término de cinco años y su vigencia estaba sujeta a que éste comenzara formalmente sus trabajos el primero de enero de 1885 e inaugurara sus servicios con 50 teléfonos el primer día del mes siguiente, ya que, de lo contrario, la misma caducaría. Finalmente, estos términos fueron prorrogados por tres meses más.

Gracias al apoyo financiero de una compañía californiana, para 1890 Toledo ya había habilitado 180 aparatos telefónicos, cifra considerable si se tienen en cuenta las limitaciones técnicas de la época.

El 9 de enero de 1891, un grupo de guatemaltecos y extranjeros compró las acciones de la sociedad que inició Toledo y, en 1909 cambió su nombre al de *Compañía de Teléfonos de Guatemala*. Esta empresa inició con 900 aparatos habilitados y funcionaba las 24 horas del día. Su capital ascendía a $400,000.00, dividido en 4,000 acciones de $100.00 cada una. En esa época, en el ámbito nacional como en el interna-

3 Julio Luis Pereira Beckman, 1971.

4 Las fuentes consultadas no indican claramente si esta empresa privada inició siendo una empresa individual o si el servicio fue prestado desde un principio por una sociedad mercantil. Lo que sí se puede concluir es que para finales de 1890, el servicio de telefonía ya era prestado por una sociedad mercantil cuya dirección técnica y administrativa estaba, en gran medida, a cargo de Roderico Toledo.

5 En aquel entonces, debido a la insuficiencia de las instalaciones, únicamente se podía hablar desde los extremos del mismo hilo telegráfico y sólo de las diecinueve horas en adelante, para no obstaculizar la transmisión de telegramas.

6 Simultáneamente a la aparición de los primeros teléfonos, fue fundada la primera *Escuela de Telegrafía y Telefonía*, por el canadiense Stanley Macnider. De 1913 a 1918 funcionó la segunda escuela, cuyas actividades se rigieron por un reglamento aprobado por el presidente Manuel Estrada Cabrera. La tercera escuela, que cambió su nombre al de *Escuela de Telegrafía, Telefonía, Radiotelegrafía y Radiotelefonía*, quedó formalmente establecida en 1939, por Acuerdo del General Jorge Ubico, Presidente de Guatemala. Esta escuela dejó de funcionar en 1944. Durante el gobierno del Coronel Jacobo Arbenz Guzmán, se acordó la reapertura de la escuela, pero esta labor se inició hasta 1954, bajo la administración del Coronel Carlos Castillo Armas. Esta vez la escuela se llamó *Escuela de Telegrafía y Capacitación* (José Luis Pereira Beckman, 1971:9-10).

7 *Leyes*, 1886-IV:241-243.

cional, se consideraba que la compañía era eficiente; así, en 1916, T.N. Vail, presidente de la *American Telegraph & Telephone Company (AT&T)* se refirió a ella diciendo que 'el servicio de la empresa de teléfonos opera en la capital y trabaja con buena regularidad'.[8]

2- Primeras manifestaciones del intervencionismo estatal

Si bien el servicio de telefonía había funcionado bien sin mayor reglamentación, el intervencionismo estatal no se hizo esperar más, y fue así como para esta época ya había sido decretado el primer *Código Telegráfico y Telefónico de la República de Guatemala*.[9] A partir de ese momento cada vez fue más la injerencia del Estado en la prestación del servicio de telecomunicaciones. Ello se debió no solamente a la vocación intervencionista que todo Estado ha presentado a lo largo de la historia, sino también a que este servicio específicamente se veía como un instrumento de intromisión en las actividades de los opositores políticos y de control de la ciudadanía. Adicionalmente, en el caso en cuestión, las compañías involucradas en el negocio ya habían presentado claras manifestaciones de rentabilidad, por lo que los gobiernos subsiguientes se dieron a la tarea de castigar dicha rentabilidad, primero, y de apropiarse de las compañías que la generaban, después. Sirva de ejemplo la disposición gubernativa de 4 de octubre de 1912 mediante la cual se creó un *Impuesto a las Empresas de Teléfonos particulares.*[10] Con el paso de los años, los accionistas de la Compañía de Teléfonos de Guatemala fueron vendiendo sus acciones a ciudadanos alemanes, hasta que aquéllas quedaron casi en su totalidad en manos de éstos.[11] Debido, entre otras cosas, a la nacionalidad de sus nuevos accionistas, en 1914, durante la Primera Guerra Mundial, la compañía fue intervenida y posteriormente estatizada.[12] Así, mediante Acuerdo Gubernativo de 25 de junio de 1914,[13] el Presidente Estrada Cabrera estableció que:

> '[...] 1º *Todas* las instalaciones telegráficas y telefónicas particulares establecidas o que en lo sucesivo se establezcan en el país, mediante la autorización del caso, *quedan bajo el control y dominio absoluto del Gobierno*; 2º *El Gobierno se reserva el derecho de usar en todo tiempo* y siempre que lo juzgue necesario, para sus comunicaciones, las correspondientes líneas telegráficas o telefónicas, *sin retribución alguna, y también para suspender el servicio respectivo*, temporal o definitivamente, en dichas instalaciones y retirar éstas cuando así lo considere conveniente; y 3º Las Empresas o Compañías establecidas en el país, autorizadas para el efecto, *no podrán colocar más líneas* en sus respectivos postes que las que se les haya permitido o permita, ni consentir que

8 *Diario El Independiente*, 22 de marzo de 1916, pág. 5: col. 2.

9 En los años anteriores a 1904 únicamente existía una serie de reglamentos y demás disposiciones administrativas dispersas, y no fue sino hasta el 21 de noviembre de ese año que mediante Decreto número 649 emitido por el presidente Manuel Estrada Cabrera, se creó el referido código. Con el objeto de que el lector se ilustre sobre la tendencia legislativa de aquella época en materia de comunicaciones, cabe mencionar que ese mismo día también se decretó el *Código Postal de la República de Guatemala* (Recopilación, 1909-XXIII:211-212).

10 Este impuesto se creó bajo el régimen de Manuel Estrada Cabrera y, entre otras cosas, establecía: '[*sic*] 1º. Que las Empresas de Teléfonos particulares establecidas en el país y las que en lo sucesivo se establezcan, paguen mensualmente á la Dirección General de Telégrafos, en concepto de arbitrio, y para subvenir, en parte, á los fuertes gastos que originan los servicios del ramo, cincuenta centavos ($.0.50) oro americano por cada aparato destinado al servicio local, y un peso ($.1.00), también oro americano, por cada aparato para comunicar entre fincas ó poblaciones [...] 4º. Las anteriores estipulaciones no alteran las contenidas acerca del particular en el Código de la materia, pues *el Gobierno queda en la facultad de ejercer la correspondiente vigilancia sobre las instalaciones telegráficas y telefónicas del país y suspenderlas temporal ó definitivamente cuando lo juzgue oportuno* [...]' (las cursivas son nuestras). (Recopilación, 1913-XXXI:231).

11 Pedro Barrera, 1960.

12 Algunos críticos afirman que la intervención y posterior estatización de las telecomunicaciones en Guatemala se dio solamente como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y no como manifestación del intervencionismo estatal. Esta afirmación la podemos rebatir argumentando que si solamente por esa razón hubiera sido, una vez acabada la guerra, las telecomunicaciones hubieran tomado el curso que tenían cuando iniciaron. Por el contrario, vemos que la guerra terminó no así el intervencionismo estatal en este campo -que se traduce en más de 25 años de monopolio, por lo que sostenemos que la vocación intervencionista del Estado sí fue una razón determinante para la estatización del servicio.

13 Recopilación, 1915-XXXIII:127.

otras empresas o particulares lo hagan, *teniendo únicamente el Gobierno derecho de efectuarlo* de su parte cuando lo crea necesario y sin remuneración alguna [...]' (las cursivas son nuestras).

Igual suerte corrió la compañía que prestaba servicios en Quetzaltenango.

Desde entonces, las tarifas por la prestación de los servicios de telefonía fueron fijadas por el Organismo Ejecutivo[14] y, por ende, desapareció aquel mercado de telecomunicaciones que, aunque incipiente, se había iniciado como una manifestación de la libre empresa y se había mantenido con base en el principio general de libertad de contratación. La intervención del Estado llegó a tomar tan absurdas dimensiones, que el 15 de junio de 1915 se emitió un Acuerdo Gubernativo por el que se establecía que, en lo sucesivo, *solamente el Gobierno podría importar aparatos telefónicos.*[15]

En 1927 se introdujeron los teléfonos automáticos, lo que se consideró un cambio drástico en materia de telecomunicaciones. Esta inversión[16] fue posible gracias a dos financiamientos de cerca de $725,000.00 oro americano que fueron otorgados por la compañía alemana *Allgemeine Elektricitaets Gesellschaft.* A diciembre de 1940, los pagos para cubrir estos créditos ya habían sufrido atrasos considerables por la incapacidad de las autoridades del gobierno de manejar éste y todo tipo de negocio.

En 1930 la empresa *Telefonaktitiebolaget L. M. Ericsson* se obligó a instalar dos plantas telefónicas automáticas de 4,500 y 500 líneas. En 1935 se instaló un conmutador, a efecto de poder conectar el sistema automático que ya funcionaba en la capital con los teléfonos de magneto que aún se seguían empleando en las demás poblaciones del país.

3- Telecomunicaciones: *servicio público*

Por disposición legal,[17] a partir de 1935 se estableció que el *sistema nacional de comunicaciones eléctricas* constituía un servicio público y su establecimiento y administración eran de la exclusiva competencia del Estado.

En congruencia con la nueva calidad que se le había dado a las telecomunicaciones, empezó a aparecer una serie de disposiciones administrativas dispersas que regulaban lo relativo a la prestación de este servicio. De esa cuenta y luego de varios años se emitió una ley que reguló detalladamente todo lo relativo a los aspectos administrativos y técnicos del servicio en cuestión: el Decreto-ley 272.[18] Esta disposición legal normó el proceso de contratación del servicio de telefonía fija, trámite y requisitos de instalación de las líneas telefónicas, categorías de usuarios, cuotas fijas por el servicio y tarifa por llamada, entre otros.

4- Creación de órganos administrativos específicos

El intervencionismo estatal y, en general, la tendencia estatizadora que se ha descrito, debía ser llevada a efecto por medio de un órgano administrativo especialmente dedicado a ello. De esa cuenta, en 1935, también mediante el ya mencionado Decreto 2080 de

14 Con este objeto fueron apareciendo innumerables disposiciones que regulaban lo relativo a las tarifas que se debían cobrar por la prestación del servicio de telecomunicaciones; así, por ejemplo, el 31 de agosto de 1915, se emitió un Acuerdo Gubernativo que establecía el máximum que podía cobrar la Compañía de Teléfonos de Guatemala. A este acuerdo le siguieron muchos más, como los del 31 de julio de 1916 y 31 de enero de 1917, por los que se modificaba la tarifa telegráfica y telefónica (Recopilación, 1922-XXXIV:189-190; Recopilación, 1923-XXXV:151, 295-296).

15 Este acuerdo agregaba que: '[...] 2º. Las Empresas o Compañías que, en virtud de contratos o concesiones, estén legalmente facultadas para hacer uso de líneas telegráficas o telefónicas de su propiedad y necesiten importar para el servicio de las mismas los respectivos aparatos o materiales y útiles, *deberán solicitar y obtener previamente de la Secretaría de Fomento, la correspondiente autorización escrita* [...]' (Recopilación, 1922-XXXIV:99).

16 Las instalaciones principales comprendían: una planta para dos mil líneas telefónicas; un edificio con capacidad para instalar dicha planta, previendo de antemano aumentarla a seis mil líneas; dos mil aparatos telefónicos y el sistema de distribución (Rafael Pérez Riera, 1996:427).

17 Decreto número 2080 de la Asamblea Legislativa de la República de Guatemala, dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de Guatemala el 27 de abril de 1935 (Recopilación, 1938-LIV:156-248).

18 Este Decreto-ley fue dado por Enrique Peralta Azurdia, Jefe del Gobierno de la República, el 10 de septiembre de 1964 (Recopilación, 1968-LXXXIII:125-131).

la Asamblea Legislativa de Guatemala,[19] se estableció que todas las telecomunicaciones del país, en adelante, dependerían de la *Dirección General de Telégrafos,* adscrita a la *Secretaría de Fomento.*

Posteriormente, el 3 de octubre de 1938,[20] se creó el *Servicio de Comunicaciones Radiotelegráficas y Radiotelefónicas de la República* -antecedente de lo que más tarde fue la *Dirección General de Correos y Telégrafos*-, que se encargaba de regular los aspectos técnicos y administrativos de la prestación de los servicios de telecomunicaciones, especialmente lo relativo a las tarifas que se debían cobrar. En 1964,[21] con el objeto de reglamentar concretamente lo relativo a la prestación del servicio de telefonía por el Estado, las atribuciones que tenía este órgano relativas a esta materia fueron absorbidas por la *Dirección General de Teléfonos.* Este órgano administrativo fue el antecedente administrativo inmediato de lo que más tarde sería GUATEL, y tenía por función principal la de otorgar líneas telefónicas a quienes lo solicitaran, instalarlas, y, en general, inspeccionar la red de telefonía para verificar su estado y velar por el estricto cumplimiento de las normas que regulaban este servicio.

5- Desarrollo del tráfico internacional

En lo que al servicio internacional de radiotelefonía se refiere, cabe mencionar que en 1926 entró al mercado la *Tropical RadioTelephone Co.*, que a raíz de un contrato celebrado con el Gobierno de la República, se encargó de facilitar el tráfico internacional, especialmente con Estados Unidos y Europa. Dicho contrato[22] fue celebrado entre el Secretario de Estado en el Despacho de Fomento y el Señor George Bennet, representante de la *Tropical Radio Telegraph Co.* y establecía, entre otras cosas, que el Estado de Guatemala permitiría a la compañía emplear la estación de telecomunicaciones que el gobierno poseía y operaba en Guatemala. Por su parte, la compañía se obligaba a observar estrictamente el plan tarifario que el Despacho de Fomento fijaba y ajustaba de tiempo en tiempo.

En 1941 la *Tropical Radio Telegraph Co.* suscribió otro contrato[23] con el Estado de Guatemala mediante el cual éste permitía a aquélla operar otra estación para prestar el servicio internacional de telefonía. En dicho contrato se establecía que, a su vencimiento, el Estado podría adquirir las instalaciones aportadas por la Compañía mediante el pago del 50 por ciento de la cantidad en que fueran valuadas por expertos. Como resultado de varios estudios y evaluaciones -de tipo político más que económico- se concluyó que lo más conveniente a los intereses nacionales era no prorrogar más el referido contrato, sino ejercer la opción de compra de las instalaciones de la compañía.

Así las cosas, mediante acuerdo de fecha 21 de enero de 1966,[24] emitido por el Jefe de Gobierno Enrique Peralta Azurdia, se dispuso que el Estado asumiría la posesión y administración de la empresa de servicios internacionales de telecomunicaciones que había estado operando la *Tropical Radio Telegraph Company.*

De esta forma el Estado terminó por atribuirse también la función de prestar los servicios de telecomunicaciones internacionales en todas sus variantes, desapareciendo así el último vestigio de participación de particulares en este mercado.

6- Aparece GUATEL

Siguiendo la tendencia estatizadora que se ha descrito y en vista de que los órganos administrativos existentes ya no eran suficientes para atender las crecientes necesidades en materia de telecomunicaciones, en 1966, también bajo el régimen de Peralta Azurdia, se creó la *Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones Internacionales,*[25] cuyo nombre abreviado fue GUA-

19 Rafael Pérez Riera, 1996:427.

20 Dicho órgano administrativo se creó mediante Decreto presidencial número 2151 (Recopilación, 1940-LVII:213-214).

21 Recopilación, 1938-LIV:156-248.

22 Sobre los extremos de este contrato ver: Recopilación, 1931-XVL:524-528.

23 Este contrato fue aprobado mediante Acuerdo Gubernativo de 6 de septiembre de 1941 (Recopilación, 1943-LX:553-556).

24 Recopilación, 1968-LXXXIV:1191-1192.

25 Dicha entidad de creó mediante Decreto-ley número 465 dado por el Jefe del Gobierno de la República el 3 de mayo de 1966 (Recopilación, 1966-LXXXV:76-81).

TEL. Los considerandos de esta ley establecían que su creación obedecía a que era necesaria la existencia de una empresa que como *entidad descentralizada* del Estado y con autonomía funcional, se encargara *con exclusividad* de prestar el servicio público de telecomunicaciones internacionales y el nacional que se le incorporare, teniendo en cuenta que para la realización de los fines que se perseguían, se requería de autoridad determinativa en la administración y flexibilidad en sus operaciones para actuar en forma inmediata de acuerdo con sus necesidades. Esta disposición legal dotó a GUATEL de personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía funcional y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones además de otorgarle la facultad y obligación de prestar *con exclusividad* el referido servicio, de conformidad con las tarifas aprobadas para el efecto. Además este decreto-ley incluía una disposición según la cual todas las obligaciones legalmente contraídas por la empresa gozarían de la *incondicional e ilimitada garantía del Estado*, prerrogativa que dio lugar a desmedidos endeudamientos, que frecuentemente superaron la capacidad de pago de la referida entidad.

Fue así como apareció por primera vez en Guatemala una entidad descentralizada y autónoma dedicada exclusivamente a la prestación del servicio público de telecomunicaciones, con énfasis en lo que a telecomunicaciones internacionales se refería.

Finalmente, con el propósito de reestructurar lo que fuera la *Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones Internacionales*, en 1971 se emitió el Decreto número 14-71,[26] por el que ésta pasó a ser la *Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones*, cuyo nombre abreviado también fue GUATEL. Este decreto derogó el decreto-ley número 465 y dispuso que los bienes de la antigua GUATEL y los de la *Dirección General de Teléfonos* pasaran a formar parte del patrimonio de la nueva entidad descentralizada.

A la nueva GUATEL también se le dio carácter de entidad estatal descentralizada y autónoma, con capacidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Esta ley agregaba categóricamente que GUATEL sería la institución responsable de prestar *todos* los servicios de telecomunicaciones, tanto nacionales como internacionales, existentes y que en el futuro existieran.

A partir de este momento, se terminó de consagrar el monopolio legal que el Estado se había atribuido con relación a las telecomunicaciones. Este monopolio se trató de justificar de alguna manera -justificación *a priori*, por cierto- aduciendo que los costos de las inversiones fijas en una red de telecomunicaciones eran tan altos que, según criterios de orden económico, solamente una empresa tendría la suficiente capacidad económica para soportarlos y prestar el servicio eficientemente, y, en vista de que un monopolio privado era indeseable, se prefería crear un monopolio estatal.[27]

Independientemente de esta y otras razones que se pudieron haber esgrimido para justificar esta circunstancia, el hecho es que las deficiencias técnicas y administrativas que presentó GUATEL durante sus más de 25 años de existencia, llevaron al país a un nivel inconcebible de atraso en materia de telecomunicaciones.[28] Así, hasta 1996 existían poco más de 340,000 líneas telefónicas para una población de 10 millones de habitantes, lo que significa que por cada 100 hogares había solamente 3.4 líneas telefónicas. Esto colocaba a Guatemala como uno de los países con los índices de cobertura telefónica más bajos en Latinoamérica. Todo ello sin perjuicio de que los servicios telefónicos nunca llegaron a las áreas más pobres del país, si tenemos en cuenta que de las líneas instaladas, solamente el 1 por ciento se encontraba en las áreas rurales, donde vive el 65% de la población guatemalteca.[29]

Ante esta realidad, desde hacía algunos años se había estado discutiendo en círculos académicos, primero, y estatales, después, la necesidad y conveniencia de reestructurar el sector de las telecomunicaciones en el país, mediante una redefinición legal y administrativa del mismo. Ello se llevó a efecto mediante la emisión de la *Ley General de Telecomunicaciones*[30] y la

26 *Ley Orgánica*, 1975.
27 Infraestructura, 1999:4.
28 Rafael Pérez Riera, 1997:431-450.
29 Infraestructura, 1999:2-3.
30 Decreto número 94-96, emitido por el Congreso de la República el 17 de octubre de 1996 y publicado en el *Diario de Centro América* el 18 de noviembre de 1996.

reforma de otros cuerpos legales directa e indirectamente relacionados con el sector en mención.[31]

7- Desmonopolización de GUATEL

A diferencia de lo que sucedió en otros países, en Guatemala la desmonopolización de la empresa telefónica estatal vino después de las reformas legales. Esta desmonopolización se dio a finales de 1998 mediante la venta del 95% de dicha empresa a una sociedad anónima.[32] De esta forma, GUATEL dejó de prestar el servicio de telefonía como lo había hecho desde su creación, quedándose solamente con la inversión en aquellos rubros donde no resulta rentable para el sector privado: telefonía rural y administración de teléfonos comunitarios. TELGUA, como se llamó la sociedad anónima en la que finalmente quedaron los activos de GUATEL, pasó a ser la prestadora del servicio de telefonía local y de larga distancia internacional.

Estos cambios han permitido que durante el último año haya aumentado el número de proveedores de servicios de telecomunicaciones, con la consiguiente mejoría en la calidad de éstos y la disminución de las tarifas, por lo menos en lo que a llamadas de larga distancia internacional y a telefonía móvil celular se refiere.[33]

8- Consideraciones finales

Como se puede apreciar de los datos históricos relacionados, los servicios de telecomunicaciones empezaron siendo prestados por particulares mediante empresas privadas. Al poco tiempo de haberse iniciado en este mercado, quienes con su ingenio y recursos se dieron a la tarea de romper las barreras de la distancia, fueron forzados a gestionar autorizaciones para poder seguir haciéndolo. De una autorización estatal -concesión gubernativa- para prestar estos servicios, se llegó a una intervención y posterior estatización de las compañías que los prestaban. El paso entre ambos extremos no fue de un día para otro. Como en otras tantas materias, el Estado fue ganando terreno poco a poco. Para llegar al punto en que estas compañías fueran estatizadas, los gobernantes de turno primero sopesaron los costos y beneficios de asumir funciones de tal naturaleza: los beneficios superaron a los costos, no sólo por los ingresos económicos que un negocio de este tipo les reportaría -en términos de utilidades-[34] sino principalmente por el poder que les representaba el tener en sus manos, en calidad de monopolio, tan importante instrumento de comunicación que, a la larga, constituye fuente de información y persuasión de la ciudadanía.

Las autorizaciones, reglamentos, planes tarifarios y, en fin, la política de estricta vigilancia e interven-

31 Como un reconocimiento de la incapacidad del Estado para satisfacer las necesidades de la población, previamente a la emisión de la *Ley General de Telecomunicaciones*, durante el Gobierno del Presidente Vinicio Cerezo Arévalo, GUATEL, en virtud de las facultades que le otorgó el Acuerdo Gubernativo 475-89, de fecha 29 de junio de 1989, previo concurso público, contrató a un operador privado de telecomunicaciones para la prestación de los servicios de telefonía móvil celular. Este servicio vino a ampliar la cobertura de telefonía en el país y a introducir la tecnología -ahora tan generalizada- de la telefonía móvil celular. A cambio de la referida autorización, el operador de telecomunicaciones en cuestión se obligó a entregar mensualmente a GUATEL un porcentaje de sus ingresos provenientes de la prestación de dichos servicios, como lo establece el Contrato Administrativo número 1, formalizado por el Escribano de Cámara y de Gobierno, con fecha 3 de enero de 1990.

32 Solamente el 95% de las acciones de la empresa telefónica estatal fueron vendidas; el restante 5% quedó en manos de los trabajadores de uno de sus sindicatos.

33 Ha sido una constante en todos los países en los que se ha liberalizado el mercado de telecomunicaciones, el hecho que la disminución de los precios se produce primero en los servicios de telefonía de larga distancia internacional y en los servicios de telefonía móvil celular. Los precios de los servicios de telefonía fija tienden a ser los últimos en bajar debido, entre otros factores, a que el costo de su infraestructura es tan alto que solamente se puede cubrir una vez se ha empezado a reinvertir las utilidades provenientes de la prestación de los otros dos servicios.

34 Es importante señalar que cuando hablamos de las utilidades de una empresa pública nos estamos refiriendo más bien al rubro que bajo esa denominación se registra en los estados financieros de la misma. En sentido estricto, una empresa estatal no puede generar utilidades como se les estudia desde la perspectiva del libre mercado, puesto que solamente quien aporta bienes o servicios propios a un negocio y asume el riesgo de pérdida o ganancia, en un ambiente de libre competencia, puede tener utilidades, circunstancias que no se presentan de ninguna manera en el caso de las empresas públicas. Sobre este particular, Fernando Monterroso agrega que "se dice, muchas veces, que hay empresas estatales que sí tienen utilidades, que sí son rentables. Cuando se habla de utilidades, debe de [*sic*] analizarse si fueron producto de una competencia en el mercado o si bien fueron producto de un monopolio estatal en el cual el consumidor no tenía alternativa de agenciarse ese bien o servicio más que de la empresa estatal.

cionismo a ultranza que ilustra la reseña histórica presentada, son muestra de la forma -muy astuta, por cierto- como el intervencionismo estatal que hemos tenido en Guatemala ha manipulado y, en ciertos casos, impedido, una de las más importantes manifestaciones de la libertad: la libertad de expresión, que no se logra sino mediante la posibilidad de acceder a las fuentes de información y a los medios de comunicación.

Afortunadamente, los años de intervencionismo estatal -al menos en materia de telecomunicaciones- parecen haber quedado atrás, gracias al proceso de desmonopolización y desregulación del sector. De nuevo nos encontramos en un momento como aquél histórico 1881, cuando Don Roderico Toledo inició el servicio de telecomunicaciones en Guatemala. A las autoridades estatales y a los guatemaltecos nos queda la obligación de velar porque no se vuelva ni un paso atrás, ni siquiera para subsanar supuestas imperfecciones en el referido proceso, no sea que el círculo se inicie de nuevo.

Bibliografía

Barrera, Pedro

1960 *Geografía e historia de correos y telecomunicaciones en Guatemala*. Guatemala: Tipografía Nacional.

Chang Kwan, Connie [López Fernández, Adriana]

1995 *Una estrategia para el proceso de privatización de GUATEL*. Tesis sometida para obtener el grado de Licenciadas en Administración de Empresas. Guatemala: Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Francisco Marroquín.

Greennspan, Alan

2000 'Comercio y Tecnología'. *Tópicos de Actualidad*. 864-XL (Marzo de 2000). Guatemala: Centro de Estudios Económico-sociales (CEES).

Historia

1996 *Historia General de Guatemala. Tomo V: Epoca contemporánea: 1898-1944*. Guatemala: Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo de Guatemala.

1997 *Historia General de Guatemala. Tomo VI: Epoca contemporánea: De 1945 a la actualidad*. Guatemala: Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo de Guatemala.

Ibargüen S., Giancarlo

1998 'TELGUA en la era digital: ¿Una privatización irrelevante?' *Tópicos de Actualidad*. 839-XXXIX (Marzo de 1998). Guatemala: Centro de Estudios Económico-sociales (CEES).

Infraestructura

1999 *Infraestructura para el tercer milenio. Comunicaciones*. Guatemala: Centro de Investigaciones Económicas Nacionales.

Ley Orgánica

1975 'Ley Orgánica de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones'. *Recopilación de Leyes de la República de Guatemala, 1970-1971*. (XC:293-298). Guatemala: Tipografía Nacional.

Leyes

1886 *Leyes emitidas por el gobierno democrático de la República de Guatemala y por la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa* (1º de julio de 1883 - 31 de diciembre de 1885). Recopiladas por Viviano Guerra. Guatemala: Tipografía de Pedro Arenas.

López Fernández, Adriana

1995 [Chang Kwan, Connie; -]

Monterroso V., Fernando

1990 *Lógica de la Cooperación Social 1*. Guatemala: se.

Pereira Beckman, José Luis

1971 'Las telecomunicaciones de Guatemala y Centroamérica', *Seminario de problemas eco-*

Resulta inadecuado hablar de utilidades de alguna empresa estatal cuando lo único que tiene que hacer cuando necesita fondos es subir la cuota por su servicio, ya que goza de una condición monopolística (es decir, es la única que ofrece ese bien o servicio). Si el consumidor no tiene alternativa para el servicio y tiene que aceptar la cuota como buena, no puede entonces hablarse que tuvieron [*sic*] *utilidades*. Además, convendría analizar cuál fue el costo social de esos ingresos (es decir, qué fue lo que le costó a la comunidad esos ingresos, en términos de lo que se pudo haber hecho y no se hizo)'. (Fernando Monterroso, 1990:51).

nómicos de Guatemala y Centroamérica del año 1971. Guatemala: Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de San Carlos de Guatemala.

Pérez Riera, Rafael

1996 'Transportes, comercio y servicios públicos'. *Historia General de Guatemala.* V:417-428. Guatemala: Asociación de Amigos del País y Fundación para la Cultura y el Desarrollo de Guatemala.

1997 'Infraestructura, comercio y servicios'. *Historia General de Guatemala.* VI:431-450. Guatemala: Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo de Guatemala.

Recopilación

1909-1923 *Recopilación de Leyes de la República de Guatemala, 1904-1905.* Guatemala: Tipografía y encuadernación de Arturo Síguere & Co.

Entrevistas

28/06/00 Ingeniero Luis René Pellecer Solís: Gerente de GUATEL (1971-1975) y catedrático de la Universidad Francisco Marroquín.

18/07/00 Licenciado Eduardo Palomo Escobar: asesor jurídico de *Comunicaciones Celulares, Sociedad Anónima.*

La existencia de la Personalidad, la Libertad y la Propiedad, no se debe a que los hombres hayan dictado Leyes. Por el contrario, la pre-existencia de su personalidad, libertad y propiedad es la que determina que puedan hacer leyes los hombres.

Frédéric Bastiat

GLORIA RODRIGUEZ NATARENO[1]

Nueva regulación del mercado de telecomunicaciones en Guatemala[2]

Sumario

Introducción
1- Situación anterior a la reforma y reformas complementarias
2- Ley General de Telecomunicaciones
  2.1 Antecedentes
  2.2 Fundamentos: un mínimo de reglas
  2.3 Innovaciones administrativas
3- Consideraciones finales
Bibliografía

> '[...] The direction of these changes is fairly clear, but their speed is uncertain. This survey will argue that the pace will be set not just by technology but by the interplay of regulation and competition. Governments can delay the revolution; they cannot prevent it. If they try, they will merely fail more spectacularly later'.
>
> Frances Cairncross, *The death of distance*

Introducción

La liberalización del mercado de telecomunicaciones en Guatemala es de reciente aparición, ya que no fue sino hasta la entrada en vigor de la *Ley General de Telecomunicaciones*[3] que dicho servicio pudo prestarse en un ambiente de competitividad. Para que la reforma al sector de telecomunicaciones pudiera llevarse a efecto, fue necesario derogar, modificar y emitir, según el caso, varias disposiciones legales que, en su conjunto, terminaron de abrir el camino para que nuevos competidores y servicios pudieran entrar y permanecer en el mercado guatemalteco. A continuación se hará una descripción y análisis sobre las principales reformas legislativas implementadas.

1- Situación anterior a la reforma y reformas complementarias

La *Ley General de Telecomunicaciones*, que entró en vigor en 1996, fue precedida por una serie de disposiciones legales y reglamentarias que no necesariamente daban certeza ni incentivaban a los inversionistas. Así, por ejemplo, la *Ley de Radiocomunicaciones*[4] -cuyo texto aún se encuentra parcialmente vigente- establecía que las frecuencias y canales utilizables en las radiocomunicaciones del país eran del dominio del Estado, inalienables e imprescriptibles y, por esas razones, su explotación privada era permitida únicamente bajo concesión. Este sistema daba lugar a una fuerte intervención del Estado tanto en los aspectos

1 Abogada y Notaria.

2 Capítulo segundo del trabajo equiparado a tesis de graduación, intitulado *Estudio sobre la legislacion aplicable al mercado de telecomunicaciones en Guatemala*, conformado por cuatro ensayos.

3 Decreto legislativo número 94-96, emitido por el Congreso de la República de Guatemala el 17 de octubre de 1996 y publicado en el Diario de Centro América el 18 de noviembre del mismo año. Este decreto fue reformado y parcialmente derogado por el Decreto legislativo número 115-97, emitido por el Congreso de la República de Guatemala el 19 de noviembre de 1997 y publicado en el Diario de Centro América el 21 de noviembre del mismo año.

4 Decreto-ley número 433 del Jefe de Gobierno, emitido el 10 de marzo de 1966 y publicado en el Diario de Centro America el 16 de marzo del mismo año.

técnicos como administrativos de la prestación de todos los servicios de radiocomunicaciones.

La *Ley de Radiocomunicaciones* y otras leyes restringían tanto la participación en el mercado en cuestión, que las concesiones solamente podían ser otorgadas a personas individuales guatemaltecas y a sociedades constituidas en Guatemala, cuyo capital estuviera aportado por socios guatemaltecos en por lo menos un 70% y cuyas acciones tuvieran carácter nominativo. Adicionalmente, las sociedades concesionarias eran obligadas a revelar el nombre de sus accionistas.[5]

Similares disposiciones contenía la *Ley reguladora del uso y captación de señales vía satélite y su distribución por cable*,[6] cuyo texto se inspira y complementa con la *Ley de Radiocomunicaciones*.[7]

Las restricciones a la participación extranjera en el mercado de telecomunicaciones se entendieron eliminadas mediante las disposiciones de la *Ley General de Telecomunicaciones* que establece que la misma -y su espíritu de apertura a la competencia, especialmente- es aplicable a todos los usuarios y usufructuarios del espectro radioeléctrico, así como a todas las personas que operan y comercializan servicios de telecomunicaciones en el territorio nacional, sean éstas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, con participación privada, mixta o estatal, independientemente de su grado de autonomía y de su régimen de constitución.[8] Adicionalmente, como parte de una reforma integral a la legislación relativa a las inversiones extranjeras y con el objeto específico de evitar que en el futuro se pudiera argumentar cualquier criterio limitativo de la participación de capital extranjero en las sociedades prestadoras de servicios de telecomunicaciones, las disposiciones de la *Ley de Radiodifusión* que imponían las referidas restricciones a los capitales extranjeros, fueron expresamente derogadas por la *Ley de Inversión Extranjera*.[9]

De esta forma, la *Ley de Inversión Extranjera* terminó de eliminar las barreras legales que frenaban el ingreso de competidores extranjeros al mercado de telecomunicaciones[10] del país, obstaculizando así los potenciales beneficios en transferencia de tecnología, generación de empleo y desarrollo del sector privado.

Otra importante limitante a las relaciones comerciales que fue eliminada de la legislación guatemalteca es la norma del Código Civil,[11] según la cual las estipulaciones y tarifas de los contratos cuyas condiciones fueran establecidas unilateralmente por el oferente[12] -y ante las cuales el consumidor solamente puede optar por adherirse o no participar en el contrato-debían ser previamente aprobadas por el Organismo Ejecutivo, como condición para que aquél pudiera participar en el mercado. Esta norma daba lugar a que el Estado interviniera en la fijación del precio a pagar por los servicios de telecomunicaciones y a que, eventualmente, pudiera revisar e incluso modificar los términos de los contratos. En lo atinente al mercado de telecomunicacio-

5 Estas restricciones estaban contenidas en el artículo 9 de la Ley de Radiocomunicaciones.

6 Decreto legislativo número 41-92, emitido por el Congreso de la República de Guatemala el 26 de mayo de 1992 y publicado en el Diario de Centro América el 16 de junio del mismo año.

7 Si bien este trabajo trata específicamente sobre telecomunicaciones, es necesario hacer referencia a algunos aspectos relacionados con la radiodifusión (radio, televisión tradicional y televisión por cable) por cuanto la infraestructura que sirve de base para transmitir la televisión por cable -satélites y cableado, entre otros- es una de las alternativas que existe para correr los servicios de telefonía, y que de hecho ya se ha utilizado en nuestro país para ese fin. El sistema de televisión por cable y las redes de fibra óptica se presentan como una alternativa a las tradicionales redes de cobre, tanto por ser menos costosas a largo plazo como por ser técnicamente más eficientes. Sin embargo, no cabe duda que la tecnología de fibra óptica supera en mucho a las otras dos y, de hecho, ya las ha desplazado. Otros datos sobre las connotaciones técnicas y económicas del mercado de telecomunicaciones pueden ser encontrados en: Frances Cairncross, *The death of distance: how the communications revolution will change our lives*, Harvard Business School Press, Cambridge, Mass.

8 Artículo 2 de la Ley General de Telecomunicaciones.

9 Decreto legislativo número 9-98, emitido por el Congreso de la República de Guatemala el 4 de febrero de 1998 y publicado en el Diario de Centro América el 3 de marzo del mismo año.

10 Entre otras cosas, la Ley de Inversión Extranjera eliminó la discriminación de que eran objeto los inversionistas extranjeros en contraposición con el trato preferencial que recibían los nacionales. Así, el artículo 2 de esta ley establece que los inversionistas extranjeros gozan de los mismos derechos y de los mismos medios para ejercerlos que los inversionistas nacionales. Por su parte, el artículo 4 dispone que el inversionista extranjero puede participar en el desarrollo de cualquier actividad económica lícita en el país, así como en cualquier proporción en el capital de sociedades mercantiles.

11 Artículo 1520 del Código Civil de la República de Guatemala, Decreto-ley número 106 del Jefe de Gobierno, emitido el 14 de noviembre de 1963.

12 Estos contratos se conocen como *contratos de adhesión* o *contratos mediante formularios* y constituyen la categoría dentro de la cual, en términos generales, se pueden situar los contratos de prestación de servicios de telecomunicaciones.

nes, esta disposición devino inaplicable por la *Ley General de Telecomunicaciones*, mediante la norma[13] que estableció que *en ningún caso sería aplicable el artículo 1520 del Código Civil a las relaciones jurídicas contempladas en esa ley.*[14] Adicionalmente y en coherencia con lo dispuesto por la norma en mención, la *Ley General de Telecomunicaciones* fue más lejos, al establecer expresamente que *las condiciones contractuales así como los precios para la prestación de toda clase de servicios comerciales de telecomunicaciones, serán libremente estipulados por las partes y no estarán sujetos a regulación ni aprobación por autoridad estatal alguna.*[15]

La anterior descripción ilustra la forma cómo la legislación guatemalteca ha ido dando paso a la reforma del sector de telecomunicaciones en el país, la que encontró su más importante manifestación en la *Ley General de Telecomunicaciones,* cuyos aspectos más relevantes detallaremos a continuación.

2- Ley General de Telecomunicaciones

2.1 Antecedentes

La necesidad de una ley que regulara los servicios de telecomunicaciones fue contemplada como parte de la reforma al sector de infraestructura del país que el gobierno del Presidente Alvaro Arzú presentó en el *Programa de Gobierno 1996-2000.* El ofrecimiento de un marco legal claro y transparente que fomentara la competencia e impidiera los privilegios, se concretizó en la emisión de la *Ley General de Telecomunicaciones* en 1996, cuyas disposiciones fueron formuladas con base en la legislación vigente y experiencia acumulada de países como Chile -cuyo mercado de telecomunicaciones, tanto local como internacional, es el más exitoso en el ámbito mundial-, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos de América, Inglaterra y México.

2.2 Fundamentos: un mínimo de reglas

Como su propio texto lo indica,[16] este cuerpo normativo tiene por objeto establecer un marco legal para desarrollar actividades de telecomunicaciones[17] y normar el aprovechamiento y la explotación del espectro radioeléctrico,[18] a fin de promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, estimular las inversiones y la competencia en el sector, así como proteger los derechos de los usuarios[19] y de las empresas proveedoras de estos servicios. Es aplicable tanto a los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones

13 Artículo 100 de la Ley General de Telecomunicaciones.

14 Finalmente, la parte del artículo 1520 del Código Civil que imponía las referidas limitaciones a las contrataciones mediante Contratos de Adhesión, fue derogada -con lo que ya no fue simplemente inaplicable a las relaciones jurídicas de telecomunicaciones- por el artículo 2 de las Disposiciones Derogatorias del Decreto 20-97, que contiene reformas a la Ley de Contrataciones del Estado. Este decreto fue emitido el 5 de marzo de 1997 y publicado en el Diario de Centro América el 7 de abril de 1997.

15 Artículo 22 de la Ley General de Telecomunicaciones.

16 Artículo 1 de la Ley General de Telecomunicaciones.

17 Según las *Recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones* (UIT), por *actividades de telecomunicaciones* debera entenderse toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos e informaciones de cualquier naturaleza, por línea física, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos; pero no significa distribucion de televisión por cable, radiodifusión u otro tipo de distribución electromagnética de programación de radio, televisión tradicional o televisión por cable. Las actividades de telecomunicaciones son las actividades que, cuando son libremente demandadas y ofertadas, dan lugar al *mercado de telecomunicaciones.* http://www.itu.int/search/wais/Termite/index.html
La diferenciación entre *telecomunicaciones y radiodifusión* se conoce con claridad desde hace poco tiempo, gracias a la definición de términos que se ha logrado luego de recientes estudios e investigaciones sobre el tema. Anteriormente, no estaba exactamente definido lo que comprendía cada una de estas materias; ejemplo de ello es que en Guatemala los servicios de telecomunicaciones eran normados por la *Ley de Radiodifusión.*

18 La Ley General de Telecomunicaciones, en su artículo 50, establece que el *espectro radioeléctrico* es el conjunto de ondas electromagnéticas, ondas de radio o hertzianas y frecuencias radioeléctricas.

19 *Lato sensu*, son *usuarios* de los servicios de telecomunicaciones todas las personas naturales o jurídicas que, dentro de la cadena de consumo de los servicios de telecomunicaciones, perciben beneficios patrimoniales de éstos. En ese sentido, es usuario del servicio de telecomunicaciones tanto la persona individual o jurídica que tiene acceso a una línea telefónica en condición de usarse, como el operador de servicios de telecomunicaciones, que en uso de su calidad de tal, percibe beneficios patrimoniales de la venta de sus servicios a quien puede usar la línea telefónica por él habilitada. *Strictu sensu*, son *usuarios* de servicios de telecomunicaciones los consumidores finales de éstos, es decir, aquéllos que en el curso de sus actividades comerciales o personales hacen uso de los servicios de telefonia que los operadores de telecomunicaciones ponen a su disposicion a cambio de una remuneración

como a los usufructuarios[20] del espectro radioeléctrico.[21]

Esta ley se creó partiendo del principio que los resultados de los mecanismos de mercado son siempre mejores que los que se obtienen mediante las leyes creadas para lograr resultados predeterminados, pero que, en todo caso, para que estos mecanismos de mercado pudieran hacer lo más eficiente posible las relaciones entre los operadores de redes comerciales de telecomunicaciones y entre éstos y los usuarios finales de los servicios, era necesario un mínimo de reglas claras, de aplicación general y cuya ejecutabilidad fuera pronta y certera. Además de los estudios que en el ámbito académico se hicieron sobre las diversas formas de liberalizar los mercados de telecomunicaciones, la experiencia internacional aconsejó que era necesario establecer un mínimo de reglas -por lo menos en la primera etapa del proceso de liberalización- por cuanto el operador dominante inicial -que es el operador en cuyas manos quedaría la infraestructura del órgano estatal que otrora tuviera el monopolio del servicio- tendería a prolongar su poder de mercado aún después de la desmonopolización, mediante la explotación de los beneficios inherentes a la red de telecomunicaciones que recibiría ya montada, en funcionamiento y con un buen segmento de mercado captado. Este mínimo de reglas es el que en la *Ley General de Telecomunicaciones* se refiere a los derechos de interconexión, acceso a recursos esenciales, selección de operador de red y el mecanismo de solución de disputas derivadas de la negociación de éstos.

Derecho de interconexión

En términos generales, es el derecho que un operador de red[22] tiene de lograr y asegurarse que sus usuarios (clientes) puedan hacer y recibir llamadas hacia o desde la red de telecomunicaciones de otro operador de telefonía; y se concreta en la facultad que tienen todos los operadores que vayan entrando al mercado de conectarse físicamente a la red del operador dominante[23] y de los otros operadores que ya estén en funcionamiento. En otras palabras, constituye el derecho que el operador A (nuevo operador) tiene de que el operador B (operador dominante o cualquier otro operador ya en funcionamiento) permita que todas las llamadas que se generen en la red de aquél con destino a usuarios de la red de éste puedan cursarse con fluidez y sin interferencias, tal como si se hubiesen generado y terminado dentro de la misma red.[24]

Desde un punto de vista técnico, nuestra ley define la interconexión como la función mediante la cual se asegura la operabilidad entre redes, de tal modo que se pueda cursar tráfico de telecomunicaciones entre ellas.[25]

La importancia del derecho de interconexión radica en que siendo el principio rector de la *Ley General de Telecomunicaciones* el de la libre competencia entre los actores del sector, ésta no sería posible si no existiera un mecanismo por el cual los operadores entrantes pudieran realmente entrar a competir. Este mecanismo es el que impide que el operador dominante haga uso de los beneficios inherentes a la red

20 *Usufructuarios del espectro* radioeléctrico son las personas individuales o jurídicas a las que el Estado les ha otorgado, previo concurso público, el derecho de usar, gozar y disponer de una porción del espectro radioeléctrico por un período de 15 años. Estos derechos son representados mediante *títulos de usufructo*. Bajo esta modalidad de aprovechamiento del espectro radioeléctrico por particulares, el Estado de Guatemala conserva la nuda propiedad de la porción dada en usufructo, de modo que cuando el título vence, la plena propiedad sobre dicha porción se revierte al Estado de Guatemala.

21 Artículo 1 de la Ley General de Telecomunicaciones.

22 La Ley General de Telecomunicaciones establece en su artículo 2 que es *operador* toda persona, individual o jurídica, que posee y administra una red de telecomunicaciones; y en su artículo 23, que es *red comercial de telecomunicaciones* toda red de telecomunicaciones que permite el libre acceso a sus servicios a cualquier persona individual o jurídica, a cambio del pago de una contraprestación.

23 En Guatemala, el operador dominante es *Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima*. Esta compañía es ahora la propietaria del 95% de los activos de la compañía estatal que tuvo el monopolio legal del servicio de telefonía, por lo que resulta claro que su posición dominante se debe a que recibió una red de telecomunicaciones -infraestructura- muy grande y ya en funcionamiento. Su posición de operador dominante irá desapareciendo en la medida que nuevos operadores de red entren al mercado y logren montar redes tan completas que la necesidad de la interconexión desaparezca en proporción al crecimiento de éstas.

24 Para efectos prácticos, valga decir que la interconexión es lo que permite que nos podamos comunicar telefónicamente con usuarios -clientes- de redes distintas de la nuestra.

25 Artículo 26 de la Ley General de Telecomunicaciones

que recibió para impedir la entrada de nuevos operadores o dificultando su permanencia en el mercado.

Es un hecho que en todos los países en los que se ha liberalizado el mercado de telecomunicaciones, el operador dominante -aún existiendo el derecho de interconexión claramente determinado en la ley- ha tratado de mantener su posición monopólica negando, retrasando o dificultando la interconexión en un intento por mantener su posición dominante.[26]

Sobre este particular, Pablo Spiller señala que mientras el derecho de interconexión ahora es visto como un elemento obvio para que se desarrollen los mercados de telecomunicaciones, hasta hace algunos años ello no era así. Por ejemplo, este importante elemento fue omitido en las legislaciones de Chile y Nueva Zelanda, lo que trajo serios problemas en el proceso de desmonopolización del mercado.

En Chile, la Ley General de Telecomunicaciones de 1982 pretendió el libre y no discriminatorio acceso de todos los competidores a este mercado, pero no especificó los procedimientos, métodos de compensación de costos ni otros detalles importantes sobre el derecho de interconexión. El resultado fue casi una década de litigios que impidieron la desmonopolización del sector, la pérdida de credibilidad en el proceso de apertura a la competencia y altísimos costos para los nuevos operadores. Finalmente, estas imperfecciones de la ley fueron eliminadas mediante un grupo de reformas cuyas características son muy parecidas a las de la ley guatemalteca.

Similares problemas surgieron en Nueva Zelanda, donde en un intento por evitar la sobre regulación, los problemas que pudieran surgir por la negativa del operador dominante a otorgar la interconexión se dejaron al amparo de las leyes antimonopólicas generales. De nuevo, esto trajo como resultado cientos de litigios que las cortes nunca pudieron resolver y que el mercado de telecomunicaciones no se lograra liberalizar.[27]

26 En Guatemala ya se han presentado algunas disputas en torno al otorgamiento de este derecho, tanto previas a la celebración de los contratos de interconexión como posteriores a su otorgamiento. Una investigación realizada por la autora de este trabajo en la Superintendencia de Telecomunicaciones dio como resultado que desde mediados de 1997 hasta mayo de 1998 este organismo tuvo conocimiento de varios conflictos entre el operador dominante y otras entidades interesadas en ser operadores, debido a que aquél se negaba, mediante el uso de técnicas dilatorias, a proporcionar la interconexión. En algunos casos el operador dominante ni siquiera quería negociar las condiciones contractuales dentro de las cuales permitiría la interconexión, menos aún se llegaba a la firma de los contratos. Su política fue ignorar a los nuevos operadores. Pese a que fueron varios los casos así, ninguno de los afectados solicitó a la Superintendencia la iniciación del procedimiento para la solución de este tipo de discordias, contemplado en los artículos 33 al 40 de la Ley General de Telecomunicaciones. Ello se debió principalmente al temor que tenían los operadores de las consecuencias que podrían sufrir por entrar en conflictos con el operador dominante. Prueba de estos conflictos que no llegaron formalmente al conocimiento de la Superintendencia, es que aunque desde mediados de 1997 se pudo celebrar contratos de interconexión, no fue sino hasta marzo de 1998 que se logró firmar el primero. El único caso en que la Superintendencia conoció de un reclamo sobre esta materia se dio cuando el señor Luis Alfonso Aguilar Castro -un comerciante individual interesado en prestar servicios de telecomunicaciones- solicitó la intervención de aquélla debido a que, luego de muchos intentos, no se había celebrado el contrato de interconexión por causa imputable al operador dominante. En esa oportunidad el reclamante cumplió con presentar a la Superintendecia -en la forma establecida por la ley- un informe sobre los puntos en discordia y las propuestas de solución a éstos. Por su parte, el operador dominante al presentar su informe no compareció por medio de su representante legal, por lo que se tomó como si no hubiera comparecido y, en consecuencia, se resolvió en favor del reclamante. En la resolución en la que se puso fin a esta discordia, la Superintendencia aprobó la gestión del reclamante; ordenó al operador dominante que otorgara el contrato de interconexión en un plazo de 10 días hábiles; y lo apercibió con que en caso de incumplimiento incurriría en una multa de US $60,000.00. Finalmente, se otorgó el contrato dentro del plazo fijado y no hubo necesidad de hacer efectiva la multa. Información proporcionada por los Ingenieros Raúl Solares -Gerente de Operaciones de la Superintendencia- y Claudia Contreras -Subgerente de Operaciones-. Resolución SIT 653-99, emitida por la Superintendencia de Telecomunicaciones el 4 de agosto de 1999.

Además de los conflictos que se han dado previos a la celebración de los contratos de interconexión, también se han suscitado disputas cuando, ya habiéndose firmado los contratos, el operador dominante no ha cumplido con permitir la interconexión física (material). Estos problemas se han dado varias veces pero, de nuevo, los afectados han preferido no formalizar sus reclamos ante la Superintendencia por temor a represalias. Así por ejemplo, tenemos el caso en el que el señor Aguilar Castro, luego de lograr la celebración del contrato de interconexión, se vio en la necesidad de presentar una queja informal a la Superintendencia, haciendo ver que el operador dominante se negaba a permitirle la interconexión física. En este caso el Superintendente pidió a las partes una queja formal pero no la hubo. Finalmente, el operador dominante otorgó la interconexión al reclamante y no hubo necesidad de iniciar el procedimiento administrativo contemplado en los artículos 79 a 84 de la Ley General de Telecomunicaciones. Información proporcionada por el Licenciado José Toledo Ordóñez, Superintendente de Telecomunicaciones hasta el mes de febrero de 2000.

27 Pablo Spiller, 1997.

A pesar de la necesidad e importancia de la interconexión entre redes, no podemos negar que ella genera costos al operador dominante (otorgante de la interconexión), por cuanto los operadores solicitantes hacen uso de la infraestructura de aquél para cursar tráfico telefónico por el que no percibirá beneficio económico alguno. Estos costos le deben ser compensados al operador otorgante con el precio que el operador entrante le debe pagar. Con el fin de fijar este precio, previo al otorgamiento de esta facilidad deben celebrarse los acuerdos respectivos entre los operadores involucrados. Estos acuerdos son llamados *contratos de interconexión* y en ellos queda establecido el plazo, precio, forma y demás elementos incluidos en el mismo.

Sobre estos contratos la ley solamente indica que serán libremente negociados entre las partes y que ningún operador puede interconectar equipos que ocasionen daño a equipos en uso. No entra a señalar cómo deben ser celebrados los acuerdos, pero sí indica, *numerus clausus*, los servicios que los operadores deben ofrecer a los nuevos competidores. Estos servicios son conocidos como *recursos esenciales*.

Recursos esenciales

Los recursos esenciales son aquellos elementos de la red del operador dominante -o de cualquier otro operador ya en funcionamiento- a los que el nuevo operador precisa tener acceso para cursar tráfico entre ambas redes.

La interconexión es la unión física entre elementos de las redes y los recursos esenciales son los elementos a los que el operador dominante tiene obligación de dar acceso a los nuevos competidores mediante tal interconexión.

En nuestra legislación se consideran recursos esenciales solamente los siguientes:

* La terminación en la red de una de las partes, de telecomunicaciones originadas en cualquier otra red comercial;
* La transferencia de telecomunicaciones originadas en la red de una de las partes a cualquier otra red comercial de telecomunicaciones seleccionada por el usuario final, implícita o explícitamente;[28]
* La señalización;
* Los datos necesarios para la facturación de los servicios prestados;
* El derecho de publicación de datos y registro de usuarios en las páginas blancas de todo directorio telefónico;
* El derecho de acceso a las bases de datos de los directorios públicos de los clientes de otras empresas de servicios de telecomunicaciones, con la única finalidad de su publicación en las páginas blancas de su directorio telefónico; y
* El traspaso de identificación automática del número de identificación del usuario que origina la comunicación.[29]

La característica de desregulación y apertura a la competencia que muestra nuestro mercado de telecomunicaciones encuentra una importante excepción en lo que se refiere al derecho de acceso a recursos esenciales que la ley otorga a los nuevos operadores. En efecto, los acuerdos de interconexión relativos a recursos esenciales *no necesariamente son libremente negociados entre las partes porque la ley expresamente indica que todo operador de redes comerciales de telecomunicaciones debe proporcionar acceso a estos*

28 La transferencia y la terminación de telecomunicaciones constituyen el primero y el último paso en toda telecomunicación. Cuando la comunicación se establece entre usuarios de dos redes distintas estos dos pasos adquieren especial trascendencia, porque de su otorgamiento recíproco -en ambas vías- depende el flujo de información. Si en una red se produce la transferencia de telecomunicaciones pero en la otra no se produce la terminación, el proceso no cumple su fin.

29 Artículo 27 de la Ley General de Telecomunicaciones. Este artículo fue modificado por el artículo 1 del Decreto número 115-97, que suprimió la literal h). Esta literal establecía que también era recurso esencial *la portabilidad del número de identificación del usuario final, en caso de cambio de la empresa que brinda el acceso a los servicios de telecomunicaciones.* Mediante la función contemplada en este recurso esencial, hubiera sido posible que los usuarios finales de los servicios pudieran cambiar de operador y aún conservar el número que les había sido asignado por el operador original. Con la supresión de este servicio como recurso esencial se impidió en alguna medida la competencia entre operadores, por cuanto muchos usuarios del servicio de telefonía se resignan a permanecer con un operador con el que no están conformes a fin de evitar los inconvenientes derivados de un cambio de número. Esta supresión se justificó con el argumento que no era técnicamente posible dar acceso a ese recurso, dificultad que de momento sí existe -según estudios técnicos efectuados- pero que no necesariamente es insalvable en el futuro.

recursos a cualquier operador que lo solicite mediante el pago correspondiente, y que si aquél no otorga el acceso, puede llegar a ser severamente multado hasta que lo haga. Adicionalmente, la ley establece un criterio para determinar las condiciones contractuales que el operador entrante puede pedir, al indicar que cuando un operador solicite el acceso a un recurso esencial, tendrá derecho a condiciones contractuales similares a las que el operador que otorgue dicho recurso mantenga vigentes con otros operadores en similares circunstancias.[30]

Para ejercer el derecho a acceder a recursos esenciales, el operador interesado debe solicitarlo expresamente al operador dominante. En esta primera etapa, los precios y las condiciones de acceso a cualquier recurso esencial deben ser negociados entre las partes. De no llegarse a un acuerdo, las partes pueden solicitar su intervención al órgano estatal encargado de dirimir las controversias entre los actores del sector -la *Superintendencia de Telecomunicaciones*-, para lo cual se precisa del dictamen de un perito. El dictamen del perito y la resolución de la Superintendencia, en último término, solamente pueden versar sobre asuntos relativos al precio y a las condiciones de acceso a estos recursos, y deben fundamentarse en criterios de orden económico, técnico y de tráfico internacional.

Como vemos, el derecho de acceso a recursos esenciales como se encuentra definido por nuestra legislación, es una clara excepción al principio según el cual la fijación de los precios para la prestación de servicios comerciales de telecomunicaciones es libremente fijado por las partes; de hecho, en esta materia los precios sí podrían estar sujetos a regulación y aprobación estatal.[31]

Selección de operador de red

La selección de operador de red es la función mediante la cual el usuario de la red de un operador puede escoger a otro operador para que le curse sus llamadas hasta el destino final, mediante la marcación de los números -código de multiportador- correspondientes al operador elegido. Es decir, es el sistema por el cual el usuario de la red de telefonía del operador B puede generar y terminar comunicaciones haciendo uso de la red del operador A, mediante la marcación del código correspondiente a A. Con este sistema, el cliente de B solamente hace uso de la red de éste para seleccionar el operador deseado. Una vez seleccionado este operador, la comunicación se cursa por la red de A.[32]

Nuestra ley no define lo que es esta función sino que se limita a establecer que los operadores de redes comerciales con más de 10 mil líneas de acceso, deberán permitir a los usuarios conectados a su red utilizar los servicios de un operador de red diferente para comunicarse, mediante la selección de un código de operador de red definido de acuerdo con el plan de numeración elaborado por la Superintendencia de Telecomunicaciones.[33]

La conveniencia de este sistema adoptado por nuestra ley es que permite a los usuarios de la red de un operador elegir a otro operador que curse sus llamadas permitiendo así una mayor competencia entre operadores. Solamente a falta de la marcación de un código seleccionado, las llamadas son cursadas por el operador cuya red se utiliza para cursar llamadas locales. Idealmente, esta facilidad debe implementarse tanto para las llamadas locales como para las internacionales. En Guatemala únicamente se ha implementado en lo que a tráfico internacional se

30 Artículo 28 de la Ley General de Telecomunicaciones, reformado por el Decreto 115-97. Antes de la reforma, el artículo establecía que cuando un operador solicitara el acceso a un recurso esencial, tendría derecho a condiciones contractuales similares a las que el operador que otorgara dicho recurso hubiere pactado con otros operadores en cláusulas contractuales que estuvieran vigentes. La reforma efectuada a este artículo fue criticada por cuanto el parámetro brindado por las cláusulas contractuales vigentes hasta cierto punto determinaba un criterio objetivo para evaluar las condiciones contractuales que se solicitaban y las que se otorgaban, mientras que el parámetro que se debe usar ahora da lugar a un alto grado de subjetividad, por cuanto 'la similitud de circunstancias' no puede determinarse según un criterio objetivo preestablecido -como sí lo eran los contratos ya vigentes- sino solamente a través del criterio que, influenciado por las circunstancias del momento, tenga alguien más.

31 Artículo 22 de la Ley General de Telecomunicaciones.

32 En nuestro medio, se selecciona un operador de red cada vez que haciendo uso de una línea domiciliar proporcionada por Tel gua, hacemos una llamada internacional utilizando la red de otro de los operadores que trabajan en esta sección del mercado, mediante la marcación del código de multiportador respectivo.

33 Artículo 48 de la Ley General de Telecomunicaciones, reformado por el artículo 7 del Decreto número 115-97. Originalmente, la facilidad de selección de operador de red debía ser habilitada el 18 de noviembre de 1997. Sin embargo, con las reformas introducidas a la Ley General de Telecomunicaciones mediante el Decreto 115-97, esta fecha se pospuso para el 31 de diciembre

refiere, porque aún no existe un mercado lo suficientemente desarrollado y por las características técnicas de los operadores de redes locales. Por el momento, su habilitación a nivel de telefonía local carece de objeto.

2.3 Innovaciones administrativas

En lo que a innovaciones administrativas se refiere, esta ley creó una *Superintendencia de Telecomunicaciones* y un *Registro de Telecomunicaciones*. La Superintendencia es un organismo eminentemente técnico, que goza de independencia funcional.[34] Es dirigida por un Superintendente, entre cuyas funciones se encuentra la de crear, reformar y derogar las disposiciones de la Superintendencia, previo refrendo ministerial. Entre otras cosas, sus actuaciones se encaminan a administrar y supervisar la explotación del espectro radioeléctrico, así como a dirimir las controversias que surjan entre operadores por el acceso a recursos esenciales.

3- Consideraciones finales

Después de los más de 25 años que duró el monopolio estatal del servicio de telecomunicaciones en Guatemala, en la década de los noventa, la liberalización del sector se empezó a contemplar como una necesidad apremiante. Varios académicos se dieron a la tarea de estudiar las diversas formas como se podía iniciar este proceso sobre la base de una realidad que se tomaba ya sobre la marcha y muy viciada. Adicionalmente, se estudiaron los modelos adoptados en varios países en los que el proceso, tras varios años de ensayo y error, había ya empezado a dar visos de éxito. Fue bajo la perspectiva de estas dos fuentes que en nuestro país, a partir de 1996, se dio una serie de reformas a varios cuerpos legislativos que de una u otra forma consolidaban la tradición monopólica en la prestación de los servicios de telecomunicaciones. Más importante que estas reformas periféricas fue la emisión de la *Ley General de Telecomunicaciones*, cuyo texto se inspiró en el principio de libertad de entrada y permanencia de competidores en el sector, así como por un afán de eficientizar el servicio donde ya lo había y de que llegara a donde nunca antes había llegado, gracias a las bondades que la libertad de competencia lleva a donde se le deja entrar.

Es innegable que una buena parte de la población del país ha empezado ya a recibir beneficios concretos derivados de este proceso de liberalización. Ello se debe a que a consecuencia de la referida reforma al

de 1998. La reforma añadia que esta fecha podía ser pospuesta para el 1 de julio de 1999 si la Superintendecia llegaba a determinar y a informar al Organismo Ejecutivo que, a pesar de los esfuerzos diligentes de los operadores de redes de telecomunicaciones, no existían las condiciones técnicas para implementar la facilidad en cuestión. Según información proporcionada por el Licenciado José Toledo Ordóñez, ex superintendente de Telecomunicaciones, la fecha de exigibilidad de esta facilidad no se corrió al 1 de julio de 1999 en vista que el operador dominante no probó que hubiera estado haciendo los esfuerzos diligentes para habilitarla. Por el contrario, dictámenes elaborados por peritos contratados por la Superintendencia llevaron a concluir que al operador dominante sí le era posible habilitar los códigos y que si no lo había hecho era para impedir que los nuevos operadores pudieran entrar a competir en el mercado de telefonía de larga distancia. Esta negativa empezó a dar origen a disputas a nivel administrativo, porque a pesar de que desde noviembre de 1997 el operador dominante supo que a partir del 31 de diciembre de 1998 sería exigible la obligación de permitir a sus usuarios el acceso a los códigos correspondientes a otros operadores, llegó esta fecha y los códigos aún no habían sido habilitados. Así las cosas, la Superintendencia se dio a la tarea de hacer varias pruebas para verificar si el operador dominante permitía a sus usuarios realizar llamadas internacionales a través de un operador diferente. Todas las pruebas arrojaron resultados negativos, por lo que la Superintendencia otorgó al obligado un plazo de 10 días para que hiciera valer sus pruebas de descargo, oportunidad en la que éste argumentó que estaba sufriendo dificultades técnicas que le impedían dar cumplimiento a la ley. Ningún argumento fue considerado válido por la Superintendencia por lo que ésta resolvió imponer al infractor una multa de US $50,000.00. A pesar de esta multa, el operador dominante persistió en su negativa por lo que la Superintendencia le impuso multas de US $100,000.00 diarios por cada código no habilitado y, ante esto, la habilitación finalmente tuvo lugar. En la vía administrativa, este problema llegó a su término con la emisión de la resolución SIT-080-99, del 24 de febrero de 1999, y actualmente se encuentra ventilándose a nivel judicial. Ver expediente 299-99 que se sigue ante el Juez Segundo de lo Económico-coactivo, Oficial 3º.; y el 141-99 que se sigue ante la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo, Oficial 1º.

34 La independencia funcional a que se refiere el artículo 5 de la Ley General de Telecomunicaciones podría ser cuestionable, desde el momento que el Superintendente es nombrado por el Ministro de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas. A ello se agrega el hecho que sus disposiciones deben contar con el refrendo ministerial para poder ser ejecutadas y que, además, debe rendir informes periódicos al referido ministerio. Estos cuestionamientos podrían llevar a concluir que tal independencia funcional termina siendo relativa.

sector de telecomunicaciones, se han implementado varios mecanismos que, haciendo uso de la técnica, han permitido que nuevos operadores ingresen en el sector y mejoren la calidad y cantidad de los servicios. Dentro de estos mecanismos se encuentran la implementación de derechos de interconexión claramente amparados por la ley, el acceso a recursos esenciales y la habilitación de los códigos de operador. Sin perjuicio de que la Ley General de Telecomunicaciones contiene muchos otros aciertos, no cabe duda que los tres aspectos señalados son los que más beneficios han rendido ya.

Bibliografía

A survey

1995 'A survey of Telecommunications'. *The Economist*, 336 (7934):5-28.

Antecedentes

1996 *Antecedentes y dictamen favorable de la Ley General de Telecomunicaciones.* Guatemala: Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas del Congreso de la República de Guatemala.

1997 *Antecedentes y dictamen favorable del proyecto de reformas de la Ley General de Telecomunicaciones.* Guatemala: Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas del Congreso de la República de Guatemala.

Bell, Tom W. [Singleton, Solveig] (editores)

1998 *Regulators' Revenge: The future of Telecommunications Deregulation.* Washington, D.C.: Cato Institute.

Bernt, Phyllis W. [Weiss, Martin B. H.]

1996 *International Telecommunications.* Carmel, Indiana: Sams Publishing, Prentice Hall Computer Publishing.

Cairncross, Frances

The death of distance: how the communications revolution will change our lives. Cambridge, Mass.: Harvard Business School Press.

Enmiendas

1996 *Enmiendas a la Ley General de Telecomunicaciones propuesta por la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas.* Guatemala: Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas del Congreso de la República de Guatemala.

Entrevista

2000 Entrevista con Ingeniero Raúl Solares, Gerente de Operaciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala. Guatemala: marzo de 2000.

2000 Entrevista con el Licenciado José Toledo, Ex superintendente de Telecomunicaciones de Guatemala. Guatemala: abril de 2000.

2000 Entrevista con la Ingeniera Claudia Contreras, Subgerente de Operaciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala. Guatemala: junio de 2000.

2000 Entrevista con la Licenciada Carmen Urízar, investigadora asociada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y catedrática de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín. Guatemala: 28 de junio de 2000.

2000 Entrevista con el Ingeniero Luis René Pellecer Solís, Gerente de GUATEL, durante los años 1971 a 1975 y catedrático de la Universidad Francisco Marroquín. Guatemala: 28 de junio de 2000.

2000 Entrevista con el Licenciado Eduardo Palomo Escobar, asesor jurídico de *Comunicaciones Celulares, Sociedad Anónima*. Guatemala: 18 de julio de 2000.

Gasman, Lawrence

1994 *Telecompetition: the free market road to the information highway.* Washington, D.C.: Cato Institute.

Greennspan, Alan

2000 'Comercio y Tecnologia'. *Tópicos de Actualidad*, 864(XL). Guatemala: Centro de Estudios Económico-sociales (CEES).

Ibargüen S., Giancarlo

1998 'TELGUA en la era digital: ¿Una privatizacion irrelevante?' *Tópicos de Actualidad*, 839(XXXIX). Guatemala: Centro de Estudios Economico-sociales (CEES).

Singleton, Solveig

1998 [Bell, Tom W.; -]

Spiller, Pablo
1997 'The frontier of telecommunications deregulation: small countries leading the pack'. Paper presentado en la conferencia *Beyond the Telecommunications Act of 1996: The future of deregulation*. Washington, D.C.: Cato Institute.

Telecomunicaciones
1996 *Las telecomunicaciones y el futuro de Europa*. CC-AD-86-008-ES-C. Bélgica: Comisión de las Comunidades Europeas. Dirección General de Información, Comunicación y Cultura.

Weiss, Martin B.H.
1996 [Bernt, Phyllis W.; -]

Hay tres clases de personas en este mundo: quienes hacen que sucedan las cosas; las que ven suceder las cosas; y quienes no saben lo que está sucediendo.

Nicholas Murray Butler

LUIS PEDRO ALVAREZ MORALES[1]

Efectos de la exhibición personal al dar cumplimiento a garantías constitucionales procesales

Sumario

Notas del autor
1- Garantías constitucionales procesales
2- Concepto y regulación legal de la exhibición personal
3- Análisis sustantivo y procesal de la exhibición personal y sus efectos
Bibliografía

Notas del autor

'Todas las normas procesales en el ámbito del derecho, todos los principios establecidos para proteger al individuo y asegurar la imparcialidad de la justicia, presuponen que las disputas entre individuos o entre individuos y el estado han de ser resueltas mediante la aplicación de leyes generales. Están concebidas para que prevalezca la ley, pero carecen de poder para proteger a la justicia cuando aquélla, de manera deliberada, entrega la decisión a la discreción de la autoridad. *Los procedimientos de salvaguarda únicamente preservan la libertad cuando la ley decide o, lo que es lo mismo, cuando magistrados independientes pronuncian la palabra final*'.[2]

En Guatemala, y demás países subdesarrollados o en vías de desarrollo, constantemente, de suyo con más intensidad que en los países desarrollados, se oye el clamor popular para detener los abusos y arbitrariedades cometidos, por los empleados y funcionarios públicos encargados de la administración de justicia,[3] contra los ciudadanos. Este problema, que enfrenta el hombre en sociedad, requiere de nuestra mayor atención ya que, en este momento en la historia, nadie está a salvo de ser una víctima.

El objeto del presente artículo no es desarrollar extensivamente el concepto, la evolución histórica o el trámite procesal del *habeas corpus*,[4] temas de importancia que de alguna forma serán cubiertos ya que no podemos prescindir de ellos. En esencia, lo que se persigue es dejar claramente establecida nuestra interpretación sobre *cuáles son y cómo deberían ser* los efectos sustantivos y procesales de la acción constitucional de *exhibición personal* al ser utilizada como medio procesal para dar cumplimiento a garantías constitucionales del tipo penal. Principalmente aquellas garantías procesales anteriores a la detención legal del imputado y que están consagradas en nuestra Constitución.

1- Garantías constitucionales procesales

Por el concepto de '*garantías constitucionales procesales*' no debemos entender más que aquellos derechos que le asisten a las personas al ser detenidas por cual-

1 Abogado y Notario.
2 F.A. Hayek, 1992:339.
3 En sus orígenes, antes de conceptualizarse y darse la división de poderes del Estado, la acción de hábeas corpus se interponía como una limitación a los poderes del Rey. Sobre el tema de la evolución histórica de esta institución, puede consultarse J.E. Rosales Pichardo, 1988:35-56.
4 Expresión latina que significa 'que tengas el cuerpo'.

quier agente de autoridad,[5] los cuales deben considerarse como inviolables para asegurar que el detenido gozará de un debido y justo proceso.

Las garantías procesales, especialmente las que han adquirido un nivel de protección constitucional, son límites impuestos a las autoridades estatales en su función. Estos límites son el legado de una trayectoria de continuos abusos por parte de los que gobiernan. Es difícil decir con precisión, sin cometer un atropello a la historia, en qué momento o a quién se le atribuyen cada una de ellas. Tal vez, y siguiendo al profesor Hayek, sus primeros importantes vestigios los encontramos en la tradición del *common law* inglés.[6] El aporte norteamericano, es decir, de los Estados Unidos de América, en este sentido, ha sido de incalculable valor. El hecho de haber plasmado una Constitución escrita (aunque no fue la primera vez que se hizo, sí la que mayor éxito tuvo) en la cual se establecieran ciertas normas generales, abstractas e impersonales, las cuales debieran ser el marco en el cual se desarrollaría el resto de la legislación, dio como resultado ser el medio más eficaz para limitar las arbitrariedades de los que ostentan el poder.[7] Vemos entonces que, como nos lo enseña la historia, la evolución de las garantías constitucionales no se detiene, por el contrario, la experiencia es la que con mayor acierto nos demuestra cuáles derechos son dignos de proteger y cuáles han dejado de tener mayor relevancia. Pero este proceso es lento y dentro de las misiones del jurista está la de poder observar y descubrir estos cambios.

Deliberadamente no hemos querido abordar este tema desde la teoría de los *derechos humanos*. Estas últimas dos palabras, en la época contemporánea, ya no significan nada, o por el contrario, lo significan todo.[8] En realidad se ha dicho mucho sobre los mismos y, desgraciadamente, se han manipulado de tal forma que tanto los defensores de la libertad, como sus enemigos, los utilizan como si existiera una concepción definida y generalmente aceptada de éstos. Dentro de la teoría general de los derechos humanos, podemos aceptar que las *garantías constitucionales procesales* se encuentran mayormente incluidas dentro de los derechos individuales,[9] también conocidos como derechos humanos de la primera generación.[10] Es en estas declaraciones, aceptadas por la mayoría y casi totalidad de naciones, donde ha quedado evidenciada la necesidad de regular concretamente el marco de actuación de los que ejercen el poder. Por lo que, reiteramos, preferimos enfocar el problema directamente como una cuestión de directa interpretación constitucional.

2- Concepto y regulación legal de la exhibición personal

Sobre la etimología del *hábeas corpus* el Diccionario de la Real Academia Española nos dice poco al respecto,[11] por lo que, para fines metodológicos, nos basta el concepto que da el *Diccionario Jurídico* de Cabanellas y Alcalá-Zamora, el cual, al definirlo, literalmente nos dice: 'Palabras latinas, y ya españolas y universales, que significan literalmente: 'que traigas tu cuerpo, 'que tengas tu cuerpo'.[12]

Nuestra Constitución Política de la República nos dice literalmente, en su artículo 263:

'Quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella,

5 Hay personas que consideran que a los particulares, es decir, aquellos individuos que no están investidos de autoridad estatal, tambien pueden violar este tipo de garantías. Nosotros consideramos que esto es incorrecto, toda vez que los procedimientos comunes son los encargados de resolver ese tipo de problemas.

6 Sobre un análisis detallado de la evolucion del estado de derecho, consultar J.E. Rosales Pichardo, 1988:267-287.

7 Sobre el aporte norteamericano al Derecho Constitucional, ver F.A. von Hayek, 1975.

8 Es un término que ha quedado vacío de contenido, *comadreja* en palabras del ilustre Mario Vargas Llosa.

9 Sobre un enfoque moderno de los mismos puede consultarse a G.J. Bidart Campos, 1989. Sin menospreciar el gran trabajo de los autores ubicados dentro de la línea citada, es necesario hacer la advertencia al lector que: si no se cuenta con una clara concepción de la función de las garantías individuales, estos libros pueden confundir más que aclarar el panorama sobre lo que se entiende por derechos del hombre, ya que desarrollan extensas clasificaciones de tipo técnico jurídico.

10 Sobre un catalogo de los mismos puede consultarse la *Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Americana de los Derechos del Hombre*.

11 Diccionario, 1992 II:1079.

12 G. Cabanellas, 1979-III:537.

o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviere sujeto.

Si el tribunal decretare la libertad de la persona ilegalmente recluida, ésta quedará libre en el mismo acto y lugar.

Cuando así se solicite o el juez o tribunal lo juzgue pertinente, la exhibición reclamada se practicará en el lugar donde se encuentre el detenido, sin previo aviso ni notificación.

Es ineludible la exhibición personal del detenido en cuyo favor se hubiere solicitado'.

Para terminar la regulación constitucional en el artículo 264, literalmente se establece:

'Las autoridades que ordenen el ocultamiento del detenido o que se nieguen a presentarlo al tribunal respectivo, o que en cualquier forma burlen esta garantía, así como las (*sic*) agentes ejecutores, incurrirán en el delito de plagio y serán sancionados de conformidad con la ley.

Si como resultado de las diligencias practicadas no se localiza a la persona a cuyo favor se interpuso la exhibición, el tribunal de oficio, ordenará inmediatamente la pesquisa del caso, hasta su total esclarecimiento'.[13]

El aspecto procesal de la acción de *exhibición personal* está regulado en el Título tercero (III) de nuestra Ley Constitucional de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en sus artículos que van del ochenta y dos (82) al ciento trece (113); además, existe un procedimiento especial nuevo en nuestra legislación procesal penal denominado 'Procedimiento especial de Averiguación'[14] que es el resultado del fracaso de la institución de la *exhibición personal*, pero que al mismo tiempo trae innovaciones interesantes como el hecho de darle más participación a los particulares y el acceso a los medios de coacción del Estado a los mismos.

3- Análisis sustantivo y procesal de la exhibición personal y sus efectos

No existe en nuestra legislación un desarrollo normativo de los efectos de la declaración con lugar de la acción de *exhibición personal*, más allá de decirnos que la persona debe quedar en inmediata libertad.[15] Pero surgen interrogantes importantes como qué pasa con el proceso, con la prueba recabada hasta el momento, con la situación jurídica del imputado con relación a la misma causa (es decir, el alcance de la libertad otorgada) y otras que podrían tener relación con las anteriores. Al existir un vacío legal al respecto, y por el principio de la plenitud hermética del derecho, debemos tratar de dar una respuesta concreta a estos cuestionamientos con las herramientas a nuestro alcance, siendo la principal de ellas nuestra Constitución, seguida por la legislación ordinaria y la jurisprudencia que se vaya formando al respecto.

Según se deriva del texto citado en el parágrafo anterior, el artículo 263 constitucional, en su primer párrafo, contiene tres -principales- supuestos de procedencia de la exhibición personal. Para cumplir con el objeto del presente artículo, nos ceñiremos al primero de ellos, es decir: a cuando alguien se encuentre *ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad individual.*[16] La pregunta que surge entonces, necesariamente, es cuándo se encuentra alguien ilegalmente preso, detenido o cohibido de su libertad individual. Como ya lo mencionáramos con anterioridad, existen muchos supuestos (garantías procesales) dentro de nuestra legislación que han de satisfacerse para que una persona pueda ser detenida, importando para efectos de este trabajo únicamente los de carácter constitucional. Nuestra Constitución enuncia un catálogo de derechos humanos en su título segundo, dentro del cual regula las principales garantías procesales penales en su parte sobre los *derechos individuales*, específicamente en sus artículos que van del tres (3) al treinta y dos (32) y el cuarenta y seis (46). Dentro de

13 Sobre la evolución histórica en Guatemala de la Exhibición Personal, puede consultarse: 1) Ob. Cit. II. Pags. 39-50; R. Diaz Castillo, 1967; L.A. Mazariegos Fernández, 1994:73.

14 Artículos que van del cuatrocientos sesenta y siete (467) al cuatrocientos setenta y tres (473) del Codigo Procesal Penal.

15 Siempre recordando que nos referimos al primer supuesto del artículo 263 de nuestra Constitución.

16 Sobre una clasificación formal completa del *hábeas corpus*, según los diferentes supuestos de procedencia, puede consultarse a M. M. Serra, 1992:361.

las garantías constitucionales procesales penales más importantes podemos mencionar: la libertad de acción, el principio de legalidad, las causas de detención, el plazo para presentar a un sindicado a la autoridad, el plazo para que un juez competente reciba la declaración del imputado, la notificación de la causa de detención, la comunicación del procesado, los lugares destinados para la detención del sindicado, el trato que ha de dársele, el derecho de defensa, la presunción de inocencia, la publicidad del proceso, y otras que no son menos importantes que para efectos metodológicos tienen el mismo efecto que cualquiera de las anteriores.

Establece el artículo cuarenta y cuatro (44) de la Constitución Política de la República, en su parte conducente, que: '[...] Serán nulas ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza'.[17] Entonces, a la luz del artículo citado, podemos concluir con certeza que el efecto sustantivo y procesal inmediato de transgredir cualquiera de las garantías procesales penales que la Constitución establece es el de provocar su *nulidad* de pleno derecho. ¿Qué debería significar esto en la práctica? Pues, para nosotros, que todas aquellas diligencias, pruebas, indicios y elementos incriminatorios aportados al proceso hasta el momento de la declaración de detención ilegal, por la vía de la exhibición personal, deben ser rechazados con el efecto de no poderse volver a utilizar en contra del imputado.[18] Ahora, ¿qué pasa con la libertad del imputado? Recordemos lo establecido, en su parte conducente, por el artículo 263 constitucional que nos dice:

> 'Quien se encuentre ilegalmente preso [...] tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia [...] con el fin de que se le restituya [...] su libertad [...] Si el tribunal decretare la libertad de la persona ilegalmente recluida, ésta quedará libre en el mismo acto y lugar [...]'.

Entonces, nos preguntamos: ¿será procedente que el imputado, al ser dejado en libertad en el mismo acto, pueda ser vuelto a apresar inmediatamente después del momento de su liberación?, ¿será esto una violación a la garantía constitucional de la exhibición personal? o ¿a la del debido proceso?

Del análisis exegético de la norma constitucional citada, nos inclinamos a responder en el sentido afirmativo la primera interrogante, es decir, que el sindicado, llenando todos los requisitos legales del caso (por ejemplo, que no haya transcurrido el período de prescripción de la responsabilidad penal), sí puede ser vuelto a aprehender por el mismo delito, aun inmediatamente después de haber sido puesto en libertad. Lo anterior, porque el párrafo segundo de la norma citada dice '[...] Si el tribunal decretare la libertad de la persona ilegalmente recluida, ésta quedará libre en el mismo acto y lugar [...]', o sea, en *contrario sensu*, el tribunal sí tiene la facultad de NO decretar la libertad del imputado. Como vemos, respondiendo a las otras interrogantes, esta situación no viola las garantías constitucionales que se protegen a través de la acción de *exhibición personal* ni el debido proceso, porque la persona vuelve a ser detenida llenando todos los requisitos que establece la ley. Por otro lado, independientemente de las responsabilidades civiles y penales de los funcionarios infractores, creemos que entender esta norma en otro sentido significaría, a parte de desviarse de la correcta interpretación constitucional, llevar los formalismos procesales a un extremo contraproducente y olvidar el objeto de las garantías procesales, que en realidad no buscan la impunidad de los delincuentes sino únicamente que éstos no sean sujetos de procedimientos generalmente repudiados por la humanidad. Ya que mencionamos las responsabilidades en que incurren los funcionarios públicos responsables que dieron lugar a la procedencia de la acción de *exhibición personal*, es necesario aclarar que serán civilmente responsables por los daños y perjuicios ocasionados, responsabilidad que se deduce a través de un procedimiento sumario de conocimiento;[19] y, penalmente por el delito de *plagio* como lo establece el artículo 264 de nuestra Constitución.[20]

Ahora, desplazándonos a la práctica, es difícil contar con datos estadísticos realmente confiables sobre

17 En el mismo sentido, sobre la jerarquía constitucional también pueden consultarse los artículos 175 y 204 de la Constitución.

18 Sobre la objetividad, libertad e inadmisibilidad de la prueba ver: arts. 181, 182 y 183 del Código Procesal Penal.

19 Ver artículos 148-149 de la *Constitución Política de la República, 18 de la Ley de Responsabilidades y 246 al 249 del Código Procesal Civil y Mercantil.*

20 Es interesante la discusión acerca de si es en realidad el delito de 'plagio' el que cometen los empleados y funcionarios públicos

Cuadro 1: Acciones de *exhibición personal* presentadas a los tribunales de justicia durante los años 1997-1998

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1997	Total	2,690	2,413	263	527	687	177	118	383	108	22
Enero		267	250	19	41	64	4	11	19	12	0
Febrero		154	135	21	41	40	8	4	24	8	1
Marzo		334	315	47	108	102	12	12	68	3	4
Abril		231	211	14	43	63	6	5	31	12	0
Mayo		116	104	16	31	36	40	12	19	17	0
Junio		335	318	26	122	92	10	11	61	2	0
Julio		111	119	20	29	38	0	3	9	30	6
Agosto		429	372	46	45	91	46	20	71	0	0
Septiembre		179	154	12	15	45	4	13	20	12	0
Octubre		81	63	11	4	13	19	5	8	0	0
Noviembre		322	270	18	32	69	7	18	37	10	0
Diciembre		131	102	13	16	34	21	4	16	2	11
1998	Total	2,038	1,703	156	200	417	66	100	244	99	15
Enero		79	58	8	13	15	7	6	8	16	0
Febrero		429	388	25	52	95	9	16	60	15	0
Marzo		148	140	13	4	29	2	12	20	17	0
Abril		98	92	9	10	21	9	4	11	4	10
Mayo		139	106	3	14	20	5	2	15	0	0
Junio		29	14	2	0	3	3	2	6	4	4
Julio		233	203	23	28	52	5	13	22	20	0
Agosto		271	214	13	23	55	6	9	26	9	0
Septiembre		179	154	12	15	45	4	13	20	12	0
Octubre		89	74	12	18	24	2	8	11	2	1
Noviembre		52	49	13	2	6	2	7	6	0	0
Diciembre		292	211	23	21	52	12	8	39	0	0

Claves: A: Recibidas; B: Delegadas; C: Presentadas por particulares; D: Presentadas por entidades; E: Resueltas; F: Apareció la persona; G: Declaradas con lugar; H: Declaradas sin lugar; I: Se presentó desistimiento; J: Se decretó sobreseimiento.

el número de *exhibiciones personales* presentadas a los órganos jurisdiccionales y el estado de su trámite, esto por las razones adelante comentadas. Hemos recabado la información que sobre el tema se encuentra disponible en la Sección de Estadigrafía del Organismo Judicial para los años 1997-1998,[21] los cuales forman parte de este artículo como Anexo número uno.[22] Como se puede apreciar de estos datos estadísticos, tan sólo un pequeño porcentaje de las acciones de *exhibición personal* son declaradas con lugar, y la mayor parte de ellas no terminan por sus medios normales (con lugar o sin lugar) sino quedan perdidas y abandonadas en puro trámite, lo cual es el resultado de una mala práctica tribunalicia consistente en que cuando, después de haber infringido ya las garantías procesales mínimas del imputado, se recibe tardíamente la declaración del mismo, las autoridades dan por solventadas las irregularidades del proceso y como se dice en lenguaje coloquial (buen chapín): *parte sin novedad*. Por nuestra parte no confiamos en los datos estadísticos proporcionados, ya que, a simple vista, encontramos contradicciones en los mismos, como el hecho de no cuadrar matemáticamente los resultados de las acciones de *exhibición personal* presentadas con el número de casos tramitados y fenecidos, y muchas otras observaciones similares que se pueden apreciar de la tabla adjunta.

responsables por violar garantías constitucionales que dieron lugar a la acción de *exhibición personal*, ya que en realidad para que esta figura delictual se tipifique es necesario que se solicite una recompensa (artículo 201 del Código Penal), nos inclinamos por otras figuras delictivas como lo son el *abuso de autoridad* (art. 418 del Código Penal), la *detención irregular* (art. 424 del Código Penal), el *abuso contra particulares* (art. 425 del Código Penal) y otros que pueden resultar más convenientes.

21 Un especial agradecimiento a la Señora Edith López de Soler, encargada de la Ventanilla de Estadigrafía de la Corte Suprema de Justicia, por haberme facilitado la información solicitada.

22 Más datos estadísticos se pueden consultar en L.E Andrade Pereira, 1993:37; 11) Ob. Cit. 11.

En conclusión, creemos haber dejado claro lo que para nosotros deben ser los efectos sustantivos y prácticos del uso de la acción de *exhibición personal* como medio de defensa de las garantías procesales constitucionales de carácter penal, especialmente aquellas anteriores a la detención del imputado y estamos convencidos que este medio jurídico de defensa es uno de los bastiones más importantes para preservar y garantizar la libertad individual. Esperamos haber contribuido a que por medio de la difusión de su concepto, regulación legal y, específicamente, sus efectos jurídicos sirva a las personas para comprender que existe ya un medio civilizado para poner freno a las arbitrariedades de quienes ostentan el poder, especialmente en lo relacionado con la administración de justicia del tipo penal.

Bibliografía

Andrade Pereira, Leonel Estuardo

1993 *Las detenciones ilegales, una violación a las garantías constitucionales en Guatemala.* Tesis de licenciatura. Guatemala: Facultad de Derecho, Universidad San Carlos.

Bidart Campos, Germán J.

1989 *Teoría general de los Derechos Humanos.* Buenos Aires: Editorial Astrea.

Cabanellas, Guillermo

1979 *Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.* Buenos Aires: Editorial Heliasta.

Código Penal

1973 *Código Penal.* Guatemala: Decreto 17-73 del Congreso de la República, emitido el 5 de julio de 1973.

Código Procesal Civil y Mercantil

1963 *Código Procesal Civil y Mercantil.* Decreto ley 107, emitido el 14 de septiembre de 1963 por Enrique Peralta Azurdia. Guatemala: Tipografía Nacional.

Código Procesal Penal

Código Procesal Penal de Guatemala. Guatemala: Tipografía Nacional.

Constitución

1985 *Constitución Política de la República de Guatemala.* Guatemala: Asamblea Nacional Constituyente, 31 de mayo de 1985.

Díaz Castillo, Roberto

1967 'Origen del *hábeas corpus* en Guatemala y su regulación legal durante el siglo XIX'. *Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala*, Números 1-2. Guatemala: Universidad de San Carlos.

Diccionario

1992 *Diccionario de la lengua española.* Vigésima primera edición. Madrid: Real Academia Española, Editorial Espasa-Calpe S. A.

Hayek, Friedrich August von

1992 *Sobre la libertad.* Rigoberto Juárez Paz, compilador. Primera Edición. San José, Costa Rica: Asociación Libro Libre.

1995 *Los fundamentos de la libertad.* Guatemala: UFM.

Ley de amparo

1986 *Ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad.* Decreto 1-86. Guatemala: Asamblea Nacional Constituyente.

Mazariegos Fernández, Luis Antonio

1994 *Las garantías constitucionales.* Tesis de licenciatura. Guatemala: Facultad de Derecho, Universidad de San Carlos.

Rosales Pichardo, Jorge Edwin

1988 *La exhibición personal.* Tesis de Licenciatura. Guatemala: Facultad de Derecho, Universidad Francisco Marroquín.

Serra, María Mercedes

1992 *Procesos y recursos constitucionales.* Buenos Aires: Editorial Depalma.

JARY LETICIA MENDEZ MADDALENO[1]

La aplicación de la clonación en la producción ganadera: propuesta de una fórmula jurídica para establecer el vínculo contractual[2]

Sumario

Introducción
1- Nociones generales
2- Un instrumento jurídico adecuado
3- De las particularidades de la fórmula jurídica propuesta
Bibliografía

'El contrato es la causa más frecuente, la única fuente ordinaria y normal de las obligaciones. Trascendental para la vida social y económica, hasta el punto de que contratación y progreso siguen en la historia una curva ascendente paralela [...]' (José Castán Tobeñas)

Introducción

Ya es por todos conocidos que la clonación de la oveja Dolly revolucionó el campo de la biotecnología y la tecnología en general se vio innovada. La Dollymanía no fue más que un esfuerzo del Instituto Roslin, una entidad de biotecnología para el mejoramiento de la producción agropecuaria, por maximizar los recursos naturales. La biotecnología como parte de la propiedad industrial se distingue por comprender el conjunto de invenciones que tienen por objeto el material biológico, el cual podrá ser de origen animal, vegetal o humano, incluyéndose tanto las formas de vida superior como los microorganismos o bien los fragmentos de ácido desixorribonucleico (ADN). Todas esas categorías implican una elaboración técnica y de ahí el nombre de biotecnológicas.

No obstante, aunque continuamente se producen avances científicos y exista tecnología extraordinaria como ésta, nadie está en la capacidad de predecir su futuro. La estabilidad y predecibilidad del futuro son elementos de gran importancia para nuestro diario vivir, ya que permiten un nivel de planificación a mediano y largo plazo, aunque permanezca cierto nivel de riesgo. Precisamente para esa predictibilidad de nuestros actos existe el Derecho. La seguridad jurídica, al igual que el bien común y la justicia son valores permanentes del mismo y, por ende, fundamentales para el desenvolvimiento de la vida en común. Es decir, del marco jurídico que rige la convivencia social depende el adecuado desarrollo sostenido de una sociedad.

Las modernas corrientes legislativas no proponen para la tutela de las invenciones biotecnológicas la creación de un Derecho específico que sustituya al Derecho de patentes; no obstante, el mismo debe adaptarse o complementarse en determinados puntos para poder proteger adecuadamente los nuevos avances biotecnológicos y permitir el desarrollo y utilización de aquéllos. En la anterior aseveración existe una diversidad de aspectos que deben analizarse, pero, en este artículo, me limitaré a desarrollar el planteamiento del hecho concreto que una patente sólo confiere el derecho de excluir a otros de la utilización de la invención; si el legislador o el titular de la patente considera que determinados conoci-

1 Abogada y Notaria.

2 Capítulo tercero del trabajo intitulado *Análisis de algunos supuestos de la aplicación del procedimiento biotecnologico de la clonacion dentro de la legislación guatemalteca.*

mientos técnicos deben utilizarse en condiciones limitadas, a ellos corresponde establecerlo ya sea en la legislación o en el contrato respectivo. Así, corresponde al primero establecer los límites y alcances del uso de esa patente y al titular de ésta los presupuestos bajo los cuales conferirá la explotación de la misma. Será este último aspecto el que ocupará nuestro estudio.

1- Nociones generales

El *Código Civil* establece que 'hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación'.[3] En el campo de la contratación, cuando las personas establecen un vínculo contractual, lo realizan con base en sus expectativas, esto es, basadas en lo que en el futuro esperan que será su situación. Es por ello que la creación de un contrato depende en gran medida de las expectativas que las personas guarden sobre su posible situación futura.

El contrato reside en el equilibrio y conciliación de los principios de personalidad y comunidad, de libre autonomía y de interés social. Esto porque, como tal, conlleva una limitación de la libertad, fundamentada en la libertad misma, de la cual se origina el derecho de cada persona de disponer de los propios bienes, de sus actos o bien de servicios en beneficio de los demás, pero siempre dentro del criterio supremo del bien común. Y es que como afirma el Doctor Rafael Termes *'[...] el ser humano es libre y responsable y que, por ser libre, puede obrar mal pero también puede, y debe, obrar bien; puede ser mentiroso, pero también puede, y debe ser siempre sincero; puede ser egoísta, pero precisamente por ser libre, y debe, usar esa libertad responsablemente para hacer cosas que redunden en beneficio de otras personas'*.[4]

La eficacia de un negocio jurídico se desprende indiscutiblemente del adecuado instrumento jurídico que lo documente. De aquí la importancia de que la voluntad de los contratantes no solamente quede plasmada en el contrato respectivo sino que a su vez provea la certeza jurídica que aquella relación jurídica necesita. Esto con el objeto de dotar a quienes otorgan el contrato de la predictibilidad de sus actos respecto del mismo y, en consecuencia, de la predecibilidad de sus expectativas en el futuro.

2- Un instrumento jurídico adecuado

Uno de los efectos de la revolución tecnológica, a la que en párrafos anteriores hacía referencia, es que permite que una persona, ya sea individual o jurídica, ubicada en cualquier lugar del mundo, utilice recursos localizados en cualquier lugar del mundo, para negociar con ellos en cualquier lugar del mundo. La aplicación de la clonación en la producción ganadera puede, en un futuro cercano, ser objeto de contratación, lo cual nos plantea la necesidad de diseñar un contrato que responda a las particularidades que la biotecnología en sí manifiesta, como también la correcta adecuación del mismo al ordenamiento jurídico vigente. Es necesario hacer hincapié que esto último implica tanto el derecho local como la legislación internacional al respecto. Cabe decir que aquí únicamente se hará una propuesta del contrato que podría utilizarse para este caso, la cual se encuentra dentro de lo estipulado por ambas legislaciones, pero no se harán elucubraciones al respecto, puesto que esto no es el propósito de este estudio.

La comercialización del procedimiento de la clonación, y a mi criterio la de cualquier procedimiento tecnológico, no puede realizarse por medio únicamente de un contrato de licencia de uso. Esto resulta insuficiente por la naturaleza misma de la biotecnología. A este respecto, Maredia, Erbisch, Ives y Fischer de la Michigan State University, en su trabajo *Technology Transfer and Licensing of Agricultural Biotechnologies in the International Arena*, desarrollan una idea fundamental en cuanto a que consideran que un objetivo integrado se requiere para que la transferencia de biotecnologías agropecuarias sea exitosa; este objetivo integrado es y debe

3 *Código Civil*, 1996:140.

4 Rafael Termes es Doctor Ingeniero Industrial. Académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales Políticas y de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras; profesor de Finanzas del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE), de la Universidad de Navarra, y Director de su Centro de Madrid. Autor de varios libros. Este párrafo fue tomado de las palabras pronunciadas por el Doctor Termes en el acto de graduación de la promoción de 1998, de la Universidad Francisco Marroquín, en la que fue investido Doctor Honoris Causa en Ciencias Sociales. R. Termes, 1998:59.

ser los requerimientos legales y de bioseguridad, los cuales deben estar plenamente conocidos por ambos contratantes. Cuando esto sucede, afirman estos autores, todas las partes, patrocinador, inventor, proveedor de tecnología, quien recibe la tecnología y el usuario de ésta, pueden estar seguros que la transferencia de la tecnología y la licencia de uso son eficientes. El objeto del presente estudio es proponer una fórmula jurídica que trate de conciliar esos puntos fundamentales para la protección de la biotecnología y la continuidad de las innovaciones en ese campo.

En este orden de ideas, considero que son varios los vínculos contractuales que surgen entre el Instituto Roslin, actual propietario de la patente del procedimiento de la clonación y el propietario del ganado, instituto biogenético, universidad, centro de investigación [...] que quisiera aplicar ese proceso. El punto de partida de la relación contractual no puede ser otro que la licencia de uso, pero éste necesariamente va acompañado de los contratos de transferencia de tecnología y del de conocimientos técnicos o '*know how*'.

Antes de continuar, es preciso establecer los conceptos que permitirán luego proponer la serie de cláusulas del vínculo contractual que podrían establecer el marco jurídico adecuado para la aplicación de la clonación a la producción ganadera. El término tecnología se refiere a la aplicación práctica del conocimiento; en otras palabras, es la aplicación práctica de la ciencia.[5]

Cuando se habla de transferencia de tecnología se hace referencia al movimiento o traslado de la tecnología de un lugar a otro; comprende no sólo la transmisión de la tecnología en sí, sino también el proveer el soporte técnico, la información y el conocimiento asociado con el uso de esa tecnología a transmitir.

La licencia comporta la transferencia de tecnología bajo términos específicos y condiciones pactadas entre las partes.

Usualmente la tecnología es desarrollada localmente para resolver algún problema del lugar. No obstante, esa misma tecnología puede ser aplicada en otros lugares, pero para ello es necesario que ésta sea transferida. Los beneficios de la transferencia de tecnología son innumerables; los hay económicos, sociales, políticos y ambientales. Pero la transferencia de tecnología es un proceso complejo y multifacético, y por ello conlleva una serie de prerrequisitos de los cuales depende que la misma sea o no exitosa. Son precisamente esos prerrequisitos los que el vínculo contractual debe contemplar. Así, la transferencia de tecnología incluye, además de la transmisión de la tecnología, la de la información, el entrenamiento, los mecanismos de soporte y las políticas de desarrollo y comercialización.

Además de estos requisitos, propios de este contrato en particular, no pueden dejar de ser parte del mismo una cláusula que establezca lo relativo a la propiedad intelectual, una estipulación respecto de la resolución de conflictos,[6] una cláusula relativa a la rescisión del contrato y sus efectos, una disposición sobre la terminación del contrato y sus efectos, lo relativo al caso fortuito y fuerza mayor; todas estas cláusulas con arreglo a las características peculiares del ganado y del procedimiento biotecnológico a aplicar.

3- De las particularidades de la fórmula jurídica propuesta

En el apartado que precede al presente, he determinado el contrato que, a mi parecer, sería el adecuado para el caso de que el Instituto Roslin quisiera explotar la patente de la cual es titular en el caso concreto de la aplicación de la clonación al ganado. La transferencia de tecnología y la licencia de uso.

Como ya he mencionado anteriormente, existen presupuestos en este tipo de contratos. Estos son:

3.1- Tecnología apropiada

Debe establecerse con claridad que la clonación aplicada al ganado coincide con las necesidades locales y es aceptada por la sociedad. Si esto no queda determinado, podría tener consecuencias económicas y sociales negativas, o bien un impacto ambiental inadecuado.

5 Cfr. Maredia M. Karim, Frederic H. Erbisch, Catherine L. Ives y Andrew J. Fischer, 1997.

6 Aquí sugiero el sometimiento a un juicio arbitral de equidad por la especialidad de la materia, aunque nada obsta a que se puedan someter a los tribunales que mejor consideren convenientes.

3.2- Estipulaciones respecto del desarrollo de investigación y tecnología

Antes de cualquier intercambio de tecnologías o transferencia de tecnología al ámbito internacional, especialmente en el caso de proyectos multiinstitucionales o sociedades mercantiles, deben determinarse las bases sobre la apropiada investigación y la transferencia de tecnología con sus límites.

3.3- Infraestructura adecuada

La infraestructura física tiene que determinarse con exactitud, porque el uso, prueba y desarrollo final de los productos se desarrollan en ella y de eso depende el éxito del contrato en gran parte. Aquí se incluyen los laboratorios, los establos, el pasto, los sistemas informáticos y de comunicación, las oficinas comerciales, los centros de venta y distribución, y otras estructuras de soporte.

3.4- Políticas institucionales, procedimientos y logística

La política de desarrollo de la transferencia de tecnología debe darse tanto a nivel nacional como institucional. Esto se refiere a lo relativo a la propiedad intelectual y su protección, tanto por los otorgantes del contrato como por los demás miembros de la sociedad.

3.5- Entrenamiento del equipo de trabajo

Con el objeto de aplicar la clonación a la producción ganadera, se necesitan el acceso y manejo del procedimiento de clonación, para lo cual se requiere de personas bien entrenadas. Estas deben ser capacitadas por el mismo Instituto Roslin, tanto en lo técnico como en los asuntos de propiedad intelectual, desarrollo investigativo y aspectos de comercialización. El liderazgo organizacional también es esencial. Aquí es donde el contrato de *know how* o conocimientos técnicos es necesario para una mejor eficacia del contrato de transferencia de tecnología.

De lo anterior se deriva que, para poder aplicar la clonación a la producción ganadera, es necesario primero obtener una licencia de uso por parte del Instituto Roslin, posteriormente elaborar un contrato de transferencia de tecnología y conocimientos técnicos o *know how*. Esto porque con la licencia de uso se permite la comercialización de la tecnología. Con ese contrato se establecen los términos y condiciones para ambas partes respecto del proceso de comercialización; usualmente las licencias son vínculos a largo plazo que requieren la reciprocidad entre los contratantes en el mencionado proceso de comercialización. El papel de la transferencia de tecnología es el correcto desarrollo de la licencia de la patente biotecnológica otorgada, con el objeto de continuar con la investigación y el mejoramiento de la patente, que trae consigo el contrato de conocimientos técnicos. Con esto, nos aseguramos el éxito de la introducción de esos nuevos avances biotecnológicos a nuestros recursos agropecuarios y la certeza jurídica necesaria para la maximización de los siempre escasos recursos y, en consecuencia, del progreso económico del país. Con la galvanización, los países están continuamente intercambiando tecnologías unos con otros. Los nuevos avances biotecnológicos son fundamentales para el aumento de la productividad del sector agropecuario y en consecuencia para alimentar a las próximas generaciones. Este acceso e intercambio requiere que los países, instituciones y personas, en general, tengan no solamente el marco jurídico adecuado, sino también los instrumentos apropiados para el manejo de la tecnología, de modo que ésta sea legal y segura.

Bibliografía

Código Civil

1963 *Código Civil*. Guatemala: Decreto Ley 106, emitido el 14 de septiembre de 1963 por Enrique Peralta Azurdia.

1996 *Código Civil de Guatemala*. Decreto-Ley Nº 106. Guatemala: Ediciones Alenro.

Erbisch, Frederic H.

1997 [Maredia, Karim M. -; Ives, Catherine L.; Fischer, Andrew J.]

Fischer, Andrew J.

1999 [Maredia, Karim M.; Erbisch, Frederic H.; Ives, Catherine L.; -]

Ives, Catherine L.

1997 [Maredia, Karim M.; Erbisch, Frederic H.; -; Fischer, Andrew J.]

Maredia, Karim M. [Erbisch, Frederic H.; Ives, Catherine L.; Fischer, Andrew J.]
1997 'Technology Transfer and Licensing of Agricultural Biotechnologies in the International Arena'. *I Seminario Centroamericano sobre Propiedad Intelectual y su relación con la biotecnología y la biodiversidad*. San José, Costa Rica: IICA.

Termes, Rafael
1998 '¿Qué es la verdad?' *Tópicos de actualidad*. Guatemala: Centro de Estudios Económicos (CEES). Junio.

Seminario
1997 *Seminario de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) sobre la protección legal de las invenciones y los diseños industriales para los países del Istmo Centroamericano*. Guatemala: OMPI en cooperación con el Ministerio de Economía y la Cámara Empresarial de Guatemala.

El principio que debe guiar cualquier intento de crear un mundo de hombres libres, tiene que ser éste: una política de libertad individual es la única política que verdaderamente conduce al progreso.

Friedrich A. Hayek



Los argumentos favorables a la libertad individual descansan principalmente en el reconocimiento de nuestra inevitable ignorancia de muchos de los factores que fundamentan el logro de nuestros fines y bienestar.

Friedrich A. Hayek

Derecho y Economía

JULIO H. COLE[1]

Patentes: costos y beneficios



Sumario

Abstracto
Introducción
1- Patentes como Propiedad
2- Patentes y progreso técnico
3- Costos de las Patentes
Conclusiones
Bibliografía

Abstracto

Las patentes son formas especiales de 'propiedad' inmaterial que otorgan el derecho exclusivo de controlar la producción y venta de un determinado producto. El concepto de 'propiedad intelectual' también incluye otros conceptos muy distintos, tales como marcas comerciales. La diferencia entre una marca y una patente es que la marca identifica el origen de una mercancía, pero no prohíbe la fabricación de productos similares, y por tanto no tiene el carácter monopólico de la patente. Muchas personas que aceptarían de buen grado la protección de marcas comerciales como algo perfectamente legítimo y de vital importancia en una economía moderna, podrían no obstante oponerse a las patentes de invención por constituir privilegios monopólicos. La propiedad privada garantiza que los bienes escasos serán usados de la forma más eficiente y productiva. Es difícil justificar los derechos de 'propiedad intelectual' bajo este concepto de propiedad, ya que éstos no surgen de la escasez de los objetos apropiados. Más bien, su propósito es *crear* una escasez, para de este modo generar una renta monopólica para los tenedores del derecho. Aunque los defensores del sistema de patentes argumentan que éste es necesario para promover el progreso técnico, es importante señalar que no todo el 'progreso técnico' actual se debe a la innovación tecnológica propiamente dicha, y no todas las innovaciones tecnológicas se deben a invenciones patentables. La protección de patentes incrementa el retorno promedio sobre la actividad inventiva dedicada a invenciones patentables, y por tanto en teoría induce más actividad de este tipo, aunque la magnitud empírica de este efecto es debatible. Por otro lado, no es del todo obvio que el sistema de patentes sea siempre beneficioso para el progreso técnico, y muchas veces resulta ser en la práctica un estorbo. La existencia de patentes también puede distorsionar los incentivos, desviando la actividad inventiva hacia productos más fácilmente 'patentables'.

> *The greatest constraint on your future liberties may come not from government but from corporate legal departments laboring to protect by force what can no longer be protected by practical efficiency or general social consent* (John Perry Barlow, 1994)

Introducción

Patentes y *copyrights* son formas especiales de 'propiedad' inmaterial que otorgan a sus propietarios o beneficiarios el derecho exclusivo de controlar la producción y venta de un determinado producto una obra literaria o artística en el caso del *copyright*, un invento o proceso productivo en el caso de las patentes. A menudo estos conceptos se engloban en un concepto más amplio de

1 Licenciado en Economía en la Universidad Francisco Marroquín. Director de la Biblioteca Ludwig von Mises.

'propiedad intelectual', pero no son completamente análogos, y no siempre se pueden justificar con los mismos argumentos. Por otro lado, bajo el rubro de 'propiedad intelectual' también se incluyen otros conceptos muy distintos, tales como marcas comerciales. Lamentablemente, en discusiones recientes sobre estos temas el concepto de 'propiedad intelectual' se emplea muchas veces en forma genérica, obviando distinciones que en la práctica son muy importantes.

La marca comercial (o 'marca registrada') es un signo o rótulo que distingue los productos de un fabricante de los de otros. La marca se inscribe en un registro estatal y concede a su propietario el uso exclusivo de la misma. Esto garantiza la procedencia del producto avalado por la marca, lo cual permite a los consumidores comprar con más certidumbre (ya que los propietarios de marcas conocidas tendrán incentivos para proteger el valor económico de las mismas manteniendo estándares de calidad para sus productos), y protege al fabricante de falsificadores que tratan de vender sus propios productos aprovechándose de la buena reputación de marcas renombradas. La diferencia entre una marca y una patente es que la marca identifica el origen de una mercancía, pero no prohíbe la fabricación de productos similares (o incluso idénticos), y por tanto no tiene el carácter monopólico de la patente: Si decido fabricar y vender whisky marca 'Chivas Regal', estaría violando la ley, pero eso no quiere decir que no puedo fabricar y vender whisky, siempre que no le ponga una marca registrada que no sea de mi propiedad. La existencia de una patente, en cambio, me impide producir y vender el artículo patentado. Por esto, muchas personas que aceptarían de buen grado la protección de marcas comerciales como algo perfectamente legítimo y de vital importancia en una economía capitalista moderna, podrían no obstante oponerse a las patentes por constituir privilegios monopólicos.

1- Patentes como Propiedad

Aunque el término 'propiedad intelectual' es ya de uso común en el plano jurídico, en el plano económico no deja de ser un tanto problemático, ya que es difícil justificar este tipo de derechos de propiedad con los mismos argumentos que se usan para justificar la propiedad privada sobre bienes tangibles.

Según la teoría económica de la propiedad (que proviene de David Hume), a la sociedad le conviene definir y proteger derechos de propiedad privada porque los bienes son escasos. No tiene objeto delimitar derechos de propiedad sobre bienes cuando éstos existen en abundancia. Por otro lado, cuando los bienes son escasos y la propiedad es comunal, éstos no son usados eficientemente. La propiedad privada garantiza que los bienes escasos serán usados de la forma más eficiente y productiva. Es difícil justificar los derechos de propiedad intelectual bajo este concepto de propiedad, ya que éstos no surgen de la escasez de los objetos apropiados- más bien, su propósito es *crear* una escasez, para de este modo generar una renta monopólica para los tenedores del derecho: aquí la ley no protege la propiedad de un bien escaso, sino que la 'escasez' es creada por la misma ley (y dicha escasez 'artificial' es precisamente la fuente de las rentas monopólicas que confieren valor a dichos derechos). La gran diferencia entre las patentes (y *copyrights*) y los títulos de propiedad sobre bienes tangibles es que estos últimos serán escasos incluso aunque no haya derechos de propiedad definidos, mientras que en el caso de patentes y *copyrights* la escasez solo existe después de definir el derecho de propiedad.[2]

Los defensores de las patentes a menudo tratan de negar que éstas constituyan concesiones monopólicas, y sostienen que el término 'monopolio' está mal empleado en este caso.[3] En parte se trata de una cuestión meramente semántica, aunque no existe en todo caso ninguna contradicción o incompatibilidad entre la noción de 'patente como propiedad' y la de 'patente como monopolio', y en la práctica ambas nociones están íntimamente relacionadas, puesto que el carácter monopólico de las patentes es precisamente lo que les confiere valor económico.[4] Obviamente, como cualquier privilegio monopólico, las patentes pueden ser muy valiosas para sus propietarios, aunque eso no es en sí razón suficiente para justificar una concesión de ese tipo. Aquí las preguntas relevantes son: ¿Qué im-

2 En este siglo, la explicación más clara de este argumento se debe al economista inglés Arnold Plant, en un artículo de 1934 titulado 'The Economic Theory Concerning Patents for Inventions' (Plant, 1974:35-56). Sobre el pensamiento económico de Plant, véase Coase (1986).

3 Por ejemplo, Novak, 1997:69, 144.

4 'Una patente cumple cuatro propósitos. Del punto de vista moral y social, y quizá [también] psicológico, es una recompensa para

plicaciones tienen las patentes para la eficiencia en la asignación de recursos, y por qué querría la sociedad conceder a algunos de sus miembros privilegios de este tipo? ¿En qué se beneficia la sociedad de la existencia de patentes? ¿Por qué debería la sociedad otorgar a la producción y venta de ciertos productos alguna protección especial más allá de la que pueda estar implícita en la protección de marcas registradas?

La literatura sobre patentes a menudo enfatiza los derechos del inventor, aunque si se analiza la legislación relevante se aprecia claramente que ésta incorpora además una fuerte presunción de que la concesión de patentes de invención favorece el interés público. La primera ley formal sobre patentes fue la de Estados Unidos, aprobada en 1790 y basada en una provisión de la nueva Constitución de 1787, que en su enumeración de las facultades del Congreso incluía la de 'promover el progreso de la ciencia y las artes útiles, asegurando por períodos limitados a autores e inventores el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos'.[5]

En vista de esto, no deja de ser interesante el hecho de que desde un principio no hubo nunca un consenso real sobre la conveniencia de adoptar un sistema de patentes. En efecto, algunos de los más prominentes redactores de la Constitución norteamericana (entre ellos algunos destacados inventores) se oponían a la idea, a veces con vehemencia. Entre ellos, podemos citar a Benjamin Franklin, quien rechazó el ofrecimiento de una patente en su favor por la invención de su famosa estufa: '... así como disfrutamos de muchas ventajas de los inventos de otros, deberíamos con gusto aprovechar la oportunidad de servir a otros mediante cualquier invención nuestra; y deberíamos hacerlo libre y generosamente'.[6]

Aunque las patentes de invención se originaron en Europa, tampoco puede decirse que hubo allí en el pasado reciente algún consenso unánime sobre el tema. De hecho, en el siglo XIX hubo un debate muy intenso y prolongado, especialmente durante el cuarto de siglo comprendido entre 1850 y 1875, y en un momento parecía muy probable la victoria del movimiento anti-patentes.[7] El eventual triunfo de la posición pro-patentes en el plano legislativo refleja una victoria política, pero no necesariamente una victoria intelectual.

---

la habilidad inventiva extraordinaria. Del punto de vista de la economía y del derecho comercial, es un derecho de propiedad. Ninguno de estos propósitos -el premio al inventor o la creación de un derecho de propiedad- tiene por sí mismo algún efecto económico restrictivo. Pero entonces llegamos a la tercera fase de la patente -desde la perspectiva del estado, una patente es una concesión de un monopolio en favor del inventor basado en el interés público en promover el crecimiento y la difusión de tecnología. La concesión monopólica es lo que hace tangible la recompensa del inventor y convierte un derecho de propiedad formal en algo real. Es más, la concesión monopólica tiene un evidente impacto económico, porque el monopolio otorgado por la patente es el derecho de excluir a otros de la fabricación o venta del producto patentado, o de utilizar el proceso patentado' (Timberg, 1962:72) -cfr. las opiniones de Hayek a este respecto: 'Donde más agudamente se plantea el problema de la prevención del monopolio y la preservación de la competencia es en ciertos otros campos donde el concepto de propiedad ha sido aplicado solo en tiempos recientes. Estoy pensando aquí en la extensión del concepto de propiedad a derechos y privilegios tales como patentes de invención, copyright, marcas comerciales, etc. Me parece indudable que en estos campos una aplicación poco crítica del concepto de propiedad tal como éste se ha desarrollado para bienes materiales ha contribuido enormemente a favorecer el crecimiento del monopolio y que podrían requerirse aquí drásticas reformas si queremos que la competencia funcione. En el campo de las patentes industriales, en particular, tendremos que examinar seriamente si la concesión de un privilegio monopólico es realmente la manera más apropiada y efectiva de recompensar el tipo de riesgos involucrados en la investigación científica. Las patentes, en particular, son especialmente interesantes desde nuestro punto de vista porque proporcionan una ilustración muy clara de cómo es necesario en cada instancia no aplicar una fórmula pre-establecida sino retornar a la justificación del sistema de mercado y decidir en cada caso cuáles deben ser los derechos específicos que el gobierno debe proteger. Esta es una tarea tanto para economistas como para abogados. Quizá no sea una pérdida de su tiempo si ilustro lo que tengo en mente citando una decisión [judicial] bastante conocida en la que un juez estadounidense argumentó que 'en cuanto a la sugerencia de que los competidores fueron excluidos del uso de la patente respondemos que dicha exclusión podría decirse que constituye la esencia misma del derecho conferido por la patente' y agrega 'así como es el privilegio de cualquier propietario usar o no usar [su propiedad] sin ninguna consideración de motivos' [Continental Bag Co. v. Eastern Bag Co., 210 U.S. 405 (1909)]. Es esta última afirmación la que me parece significativa por la manera en que una extensión mecánica del concepto de propiedad por parte de los abogados ha contribuido a crear privilegios perjudiciales e indeseables (Hayek, 1948:113-114; véase también Hayek, 1990:75-76).

5 Art. 1, Secc. 8, párrafo 8.

6 *The Autobiography of Benjamin Franklin* (Franklin, 1909:112). Thomas Jefferson también se oponía a las patentes -sobre el pensamiento de Jefferson, véase Meier, 1990.

7 Para una reseña muy detallada de la historia de este debate y la voluminosa literatura en inglés, alemán y francés que generó, véase Machlup y Penrose, 1950.

2- Patentes y progreso técnico

Los modernos defensores del sistema de patentes, deslumbrados por los prodigios de la tecnología moderna, nunca se cansan de subrayar la necesidad de estimular el desarrollo tecnológico.[8] A menudo se citan en este contexto los famosos estudios pioneros de Robert Solow y Edward Denison sobre la importancia del progreso técnico para explicar el crecimiento económico.[9] Lo interesante, sin embargo, es la manera como se citan estos estudios. Estas citas se realizan en forma muy general, y daría la impresión de que los autores que emplean este recurso quisieran atribuir *la totalidad* de dicho progreso técnico a los inventos patentados. El hecho, sin embargo, es que el concepto de 'progreso técnico' en los estudios tipo Solow-Denison es un concepto muy general que abarca, en principio, cualquier incremento en la producción que no puede atribuirse directamente al incremento en el uso de insumos o factores básicos de producción -i.e., es equivalente a lo que hoy en día llamamos 'productividad total de factores'. Esto incluye no sólo el efecto de nuevas tecnologías (no todas las cuales representan invenciones patentadas), sino también los efectos de economías de escala, y de mejoras en la calidad de la fuerza laboral, incluyendo mejor educación (Denison trata de separar el efecto de la educación), la salud y estado nutricional de la fuerza laboral, e incluso cambios en su composición demográfica. Sería pues un grave error atribuir todo 'progreso técnico' únicamente a la innovación tecnológica. Pero aún descontando los importantísimos efectos de la educación y otras mejoras en la calidad de la fuerza laboral, atribuir el efecto residual únicamente a un *determinado tipo* de innovación tecnológica (inventos patentados) sería como atribuir el efecto de la 'educación' únicamente a la enseñanza que se imparte en escuelas formales (error que también se comete muy a menudo). El hecho, sin embargo -y contrariamente a lo que se supone en la literatura pro - patentes- es que los inventos patentados sólo explican una fracción del incremento en la productividad total. Zvi Griliches, reconocido experto en el estudio de la productividad, es muy explícito a este respecto:

> *[...] no todo el incremento en la productividad se debe a la invención y sólo una fracción de esta última surge de los inventos patentados. Si tomamos 1.5 a 2.0 por ciento como la tasa aproximada de crecimiento anual en la productividad, al menos la mitad de ella se debe al mejoramiento en la calidad de la fuerza laboral, economías de escala, y diversas asignaciones de capital entre activos e industrias. Es más, es poco probable que los inventos patentados expliquen más de la mitad de los avances relevantes en conocimientos. Esto nos deja a lo sumo una cuarta parte del crecimiento total en la productividad, y una fracción desconocida de sus fluctuaciones, que podría atribuirse a los inventos patentados.*[10]

Incluso esto probablemente sobre-estima el efecto neto de las patentes, dado que en principio nos interesa estimar los beneficios *marginales* que se derivan de la existencia de patentes, i.e., las invenciones que no se habrían producido sin ellas. Puesto que la protección de patentes incrementa el retorno promedio sobre la actividad inventiva dedicada a invenciones patentables, induciendo por tanto más actividad de ese tipo, podemos suponer que la eliminación de dicha protección tendría el efecto de reducir la producción de ese tipo de inventos. ¿Pero cuán grande sería la magnitud de esa pérdida? No podemos simplemente suponer que *todos* los inventos patentados se deben a la existencia de patentes, puesto que muchos de ellos se habrían desarrollado aún sin ese incentivo.[11] Por otro lado, ciertamente parece razonable suponer que las patentes tienen *algún* efecto sobre la innovación tecnológica, y los modelos teóricos así lo confirman, aunque nuevamente la pregunta inter-

8 Véase, por ejemplo, Beier, 1986; y Novak, 1997:53-83.

9 Por ejemplo, Sherwood, 1992:89-90; y Spector, 1991:132. Las referencias son a los estudios de Solow, 1957; y Denison, 1967, 1974 y 1979; véase también Denison, 1962.

10 Griliches, 1990:1699.

11 No existe mucho consenso entre los historiadores económicos acerca de la importancia de las patentes como factor en la Revolución Industrial. Por un lado, Ashton (1948:21) pensaba que las patentes fueron poco importantes ('Es muy posible que, sin el aparato de la protección [de patentes], las invenciones se hubieran desarrollado con la misma rapidez con que lo hicieron'); y Mokyr (1990:177) expresa una opinión similar ('El sistema de patentes podría haber sido un estímulo a la invención, pero obviamente no fue un factor necesario'). Por otro lado, Douglass North argumenta que las patentes tuvieron un impacto significativo: 'La falta de

sante es la magnitud de este efecto en la práctica.[12] A este respecto, las predicciones de los modelos formales contrastan marcadamente con la evidencia empírica disponible: aunque el efecto es teóricamente importante, los resultados de los pocos estudios que han tratado de detectarlo empíricamente no favorecen la posición pro-patentes. Edwin Mansfield dirigió dos importantes estudios sobre este tema en la década de los 80's.[13] El primero fue un estudio de 31 innovaciones patentadas en cuatro industrias (químicos, farmacéutica, electrónica y maquinaria). Uno de los objetivos del estudio fue contestar una pregunta muy simple: ¿Qué proporción de estas innovaciones se hubieran introducido con atraso (o nunca) si no se hubieran podido patentar?

> *Para investigar esta cuestión, preguntamos a cada firma innovadora si hubieran introducido cada una de sus innovaciones patentadas de no contar con protección de patentes [...] Según las empresas, cerca de la mitad de las innovaciones patentadas en nuestra muestra no se hubieran introducido sin protección de patentes. La mayor parte de estas innovaciones ocurrieron en la industria farmacéutica. Si se excluyen las innovaciones farmacéuticas, la ausencia de protección de patentes habría afectado a menos de la cuarta parte de las innovaciones patentadas en nuestra muestra.*[14]

Los resultados del segundo estudio fueron aún más negativos:

> *Según datos detallados obtenidos de una muestra aleatoria de 100 empresas en 12 industrias manufactureras, la protección de patentes se consideró esencial para el desarrollo o introducción de un tercio o más de las invenciones durante 1981-83 en sólo dos industrias-farmacéuticos y químicos. Por otro lado, en 7 industrias (equipo eléctrico, equipo de oficina, vehículos motorizados, instrumentos, metales primarios, hule y textiles), la protección de patentes se estimó esencial para el desarrollo e introducción de menos de 10 por ciento de sus invenciones. De hecho, en las industrias de equipo de oficina, vehículos motorizados, hules y textiles, las empresas fueron unánimes en reportar que la protección de patentes no fue esencial para el desarrollo o introducción de ninguna de sus invenciones durante este período.*[15]

---

desarrollo de derechos de propiedad sistemáticos sobre innovaciones hasta épocas relativamente modernas fue una causa principal del lento ritmo de cambio tecnológico [...] fue únicamente con el sistema de patentes que se estableció un conjunto sistemático de incentivos para fomentar el cambio tecnológico y elevar la tasa de retorno privada sobre la innovación y acercarla a la tasa de retorno social [...] En ausencia de derechos de propiedad sobre la innovación, el ritmo de cambio tecnológico era influenciado fundamentalmente por el tamaño de los mercados. *Ceteris paribus*, el retorno privado sobre la innovación aumentaba con mercados más grandes. En el pasado un aumento en el ritmo de cambio tecnológico estuvo asociado con eras de expansión económica. Resumiendo, los historiadores de la Revolución Industrial se concentraron en el cambio tecnológico como el principal factor dinámico del periodo. Generalmente, sin embargo, no se han preguntado qué causó el aumento en el ritmo de cambio tecnológico durante este periodo: a menudo, parecería que al argumentar sobre las causas del progreso tecnológico ellos suponen que dicho progreso tecnológico fue generado espontáneamente sin costo alguno. Pero en suma, un incremento en el ritmo de progreso tecnológico resultará ya sea de un incremento en el tamaño del mercado o un incremento en la capacidad del inventor de capturar una mayor proporcion de los beneficios creados por su invención' (North, 1981:164-66). North señala enseguida, sin embargo, que 'Sería erróneo poner demasiado énfasis en una sola ley [...] Más importante que la ley de patentes *per se* es el desarrollo y aplicación de un corpus de derecho impersonal que protege y garantiza contratos que especifican derechos de propiedad' (North, 1981:165). Nuevamente, es importante subrayar que el cambio tecnológico no es, de ninguna manera, la única fuente de aumentos en la productividad (y muchas veces ni siquiera es la fuente principal). Es interesante notar que North cita en este contexto su propio estudio sobre la productividad en el transporte marítimo (North, 1968), que encontró que las principales causas del tremendo aumento en productividad durante el período 1600-1850 no fueron principalmente desarrollos tecnológicos, sino la disminución en la piratería (lo que redujo los costos de seguros y permitió que las naves redujeran sus tripulaciones y el uso de armamento), un aumento en el número anual de viajes por nave (debido, no tanto a mayor velocidad, sino a la reducción del tiempo promedio en puerto), y un incremento en el factor de carga en viajes de retorno. Lo interesante, en este contexto, es que ninguna de estas importantes fuentes de incremento en productividad fue de carácter esencialmente tecnológico. En palabras del propio North: '[...] menores costos de transacción resultado de reducciones en la piratería, naves más grandes, mayor comercio, y menor tiempo en puerto resultaron en significativos incrementos en productividad empezando (por lo menos) 150 años antes de la Revolución Industrial; y esos factores, *más que el cambio tecnológico*, explican los incrementos en la productividad [del transporte marítimo]' (North, 1981:166, énfasis nuestro).

12 La mayoría de los modelos formales modernos se basan en el 'modelo Nordhaus-Scherer' (véase Scherer, 1972).

13 Mansfield, Schwartz y Wagner, 1981; Mansfield, 1986.

14 Mansfield, Schwartz y Wagner, 1981:915, énfasis nuestro.

15 Mansfield, 1986:193. Por otro lado, como señala Mansfield, 'esto no significa que las empresas patentan solo un pequeño por

Un estudio más reciente por Sakakibara y Branstetter,[16] que enfoca el problema desde una perspectiva ligeramente diferente, tampoco apoya la posición pro-patentes. Si las patentes realmente estimulan la innovación, entonces presumiblemente una protección más fuerte debería inducir un mayor ritmo de innovación. Los autores trataron de investigar si patentes más fuertes efectivamente inducen más innovación, estudiando el impacto de una significativa reforma a la ley de patentes japonesa, implementada en 1988. Lo que encontraron fue que 'la respuesta promedio, en términos de mayor investigación y desarrollo y producción de innovaciones adicionales, fue bastante modesta'. Un análisis econométrico usando datos sobre patentes japonesas y estadounidenses para 307 empresas japonesas confirmó que la magnitud de la respuesta fue muy pequeña.

3- Costos de las Patentes

Los beneficios de las patentes, por tanto, no son tan grandes como podría suponerse a primera vista. Por otro lado, si estos beneficios fueran sin costo -si las patentes fueran una especie de 'free lunch'-0 entonces no habría motivos para quejarse. El hecho, sin embargo, es que existen varios costos importantes que a menudo no son tomados en cuenta. Aparte del considerable costo administrativo y los gastos legales asociados con el sistema,[17] el costo económico más obvio es que, a fin de crear incentivos para la producción de inventos que de otro modo no se habrían desarrollado, las patentes crean privilegios monopólicos sobre inventos que se hubieran desarrollado aún sin el incentivo. Sin embargo, también hay otros costos que deben ser considerados:

a- En la práctica, las patentes a menudo estorban el progreso técnico. En la industria automovilística, por ejemplo, Henry Ford no tenía la patente sobre el automóvil y tuvo que luchar contra los dueños de la patente, quienes constituían un cartel cerrado y no tenían interés en la producción masiva de modelos económicos.[18] Otro caso interesante se dio durante los primeros años de la aviación.[19] Las patentes exageradamente amplias son especialmente problemáticas.[20] Un ejemplo reciente se ha dado en el campo de la 'bio-tecnología': En Octubre de

centaje de sus invenciones patentables. Por el contrario, patentan entre 50 y 80 por ciento de ellas, lo que demuestra que, para ellos, los beneficios potenciales de la protección de patentes [...] frecuentemente exceden sus costos'.

16 Sakakibara y Branstetter, 1999.

17 Gastos legales durante los 14 años que duró la batalla judicial [Kodak-Polaroid] le costaron a Kodak [...] $100 millones' (Rivette y Kline, 2000:65).

18 En la época en que Ford empezó a trabajar, la industria automotriz estaba dominada por la Association of Licensed Automobile Manufacturers [ALAM], un reducido grupo de fabricantes que intentaban monopolizar el mercado mediante el control de una patente otorgada en 1895 en favor de George Selden, un abogado, fijando cuotas de producción e impidiendo el ingreso de nuevas firmas en la industria. A Ford se le negó una licencia, y cuando persistió en producir carros se le planteó una demanda legal. El pleito al final fue decidido en su favor, y la ALAM se desintegró (Flink, 1990:181-82).

19 'Orville y Wilbur Wright [...] imitaron el vuelo de las aves al construir un mecanismo que deformaba el plano horizontal de las alas de un avión en ambos lados en direcciones contrarias. Ellos patentaron este mecanismo y afirmaron en su patente que sus derechos se extendían a cualquier sistema que variaba los 'márgenes laterales' en direcciones contrarias'. Otro grupo de pioneros de la aviación, financiados por Alexander Graham Bell, 'sabían acerca de la patente de Wright pero aparentemente tenían reservas acerca del método de deformar las alas [...] Bell sugirió usar alas plegadizas, o 'alerones', que habían sido utilizadas en Francia. [Glenn] Curtiss posteriormente incorporó este concepto en sus exitosos vuelos de 1908 [...] Los Wright demandaron a Curtiss por infracción de patente en 1909, argumentando que su método se aplicaba también a las alas plegadizas. Después de un largo litigio, Orville Wright, [...] ganó el juicio en 1914 [...] Curtiss [entonces hizo] un pequeño cambio en su método para controlar los alerones, lo que obligó a la empresa de Wright a plantear una nueva demanda. Orville Wright vendió su empresa en este punto, pero la empresa sucesora prosiguió con el pleito. Sin embargo, con la inminente entrada de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, el gobierno buscó una solución al litigio sobre la patente, puesto que algunas firmas estaban renuentes a aceptar contratos [de fabricación de aviones] debido a la posibilidad de demandas judiciales por violación de patente. La empresa Wright-Martin [...] amenazaba con demandar a quienes consideraba infractores de su patente -en efecto, cualquier fabricante de aeroplanos' (Bittlingmayer, 1988:230-232). Como señala el autor de este estudio en una nota de pie: 'Parece poco probable que las definiciones amplias -una patente sobre el automóvil o sobre el aeroplano -puedan defenderse sobrebases económicas. Aunque los hermanos Wright dedicaron sus energías a la invención de aviones con la esperanza de hacerse ricos [...] otros, anticipando premios mucho más modestos, estaban justo detrás de ellos. El desarrollo de una máquina voladora exitosa era sólo cuestión de tiempo, y es poco probable que la introducción del aeroplano unos pocos años antes justificara una concesión monopólica sobre el aeroplano y el consumo adicional de recursos ocasionado por la competencia por conseguirlo' (Bittlingmayer, 1988:246n).

20 [...] durante casi un cuarto de siglo, por ejemplo, James Watt pudo impedir que otros ingenieros construyeran nuevos tipos de

1992, la Oficina de Patentes de Estados Unidos otorgó a una sola empresa, Agracetus Inc. de Middleton, Wisconsin, una patente para derechos sobre toda forma de ingeniería genética en algodón -no importa cuáles técnicas o genes sean usados para crearlas. A este respecto, un ejecutivo en esta industria comentó: 'Es como si el inventor de la línea de ensamblaje hubiese obtenido derechos de propiedad sobre todos los bienes producidos en masa, desde automóviles hasta lavadoras de ropa'.[21]

b- La existencia de patentes también muchas veces induce anti-económicos expendios de recursos por parte de competidores que tratan de 'inventar alrededor de la patente', i.e., desarrollar productos competitivos suficientemente diferenciados como para no infringir una patente vigente. Nelson[22] lo expresa de esta manera: 'Una empresa tiene incentivos para duplicar la mejor tecnología disponible patentada por otra empresa en una forma que no viole la patente. En general, existen incentivos para que una empresa desarrolle una tecnología incluso si es peor que la mejor tecnología actual, si es mejor que la que tiene y la mejor está bloqueada por patentes [...]' Como señala Nelson, aunque estas actividades incrementan el nivel de gastos en 'investigación y desarrollo', desde el punto de vista social no son necesariamente un uso eficiente de los recursos disponibles.[23]

c- A menudo la innovación tecnológica es estimulada precisamente cuando las patentes son poco efectivas. Este fue el caso de la firma Eastman Kodak, que decidió adoptar su conocida política de investigación permanente e 'innovación continua' precisamente como una forma de mantener su liderazgo competitivo ante la imposibilidad práctica de enforzar todas sus patentes.[24] Presumiblemente, caso de que hubiesen logrado enforzar efectivamente sus patentes, probablemente hubieran dedicado menos recursos para la investigación y desarrollo de nuevos productos, y el desarrollo tecnológico en esta industria hubiera sido menos rápido.

Un aspecto del problema que no siempre recibe suficiente consideración es que la existencia de patentes podría distorsionar los incentivos, desviando la actividad inventiva hacia productos más fácilmente 'patentables'. Nuevamente, hay que tomar en cuenta que no todos los descubrimientos e innovaciones son patentables, aún cuando pueden ser altamente beneficiosos. Milton Friedman[25] hizo un comentario muy interesante a este respecto en su libro *Capitalism and Freedom*. Luego de pronunciarse en favor de las patentes, agrega: 'Al mismo tiempo, hay costos involucrados. Por una parte, hay muchas «invenciones» que no son patentables. El «inventor» del supermercado, por ejemplo, produjo grandes beneficios para sus prójimos y por los cuales no les pudo cobrar. En la medida en que el mismo tipo de habilidad se requiere para ambos tipos de inventos, la existencia de patentes tiende a desviar la actividad hacia inventos patentables'.[26] La pregunta

máquina de vapor, incluso bajo su licencia' (Ashton, 1948:20). Por lo menos un historiador argumenta que la Revolucion Industrial realmente arrancó en 1785, el año en que caducó la patente de Watt (Rougier, 1971:118).

21 Stone, 1995:656.

22 Nelson, 1981:107.

23 Peor aún, los dueños de la patente también tienen incentivos para hacer lo mismo (i.e., 'inventar alrededor' de sus propias patentes) a fin de impedir competencia potencial. En la medida en que estas actividades son inducidas por el mismo sistema de patentes, los recursos que consumen (lo mismo que los gastos legales asociados) son esencialmente un desperdicio desde el punto de vista social, y deberían considerarse como otro costo del sistema. Para citar un ejemplo, Bresnahan (1985:16) menciona que para proteger su posición monopólica en el mercado de fotocopiadoras de papel común, Xerox patentó cada aspecto imaginable de su tecnología. 'IBM había gastado millones para 'inventar alrededor' de las principales patentes de Xerox -cerca de 25% de lo presupuestado fue gastado en consultas legales, no en investigación y desarrollo'. Para otro interesante ejemplo de 'patentes precaucionarias' véase el artículo de Reich (1977) sobre la historia de las primeras radio emisoras.

24 Jenkins, 1990:134-136.

25 Milton Friedman, 1962.

26 Friedman, 1962:127. Un ejemplo: 'La empresa de biotecnología Genetics Institute decide que version de una droga deber desarrollar, basándose en parte en la iteración que muestra los mejores resultados en pruebas clínicas, pero también en base a la versión que podría obtener la mejor protección de patentes. Los asesores legales de Genetics Institute dicen que la fuerza [legal] de la patente potencial es un 'factor importante' en la decisión sobre dónde orientar la investigación' (Rivette y Kline, 2000:58).

de los 64 dólares: ¿Habría realmente menos inventos si no existieran patentes, o simplemente habría diferentes tipos de inventos?

Conclusiones

El tema de la propiedad intelectual se está volviendo cada vez más importante en discusiones sobre política económica. La tecnología moderna ha creado productos totalmente nuevos que plantean problemas para la definición y delimitación de los 'derechos de propiedad' -citemos como ejemplos el *software* de computadoras y las llamadas 'bio-tecnologías', para mencionar sólo dos campos que se encuentran al filo de la tecnología de vanguardia (son notorios los problemas planteados por el 'patentamiento de formas de vida' y la cuestión de las 'patentes de internet'[27]). Al mismo tiempo, algunos de estos mismos desarrollos están haciendo cada vez más difícil la protección de las formas más convencionales de propiedad intelectual- el desarrollo de archivos tipo '.mp3', por ejemplo, que plantea serias dudas sobre la viabilidad futura del *copyright* sobre grabaciones musicales. Las tensiones que las nuevas tecnologías imponen sobre las actuales leyes de propiedad intelectual están generando demandas para una mayor firmeza en la aplicación de los mecanismos legales existentes. A nivel internacional, el gobierno de los Estados Unidos desde hace varios años ha tomado la delantera a este respecto, presionando a otros países para que fortalezcan sus leyes de propiedad intelectual y/o las modifiquen para que se apeguen más a los actuales estándares norteamericanos.

En vista de estas tendencias, ahora es un buen momento para repensar radicalmente los tradicionales conceptos de propiedad intelectual. ¿No será que, en lugar de considerar reformas para *fortalecer* las patentes y *copyrights*, deberíamos movernos en la dirección contraria? Por supuesto que en ausencia de estimaciones precisas sobre los costos y beneficios de un sistema de patentes no podemos proporcionar una respuesta inequívoca a la pregunta implícita en el título de este trabajo. Quizá nunca sabremos con certeza si los costos superan los beneficios, o viceversa. Sin embargo, sí podemos señalar que los beneficios enfatizados por el campo pro-patentes no son tan grandes como se supone convencionalmente, mientras que hay muchos costos que a menudo no son tomados en cuenta. Por tanto, la relación costo/beneficio no es tan favorable como nos quieren hacer creer. Por lo menos deberíamos oponernos a los actuales esfuerzos por ampliar la cobertura de las leyes de patentes, hasta no contar con evidencia más segura de que los beneficios efectivamente exceden los costos.

Bibliografía

Archibugi, Daniele

1992 'Patenting as an Indicator of Technological Innovation: A Review'. *Science and Public Policy*, 19:357-368.

Ashton, T. S.

1973 *La Revolución Industrial, 1760-1830.* México: Fondo de Cultura Económica.

Barlow, John Perry

1994 'The Economy of Ideas: A Framework for Patents and Copyrights in the Digital Age (Everything You Know about Intellectual Property is Wrong)'. *Wired*, 2-3 (March 1994):85-90, 126-129. (www.wired.com/wired/archive/2.03/economy.ideas.html).

Barton, John H.

1991 'Patentar Seres Vivos'. *Investigación y Ciencia*, 176:6-14. (Mayo 1991).

1991 'Patenting Life'. *Scientific American*, 264:18-24.

Beier, Karl-Friedrich

1986 'La Importancia del Sistema de Patentes para el Progreso Técnico, Económico y Social'. *Derechos Intelectuales*, 1:11-37. Buenos Aires: Editorial Astrea.

27 Sobre el 'patentamiento' de seres vivos, véase Barton (1991). En cuanto a las 'patentes de internet', nótese que en Octubre de 1999 Priceline.com demandó al grupo Expedia (de Microsoft) por infringir su sistema patentado de subastas tipo 'name your own price', mientras que Amazon.com, la conocida librería por Internet, demandó a su principal rival, Barnes & Noble, por violar su patente sobre su conocido sistema de pedidos 'one-click' (Rivette y Kline, 2000:56, 66).

Benegas Lynch, Alberto
1998 'Apuntes sobre el Concepto de *Copyright*'. *Libertas*, 29:121-147.

Bergel, Salvador Darío
1992 'La Materia Viva y el Derecho de Propiedad Industrial'. *Revista del Derecho Comercial*, 25:551-576.

Bittlingmayer, George
1988 'Property Rights, Progress, and the Aircraft Patent Agreement'. *Journal of Law and Economies*, 31:227-248.

Branstetter, Lee
1999 [Sakakibara, Mariko; -]

Bresnahan, Timothy F.
1985 'Post-Entry Competition in the Plain Paper Copier Market'. *American Economic Review*, 75:15-19.

Carrión R., Guadalupe [Ruíz O., Ignacio]
1999 'Las Patentes y las Normas: Documentos para la Transferencia de Tecnología'. *Investigación Bibliotecológica*, 13:180-194.

Coase, R. H.
1986 'Professor Sir Arnold Plant: His Ideas and Influence', en M. J. Anderson, ed., *The Unfinished Agenda: Essays on the Political Economy of Government Policy in Honour ofArthur Seldon*, pp. 81-90. London: Institute of Economic Affairs.

Cohen, Wesley M. [Nelson, Richard R.; Walsh, John P.]
2000 'Protecting Their Intellectual Assets: Appropriability Conditions and Why U. S. Manufacturing Firms Patent (or Not)'. *NBER Working Paper* Nº W7552 (Abstract), Feb 2000 (http://papers.nber.org/papers/W7552).

Correa, Carlos M.
1990 'Patentes, Industria Farmacéutica y Biotecnología'. *Revista del Derecho Industrial*, 12:335-343.
1990 'Protección del Software: Estudio de Caso sobre el Desarrollo del Derecho Económico'. *Revista del Derecho Industrial*, 12:557-583.
1992 'Los Recursos Biológicos y los Derechos de Propiedad Intelectual'. *Revista del Derecho Industrial*, 14:557-567.

Cheung, Steven N. S.
1986 'Property Rights and Invention', *Research in Law and Economics*, 8:5-18. Greenwich, Conn.: JAI Press.

Denison, Edward F.
1962 *The Sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives Before Us*. Supplementary Paper 13. New York: Committee on Economic Development.
1967 *Why Growth Rates Differ*. Washington: Brookings Institution.
1974 *Accounting for United States Economic Growth, 1929-1969*. Washington: Brookings Institution.
1979 *Accounting for Slower Economic Growth*. Washington: Brookings Institution.

Desantes Guanter, José M.
1998 'Los Derechos de Autor en los Medios Ciberespaciales'.*Investigación Bibliotecológica*, 12:17-32.

Desrochers, Pierre
1998 'On the Abuse of Patents as Economic Indicators'. *Quarterly Journal of Austrian Economies*, 1:51-74.
2000 'Excludability, Creativity and the Case Against the Patent System'. *Economic Affairs*, 20:14-16.

Flink, James J.
'Henry Ford and the Triumph of the Automobile', en C. W. Pursell, ed., *Technology in America*, pp. 177-89, Cambridge: MIT Press.

Franklin, Benjamin
1909 *The Autobiography of Benjamin Franklin*, Harvard Classics, vol. 1. New York: P. F. Collier & Son.

Friedman, David D.
2000 *Law's Order*. Princeton University Press, (http://www.best.com/~ddfr/ laws_order/).

Friedman, Milton
1962 *Capitalism and Freedom*. University of Chicago Press.

Gemignani, Michael
1981 'What is a Computer Program?' *American Mathematical Monthly*, 88:185-188.

Goldstein, Paul
199 *Copyright's Highway: The Law and Lore of Copyright from Gutenberg to the Celestial Jukebox*. New York: Hill and Wang.

Griliches, Zvi
1990 'Patent Statistics as Economic Indicators: A Survey'.*Journal of Economic Literature*, 28:1661-1707.

Hayek, Friedrich A.
1948 'Free' Enterprise and Competitive Order' [1947], *Individualism and Economic Order*, 107-118. University of Chicago Press.
1990 *La Fatal Arrogancia*. Madrid: Unión Editorial.
Hollomon, J. Herbert
1967 'The U. S. Patent System'. *Scientific American*, 216:19-27.
Hurt, Robert M.
1966 'The Economic Rationale of Copyright'. *American Economic Review*, 56:421-432.
Jefferson, Thomas
1988 'Carta a Isaac McPherson (Agosto 13, 1813)', en Merril D. Peterson, ed., *Thomas Jefferson: Cartas y Escritos Escogidos*, pp. 600-607. Buenos Aires: Ediciones Tres Tiempos.
Jenkins, Reese V.
1990 'George Eastman and the Coming of Industrial Research in America', en C. W. Pursell, ed., *Technology in America*, 129-141. Cambridge: MIT Press.
Kinsella, N. Stephan
e.p. 'Intellectual Property: A Libertarian Critique'. *Journal of Libertarian Studies.*
Kitch, E. W.
1977 'The Nature and Function of the Patent System'. *Journal of Law and Economics*, 20:265-290.
Kline, David
2000 [Rivette, Kevin G.; -]
Ladas, Stephen P.
1948 'Patents'. *Encyclopaedia of the Social Sciences*, 12:19-25. New York: Macmillan.
Landes, William M. [Posner, Richard A.]
1989 'An Economic Analysis of Copyright Law'. *Journal of Legal Studies*, 18:325-363.
Lindberg, Stanley W.
1991 [Patterson, L. Ray; -]
Lippert, Owen editor
1999 *Competitive Strategies for the Protection of Intellectual Property.* Vancouver: Fraser Institute.
Lobo, Félix
1989 'La Evolución de las Patentes sobre Medicamentos en los Países Desarrollados'. *Revista del Derecho Industrial*, 11:311-348.
Lyman, Peter
1996 'What is a Digital Library? Technology, Intellectual Property, and the Public Interest'. *Daedalus*, 125:1-33.
Machlup, Fritz
1975 'Patentes'. *Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales*, 7:665-674. Madrid: Aguilar.
Machlup, Fritz [Penrose, Edith T.]
1950 'The Patent Controversy in the Nineteenth Century'. *Journal of Economic History*, 10:1-29.
Mann, Charles C.
1998 'Who Will Own Your Next Good Idea?' *The Atlantic Monthly*, 282:57-82 (http://www.theatlantic.com/issues/98sep/copy.htm).
Mansfield, Edwin
1986 'The R&D Tax Credit and Other Technology Policy Issues'. *American Economic Review*, 76:190-194.
Mansfield, Edwin [Schwartz, Mark; Wagner, Samuel]
1981 'Imitation Costs and Patents: An Empirical Study'. *Economic Journal*, 91:907-918.
McGee, John S.
1966 'Patent Exploitation: Some Economic and Legal Problems'. *Journal of Law and Economics*, 9:135-162.
Meier, Hugo A.
1990 'Thomas Jefferson and a Democratic Technology', en C. W. Pursell, ed., *Technology in America*, pp. 17-33. Cambridge: MIT Press.
Merges, Robert P.
1999 'As Many as Six Impossible Patents Before Breakfast: Property Rights for Business Concepts and Patent System Reform'. *Berkeley Technology Law Journal*, 14:577-615.
Mokyr, Joel
1990 *The Lever of Riches: Technological Creativity and Economic Progress.* Oxford University Press.
Molitor, Bruno
1974 'Patent Protection Considered as an Economic Problem'. *Economics*, 9:55-64.
Nelson, Richard R.
1981 'Assessing Private Enterprise: An Exegesis of Tangled Doctrine'. *Bell Journal of Economics*, 12:93-111.
2000 [Cohen, Wesley M.; -; Walsh, John P.]

Nogués, Julio
1991 'Regulaciones y Búsqueda de Rentabilidad: El Caso de las Patentes de Drogas Farmacéuticas'. *Revista de Derecho Industrial*, 13:567-578.

North, Douglass C.
1968 'Sources of Productivity Change in Ocean Shipping, 1600-1850'. *Journal of Political Economy*, 76:953-970.
1981 *Structure and Change in Economic History*. New York: Norton.

Novak, Michael
1997 *The Fire of Invention*. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield.

Okerson, Ann
1996 'Who Owns Digital Works?' *Scientific American*, 275:80-84 (http:// www.sciam.com/0796issue/0796okerson.html).

Pakes, Ariel
1986 [Schankerman, Mark; -]

Palmer, Tom G.
1989 'Intellectual Property: A Non-Posnerian Law and Economics Approach'. *Hamline Law Review*, 12:261-304.
1990 'Are Patents and Copyrights Morally Justified?' *Harvard Journal of Law and Public Policy*, 13:817-865.

Patterson, L. Ray [Lindberg, Stanley W.]
1991 *The Nature of Copyright: A Law of Users' Rights*. University of Georgia Press.

Peacock, Alan
1979 'Public Policy and Copyright in Music: An Economic Analysis', en *The Economic Analysis of Government and Related Themes*, pp. 137-152. Oxford: Martin Robertson.

Plant, Arnold
1974 'The Economic Aspects of Copyright in Books' [1934]. *Selected Economic Essays and Addresses*, pp. 57-86. Londres: Routledge & Kegan Paul.
1974 'The Economic Theory Concerning Patents for Inventions' [1934]. *Selected Economic Essays and Addresses*, pp. 35-56. Londres: Routledge & Kegan Paul.

Penrose, Edith T.
1950 [Machlup, Fritz; -]

Pool, Ithiel de Sola
1990 *Technologies without Boundaries: On Telecommunications in a Global Age*. Harvard University Press.

Posner, Richard A.
1989 [Landes, William M.; -]

Priest, George L.
1977 'Cartels and Patent License Agreements'. *Journal of Law and Economics*, 20:309-377.

Quéau, Philippe
2000 'Defining the World's Public Property: Who Owns Knowledge?' *Le Monde diplomatique*, Jan 2000 (http://www.monde-diplomatique.fr/en/2000/01/14queau).

Reich, Leonard S.
1997 'Research, Patents, and the Struggle to Control Radio'. *Business History Review*, 51:208-235.

Rivette, Kevin G. [Kline, David]
2000 'Discovering New Value in Intellectual Property'. *Harvard Business Review*, 78:54-66.

Rougier, Louis
1971 *The Genius of the West*. Los Angeles: Nash Publishing Co.

Rozanski, Félix
1987 'La Divulgación Optima de Productos de Alta Tecnología y las Patentes de Invención'. *Derechos Intelectuales*, 2:127-139. Buenos Aires: Editorial Astrea.

Ruíz O., Ignacio
1999 Carrión R.; -]

Sakakibara, Mariko [Branstetter, Lee]
1999 'Do Stronger Patents Induce More Innovation? Evidence from the 1988 Japanese Patent Law Reforms'. *Working Paper* 7066, National Bureau of Economic Research, April 1999 (http://www.nber.org/papers/w7066).

Salazar F., Silvia
2000 'Propiedad Intelectual', en Edgar A. Robles, ed., *Centroamérica y la Integración Economica hacia el Siglo XXI*, pp. 89-108. San Jose, Costa Rica: Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas.

Schankerman, Mark [Pakes, Ariel]
1986 'Estimates of the Value of Patent Rights in European Countries During the Post-1950 Period'. *Economic Journal*, 96:1052-1076.

Scherer, F. M.
1972 'Nordhaus' Theory of Optimal Patent Life: A Geometric Interpretation'. *American Economic Review*, 62:422-427.
Schwartz, Mark
1981 [Mansfield, Edwin; -; Wagner, Samuel]
Sherwood, Robert M.
1992 *Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico.* Buenos Aires: Editorial Heliasta.
Solow, Robert M.
1957 'Technical Change and the Aggregate Production Function'. *Review of Economics and Statistics*, 39:312-320.
Soltysinski, Stanislaw
1990 'Protección de los Programas de Computación: Aspectos Comparativos e Internacionales'. *Revista del Derecho Industrial*, 12:585-621.
Spector, Horacio
1991 'Patentes de Invención y Bien Social'. *Derechos Intelectuales*, 5:129-137. Buenos Aires: Editorial Astrea.
Stigler, George J.
1968 'A Note on Patents'. *The Organization of Industry*, pp. 123-25. Homewood, Ill.: R. D. Irwin.
Stone, Richard
1995 'Intellectual Property: Sweeping Patents Put Biotech Companies on the Warpath'. *Science*, 268:656-658.
Timberg, Sigmund
1962 'The Effect of the European Common Market on Anti-Trust and Patent Policy', en Crawford Shaw, ed., *Legal Problemsin International Trade and Investment*, pp. 71-88. Yale Law School.
Wagner, Samuel
1981 [Mansfield, Edwin; Schwartz, Mark; -]
Walker, Jesse
2000 'Copy Catfight: How Intellectual Property Laws Stifle Popular Culture'. *Reason Magazine*, 31:44-51.
Walsh, John P.
2000 [Cohen, Wesley M.; Nelson, Richard R.; -]
Whipple, Leon
1948 'Copyright'. *Encyclopaedia of the Social Sciences*, 4: 401-404. New York: Macmillan.
White, Eduardo
1990 'El Problema de las Patentes en el Sector Farmacéutico'. *Revista del Derecho Industrial*, 12:345-374.

El estudio sin pensar es vano; el pensar sin estudiar es peligroso.

Confucio

ADA LISSETTE REDONDO AGUILERA[1]

El conflicto entre Marcas y Nombres de Dominio en Internet

Sumario

Introducción
1- El Sistema de Nombres de Dominio
2- El conflicto entre el registro de un Nombre de Dominio en Internet y el Derecho de Marcas
3- Factores que han contribuido al incremento de los conflictos entre los Derechos de Marca y el registro de Nombres de Dominio en Internet
4- El rol del sistema de Nombres de Dominio en el conflicto entre Marcas y Nombres de Dominio en el Internet
Conclusiones

Introducción

El conflicto entre la titularidad y el uso de nombres de dominio en el espacio cibernético y el derecho de marcas en el mundo terrestre, es un área de disputas que está a la vanguardia recientemente en los debates que surgen de las complicaciones del Derecho y el Internet. En vista de la ausencia de regulación del espacio cibernético (en parte debido a su origen académico) se han venido utilizando algunas reglas 'terrestres' o nacionales del derecho de marcas a casos concretos de conflictos entre marcas e inscripciones de nombres de dominio en el Internet. Curiosamente, con resultados muy sorprendentes, ya que en algunos casos las Cortes han protegido con vehemencia los derechos de propiedad intelectual sobre 'el nombre' que se ha registrado como nombre de dominio y en otros casos es el nombre de dominio el que ha sido protegido mediante una resolución judicial.

Así mismo, se ha descubierto el role que tienen los Centros de Información de Redes (Network Information Center NIC) en el registro de nombres de dominio para prevenir los conflictos que puedan surgir entre marcas y nombres de dominio.

El objeto de este documento es en primer lugar, describir cómo funciona el sistema de nombres de dominio. En segundo lugar analizar el conflicto que surge del registro de nombres de dominio en el Internet y el derecho de marcas. Así mismo, dar un vistazo a las tendencias que han surgido en las Cortes de Estados Unidos y las resoluciones a las que han llegado finalmente los jueces.[2] Finalmente el tercer objetivo, es profundizar un poco en las medidas y políticas que han adoptado los Administradores de Nombres de Dominio tanto genéricos (g TLD) como del código de cada país (ccTLD) y expresar algunas ideas que servirán para prevenir los conflictos entre marcas y nombres de dominio en el Internet. Así como también erradicar algunos actos de abuso y parasitismo que han surgido del Sistema de Nombres de Dominio.

1- El Sistema de Nombres de Dominio

1.1¿ Qué es un Nombre de Dominio?

Un nombre de dominio es la asignación alfanumérica de carácter único que en realidad designa a un conjunto de números subyacentes que ubican a una computadora o recursos en el Internet. Por ejemplo el

1 Abogada y Notaria. Postgrado en Derecho Europeo comparado y Derecho Comunitario. Consultora del Proyecto de propiedad Intelectual de SIECA-AID.

2 El documento trata de casos de conflictos entre marcas y nombres de dominio en Internet que se han presentado ante cortes extranjeras como las de Estados Unidos porque en estas cortes es donde se han presentado mas casos y en donde los jueces ya han

nombre de dominio www.wipo.int tiene una dirección IP numérica única subyacente la cual es 192.91.247.53. Debido a que las direcciones IP eran difíciles de manejar se diseñó el Sistema de Nombres de Dominio que consiste en direcciones amigables y fáciles de reconocer para los seres humanos.

El Internet es una red de redes. Una red es un conjunto de dos o más computadoras que comparten entre sí información y recursos. Lo que permite que las computadoras puedan comunicarse entre sí, es el lenguaje común. En el Internet, esta comunicación es posible en dimensiones globales, gracias al lenguaje o protocolo TCP/IP acrónimo de Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Cualquier recurso en el Internet, tal como lo es una página WEB o un documento con información tienen su propia dirección- o Uniform Resource Locator (URL). Un nombre de dominio consiste en una dirección asignada a cada computadora o servicio en el Internet. Un ejemplo de nombre de dominio puede ser: 'my.mayutty.com' Si leemos esto de derecha a izquierda el '.com' se refiere al nivel superior genérico gTLD, que usualmente identifica a actividades de comercio o Industria,[3] 'my.mayutty' es el segundo nivel de dominio, y para crear una dirección propia de correo electrónico ada@mi.mayutty.com ada (@ quiere decir hacia) de tal manera esta dirección quiere decir que ada se dirige hacia el dominio mi.mayutty.com.

Esto también funciona con los nombres de dominio del dominio de nivel superior correspondiente a cada país (ccTLD) el mismo ejemplo puede ser ada@mi.mayutty.com.gt el '.gt' corresponde al dominio de nivel superior del código de Guatemala (ccTLD).

1.2 El Sistema de Nombres de Dominio

El sistema de nombres de dominio (DNS) tiene como función principal facilitar a los usuarios la navegación en Internet. Esto se logra con la ayuda de dos componentes: el nombre de dominio y su número correspondiente del Protocolo de Internet (IP). Un nombre de dominio es la dirección fácilmente comprensible para el usuario, de una computadora, normalmente en forma fácil de recordar o de identificar por ejemplo: al nombre de dominio www.sieca.org.gt le corresponde el número (IP) 168.234.125.36.

El Sistema de Nombres de dominio opera sobre la base de una jerarquía de nombres. En la parte superior están los dominios de nivel superior, que normalmente están divididos *en dos categorías*: los dominios de nivel superior genéricos (gTLD) y los dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países (ccTLD).

Actualmente existen siete dominios de nivel superior genéricos gTLD. Tres de estos son abiertos, en el sentido que no hay restricciones respecto de las personas o entidades que pueden registrar nombres con ellos. Estos tres gTLD son.*com*,.*net* y.*org*. Los otros cuatro gTLD son restringidos en el sentido de que únicamente pueden registrar nombres ciertas entidades que satisfacen algunos criterios. Estos son *.int*, limitado al uso de las organizaciones internacionales; *.edu*, cuya utilización se limita únicamente a universidades e instituciones de educación superior con cursos de cuatro años y concesión de títulos profesionales; *.gov*, cuyo uso está limitado a organismos del Gobierno Federal de los Estados Unidos de América; y.*mil*, cuyo uso está restringido a las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América.

Hoy en día, existen 243 ccTLD. Cada uno de estos dominios lleva un código de país de dos letras derivado de la Norma 3166 de la Organización Internacional de Normalización (IS0 3166), por ejemplo Guatemala (.gt), El Salvador (.sv), Nicaragua (.ni) Costa Rica (.cr) Honduras (.hn) y Panamá (.pa). Algunos de estos dominios son abiertos en el

aplicado algunos criterios del derecho de marcas frente al registro de nombres de dominio en el Internet. Ahora bien, en Guatemala también podrán surgir conflictos entre nombres de dominio y marcas porque en Guatemala también se pueden registrar nombres de dominio bajo el dominio de nivel superior correspondiente al código de Guatemala (ccTLD).GT y cualquier persona en el mundo puede registrar un genérico (gTLD). Si desea conocer un poco más del dominio de Guatemala puede acceder y obtener información del dominio .gt en la siguiente página: www.gt

3 Este criterio no es una regla, el '.com' es tan genérico que ya no define actividades únicamente comerciales, puede ser cualquier actividad en la red que sea distinta a la educación o al gobierno o a los servicios de red, que usualmente utilizan el TLD '.net'. Por esta razón se están llevando esfuerzos en el ámbito internacional para que se incrementen el número de los TLD y se den criterios para definir las actividades que se llevan acabo en estos niveles, por ejemplo en este '.com' limitarlo al ámbito comercial. Sin embargo, esto es parte de un estudio no se han establecido aún los criterios.

sentido de que no hay restricciones sobre las personas o entidades que pueden registrarse con ellos. Otros restringen los registros de nombres únicamente a las personas o entidades que satisfagan ciertos criterios (por ejemplo, domicilio dentro del territorio).

Funcionalmente, no existen diferencias entre los gTLD y los ccTLD. Un nombre de dominio registrado en un ccTLD proporciona exactamente la misma conectividad que un nombre de dominio registrado en un gTLD. Tampoco puede decirse que los gTLD sean abiertos y que los ccTLD sean restringidos. Como ya se dijo, existen gTLD y ccTLD sin restricciones en cuanto al uso y gTLD y ccTLD que limitan el uso a personas o entidades que satisfagan ciertos criterios.

Tanto los nombres de dominio registrados por el dominio de nivel superior genérico (gTLD) como en el dominio de nivel superior correspondientes al código de cada país (ccTLD) son regulados por The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) y La Internet Assigned Numbers Authority (IANA)[4] son las instituciones que están a la cabeza del sistema de nombres de dominio en Internet. Internic es la institución que actualmente tiene a su cargo el registro y administración de nombres de dominio en el dominio de nivel superior genérico (gTLD) y los ccTLD son registrados y administrados en cada país por un Órgano de Registro o Centro de Información de Redes (Network Information Center). Más adelante se analizarán cuáles han sido los avances administrativos que ha tenido el sistema de nombres de dominio en materia de conflictos entre marcas y nombres de dominio en el Internet.

2- El conflicto entre el registro de un Nombre de Dominio en Internet y el Derecho de Marcas

Los nombres de dominio son las direcciones de Internet expresadas simplemente para facilidad del usuario. Si bien, los nombres de dominio en Internet fueron diseñados con el fin de permitir a los usuarios localizar ordenadores de manera fácil, éstos han adquirido mayor importancia, como indicadores comerciales, y como tales, han provocado conflictos con el sistema de identificadores comerciales que existía antes de la llegada de Internet. Por ejemplo: Una persona (sin tener un justo título) registra el nombre de dominio www.colgate.com ('nombre' que corresponde a una marca que ampara ciertos productos en el mercado) y su único objetivo es solicitar al titular de la marca, una suma de dinero a cambio de la liberación del nombre de dominio o impedirle a éste que utilice su nombre en el Internet. Esto se complica aún más cuando el mismo nombre se registra en varios ccTLD por ejemplo en www.colgate.com.gt, www.colgate.com.hn o www.colgate.com.cr, y el legítimo titular del 'nombre' protegido con derechos de propiedad intelectual tiene que acudir a varias cortes nacionales para hacer valer sus derechos.

Existe un buen número de personas o entidades que se consideran a sí mismos como titulares, en el sentido más simple de la palabra, de un nombre de dominio. Sin embargo, es muy difícil sino casi imposible determinar quién sea el propietario del nombre de dominio por 'derecho'. O mejor dicho a quién le corresponde utilizar un nombre de dominio determinado. Por ejemplo: 'fellowes'. En el Reino Unido, la palabra 'Fellowes' puede referirse a una marca registrada, puede ser el nombre de un mercado en Londres, o el nombre de una galería en Aberdeen; puede existir una Firma de Abogados o de cualquier otra actividad profesional denominada 'Fellowes', o una marca no registrada para utensilios de cocina o del hogar denominada 'Fellowes' y cuyo registro ampare cualquier otro producto en el mercado, como pueden ser semillas de plantas exóticas o cualquier otro equipo, como se ha visto 'el nombre' puede amparar lo que sea. Y de hecho pueden existir diferentes entidades, titulares de la misma marca registrada en otros países alrededor del mundo, ya sea que operen en el mismo giro del negocio que ampara la marca o no. El derecho de marca, es después de todo, 'territorial'. Pero solamente 'una' de las organizaciones antes mencionadas puede obtener el nombre de dominio 'Fellowes.com'. y una presencia global o internacional por medio del Internet.

4 La atribución de un código de país a un dominio por la IANA no representaba reconocimiento de la situación del territorio designado por el código de país. Como se indicó en la RFC 1591, la IANA no esta en el negocio de decidir lo que es y lo que no es un país.

La controversia recae principalmente sobre quién obtiene primero un nombre de dominio determinado y porqué.

Los conflictos, que generalmente se han venido dando, se deben a que una tercera parte intencionalmente y generalmente sin ningún derecho legítimo, registra un nombre de dominio con el conocimiento previo, de que alguien reclamará dicho nombre. Por ejemplo 'windows95.com', este nombre de dominio fue inscrito por un estudiante universitario en Utah. La intención por parte de éste estudiante era vender el nombre o poner entre la espada y la pared a la entidad (quien tiene un interés legítimo sobre dicho nombre) que quiere registrar el nombre, ya sea una marca o nombre comercial, como nombre de dominio, y solicitar una suma de dinero por la liberalización de dicho nombre en el Internet.

Otro ejemplo es el caso de Mcdonals, nombre que fue inscrito por un periodista 'el señor Quittner' en 1994 quien registró el nombre de dominio www.mcdonalds.com. Para asegurarse, el uso del nombre de dominio, después de largas discusiones y de muchas negociaciones, la compañía Mcdonals se vio obligada a hacer una donación de equipo de computación a una escuela de primaria a cambio de la liberación del nombre de dominio www.mcdonalds.com.

Las personas que llevan a cabo estas actividades, se conocen con el nombre de 'cyber-squatter' o ciberocupación u ocupación ilegal del espacio cibernético, hecho que ha sido universalmente condenado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en su Informe Final relativo a los Nombres de Dominio en Internet.[5]

Una segunda forma, en que surgen los conflictos entre nombres de dominio y derechos de marca son los casos en los que terceros inscriben marcas, como nombres de dominio para llevar a cabo sus propios negocios, e impedir que el verdadero titular de la marca o nombre comercial utilice su nombre como nombre de dominio en el Internet. Por lo tanto, los visitantes de estas páginas WEB, se ven sorprendidos al encontrar que en estos sitios se están anunciando bienes o servicios distintos a los que normalmente están asociados con la marca que ellos conocen y entienden.

Y por si fuera poco, otra manera en la que surgen conflictos entre marcas y nombres de dominio se da cuando una compañía inscribe el nombre de dominio de su competencia, con el objeto que esta última no pueda hacer uso del dominio en el Internet. Un ejemplo de estos casos fue el de, Teubner & Associates, empresa de alta tecnología. Un oponente en la competencia de Teubner inscribió el nombre de 'tuebner.com' que es una alteración en la escritura normal de la palabra Teubener. Después de arduas negociaciones, Teubner & Associates, logró obtener el nombre 'tuebner.com'.

En tercer lugar, los conflictos pueden surgir también de algunos registros de nombres de dominio inocentes. Este caso se da cuando existe buena fe o con un interés legítimo por parte de quien registró el nombre de dominio que coincide con el nombre de una marca de un tercero.

Existen muchas historias con relación al conflicto entre nombres de dominio y derechos de marcas, la mayor parte de éstas son casos que han conocido las Cortes de los Unidos de América, del Reino Unido y de algunos países de la Unión Europea en los que han surgido este tipo de casos, se han invocado la protección a los derechos de marca, sin que necesariamente haya lugar a esa protección. También se han dado casos en los que las Cortes han tenido que profundizar sobre la naturaleza del Internet y del Sistema de Nombres de Dominio sea para dar una protección efectiva a los derechos legítimos de propiedad intelectual que pueda tener una persona sobre un nombre de dominio o para amparar a un titular de marca que ha sido víctima de infracciones o se le ha impedido registrar su marca ante el órgano de registro de nombres de dominio en el Internet.

En Estados Unidos los aspectos generales de derechos de marca que entran en la discusión son dos: a) La confusión y b) la dilución de la marca.

a- La confusión en el Derecho de Marcas

El derecho de marca ha sido definido en los Estados Unidos por el Lanham Act de 1984, como 'cualquier nombre, símbolo o recurso o cualquier combinación que se utiliza o se intenta utilizar para identificar el origen de los productos'. El punto clave para respon-

5 Puede acceder a éste documento en la siguiente dirección en Internet: http://wipo2.wipo.int

sabilizar a alguien por medio de una demanda, con base a esta norma es la confusión.

El caso que a continuación se cita es un caso de marcas y no de nombres de dominio, que nos ilustra forma en que se puede dar confusión entre marcas. El caso es el de Wagamama Limited v City Centre Restaurants plc and others. Wagamama es propietaria de la marca Wagamama que fue registrada para los restaurantes. City Centre Restaurants decidió abrir un restaurante con el nombre de Rajamama. En este caso Wagamama demandó a City Centre Restaurants por infracción de la marca, en el juicio la mayor parte de la discusión se dio en torno a la frase 'probabilidad de asociación'. La Corte decidió en este caso, que sí podía darse confusión en la mente del público, ya que la gente creería que los restaurantes con el nombre RAJAMAMA estaban conectados de alguna forma con WAGAMAMA.

Este principio también ha sido invocado en los conflictos entre marcas y nombres de dominio en el Internet.

b- La teoría de la dilución de la Marca

El segundo aspecto que ha sido muy discutido ante las cortes nacionales y federales de los Estados Unidos, en los casos de nombres de dominio, es la dilución de la marca. La doctrina de la anti-dilución persigue proteger al titular de la marca en contra de un uso ilegítimo, en aquellos casos en los que no hay confusión. Esta doctrina no tiene por objeto proteger las ideas del origen del producto o servicio, pero si la calidad que la marca protege. Por dilución se entiende: 'El cercenamiento gradual de una marca utilizando otra para identificar productos idénticos o similares a los que la marca notoria ampara con el objeto de que ésta pierda su originalidad y carácter distintivo'.[6] Por ejemplo, si la marca Rolls Royce que es conocida y asociada a carros de lujo y a la vez es utilizada para amparar llavines de mediana calidad, la calidad asociada con la marca 'Rolls Royce' puede verse afectada, a este hecho responde el principio general denominado 'la dilución de la marca'.

Un caso en el que se discutió la dilución de una marca es el caso Toeppen vrs Panavision.

Los hechos del caso en resumen fueron: que el señor Denis Toeppen registró el nombre de dominio Panavision.com en 1995. En mayo de 1996 Panavision Internacional inició una acción legal en contra del señor Denis Toeppen y Networksolutions ante la Corte del Distrito Central de California. El fundamento de la demanda fue: la dilución de la marca, la competencia desleal, el incumplimiento de contrato entre Denis Toeppen e Internic. El señor Toeppen ofreció a Panavision la cantidad de $13,000.00 por liberar el nombre de dominio.

Lo primero que argumentó el señor Denis Toeppen fue la falta de competencia de la Corte del Distrito Central de California, para conocer el asunto, ya que el demandado (Toeppen) tenía su domicilio en la ciudad de Pana Illinois. Sin embargo, la Corte del Distrito Central de California estableció que sí era competente para conocer el caso porque entre otros argumentos, uno de los actos objeto de la demanda o sea 'la oferta de venta' del nombre de dominio fue efectuada en California, domicilio del demandante 'Panavisión.Inc'

Una vez aclarada la competencia del juez, se entró a discutir el fondo del asunto, resolviendo a favor del Panavision International. El caso fue apelado ante la Corte de Apelaciones quien estableció que de acuerdo a la Ley Anti-dilución de Estados Unidos existen ciertos requisitos o criterios que debe tomar en consideración el juez para resolver si una marca puede o no ser protegida como marca famosa o notoriamente conocida. En este caso, el Juez resolvió que la marca Panavision cumplía con la mayor parte de los requisitos que impone esta ley para darle el trato jurídico especial de marca famosa. Así mismo, el juez determinó que el intento de vender la marca a un precio determinado a cambio del nombre de dominio de Internet constituía *un uso comercial* de la marca por parte de Denis Toeppen. La Corte fue muy cuidadosa y no establecio una definicion de marca y de nombre de dominio, ni tampoco resolvió alguna diferencia entre éstas. La Corte principalmente se concentró en el uso de la marca por parte de Toeppen. Entre otras compensaciones, la Corte obligó a Toeppen a trasladar el nombre de dominio www.panavisión.com a favor de la compañía Panavi-

6 J. Otamendi

sion. Inc., y tiene prohibido efectuar cualquier uso del nombre 'Panavision'.

Un poco más amplia, fue la sentencia del caso, Intermatic v Dennis Toeppen, en el que el mismo demandado Denis Toeppen registró el nombre 'Intermatic.com'. En este caso la Corte otorgó a Intermatic el derecho de un juicio sumario de DILUCIÓN DE LA MARCA, porque las acciones de Toeppen impedían que una marca famosa como Intermatic pudiera identificar los bienes o servicios que apara en el Internet. Se estableció que la marca Intermatic era una marca famosa a la luz de la definición que establece la ley federal de Dilución de las Marcas de 1995; Toeppen hizo un uso comercial de la marca, evidencia de esto es la intención de vender el nombre de dominio 'Intermatic.com'; y que el uso del nombre en conexión con el Internet constituye 'comercio' bajo las normas de esta ley.

El intento de vender la marca, por parte de Toeppen fue considerado por la Corte como causal de la dilución del poder distintivo de la marca, impidiendo que Intermatic pudiera identificar sus bienes y servicios a través del Internet, destruyendo el valor distintivo de la marca. En este caso, 'el uso comercial de la marca', se encuentra precisamente en el hecho de la intención de liberar el nombre de dominio a cambio de un precio.

Las Cortes tanto Estatales como Federales que han conocido de casos de conflictos entre marcas y nombres de dominio en Estados Unidos se han pronunciado a favor de los derechos de marca y han tenido mucho cuidado en no definir como sinónimos 'nombres de dominio y derechos de marcas'. Las Cortes también se han limitado en establecer si el responsable del nombre de dominio tiene un interés legítimo y no han entrado a discutir los derechos de marca que puedan generarse del registro de un nombre de dominio. La legislación de Estados Unidos muestra un grado superior de desarrollo, sobre todo en el área de protección de las marcas notorias y famosas. Este aspecto ha contribuido a que las Cortes protejan a toda costa una marca frente a cualquier uso que se le pueda dar, sea en el territorio nacional o en el espacio cibernético.[7]

De los casos más recientes podemos citar es el que se presentó en diciembre de 1999 ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) fue el del nombre de dominio: www.worldwrestlingfederation.com. El caso fue resuelto por un panel administrativo de expertos de acuerdo al Reglamento y la Política de Solución de Controversias especial para el registro abusivo de nombres de dominio en el Internet.

Las partes involucradas en este caso fueron: WORLD WRESTLING FEDERATION ENTERTAINMENT, Inc (como demandante y titular de la marca) y Michael Bosman (como demandado) Case Nº D99-001.

El nombre de dominio de Internet objeto del Proceso Administrativo de Solución de Controversias especial para el registro abusivo de nombres de dominio fue www.worldwrestlingfederation.com el cual fue registrado ante el Órgano de Registro MELBOURNE IT la cual tiene su sede en Australia. El Panel Administrativo resolvió de acuerdo a las siguientes pruebas presentadas en el Proceso Administrativo: Registro de Marca WORLD WRESTLING FEDERATION como marca de servicios, en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, cuyo plazo es de 20 años contados a partir del 29 de enero de 1985 y el registro de la marca WORLD WRESTLING FEDERATION, cuyo plazo es de 20 años contados a partir del 7 de noviembre de 1989. Correspondencia electrónica entre el demandante y el demandado en la que se solicita al demandante una cantidad de dinero por la liberación del nombre de dominio.

Michael Bosman tenía por objeto vender el nombre de dominio al titular de la marca, lo cual se presentó como evidencia de su mala fe en la posesión del nombre de dominio. Así mismo el demandado nunca desarrolló un sitio Web en el nombre de dominio o tuvo un legítimo interés en el mismo. Adicionalmente, el demandado no se presentó ante el Panel Administrativo y por ende el Panel resolvió de acuerdo a las pruebas presentadas, a la Política y el reglamento de Solución de Controversias especial para el

7 La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual mediante su comité permanente de marcas, dibujos y modelos industriales e Indicaciones Geográficas recientemente ha publicado los criterios y requisitos que debe cumplir una marca para que pueda ser concebida como una marca notoriamente conocida. Estos requisitos pueden servir de guía para los jueces, árbitros y abogados en general.

registro abusivo de nombres de dominio en los siguientes términos:

a- Que el nombre de dominio registrado era idéntico o confusamente similar a una marca de bienes o servicios en la que el demandante tiene algún derecho.
b- Que el demandado no tiene un interés legítimo en relación con el nombre de dominio.
c- Que el nombre de dominio ha sido registrado y utilizado de mala fe.

El Panel solicitó que el registro del nombre de dominio worldwrestlingfederation.com sca transferido al demandante (titular de la marca).[8]

En el proceso propuesto por la OMPI y adoptado por la ICANN se conserva el derecho de las partes a acudir a las cortes nacionales, por lo que será posible un recurso ante alguna corte nacional que tenga jurisdicción en este caso.

3- Factores que han contribuido al incremento de los conflictos entre los Derechos de Marca y el registro de Nombres de Dominio en Internet

Existen una serie de factores que han llevado al sistema de nombres de dominio en oposición con el derecho de marcas. Se ha discutido que un nombre de dominio puede funcionar como una marca, y por lo tanto cualquier uso de un nombre de dominio por una persona que no sea titular del derecho de marca, incurre en una infracción. Sin embargo, esto no es del todo correcto, un nombre de dominio es y seguirá siendo una dirección electrónica en el Internet y por ende no confiere derechos de ninguna naturaleza sobre el nombre.

Se ha considerado como un factor importante, el hecho de que en el mismo sistema de nombres de dominio en el Internet, existen dos dominios de nivel superior que se administran por entidades distintas en forma paralela: El dominio de nivel Superior genérico (gTLD) y el dominio de nivel superior correspondiente al código de cada país (ccTLD) lo que permite que un mismo nombre de dominio pueda ser registrado varias veces. De todos los dominios de nivel alto, en el que más conflictos han surgido es dominio de nivel superior genérico '.COM'. Esto se debe a varias razones, entre las cuales mencionamos las siguientes: en primer lugar, es uno de los dominios de nivel superior genérico, con más trayectoria, ya que estuvo presente desde los orígenes del sistema de nombres de dominio; en segundo lugar, el genérico resulta más fácil de identificar porque se pueden utilizar únicamente dos nombres por ejemplo 'hotmail.-com', 'panavision.com' o 'harrods.com' esto hace que la dirección sea fácil e instantáneamente reconocible. Al contrario, en un nivel superior correspondiente al código de cada país el ejemplo se volvería 'hotmail.-com.gt' (para Guatemala) o 'harrods.com.gt'. En tercer lugar, el '.COM' puede ser identificador de organizaciones o individuos que llevan a cabo actividades comerciales. Por esta razón el '.COM' se ha convertido en una dirección 'atractiva' para todas aquellas organizaciones comerciales que tienen como objetivo establecer presencia comercial en el Internet mediante un sitio WEB; y finalmente, como el '.COM' tiene una connotación internacional, no limita a una región específica.

El registro de nombres de dominio bajo los dominios de niveles superiores genéricos.com,.net y.org se han vuelto una verdadera carrera. Las empresas se están apresurando en registrar todas sus marcas, nombres comerciales y signos distintivos, e incluso también sobre los dominios de nivel superior correspondientes al código de cada país ccTLD para evitar que terceros los registren antes que éstas. Ya que también los registros de nombres de dominio bajo el dominio de nivel superior correspondiente a cada país (ccTLD) han demostrado proporcionar muchas ventajas, entre éstas la mas importante, es la posible ubicación geográfica de los comerciantes, empresarios, asociaciones (con fines lucrativos o no lucrativos) personas individuales, etc., en el Internet.

Otro factor que ha contribuido a que proliferen las controversias, ha sido el desarrollo de los buscadores y motores de búsquedas que han hecho de las búsquedas (valga la redundancia) en el Internet, algo relativamente sencillo. Casi todos los 'browsers' o

8 La base jurídica del Proceso Administrativo de Solucion de Controversias ha sido ampliamente discutida y desarrollada en el INFORME FINAL DE LA OMPI, documento al cual puede acceder en la siguiente pagina web: http://wipo2.wipo.int

buscadores permiten a un cibernauta[9] encontrar una compañía únicamente tecleando el nombre. Si utiliza el sistema de Netscape o de Explorer (N), sólo tendrá que teclear 'apple' para que el sistema lo ubique con la página 'http://www.apple.com', para dirigir al cibernauta directamente al sitio web de computadoras APPLE. Antes, cuando estos sistemas, aún no estaban tan desarrollados era un poco más complicado navegar atravez del Internet. Los motores debúsqueda tales como: Yahoo!, Alta Vista e Infoseek han simplificado la tarea del cibernauta, ya que permiten encontrar un sitio, utilizando únicamente una palabra clave, numerosas veces, esta palabra es utilizada como parte de una marca de un negocio

4- El rol del sistema de Nombres de Dominio en el conflicto entre Marcas y Nombres de Dominio en el Internet

4.1 La actual administración del sistema de nombres de dominio en Internet. Inernic y los Centros de Información de Redes (Políticas y Regulaciones)

Actualmente la organización que está a la cabeza del sistema de nombres de dominio es la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) y la cual quedará encargada de la organización y administración del sistema de nombres de dominio. A los inicios del Internet el sistema de nombres de dominio se organizó con la Internet Assigned Numbers Authority(IANA) bajo la autorización del gobierno de los Estados Unidos de América y la Sociedad Internet (ISOC) y fue fundada por la NSF (National Science Fundation). IANA hizo la distribución de bloques de números IP que son administrados por Network Solutions Inc. (NSI), que tiene sobre todo autoridad para asignar direcciones IP, nombres de dominio y otros parámetros del Internet, de los Dominios de Nivel Superior Genérico (gTLD) excepto de los Dominios de Nivel Superior correspondientes al Código de País (ccTLD) cuya independencia es institucional y reglamentaria, siempre y cuando cumplan con los principios generales del sistema de nombres de dominio que son. 'Primero en tiempo, primero en ser servido' y Transparencia y equidad en el registro y administración de nombres de dominio-.

La función de registrar nombres de dominio del nivel superior genérico ha sido delegada de NSI a InterNic

Esta delegación incluye las siguientes normas que los órganos de registro deben cumplir:

* El nombre de dominio se inscribe sobre la base de primero en tiempo, primero en servicio. *No hay ninguna investigación en la que se determina si un solicitante está facultado de alguna forma a utilizar el nombre que pretende inscribir como nombre de dominio*
* Si una tercera parte reclama tener derechos sobre el nombre, ya sea de marca o cualquier otro signo distintivo o nombre comercial, deberá contactar al TITULAR DEL NOMBRE DE DOMINIO. El titular de la marca deberá mostrar a Internic una copia del certificado de la marca, extendido por la autoridad competente, correspondiente al nombre que será objeto de disputa.
* En los casos en los que un nombre de dominio ha sido registrado antes que el registro de la marca, el titular del nombre de dominio tendrá el derecho de utilizar el nombre de dominio pendiente a que se resuelva la controversia; si el registro del nombre de dominio fue hecho después del registro de la marca, entonces el titular del nombre de dominio deberá entregar el nombre de dominio al titular de la marca. El titular del nombre de dominio debe indemnizar a Internic por concepto de daños y perjuicios derivados del conflicto.

Los efectos de estas regulaciones:

* El primero en tiempo, primero en servicio:
  Esta norma ha dado lugar a que personas con el objeto de aprovechamiento, inscriban marcas como nombres de dominio, con el objeto de venderlo al titular de la marca.
* La verificación de la titularidad de la marca mediante la CERTIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LA MARCA:

9 Persona que utiliza el Internet con mucha frecuencia, y que 'navega' en él, llevando a cabo búsquedas de información y recursos. Así mismo es la persona que comparte y comunica ideas, por medios digitales a través del Internet.

Una marca registrada de cualquier autoridad es suficiente para Internic como prueba de la titularidad de la marca. Esto también ha dado lugar a conflictos, porque el titular de un nombre de dominio que no tiene inscrita la marca 'de ese nombre', puede obtener rápidamente y con mucha facilidad el registro de esa marca. Un ejemplo de estos casos es el de Road Runner Computer Systems, quienes ofrecen servicios de Internet. En diciembre de 1995, la Compañía Warner Bros, titular de la marca 'Road Runner' demandó a Internic por el registro y uso de la marca Roadrunner.com por la compañía de computadoras. En este caso Internic informó a Road Runner Computer Systems, que pondría en suspensión el nombre de dominio. Road Runner solicitó el registro de la Marca en Tunissia y lo obtuvo rápidamente. De cualquier manera Internic se resistió a que esta compañía siguiera utilizando el nombre de dominio.

Esta política de solución de controversias tuvo este fallo en particular, ya que ignora los derechos de marcas 'no registradas' que pueda tener legítimamente un particular.

Las bases en las que se sustenta esta política de solución de controversias encontraron muchos obstáculos. Por esta razón la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha venido desarrollando un proceso de Consultas para diseñar algunas medidas y en especial establecer un Sistema Especial de Solución de Controversias para los conflictos entre marcas y nombres de dominio en el Internet el cual responde a las necesidades tanto de los titulares de marcas como de los titulares de nombres de dominio y el órgano de registro. Así como el planteamiento de nuevas prácticas y contratos para los Centros de Información de Redes u Órganos de Registros, que al implementarse pueden servir para prevenir los posibles conflictos entre marcas y nombres de dominio.

Las reglas de Internic regulan el registro de los Nombres de Dominio que se registran bajo el Dominio de Nivel Superior Genérico (gTLD). Sin embargo los Centros de Información de Redes (entidades que administran el dominio de nivel superior correspondiente a cada país (ccTLD) han adoptado algunas de las normas de IANA como son: 'primero en tiempo, primero en ser servido' (no se pueden registrar dos nombres de dominio idénticos) y transparencia y equidad en el registro de nombres de dominio. Sin embargo, es importante que los Centros de Información de Redes u Órganos de Registro de la región adopten algunas medidas para evitar los conflictos entre marcas y nombres de dominio.

4.2 Las propuestas para prevenir el conflicto entre marcas y nombres de dominio en el Internet

En el proceso de Consultas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, concluido con el Reporte Final[10] se recogen los aspectos más importantes para resolver los conflictos entre nombres de dominio y derechos de marca, que son:

Las prácticas y contratos de los Centros de Información de Redes u Órganos de Registro.
Los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos y su rol en el conflicto de Nombres de Dominio y Derechos de Propiedad Intelectual
El mecanismo de exclusión a favor de marcas famosas o notorias como nombres de dominio.

Durante el proceso de la OMPI, los titulares de marcas manifestaron su preocupación y sobre todo hicieron de conocimiento público información sobre los gastos en los que han incurrido, al litigar ante las cortes nacionales este tipo de controversia. Y que el costo de hacer valer sus derechos ante los tribunales nacionales puede resultar muy elevado tanto en tiempo como en dinero. Con el posible riesgo, de que al final, los tribunales nacionales no protejan eficientemente, los derechos de propiedad intelectual sobre las marcas.

Al adoptar estas medidas los Órganos dos de Registro de nombres de dominio en Internet, evitarán conflictos entre marcas y nombres de dominio y al mismo tiempo se establecerán los mecanismos adecuados para solucionar las controversias cuando surjan.[11]

10 Puede acceder a este documento en la siguiente dirección en Internet: http://wipo2.wipo.int

11 Todas las medidas han sido adoptadas y aprobadas por el Sistema de Nombres de Dominio y las instituciones principales IANA Y EL ICANN.

Conclusiones

1- Que debido al creciente uso comercial del Internet, el registro de nombres de dominio ha adquirido cada vez más, un valor comercial. En el conflicto entre nombres de dominio y derechos de propiedad intelectual pueden darse dos variantes:

   a- Los registros de nombres de marcas y nombres comerciales como nombres de dominio en el Internet ante el dominio de nivel superior genérico (Gtld) o del dominio de nivel superior correspondiente al código de cada país (ccTLD) por parte de personas que no tienen un interés legítimo o un justo título para utilizar este nombre en el Internet y que intentan vender el nombre de dominio al titular de la marca o impedir la presencia comercial de la persona o empresa titular de la marca en el Internet (cybersquatting).

   b- La protección de algunos nombres de dominio por el derecho de propiedad intelectual o derecho de marcas, por resultar ya valiosos y distintivos en todo ámbito, por ejemplo www.-yahoo.com.

2- Que el registro de nombres de dominio en el Internet ha dado lugar a una práctica que popularmente ha sido denominada 'cybersquatting' (ocupación ilegal del espacio cibernético) que ha sido universalmente condenada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en su informe final relativo al Proceso de Nombres de Dominio en el Internet. Dicha práctica consiste en registrar nombres de dominio con cualquiera de los siguientes objetivos:

   a- Obtener una ganancia por parte del titular de la marca, por la liberalización del nombre de dominio.

   b- Impedir que el titular de la marca, la registre como nombre de dominio e impedir que éste tenga una presencia comercial en el Internet.

   c- Comercializar bienes y servicios en el Internet utilizando la marca de un tercero, creando confusión en el público o en los consumidores.

3- Que los jueces, en especial en Estados Unidos de América, han encontrado algunas dificultades jurídicas al adaptar el derecho de marcas 'nacional' al registro de nombres de dominio en el Internet que una vez en línea proporcionan una presencia mundial. Y pese a estas dificultades los jueces han logrado proteger efectivamente el derecho de marcas frente a los registros 'abusivos' de nombres de dominio en el Internet sin intervenir o provocar obstáculos al sistema de nombres de dominio, el cual es indispensable para el desarrollo del Internet.

4- Que es mejor prevenir los conflictos entre marcas y nombres de dominio en el Internet que enfrentar dichos casos ante los jueces nacionales, mediante medidas que tiendan a evitar dichos conflictos o ya una vez surgido el conflicto éste pueda ser manejado de una forma eficiente y correcta.

5- Que los órganos de registro de nombres de dominio del dominio de nivel superior genérico (g TLD) y los del dominio de nivel superior correspondiente al código de cada país (ccTLD) tienen un rol muy importante al prevenir estos conflictos, como son la adopción de contratos, políticas y métodos alternativos de solución de controversias especiales para los conflictos que surgen de sus registros y de las marcas.

Bibliografía

Otamendi, Jorge
Derechos de Marcas. Buenos Aires, Argentina: Obeldo-Perrot.

Filosofia

MILTON ESTUARDO ARGUETA PINTO[1]

Adiós muchachos (Y no olviden la lección)[2]

Sumario

1- 'Muchá ¡cayó Somoza!'
2- Junta de Gobierno de *reconstrucción* nacional
3- De vuelta a la tribu
4- Racionalismo ¿irracional?: Catedrales en la selva
5- ¿Quiere un buen consejo?
6- El diablo predica pero no se convierte
7- Y no olviden la lección
Bibliografía

'En los recuentos de los acontecimientos que hoy se hacen del siglo XX, falta la revolución sandinista. Porque se pasmó y no cambió en fin de cuentas la historia, como nosotros creíamos que iba a cambiarla, o porque hoy parece a muchos que no valió la pena, un empeño que quedó en una gran frustración y un formidable desencanto'.[3]

1- 'Muchá ¡cayó Somoza!'

La tarde del 19 de julio de 1979, el profesor de Religión entró apresuradamente a mi clase y a manera de saludo nos dijo *'Muchá ¡cayó Somoza!'*. Yo estaba en cuarto año de bachillerato. Y así era; la noticia de mayor cobertura ese día en Guatemala, y quizás en buena parte de América, era que los sandinistas habían entrado triunfalmente en Managua, la capital de Nicaragua. Tal vez el profesor de Religión ignoraba que Anastasio Somoza había abandonado el país dos días antes y que quien en verdad caía ese día era el Presidente que había dejado Somoza al partir, Francisco Urcuyo; o quizás sí lo sabía y su eufórica expresión era para referirse al régimen que en ese día llegaba a su fin. Sea como fuere, esa exclamación causó un gran impacto en mí, tan grande que después de una veintena de años aún la recuerdo. Y recuerdo también que en gran medida, esa impresión era causada por algo que en ese momento no alcanzaba a comprender: la extraña alianza entre guerrilleros y religiosos.[4] Años más tarde aprendería que esa alianza se debía ala falacia intencionalista, que por cierto, aún existe en nuestros días.[5]

Los sandinistas gobernarían Nicaragua por espacio de casi once años; desde el 19 de julio de 1979 hasta el 25 de abril de 1990, cuando habiendo sido inesperadamente derrotados en las elecciones de principios de ese año, entregan el poder a Violeta Chamorro. Un poco más de una década de gobierno sandinista fue suficiente para sumir a Nicaragua en un estado mayor de pobreza y atraso. Suficiente un indicador: Nicaragua entró en un ciclo de hiperinflación y la tasa de cambio llegó a ser de cincuenta y

1 Doctor en Derecho. Decano de la Facultad de Derecho en la Universidad Francisco Marroquín.

2 Ensayo ganador del Concurso 'Charles L. Stillman' 2000.

3 S. Ramírez, 1999:14.

4 Valga un comentario: estudiando en un colegio católico, la semana siguiente a la Semana Santa de ese año, asistí a una celebración juvenil de la Pascua a otro colegio católico. Ahí estaban reunidos estudiantes de distintos centros educativos de corte religioso. En una de las actividades llevadas a cabo en el gimnasio, una monja pedía constantemente aplausos para 'nuestros hermanos sandinistas'. Y luego cantaba el coro de aquella canción 'El Cristo de Palacaguina' cambiándole la letra para decir respecto de María: 'y ella va a lavar muy humildemente, la ropa que goza la mujer hermosa del perro Somoza'.

5 Ver 'Las Condiciones del Diálogo y otros ensayos' del Dr. Rigoberto Juárez Paz.

dos mil Córdovas por un Dólar de los Estados Unidos de América. Veinte años después, el que fuera el Vicepresidente del gobierno sandinista, Sergio Ramírez publica el libro llamado *'Adiós muchachos. Una memoria de la revolución sandinista'*. Leo un comentario promocional del libro en un periódico guatemalteco y me llama la atención que en la entrevista, el autor reconoce el fracaso de la revolución sandinista. Por supuesto, el reconocimiento es atenuado por relatos que resaltan el heroísmo de combates y operaciones y por la justificación de la revolución en virtud de los ideales que perseguía. Leer un libro crítico del experimento sandinista, escrito por un importante sandinista me resulta atractivo, así que lo compro y lo leo. ¡Cuánta frustración y desencanto transmiten sus primeras páginas! Aunque no con esas palabras, el mensaje en ellas es *'Tuvimos la oportunidad de hacer algo y fracasamos'*. La cita con la que comienza este ensayo es más que elocuente y se encuentra, precisamente, en las primeras páginas de ese libro. Coincidentemente, hoy que he comenzado a escribir estas páginas, he leído en un matutino que los sandinistas celebran el vigésimo primer aniversario de la revolución y que se preparan para recuperar el poder, ésta vez a través de las urnas, en las próximas elecciones. Y otra vez vuelvo a sentir lo que sentí aquella tarde de julio del 79: desconfianza y preocupación por el futuro. Es necesario mencionar que hace veinte años, esa sensación era producida por la incertidumbre de lo que sería *'el nuevo orden'* en Centro América y lo que esto podía significar para mi país. Hoy, esa sensación es producida por la certeza del fracaso de una nueva gestión sandinista si la hubiere y por que ello evidenciaría que a pesar de la experiencia, la oratoria plagada de falacias intencionalistas aún hace mella en el elector (nuestro propio caso es un buen ejemplo de ello), o sea que, a pesar de la experiencia, la lección no se aprendió.

Al leer *'Adiós muchachos'* es imposible dejar de pensar en la Fatal Arrogancia, escrita por Hayek[6] casi a los noventa años de edad. Y es que el reconocimiento reiterado que Ramírez hace de los errores sandinistas resulta explicable y comprensible a la luz de la arrogancia racionalista característica del socialismo. Y ante la arrogancia sandinista de querer *volver* aún y *'con la frente marchita'* no precisamente por las *'nieves del tiempo'* sino por el estrenduoso fracaso de su gestión, no puede dejar de comentarse este libro que seguramente de ser leído por aquél profesor de Religión, lo harían regresar veinte años atrás y analizar su comentario eufórico de aquella tarde desde otra perspectiva: la de la evidencia del fracaso del modelo socialista.

2- Junta de Gobierno de *reconstrucción* nacional

'La revolución nunca podría ir por etapas, debía quemarlas todas y cumplir con su ambición de modernidad'[7]

Un día antes que los sandinistas entraran a Managua, la mañana del 18 de julio de 1979, el cuerpo colegiado que ejercería el poder público en Nicaragua hasta el 10 de enero de 1985, fue juramentado en el paraninfo de la Universidad de León, conociéndosele desde ese momento como la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. El nombre que tomó ese grupo que concentró prácticamente todas las funciones públicas incluye la palabra que determinaba su objetivo y en función del cual gobernarían, tomando una serie de medidas cuyos resultados sí situaron muy lejos de lo que presumiblemente fue la intención de los gobernantes al momento de tomarlas. La Junta de Gobierno era de *reconstrucción* nacional y como lo evidencia la cita tomada del libro que se comenta en este ensayo, implicaba un ejercicio racional, deliberado, tendiente a diseñar e implementar las soluciones que según el criterio de la Junta, debían de llevarse a cabo para construir un nuevo orden en Nicaragua. Más que elocuente el comentario del expresidente sandinista:

'Fue una formidable ironía que desde la majestad del gobierno revolucionario no tardáramos en imitar aquellas medidas que entonces veíamos con comprensión piadosa y causaban no poca risa, porque eran parte del universo de inocencia donde las leyes de la oferta y la demanda habían perdido todo su

6 F.A. Hayek, s.f.
7 S. Ramírez, 1999:238.

poder, derrotadas por un sentido primitivo de la justicia'.[8]

Quizás de todas las declaraciones que hace el autor en su libro, ésta y otra que comentaré más adelante, hayan sido las que más me impactaron. Respecto a ésta, la razón de su trascendencia es que contiene la raíz o esencia, como quiera llamársele, del estruendoso fracaso de la revolución y posterior gobierno sandinista. Comencemos por desmenuzar el texto: para principiar, evidentemente se trataba de un gobierno con poder absoluto ('desde la majestad del gobierno revolucionario') y que lo usó a su arbitrio para tomar las decisiones que, según sus detentadores, eran las correctas para crear un nuevo orden social justo *('por un sentido primitivo de la justicia)*. Es conveniente ubicar al lector de este ensayo en el contexto en que esta cita aparece en el libro: en el párrafo anterior, el autor cuenta que como miembro de la Junta, le tocaba realizar viajes para resolver conflictos como *'oidor de un poder central que apenas comenzaba a definirse'*[9] conflictos que se daban por las medidas tomadas por grupos guerrilleros que habían fincado sus dominios en determinadas áreas. Más adelante, inmediatamente después de la cita, sigue comentando algunas de esas medidas tomadas por la Junta y que *'formaban parte del universo de inocencia'* tales como la aprobación de un decreto que rebajaba a la mitad la jornada de trabajo en el campo, otro que fijaba precios topes y quizás el más absurdo, el que ordenó el decomiso de productos campesinos que se encontraran en carreteras a Managua si no eran vendidos a las agencias estatales. En segundo lugar, vemos que como el autor dice, la motivación de estas medidas fue un sentido primitivo de justicia. Y en tercer lugar, usando como escudo la *inocencia*, las leyes del mercado fueron totalmente marginadas. En todo ello hay un común denominador: la Junta confió toda su actuación a la razón y usándola como cimiento, pensó en *reconstruir* el orden social: la razón usada para solucionar conflictos, para fijar precios, para decidir en dónde debían venderse los bienes, en fin, usada para diseñar la vida de todas las personas que formaban parte de ese orden social, quitándoles todo su poder de decisión y escogencia, substituyéndoles sus fines por aquellos que el gobierno revolucionario consideraba como los que debían alcanzarse. Como escribe el exgobernante sandinista: *'todo en nombre de un bien común de mecanismos imposibles'*.[10] Y era de esperarse que esto pasara. En efecto, como Hayek dice:

> *'La meta socialista no es otra que la radical reconstrucción tanto de la moral tradicional como del derecho y el lenguaje, para así acabar con el orden existente y sus presuntamente inexorables e injustas condiciones, que nos impiden acceder al imperio de la razón, la felicidad y la verdadera libertad y justicia'*.[11]

Esta cita requiere de un comentario. El racionalismo es una doctrina filosófica cuyo fundamento es la 'omnipotencia e independencia'[12] de la razón humana. Según la Teoría del Conocimiento, la razón y no la experiencia es la base del conocimiento (a priori). De esta forma, la razón resulta infalible y suficiente para conocer. De acuerdo con el pensamiento de Hayek contenido en varias de sus obras tales como *'Derecho, Legislación y Libertad, Volúmenes I y II'*, *'Camino a la servidumbre'* y por supuesto, *'La fatal arrogancia'*, la base del socialismo es precisamente el racionalismo. Aunque las obras citadas sólo hacen referencia al socialismo, pienso que otros *'ismos'* también comparten la misma base: nazismo, facismo y por supuesto, el comunismo. Es esa omnisciencia, infalibilidad y suficiencia de la razón la que sirve de base al socialismo para pretender diseñar y construir un orden social. Es a esto lo que Hayek llama en sus obras *'racionalismo constructivista'*. En palabras de Hayek:

> *'Bajo la influencia de Descartes, este moderno racionalismo no sólo desecha la tradición, sino que no duda incluso en afirmar que la razón esta en condiciones de perseguir directamente cualquier meta sin necesidad de intermediaciones, así como que, con*

8 S. Ramírez, 1999:73.
9 S. Ramírez, 1999:72.
10 S. Ramírez, 1999: 73.
11 F.A. Hayek, s.f.: 119.
12 Diccionario, 1953: Vol VIII.

autonomía plena, puede crearse, sobre la base de la razón, un mundo nuevo, una nueva moral, un nuevo orden legal y hasta un nuevo y más adecuado lenguaje'.[13]

En este experimento de crear un orden social, hay una aplicación del método científico de las ciencias naturales a las ciencias sociales. El gobierno sandinista, de corte y fundamento socialista, era también partícipe de esa base racionalista. Sin embargo, como lo demuestran reiteradamente esos experimentos de ingeniería social, resulta que la razón no ha sido suficiente para crear ese nuevo orden social. La razón habría sido suficiente para entender[14] el funcionamiento de un orden social sencillo o cerrado; un orden social en el que su sencillez hacía posible que las personas persiguieran fines comunes y esos fines fueran fácilmente identificables por quien detentaba la autoridad dentro del grupo y que una vez identificados, los considerara como buenos y válidos para todos y que por lo tanto, guiara la actuación del grupo, a través de sus mandatos, al logro de esos fines. Un orden social que por su sencillez, permitiera al que gobernaba el grupo, conocer toda la información necesaria para dictar sus mandatos en aras del logro de esos fines. Y un orden social que por su sencillez, hiciera que a la larga, ese fin común no fuera otro que la supervivencia del grupo, debiendo darse a cada uno de los miembros lo que merecía para sobrevivir, según su contribución al conglomerado, a juicio del jefe del grupo. Sin embargo, este esquema no resulta aplicable al caso de órdenes sociales complejos o sociedades abiertas, en donde las innumerables actuaciones humanas tendientes al logro de los fines personales de sus actores entretejen igualmente innumerables relaciones humanas. Ya no cabe hablar de fines comunes, ni de asignación de recursos por mérito ni de una autoridad poseedora de todo el conocimiento necesario para dirigir cada una de esas actuaciones personales y encaminarlas a determinado fin. El signo distintivo de este esquema social abierto es que el conocimiento se encuentra disperso y solamente asequible en mínima parte a cada persona, en función de su situación personal de tiempo y lugar. Y será ella, en función de ese conocimiento fraccionado, que sólo ella tiene y no los demás del conglomerado, la que decida si actúa o no, buscando el logro de sus propios fines. Como dice Hayek:

'La raíz más profunda del error cientista es, sin duda, su falsa suposición de poder justificar, proyectar y aprehender racionalmente la realidad'.[15]

Al final de esos experimentos de ingeniería social, resultó que la realidad sobrepasó la razón. Quizás lo que más preocupa a los racionalistas sea que en una sociedad abierta no puede ser que no exista una mente superior que en forma omnisciente dirija todo ese esfuerzo, ya que eso implicaría un caos, un desorden, una anarquía y eso obviamente es a todas luces irracional. Habría que responder que es cierto, no hay dirección sino más bien coordinación y que ésta tampoco es racional o deliberada, pensada y ejecutada por alguien, sino más bien espontánea, fruto de un proceso en el que los actores se relacionan unos con otros, conociendo sólo cada quien sus fines y motivaciones y sin embargo, colaborando con esa interacción y sin quererlo, con la satisfacción de los fines personales de los otros con los que se relacionan. Ese proceso que permite entender el funcionamiento de un orden social complejo es el mercado.[16]

Si el sandinismo compartió la base racionalista del socialismo, compartió también su error cientista. El experimento sandinista apostó por la razón y en ella fundamentó el tipo de decisiones propios de un orden social sencillo, cerrado y pasó por alto que se trataba más bien de un orden social complejo, imposible de percibir en su totalidad únicamente por la razón. Con la excusa de la inocencia, se desechó el proceso que hubiera podido coordinar los distintos esfuerzos individuales, al no dar cabida como dice el autor a las leyes de la oferta y la demanda. Y esas leyes fueron substituidas por los dictados de la razón.

13 F.A. Hayek, s.f.: 94.

14 Uso la palabra 'entender' porque considero que aún y cuando se trata de un orden social simple, éste no ha sido diseñado por nadie. Véase el comentario de Hayek respecto a la tribu (s.f.: 68).

15 F. Hayek, s.f.: 123.

16 'Anarquía ordenada' es el término usado por muchos para explicar la naturaleza del proceso de mercado. Por supuesto, para un racionalista, el término es por demás contradictorio, ilógico e irracional.

¿Y a qué condujo todo ello? A regresar a la tribu, muchos, muchísimos estadios atrás en el proceso de la evolución. Tarde, el autor reconoce que el experimento de *reconstrucción* fracasó:

> *'Cualesquiera que hubieran sido las fidelidades ideológicas, el proyecto de sociedad socialista fue siendo derrotado por la realidad desde el primer momento, y lo que dejó fueron sus marcas experimentales a lo largo del decenio, sobre todo las de la economía planificada, que jamás funcionó, pero llegó a crear terribles distorsiones'.*[17]

3- De vuelta a la tribu

> *'La revolución entendió al mundo campesino desde la lucha, pero no desde el poder'*[18]

El primer acto oficial de la reforma agraria sandinista fue la tarde del 18 de julio de 1979. Daniel Ortega entregó el primer título de propiedad en la finca 'La Máquina', cerca de León donde había sido juramentada la Junta de *Reconstrucción* esa mañana, a una improvisada cooperativa de campesinos. Mal comenzó la reforma agraria de la revolución, ya que como el expresidente lo reconoce, este tipo de propiedad comunal se volvería en el principal argumento en contra del gobierno sandinista y con el que *'la contra'*[19] ganaría como adeptos, a los antiguos colaboradores de la guerrilla. Es importante mencionar cuál fue la intención del gobierno sandinista en cuanto a distribuir la propiedad de la tierra en esa forma: según ellos, de esta manera evitarían que se formara una nueva clase *'pequeño-burguesa'*. El mecanismo de la reforma agraria sandinista implicaba agrupar a los campesinos en cooperativas; luego la tierra era dada en uso a la cooperativa, ya que la propiedad sería del Estado.[20] Era volver al esquema social tribal en donde todo era de todos... pero de nadie. A la postre, el campesino quedó igual que como estaba antes: sin nada propio. Ya envuelta en un conflicto armado enfrentando a *'la contra'* el gobierno sandinista decide modificar su política de reforma agraria y comienza entregar títulos de propiedad *individuales*, motivado por dos exigencias: la primera, los campesinos reacios a pertenecer a la cooperativa, o bien, los que aún conservaban la propiedad de pequeñas parcelas temerosos de que también les alcanzara la expropiación, pasaron a formar parte de la base de *'la contra'*; y en segundo lugar, como un argumento electoral. Es interesante mencionar que la primera vez que se intenta una corrección, se entregan títulos de propiedad *individuales* pero con la prohibición de vender y heredar, lo que como dice el autor, seguía siendo un contrasentido respecto del derecho de propiedad. Para 1990, el esquema había variado y ya venían entregándose títulos de propiedad plena, es decir, sin restricciones para vender o heredar, pero la grave situación económica hacía que los campesinos vendieran sus propiedades y ésta volviera a reconcentrarse. Aunque la situación se corrigió, el reconocimiento del error fue tardío. Esta cita de *'Adiós muchachos'* no puede dejar de mencionarse; ella evidencia el error cometido:

> *'El mensaje revolucionario, transmitido con persuasión deficiente, o bajo amenazas, o con demasiada retórica, imponía promesas, parámetros de conducta política y formas de organización muy ajenos a la realidad diaria de los campesinos que querían un cambio para bien en sus vidas, la tierra, las escuelas, las clínicas, buenos precios para sus cosechas, pero que no aceptaba la invasión de sus costumbres, sus maneras de ser y sus creencias. Miserables o no, la propuesta colectiva chocaba con su forma de ver la vida'.*[21]

Pero si la negación de la propiedad privada fue el primer error del gobierno sandinista, no fue el único. Amparado a la sombra de la excusa de la inocencia que quizás el autor del libro entiende como buena intención, el régimen promulgó una serie de leyes a través de las cuales ejerció un control absoluto sobre las personas y sus actos: el mismo mes en que entran en Managua, los sandinistas estatizaron el sistema

17 S. Ramírez, 1999:114.

18 S. Ramírez, 1999:229.

19 Nombre con el que se le conoció al movimiento armado contra revolucionario.

20 Al respecto escribe el autor de 'Adiós muchachos': 'Fue un error que hubo de costar sangre, porque la revolución, al violar la más sagrada de sus promesas, producía el primero de sus grandes desencantos'. (S. Ramírez, 1999:227).

21 S. Ramírez, 1999:231.

financiero y el comercio exterior, luego absorben el control de los recursos naturales, reducen el precio de los alquileres, se dictan precios tope, se regula el comercio interior sometiéndolo al control del Ministerio de Comercio, reduce el consume de combustibles, se expropian los bienes de personas que permanezcan más de seis meses fuera del país, etc. Estas leyes fueron el instrumento a través del cual se buscó el logro de objetivos determinados y particulares del gobierno sandinista. Las expectativas de las personas comunes y corrientes terminarían situándose en un plano diametralmente opuesto.

El gobierno sandinista también tenía su particular forma de asignación de recursos para la generación de riqueza: el jesuita Javier Xorostiaga, asesor del Ministerio de Planificación decía que para que el PIB creciera en 1981 un veinte por ciento, bastaba expropiar un veinte por ciento de empresas privadas. Así, en cada aniversario anual de la revolución, el gobierno anunciaba en la plaza pública el listado de las próximas empresas a ser estatizadas. Su argumento era que mientras más grande fuera el Estado y con más recursos contara, mayores beneficios se podrían trasladar a los pobres. Aunque el autor no lo diga con esas palabras, la asignación de recursos sandinista se basaba en la redistribución de la riqueza para satisfacer mediante la misma, las necesidades que el gobierno identificada y priorizaba. Con el gobierno sandinista, Nicaragua dejó de ser un orden social y pasó a ser una organización. La organización es el método de cooperación humana que permite alcanzar de mejor manera fines concretos.[22] Se basa en la implementación de un sistema jerárquico vertical que parte del jefe hacia los demás miembros del grupo. El jefe coordina los actos de los miembros del grupo a través de órdenes o mandatos, con la finalidad de lograr alcanzar un fin concreto, que el jefe ha identificado como beneficioso para el grupo, tal y como sucede en la sociedad tribal. Sin embargo, ese esquema resulta inútil cuando trata de aplicarse dentro de un orden social cuya complejidad excede lo simple de la tribu.

La gran sociedad, como un orden complejo, funciona de distinta manera. Se basa en el reconocimiento de algo real: no es posible conocer los fines de cada una de las personas que lo conforman ni tampoco es posible conocer toda la información que permita dirigir las actuaciones individuales hacia el logro de esos fines. Como dice Hayek respecto de estos órdenes:

> '*nadie conoce* -ni precisa conocer- *cuantos detalles afectan a los medios disponibles o a los fines perseguidos*'.[23]

La razón pues, tiene un límite el cual es desbordado por la realidad. Ya que el conocimiento en función del cual deben tomarse las decisiones para actuar persiguiendo determinados fines se encuentra disperso, tampoco resulta posible que una sola voluntad dirija y coordine cada actuación individual, es decir, no cabe hablar del *'miero-orden en el que el comportamiento de todos queda sometido a la exhaustiva supervisión de alguna omnisciente autoridad'*.[24] En consecuencia, no podrán dictarse mandatos u órdenes, en forma de leyes, con el objetivo de regular las actividades individuales con el fin de dirigirlas a determinados fines. Lo más relevante de este esquema es sin duda que cuando se ha pasado del estadio de las hordas o tribus al de la sociedad abierta, los fines colectivos ya no pueden identificarse con los fines individuales precisamente por la complejidad y extensión del orden. En la sociedad cerrada, los miembros del clan resultaban todos conocidos para el gobernante y quien detentaba el poder, resultaba también conocido para ellos. Había una estrecha relación personal que permitía al gobernante *interpretar* las aspiraciones *comunes* y dictar las órdenes necesarias para lograr su realización. Partiendo de estos hechos, la gran sociedad funciona espontáneamente; su dinamismo se basa en la actividad que cada uno de sus miembros realiza cuando procura alcanzar sus propios fines. Al decir que funciona espontáneamente, significa que no hay una mente superior y omnisciente que conduzca su actuación, y la inexistencia de un director que promueva su funcionamiento en lo absoluto significa que se trata de un organismo *estancado:* su constante

22 F.A. Hayek, 1994-I:86.
23 F. Hayek, s.f.: 53.
24 F. Hayek, s.f.: 69

evolución está determinada por la actuación individual de cada uno de sus miembros. Sin embargo, a pesar que a diferencia del clan o tribu, los individuos que conforman la sociedad ya no actúan en función de fines colectivos impuestos por un director sino que lo hacen en función de sus propios fines, seguimos hablando de un conglomerado social, es decir, sigue siendo un grupo. Cabría preguntarse entonces qué es lo que lo mantiene unido. La respuesta sería la existencia de normas de conducta, abstractas y generales, a las cuales los miembros del grupo se han sometido y cuya finalidad no es la de imponer el logro de fines determinados, sino establecer un marco general de actuación para que dentro del mismo, cada quien pueda perseguir sus propios fines en forma pacífica, es decir, sin provocar daño a otro, asegurándose de esta manera la convivencia de todos. La ley ya no contiene mandatos ni órdenes, contiene normas de conducta y en este caso, la ley sí se identifica con el Derecho. Estas normas no son producto de la razón; no han sido concebidas o diseñadas por alguien, si no han sido el resultado de un constante ensayo basado en la prueba y el error, de tal manera que aquellas normas que la experiencia demostró ser las más eficientes en el sentido de promover la supervivencia del grupo a través de la sumisión de éste a las mismas, son las que se han mantenido a través del tiempo.[25] El sometimiento voluntario a esas normas de conducta constituyen pues, el vínculo que mantiene unido al grupo, aún y cuando cada uno de sus componentes se preocupe sólo en alcanzar sus propios fines, y en último caso, su propio beneficio. Pero la gran sociedad presenta además otro elemento tan importante como las normas de conducta. En mi opinión, podríamos decir que su función es complementaria al sistema normativo. Como hemos mencionado, la sujeción a un sistema de normas abstractas y generales que demarcan el comportamiento de los individuos, permite que éstos puedan actuar buscando el logro de sus propios fines, dentro de ese marco. Al actuar, cada persona tomará sus decisiones usando su personal conocimiento de tiempo y lugar, que dado lo complejo del orden, constituye tan sólo una pequeñísima fracción del conocimiento. Sin embargo, actuando siempre en función de sus propios fines, al final todos los individuos lograrán alcanzar sus metas, lo que se traduce en un bienestar general. Si no hay quien dirija conscientemente cada actuación para que resultado de los actos individuales beneficie a todos ¿cómo se alcanza entonces ese bienestar general?. La respuesta la encontramos en ese otro componente de la sociedad abierta: un sistema espontáneo de flujo de información que tiene como efecto la coordinación de todas las actividades individuales de tal manera que, sin proponérselo, cada uno resulta colaborando con la realización de los fines del otro. Ese flujo de información es el que permite trasladar de actor a actor todo ese conocimiento disperso para que en determinado momento pueda tomar una decisión. Y de manera simple y sencilla, esa información se concentra en un número: el precio. Este proceso de coordinación espontánea que se basa en el uso de la información dispersa a través del mecanismo de los precios y que tiene como resultado no deseado deliberadamente la colaboración entre las personas en el logro de sus fines particulares es el proceso de mercado. Este es el segundo componente básico de una sociedad abierta. Uniendo ambos: dentro de ese marco constituido por el sistema de normas de conducta al cual todos se someten voluntariamente,[26] los individuos actúan buscando la realización de sus propios fines y en aras de su propio beneficio. Para ello, toman decisiones con base en la información que los precios les transmite, y al actuar, entran en relaciones con otros individuos e inconscientemente unos terminan colaborando con otros para lograr alcanzar cada quien sus metas. Una de las leyes sandinistas fue la relativa al congelamiento de las rentas en los alquileres. Roger LeRoy Miller[27] explica lo que sucedió

25 Aunque no es el objeto principal de este ensayo, es conveniente mencionar que la evolución espontánea de este sistema normativo se produce cuando el hombre percibe que actuando de determinada manera podrá lograr realizar el fin que persigue. De esta forma, el hombre escoge someterse a aquellas normas que ha observado que le ayudan a lograr sus fines cuando sujeta su actuación a las mismas y desecha aquellas que en ese sentido le resultan ineficientes. De este manera se va formando, paulatinamente, ese sistema normativo de conducta. Para mayor explicación, consúltese la obra de Friedrich Hayek Derecho, Legislación y Libertad. Vol. I.

26 Cfr. Caridad Velarde, 1994. La autora comenta: 'No se trata de determinar lo que los hombres pueden hacer, sino, por el contrario, de establecer los aspectos concretos en que su actuación puede ser sometida a coacción por parte de la autoridad'.

en Nueva York cuando una ley similar fue aprobada: al no reflejar las rentas el precio real de los alquileres, el ingreso del propietario de los inmuebles se situó por debajo del precio real y para él dejó de ser beneficioso darlos en alquiler. Esto produjo una reducción en la oferta de inmuebles para arrendamiento, generándose del lado de la demanda el efecto inverso. Pero no quedó ahí; no sólo bajó la demanda, sino las condiciones de habitabilidad de los inmuebles que continuaron siendo parte de negocio desmejoraron, ya que el propietario no estuvo dispuesto a invertir en ellos en cuanto a reparaciones y conservación. Al final, fueron las personas que para vivir tenían que arrendar las que salieron perjudicadas. Sería interesante preguntarle al campesino nicaragüense que transportaba la leche que producían sus vacas, si no existiendo la ley que confiscaba la leche que no fuera vendida al Estado, si en ausencia de esa ley, de todos modos se la hubiera vendido al Estado.

La motivación sandinista al dictar el tipo de leyes que hemos mencionado fue la de propiciar el bien común mediante el logro de una situación de bienestar general. Siguiendo la concepción racionalista que sirve de fundamento al socialismo, ese bienestar general sólo podía lograrse si el Estado, a través del gobierno, dirigía y coordinaba los esfuerzos individuales. Entendido de esta forma, el bienestar general pasó a ser un fin concreto, cuya realización sería posible a través de órdenes y mandatos contenidos en leyes. Dentro de la sociedad abierta, el bien común se entiende de otra forma; se trata más bien de una definición negativa: Hayek lo entiende como todo aquello que no altere el orden general, de tal manera que todos los individuos tengan la posibilidad de realizar sus fines particulares.[28]

Queda algo de suma importancia pendiente de explicar, también relacionado con el funcionamiento de la sociedad abierta. El proceso de mercado que hemos descrito, propicia una serie de relaciones entre individuos cuya consecuencia final será que cada uno pueda lograr alcanzar sus fines particulares. A esta consecuencia final se llega con fruto de la libre asignación de recursos que se produce en virtud de esas relaciones. La condición necesaria para que esa asignación pueda darse es que cada individuo sea propietario de los recursos de los que va a disponer en todas esas relaciones personales. En consecuencia, el proceso se basa en la existencia de la propiedad privada. Cuando el sandinismo era un movimiento armado, una de las ofertas que no faltaban en sus tomas de poblados y mitines era la que una vez en el poder, le darían tierra a los que no tenían, expropiándosela a los que sí tenían mediante una reforma agraria. Dejemos por un lado esta segunda parte y concentrémonos en el ofrecimiento. Aunque se cuidaron de no usar esas palabras, lo que reiteradamente ofrecían al campesino era que, de triunfar la revolución, él se convertiría en propietario, es decir, hablaban para él de gozar de propiedad privada. Cuando la revolución sandinista triunfó y se convirtió en el gobierno sandinista, esa promesa fue incumplida. Y con la idea de evitar que surgieran nuevos *'pequeño burgueses'* la tierra expropiada quedó en propiedad del Estado y al campesino, agrupado en cooperativas, únicamente le dieron el uso. Ya hemos visto cómo el expresidente sandinista reconoce que ahí comenzó el largo camino de errores de la gestión sandinista. En una sociedad abierta, más que hablar de propiedad privada, cabe hablar de propiedad plural en el sentido en que Hayek lo entiende:

> *'La libertad bajo la ley en modo alguno exige la posesión de propiedades al alcance de todos; lo importante es que exista una pluralidad de propietarios. Personalmente preferiría carecer de propiedad en una sociedad en la que las gentes poseyeran algo, que vivir en otra en la que todo fuera colectivo y todo dependiera de la arbitrariedad del poder político'.*[29]

27 Roger LeRoy Miller, 1986.

28 Aunque tampoco es el objeto principal de este ensayo, es necesario mencionar lo siguiente: dentro de un orden complejo, no puede garantizarse que todos los individuos lograrán alcanzar sus metas; habrá expectativas que se realicen en tanto otras no. Sin embargo, todos los individuos debieron haber tenido la posibilidad de actuar tratando de alcanzar sus fines y ello se garantiza mediante un sistema de normas de conducta generales y de igual aplicación para todos y evitando cualquier tipo de interferencia dentro del orden que pueda limitar en alguna medida la actuación de los individuos (bien común). La idea Hayekiana del bien común se encuentra mencionada en los volúmenes I y II de 'Derecho, Legislación y Libertad' y a ella se refiere la Doctora Caridad Velarde en su obra Hayek, una teoría de la justicia, la moral y el Derecho.

29 F. Hayek, s.f.: 133.

Dentro de la organización que fue la sociedad nicaragüense en el gobierno sandinista no hubo propiedad plural respecto del individuo.[30] En consecuencia, la asignación de recursos no fue real. Al principio, la propiedad quedó en poder del Estado. Luego, tratando de corregir el rumbo, se entregaron títulos de propiedad que aparejaban la prohibición de vender y heredar. Fue al final cuando entregaron títulos de propiedad plenos. Se repartieron las fincas que habían sido expropiadas, principalmente al tenor de la Ley de los Ausentes que ya hemos mencionado. Cuando todo pasó, hubo una especie de corrección espontánea de aquella falsa e ineficiente asignación de recursos. El autor dice al respecto:

> *'El sueño más antiguo de la revolución, la reforma agraria, está siendo derrotado como señal inconfundible de que la riqueza se reacomoda de nuevo, en términos estructurales, a la realidad de los años anteriores a 1979'.*[31]

Durante la gestión sandinista, Nicaragua retrocedió varios estadios evolutivos hasta llegar a la forma de organización tribal, cerrada, en la que hay una autoridad omnisciente que escoge los fines que el grupo debe conseguir y dicta las leyes conteniendo los mandatos que deben ser obedecidos para el efecto. Los recursos se asignan según la decisión de la autoridad y mediante esa asignación se satisfacen las necesidades que la autoridad considera que ameritan ser satisfechas. Pero la realidad era otra: el individuo tenía sus propios fines; no aceptó las normas organizativas dictadas por el gobierno sandinista; frustrado su anhelo de ser propietario terminó dándole la espalda a la revolución, y al final, se encontró aún más pobre que como estaba antes de que la revolución triunfara, pues sus necesidades no fueron interpretadas por los líderes como las del grupo. Es fácil entender la decepción que muestra el autor de *'Adiós muchachos'* en las primeras páginas del libro.

4- Racionalismo ¿irracional?: Catedrales en la selva

> *'Una lista de desmesuras de la que no debo excluir mi propio proyecto de ferrocarril de vía ancha entre la costa del Pacífico y la del Caribe, anunciado con pompa, y del que apenas se construyeron siete kilómetros porque no contaba con ningún financiamiento'.*[32]

¿Puede la razón llegar a ser irracional? Quizás la pregunta podría elaborarse de mejor manera: un pensamiento fruto de la razón ¿puede resultar irracional?. Irracional es lo opuesto a la razón o que está fuera de ella y que no puede someterse a leyes lógicas.[33] Así que a primera vista habría un contrasentido: si algo es concebido por la razón, no está fuera de ella y por lo tanto, no podría ser irracional, por lo menos, según la aplicación estricta de la definición. Quizás este aparente contrasentido pueda explicarse usando el término *'racionalismo crítico'* empleado por Hayek cuando explica los límites de la razón:

> *'uno de los logros de la razón consiste en establecer sus propios límites y en determinar en qué medida puede confiarse en otros procesos ajenos a ella'.*[34]

De esta manera, Hayek distingue entre el racionalismo constructivista y el racionalismo evolucionista: el primero de ellos parte de que solamente la razón consciente determina el comportamiento humano, en tanto el segundo parte de que la razón no es suficiente para determinar la actuación del hombre, sino que, como dice la cita, éste puede confiarse en otros procesos tales como la abstracción o la experiencia. Es curioso que Popper califique al primero como *'ingenuo'* y al segundo como *'crítico'*. Si aceptamos que la razón tiene límites que son excedidos por la realidad, entonces sí podemos decir que un pensamiento consciente, nacido de la razón, puede resultar siendo irracional, ya que cuando sea confrontado con la realidad, resultará estando situado en un plano

30 Ya veremos que sí la hubo para los dirigentes.
31 S. Ramírez, 1999:243.
32 S. Ramírez, 1999:238.
33 Diccionario, 1953: Vol. VI.
34 F.A. Hayek, 1994:60.

fuera de la razón, o como dice el dicho popular *'fuera de toda lógica'*.

La gestión sandinista estuvo plagada de actos ejecutados a raíz de pensamientos fruto de un estricto proceso racional constructivista pero que al final resultaron siendo irracionales, o más bien, absurdos. Veamos algunos ejemplos, que aún y la gravedad de la situación que originaron, no dejan de ser pintorescos:

a- Vacas canadienses confinadas en corrales provistos de máquinas ordeñadoras diseñadas para producir veinte mil litros de leche al día: al final, el costo de producción de cada uno de esos litros resultó siendo mayor que el que por métodos normales producía una vaca del país;
b- Siembra de treinta mil hectáreas de tabaco Burley: la madera para fabricar los almacenes hubiera requerido la tala de bosques enteros, sin entrar a mencionar el problema de logística que implicaba el mantenimiento de esos sembradíos;
c- Adquisición de cuatro mil tractores destinados a las cooperativas: ¿y los repuestos? ¿los garages para guardarlos? Sin mencionar que la gasolina ¡estaba racionalizada!
d- Construcción de una represa para llevar el agua a través de muchos kilómetros hasta un ingenio construido por Cuba, proyecto que se complementó con la compra al crédito de un sistema de riego por pivote: al final, el precio del consumo de energía eléctrica del sistema de riego era tan alto que no se pudo pagar;
e- Construcción de una pista de aterrizaje para aviones MIG y entrenamiento de pilotos nicaragüenses en Europa Oriental para aprender a volarlos. Al final, por la longitud que requería la pista, se consumió más cemento que el que se hubiera necesitado para construir una carretera nueva al puerto. Al final, no hubo aviones, y los pilotos entrenados terminaron trabajando como choferes de taxis: otra vez el problema de la asignación de recursos.

Al parecer, muchas de estas ideas brotaron de la mente del Ministro de Agricultura y Reforma Agraria, Jaime Whelock. Al respecto es elocuente lo que dice el autor:

> *'La mira de Jaime era la modernización radical, bajo ese síndrome de transformación instantánea que todos padecíamos, y sus proyectos fueron siempre ambiciosos, sin previsiones de costos o de rentabilidad'*.[35]

Como dice el autor, al final se trató de catedrales en la selva, en alusión a la película de Werner Herzog sobre Fitzcarraldo, que pretendía construir un teatro de ópera en Iquitos.

La única forma de entender estos desatinos es teniendo presente que el socialismo se fundamenta en el racionalismo constructivista y si el sandinismo era en esencia socialista, su actuación se basaba también en ese racionalismo ingenuo. Si el socialismo fracasó por confiarse solamente de la razón, entonces la causa de fracaso de la gestión sandinista es la misma.

5- ¿Quiere un buen consejo?

> *'Pero pienso que aún sin guerra, las sustancias filosóficas del modelo que buscábamos aplicar habrían conducido de todos modos a un colapso económico, a no ser por una evolución pacífica del sistema hacia una economía mixta real, lo que a su vez hubiera demandado una mayor apertura política'*.[36]

A pesar de las evidencias, aún hay quienes argumentan que el fracaso sandinista se debió a la guerra interna que tuvo que librar enfrentando a la contra. Según dicen, la guerra consumió todos los recursos que de otra forma, se hubieran destinado a programas de beneficio para todos, en especial, para los más pobres. La guerra y el bloqueo impuesto por los Estados Unidos, esos fueron los factores que determinaron el fracaso de la gestión sandinista. Y es probable que en estos momentos en los que el Frente Sandinista se alista para participar en las próximas elecciones generales con el objetivo de recuperar el poder, sea éste el argumento que utilice en sus mitines a

35 S. Ramírez, 1999:237.
36 S. Ramírez, 1999:241.

manera de excusa, para explicar ante los electores el fracaso de su gestión cuando ya estuvo en el gobierno. Debo mencionar también que el mismo autor de 'Adiós muchachos' se hace reiteradamente la pregunta; ¿que hubiera pasado si no hubiera habido guerra?. Llegando al final de libro, él mismo se responde. Su respuesta constituye la cita anterior. No fue la guerra ni el embargo; fue la irracionalidad del sistema. Además, la difícil situación económica no se inició cuando recrudeció la guerra interna o cuando Reagan asumió la presidencia de Estados Unidos; ya venía mal. Y a estas personas sólo cabría preguntarles: de no haber habido guerra ¿a qué proyectos se hubieran destinado los recursos? ¿a los de las vacas, al del sistema de riegos o a la pista para MIGs? El resultado hubiera sido el mismo; de ahí el reconocimiento de la causa del fracaso que hace el autor en la cita.

Mencioné que había dos citas de libro que me impresionaron muchísimo. Una de ellas ya la comenté. La segunda es la que sirve de sentencia al fracaso del experimento sandinista. Cuenta el autor que en 1987, llegó a Nicaragua un experto del Ministerio de Planificación Soviético (Gosplan) junto con una delegación de economistas. Su función era hacer un diagnóstico de la situación y presentar un documento con recomendaciones para enfrentar la crisis. Cuando se presentó a la reunión ante el Consejo Nacional de Planificación, presidido por Daniel Ortega, solamente dio dos recomendaciones:

> *'primero, que era necesario liberalizar la economía y controlar el gasto, siendo estrictos en el cálculo económico; y segundo, que los comandantes debían abandonar de inmediato las tareas de gobierno y dejarlas en manos de técnicos competentes'*.[37]

¡Un experto del Ministerio de Planificación Soviético recomendando liberalizar la economía! Hasta los comunistas se habían percatado ya que el racionalismo constructivista, fundamento del comunismo y del socialismo, no era viable, que era un fracaso. En mi opinión, esta es la enseñanza más importante que contiene el libro: es el reconocimiento del error socialista y que la vía correcta es el proceso de mercado; había que dejar de ser tribu y aspirar a llegar al estadio de la gran sociedad. Y para ello, había que reducir el gasto y ser estrictos en el cálculo económico. ¡Un experto del Ministerio de Planificación Soviético le habla de cálculo económico al Consejo Nacional de Planificación de Nicaragua! Desde donde estuviera ¿qué pensaría Oscar Lange? Tantos años de debatir con Mises sobre el cálculo económico y ahora resulta que hasta los planificadores reconocen que sin él nada se puede hacer. Y por supuesto, la liberalización de la economía implicaba el funcionamiento de un sistema de precios, ya que sin precios, no hay cálculo económico. Ese es precisamente uno de los grandes errores de la planificación económica. Pero veamos la respuesta de Daniel Ortega:

> *'¡Usted pide que nos quedemos haciendo un papel protocolario!* - le dijo Daniel muy sorprendido- *Yo no sirvo para eso'*.[38]

Bueno, tampoco sirvió como Presidente.

6- El diablo predica pero no se convierte

> *'Cuídense, se están alejando del pueblo'* (Olof Palme)[39]

Me parece que *'Adiós muchachos'* resulta siendo un libro interesante también por otro aspecto, además del reconocimiento del fracaso del experimento sandinista por parte de uno de sus principales artífices. Aunque en las páginas del libro no hay una alusión clara a este otro tema como la que puede encontrarse respecto a los desatinos sandinistas, la idea subyace en algunas partes y aflora al final del libro, cuando se describen los últimos días de la era sandinista. Este otro elemento es la actuación humana de los políticos sandinistas. Tradicionalmente, la política es estudiada desde un punto de vista romántico:[40] el gobernante es visto como una especie de *despota benevolente* que detentando el poder, es un ser huma

37 S. Ramírez, 1999:240.
38 S. Ramírez, 1999:240.
39 S. Ramírez, 1999:54.
40 Entrevista con James Buchanan por 'The Region' publicada en internet en la página http://woodrow.mpls.frb.fed.us/pubs/region/int959.html.

no bueno por naturaleza que empleará el mismo en la implementación de políticas cuyo fin último sería el beneficio de los individuos. El profesor Buchanan[41] señala que los economistas se constituyeron en los asesores de estos déspotas benevolentes, diseñándoles políticas basadas en asunciones de lo que los individuos querían. Dos cosas cabe señalar al respecto: la primera es que los economistas basaron sus diseños en la idea de un individuo homogéneo respecto de todos los demás y previsible en sus preferencias y actos: el *homo economicus*. Partir de esta premisa era la única forma de poder diseñar políticas *'estándar'*, aplicables a todos los individuos en general. En la actualidad se reconoce que la premisa descansaba sobre una proposición falsa: no es posible conocer las aspiraciones, preferencias y actuaciones de *todos* hombres simplemente porque el conocimiento es disperso y únicamente asequible en forma parcial para cada uno de esos individuos: el individuo en modo alguno es un ser predecible.[42] Esta estandarización del individuo produjo como consecuencias, en primer lugar, el desplazamiento del poder de elección de cada uno de éstos hacia terceros, los que elaborando un listado de prioridades de acuerdo a lo que ellos creían eran los deseos de los individuos para satisfacer sus necesidades, asignaban los recursos escasos en atención a esos fines; en segundo lugar y como resultado de lo anterior, el individuo perdió su derecho a elegir en función de sus propios fines; alguien con un mejor conocimiento de lo que le sería más conveniente elegiría por él; y en tercer lugar, el individuo cedió su lugar al grupo, a la colectividad. En efecto, ante la reconocida imposibilidad de conocer las preferencias y necesidades de cada individuo en particular, hubo que homogenizarlos por lo que el diseño de aquellas políticas *'estándar'* ya mencionadas se hizo en atención a lo que fue considerado como las preferencias y deseos *comunes* de todos los individuos. De esta forma, mediante su implementación, se lograrían alcanzar fines *comunes*, que beneficiaran al grupo y a la colectividad y no a individuos en particular. Ya no habían intereses individuales; ahora habían intereses comunes o de grupo. Este tendencia a homogenizar a los individuos no es otra cosa que un puro ejercicio racional. Como hemos visto, el sandinismo basó su gobierno en razonamientos de este tipo. Pero de ello ya hemos comentado lo que aparece escrito en las páginas de *'Adiós muchachos'*. Veamos ahora la otra parte, la que se refiere al gobernante. En la actualidad, la escuela de la opción pública[43] utiliza las herramientas del análisis económico para analizar la política, de ahí que muchos la definan como el análisis económico de la política. El aspecto más relevante de esta escuela es que al basarse en la economía para analizar la política, utiliza el individualismo metodológico por lo que el análisis de la política y sus actores se hace desde la perspectiva del individuo común y corriente. Y el individuo es un maximizador de beneficios, es decir, actúa con la finalidad de obtener el mayor beneficio posible como resultado de su actuación. Los políticos son individuos y por lo tanto, también actúan guiados por el mismo criterio maximizador; éste es uno de los principales aportes del análisis económico de la política y su efecto es llegar a concluir que no existe tal *déspota benevolente*. El político, como cualquier individuo, actúa en su propio beneficio.

La actuación de los gobernantes sandinistas a lo largo de su gestión y especialmente en la etapa final, demuestran la validez de esta propuesta de la opción pública. Según cuenta el autor del libro, una especie de código de conducta que regía desde la época que él llama *'de las catacumbas'*, es decir, desde la época de la clandestinidad, era la *'regla de no tener'*: fieles al credo comunista, todos debían ser iguales y la igualdad se alcanzaba cuando ninguno de ellos era propietario de algo. Según el autor, el gobierno sandinista recibió esta especie de herencia ética y la misma garantizaría el mantenimiento de los equilibrios ya en el poder, pues todos se mantendrían iguales y sin diferencias. Pero el autor olvida que su situación había cambiado: ahora eran los dueños del poder. Hablar de seguir una norma de conducta que disponga que no se debe tener nada, debe resultar

41 James Buchanan, 1993:122. El autor agrega 'Esta denominación de "déspota benevolente" es apropiada porque los economistas se han puesto a si mismos en situación de ofrecer consejo sobre la reforma política, como si quienes toman las decisiones políticas, quienquiera que éstos sean, aceptasen y actuasen con respecto a dicho asesoramiento con total independencia de todo tipo de móviles o impulsos humanos que los propios políticos pudieran tener'.

42 Se sugiere consultar las obras de Friedrich Hayek al respecto.

43 El nombre en Inglés de esta escuela es Public Choice.

fácil cuando efectivamente no se tiene nada, o quizás muy poco, o no se tienen los medios para adquirir algo. Me parece que es hasta comprensible tratar de imponer una norma de conducta de ese tipo, ya que es natural que el que está mal, pretenda que todos los demás también estén mal, obviamente incluyendo especialmente a los que están mejor. Pero ya en el poder la cosa cambió:

'Todo lo que estaba en manos de los dirigentes era del Estado. Residencias, casas de recreo, vehículos, muebles; y los gastos de servicios, las fiestas domésticas, las vacaciones, con salarios nominales que no alcanzaban para nada, eran por cuenta del Estado. Pero, precisamente, amparándose en esta forma ladina de no tener, la dirigencia empezó a quebrantar el código de Jorge Navarro, que estaba basada en la renuncia y en la modestia de vida. El poder fue el enemigo de aquella regla y creó contrastes ofensivos en un país inmensamente pobre, y donde aún la clase media se veía golpeada por los rigores de la guerra, con ingresos disminuidos por la inflación, salarios inestables, colas y desabastecimiento'.[44]

'El poder fue el enemigo de aquella regla', me parece que esta frase resume lo que en realidad pasó: el gobernante, como cualquier individuo, actúa en su propio beneficio. En esas mismas páginas, el autor cuenta que las casas de los dirigentes debían ser amplias, muchas de ellas provistas con gimnasio y piscina, con muros de seguridad y numerosos guardias personales. Los vehículos debían ser nuevos por cuestión de prestigio. Justificaciones para estas decisiones: las casas debían tener esas características porque ahí trabajaban los funcionarios y recibían y atendían a distintas personalidades; por seguridad no podían salir a hacer ejercicio físico a la calle o algún lugar público y un carro nuevo garantizaba la seguridad de su desplazamiento. Luego se abrió una tienda diplomática en la que se pagaba en dólares y a la que únicamente tenía acceso la alta dirigencia sandinista. En 1983, Olof Palme visitó Nicaragua. Durante su estancia, debió ser testigo de todas estas cosas y a su regreso a Estocolmo, el autor cuenta que les envió un mensaje muy breve:

'Cuídense, se están alejando del pueblo'

Al final de la gestión sandinista, cuando perdieron las elecciones, este *alejamiento del pueblo* alcanzaría su nivel más alto. Me imagino que Olof Palme conservaba esa visión romántica de la política; únicamente así puede entenderse su comentario. Cuando los sandinistas perdieron las elecciones, hicieron un convenio de transición con Violeta Chamorro. Ante la inminencia de encontrarse fuera del poder, los sandinistas argumentaron que el sandinismo no podía dejar el gobierno sin recursos materiales porque esto significaría su aniquilamiento. Así que durante los tres meses de la transición y utilizando a terceros como fachada, los sandinistas iniciaron una serie de transferencias de edificios, fincas, empresas, acciones, etc. a nombre de estos terceros, los que después los pasaban a favor de los dirigentes sandinistas. Esta operación llegó a conocerse como 'la piñata':

'Muchas nuevas y grandes fortunas, muchas de ellas tan odiosas como las que por rechazo inspiraron el código de conducta de las catacumbas, nacieron de todo lo que se quedó en el camino'.[45]

Al final, los gobernantes sandinistas se convirtieron en esa nueva clase 'pequeño burguesa' que al inicio de la reforma agraria querían evitar. Cuando el autor del libro menciona que al final, la riqueza se reacomoda de nuevo derrotando el sueño de la reforma agraria, agrega que la diferencia es que ahora forman parte del reacomodo muchos que en su momento alentaron ese sueño.

Al final del gobierno sandinista, Nicaragua había retrocedido hasta la época tribal y agobiados por una hiperinflación, los nicaragüenses eran más pobres que cuando estaba Somoza. Así terminó el experimento sandinista.

7- Y no olviden la lección

Frecuentemente, los detractores de las ideas de Hayek y en general, del mercado y últimamente de la opción pública, argumentan que todo eso del orden espontá

44 S. Ramírez, 1999:53.
45 S. Ramírez, 1999:55.

neo, la mano invisible que coordina las actividades individuales sin dirigirlas, el sistema de precios, la vigencia de normas abstractas y generales y la libre asignación de recursos que se fundamenta en la propiedad privada, no son más que elucubraciones teóricas, sin ninguna posibilidad de ser llevadas al plano de los hechos, no obstante hay ejemplos de sociedades prósperas que han optado por ese esquema. Encontré en este libro la oportunidad de confrontar esas teorías con un caso real del experimento socialista; la teoría que explica por qué el socialismo no puede funcionar confrontada a la realidad de un fracaso cuando se trató de llevar el socialismo a la realidad. Y lo más relevante es que el caso de confrontación es presentado por alguien que participó en ese experimento constructivista y que tiempo después reconoce que fracasó. Haber explicado las razones por las que el sandinismo fracasó, explicando nuevamente el error intelectual del socialismo, seguramente hubiera provocado las mismas críticas de parte de los usuales detractores. Pero si la evidencia que no funciona es ofrecida por uno de ellos mismos y contra ella se confrontan estas otras ideas, el resultado no puede ser otro que, aunque quizás no lo hagan expresamente, el reconocimiento de la validez de las proposiciones hayekianas, y en especial, de la eficacia del mercado. Y si su arrogancia sigue siendo tan grande, tal vez lo hagan al revés: limitándose a reconocer que el socialismo, basado en el racionalismo constructivista, no es viable. Las razones ya las conocemos.

Al título de *'Adiós muchachos'* habría que agregarle Y no olviden la lección:

> *'Los objetivos y programas socialistas son, en definitiva, inviables, tanto en cuanto al logro de los objetivos propuestos como a la eficacia de su gestión. Y, a mayor abundamiento, el modelo carece hasta de la necesaria consistencia lógica'*.[46]

Bibliografía

Buchanan, James

1993 *Economía Constitucional.* Madrid: Instituto de Estudios Fiscales.

Diccionario

1953 *Diccionario Enciclopédico UTHEA.* México: Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana.

Hayek, Friedrich A.

s.f. *La fatal arrogancia. Los errores del socialismo.*

1994 *Derecho, Legislación y Libertad.* Vol. I. Madrid: Unión Editorial.

Miller, Roger LeRoy

1986 *Microeconomía moderna.* México: Editorial Harla.

Ramírez, Sergio

1999 *Adiós muchachos. Una memoria de la revolución sandinista.* México: Editorial Aguilar.

Velarde, Caridad

1994 *Hayek, una teoría de la justicia, la moral y el derecho.* Madrid: Editorial Civitas.

45 F. Hayek, s.f.: 53.

ARMANDO DE LA TORRE[1]

Mil años, cien obras

Prólogo: A manera de excusa por reflexiones en voz alta

Lo que tiene entre sus manos, apreciado lector, es la cauda de un gesto de extremada audacia.

Fue Julio Cole, el Director General de la Biblioteca de la Universidad Francisco Marroquín, quien sugirió hacer una exposición de las cien obras de más impacto escritas en el milenio que toca a su fin.

Lissa Hanckel añadió a ello la iniciativa de acompañarla de un catálogo que sirviera de guía para el visitante curioso.

Desde esos modestos comienzos creció todo y creció...

Lissa reunió algunos amigos en su casa, de edades y ocupaciones de las más diversas, para discutir posibles selecciones. Allí estuvo Francisco Pérez de Antón, de elegante prosa y rica formación humanística; allí Erika de Borndholdt, cultísima, con todo el bagaje a cuestas de su experiencia europea; allí jóvenes juristas, inquietos y promisorios, como Andrés Wyld y Giovanni Fratti; a ellos habría de añadírseles, pocas semanas después, otro talento disciplinado, esta vez del ramo económico, en la persona de Lucía Olivero, cuya investigación acuciosa e inteligente nos condujo a la fidelidad de los títulos originales de cada obra (logro nada fácil, sobre todo con los textos medievales), así como a la respectiva biografía, breve y densa, de cada autor. Marialys de Monterroso tuvo a su cargo, con Julio Cole y Erika de Borndholdt, la revisión final del conjunto. Dinora Posadas transcribió al papel las grabaciones de mis comentarios, en una labor tediosa de muchas horas de interpretar las veleidades de mi acento. Nidya de Flores hizo otro tanto con esta introducción que hago a manera de excusa. Claudia Sosa fungió de diligente conexión entre mi oficina y el resto. Así se configuró una orquesta bien ajustada, de personas sumamente ocupadas y dispuestas, sin embargo, a hacerse de nuevas obligaciones; y a su frente, con la batuta de la eficiencia en mano, Lissa.

Nos enfrascamos por horas en discusiones, calurosas tanto por la amistad que nos unía como por el amor a los libros que nos había hecho confluir en un proyecto quijotesco.

El primer punto a aclararnos fue el del criterio de selección. Lissa puso su arrolladora elocuencia a favor de una retrospectiva histórica del impacto que cada una de las obras pudiera haber tenido, es decir, de que hubiera marcado el paso como agente importante de cambio, fuera éste social, teológico, literario, filosófico o político. Cualquier otro rasero sería demasiado subjetivo. El valor literario intrínseco, por ejemplo, o el relativo peso histórico de la *persona* del autor, o su popularidad y difusión momentáneas (los 'best sellers' de nuestro tiempo), o aun el ángulo de nuestra familiaridad con el texto en cuanto lectores del siglo XX, se nos hacían demasiado abiertos al disenso y la polémica, y ya habíamos además aprendido de los escolásticos que 'de gustibus non est disputandum'.

Así orientados hacia tamaña tarea, la siguiente dificultad a superar nos la constituyó la estrechez geográfica de nuestros propios horizontes culturales: nunca escapamos a ser hijos de nuestro tiempo y, encima, de vernos circunscritos a nuestras coordenadas lingüísticas. ¿Cómo juzgar, entonces, de lo muy pretérito, o de lo muy ajeno, que nos pudiera haber llegado del Asia desde cualquiera de las fraguas de su posible proyección universal: la de China, la India o el Islam?

1 Director de la Escuela Superior de Ciencias Sociales de la Universidad Francisco Marroquín.

Un tímido esbozo fue propuesto por los más jóvenes de entre nosotros, entusiastas de los relatos de los Marco Polo sobre sus vivencias en el exótico Oriente del Kublai Kan. Pero ¿fueron acaso verdadero agente de cambio en Occidente? ¿No influyeron mucho más los cánticos épicos a las Cruzadas, o las descripciones deslumbrantes de las hazañas de los caballeros 'sin miedo y sin tacha', del Amadís de Gaula, por citar uno, o del 'Orlando el Furioso' como lo reseñara Ariosto, o de las 'Mil y una Noches', traducidas a las lenguas romances del árabe culto y helenizado de aquella época fabulosa de Harun el Raschid? Y a propósito de relatos, ¿qué decir de las narraciones científicas que competen a los historiadores? ¿De Winckelmann y sus estudios arqueológicos? ¿De Schliemann y los suyos? ¿De Michelet, Ranke y Carlyle? ¿ O de los filosofantes: Vico, Turgot, Spengler, Toynbee, Braudel? ¿O de tantos filósofos de la cultura que sacudieron por momentos la conciencia de Occidente: Fichte, Schopenhauer, Nietzsche, Bergson, Croce, Gentile, Husserl, Peirce, Dewey, Marcuse...? ¿O de todos aquellos populizadores que agitaron con éxito en su nombre?...

Por otra parte, ¿cómo ponderar, adicionalmente, la trascendencia de *un* escrito según su perfil fuera predominantemente teológico, o inspiracional, o filosófico, o científico, o político, o aun meramente artístico...?

Un hecho que se nos ofrecía con evidente incertidumbre derivaba precisamente del cambiante 'clima intelectual' que ha dominado en sucesivas marejadas al Occidente. A la obsesión teísta de la Edad Media siguió la no menos absorbente por todo lo humano de los autores del Renacimiento. Y a éstos orilló el contagioso hallazgo del método de la ciencia experimental, seguido a su vez muy de cerca por el fermento político y social que precedió y acompañó toda la Revolución Industrial hasta nuestros días. ¿Pueden ser *comparables* entre sí estos fenomenales cambios de clima en cuanto forjaron esos distintos estadios de nuestra idiosincracia, que nos hemos acostumbrado a identificar como la común herencia 'occidental'?

Cuales travesaños añadidos en nuestro camino, no menos se nos antojaron los saltos inesperados en la tecnología. Ya Marshall McLuhan nos había aclarado que 'el medio es el mensaje', y que hasta nuestro arribo a 'la aldea global' de hoy hubimos de hacer un larguísimo peregrinaje -desde aquellas remotas aldeas agrarias anteriores a lo que Karl Jaspers llamara la era 'axial' (aproximadamente el siglo VI A. de C.)-. Ese andar, casi siempre muy doloroso, ha sido punteado, según McLuhan, por las sucesivas irrupciones tecnológicas del alfabeto, la imprenta y la televisión, y las adaptaciones consiguientes de nuestra cultura. Lo cual, sea dicho de paso, plantea adicionalmente inquietantes interrogaciones sobre el futuro de la palabra escrita, ahora que la Internet, aún más que la televisión, nos acerca planetariamente con imágenes y sonidos de conversaciones 'cara a cara' y promete permitirnos prescindir, quizás, de librerías y bibliotecas personales.

También se nos planteó el problema de la unanimidad, que sabíamos imposible, en nuestros juicios de valor. Lissa cortó de un tajo ese nudo gordiano con un recurso bastante convencional al principio de autoridad: simplemente se dejó a mi persona pronunciar la palabra final, con lo que todos los demás quedaron benditamente libres de condena y yo supuesto a asumirlas demoniacamente todas.

Por eso le indiqué, paciente lector, que está ante un gesto de extremada audacia, alguno diría rayano en la locura. Pero para algo habría de servirme el acervo celtíbero que heredé de mis padres y que recoge la constancia deleitosa, puesta por escrito, de los audaces arrebatos del Caballero de la Triste Figura.

Por último, como si la cuesta no hubiera sido suficientemente empinada, Lissa sostuvo que los breves comentarios para iluminar el aporte y el impacto de cada texto habrían de estar al alcance de la comprensión de estudiantes universitarios de primer año de carrera. Me apresuro a confesar mi absoluto fracaso también en este punto y a pedir, lector, su magnánima indulgencia.

Una palabra más sobre los escritos NO incluidos. Muchos de ellos tendrían, a juicio de ilustres letrados y sabios, un mérito igual, o aun mayor, al de los aquí escogidos. Por supuesto, nunca he pretendido hablar por la entera raza. Calculo, sin embargo, que en otras recopilaciones paralelas, con criterios en mente semejantes a los mencionados, aproximadamente un cuarenta por ciento del total coincidirían con nuestras selecciones. Pues ¿quién omitiría de tales listados 'La Divina Comedia'? ¿O la 'Suma Teológica'? ¿O 'El Príncipe'? ¿O 'Fausto'? ¿O 'El Origen de las Especies', de nuestro ascenso atlántico? ¿O quién olvidaría incluir la rebeldía alemana de Lutero, la

gravitación de Newton, la relatividad de Einstein o el subconsciente de Freud?

Además, nos interesaba la originalidad del genio individual recogido en cada escrito. Por eso no aparece entre los que han hecho una diferencia en el avance o retroceso del hombre la *Magna Carta inglesa* de 1215, una mera recopilación del *uso* inveterado de la sociedad feudal en los ámbitos jurídico y fiscal.

Entre nosotros se dio la natural tendencia, ya lo dije, a sobrevaluar lo que nos queda más cercano en el tiempo y en la distancia. Pero es ésta una complicación natural y casi diría que inevitable. Se sumó al hecho de que la inmensa mayoría de las obras escritas a considerar para esta lista de referencias han visto la luz durante los últimos tres siglos, y que en este XX que agoniza se han editado más títulos que en toda la historia previa de la humanidad. Otra manera de ilustrar lo que los franceses han dado en llamar 'la aceleración histórica'.

Por ejemplo, en el novedoso género de literatura para infantes y adolescentes, surgido a principios del siglo XIX con los hermanos Grimm, y ampliado a mediados del mismo por Julio Verne, pudieran haber competido por nuestra preferencia el creador de 'Pinocho' -mi primera lectura de niño- Carlos Collodi, o los un tiempo popularísimos hilvanadores de historias de aventuras Karl May o Emilio Salgari, o aun esa joya del despertar sentimental 'Corazón', de Edmundo de Amicis, que tanto contribuyeran a moldear la imaginación de casi todos aquellos alfabetas que crecimos en ambas riveras del Atlántico tocados por el Risorgimento italiano. Más recientemente, se ofrecía también al aprecio estético las maravillosas moralejas encerradas en 'El Principito', con las que Antoine de Saint Euxépery ha deleitado y educado a generaciones de niños y adultos del siglo XX.

Si esto sucedió con un género de las bellas letras tan relativamente simple, ¿qué decir de la literatura en grande? ¿Por qué Bocaccio y no Chaucer? ¿Por qué incluir a Víctor Hugo y no a Charles Dickens? ¿Por qué Solzhenitsyn y no Tolstoi o Dostoiesvski? ¿Por qué Ibsen y no Flaubert? ¿O Kafka y no Balzac? ¿O Ayn Rand y no Thomas Mann? O si de la mística se trata, ¿por qué San Juan de la Cruz y no Santa Teresa? O si de la pura poesía lírica, ¿cómo olvidar a Chateaubriand o Baudelaire ¿O el libro 'Azul', de Rubén Darío? ¿O a Byron, Shelley, Emily Dickenson, Hoerdelin? ¿O a nuestro incomparable 'monstruo de la naturaleza', Lope de Vega? ¿O Calderón? ¿O al gigante que nos ha sido contemporáneo, Jorge Luis Borges?... Dilemas a tan corto plazo irresolubles, aun si se tiene en cuenta que nuestro interés primordial yacía en el eco, no en el grito.

Esto explica por qué me sentí incapaz de escoger una sola creación de Shakespeare. Todo su genio hube de abarcarlo en sus obras completas. El, por si solo, es literatura.

El criterio acordado lo mantuve en esa aproximadamente cuarta parte de todo lo aquí recogido que clasificamos como estrictamente literario: nos interesaba el *impacto*, la diferencia que hizo cada texto en la historia colectiva de las emociones, de las verdades consensualmente aceptadas, de las decisiones respaldadas por la opinión pública que han hecho la diferencia en el decurso de la historia.

Un escollo que tampoco logramos siempre salvar fue el de un deslinde certero entre el impacto de la obra por sí misma, con independencia de la personalidad de su autor, y el protagonismo de la persona en 'el gran teatro del mundo'. Los escritos del género político, sobre todo, se nos hicieron los más difíciles. ¿Fue, por ejemplo, 'Mi Lucha', uno de esos textos decisivos, o más bien, mucho más allá de su contenido, la mera sombra proyectada por la torcida voluntad totalitaria del Hitler que sí marcó una época? ¿Fueron las triunfantes iniciativas políticas de Lenin, a partir de 1917 su boleto a la fama, o su singular propuesta escrita, en un ensayo de dieciséis años antes, de crear el Partido Comunista, lo que de veras hizo la gran diferencia? ¿Fue Mao, el hombre de la Gran Marcha y de la victoria sobre Chiang Kai Chek, quien dejó su impronta indeleble en un intervalo definido de la historia del Asia occidentalizada, o más bien la colección de sus aforismos, puestos por escrito en un librito de carátulas rojas, el alimento para el perenne fanatismo juvenil por una sociedad sin clases, lo mismo en su China natal que en el lejano Perú de 'Sendero Luminoso'?

Estas fueron algunas de las cuestiones que me agitaron por meses.

Pero como se le atribuye a Julio César haber dicho: 'alea jacta est', 'la suerte está echada', aquí tiene el resultado de nuestra embestida al más gigantesco de los molinos de viento del espíritu.

Y ahora que menciono la palabra 'espíritu'. Durante todo este segmento de arco que llamamos

el milenio, la Iglesia nos advirtió mil veces, en cada miércoles de ceniza: 'Recuerda, hombre, que polvo eres y en polvo te has de convertir'. Por otra parte, recientemente Carl Sagan nos explicaba que los cuatro aminoácidos claves en que se deletrea la vida orgánica con mucha probabilidad llegaron a la tierra desde el polvo cósmico; que somos, pues, hijos de las estrellas.

Esto me vino por primera vez a la mente cuando una melancólica tarde de otoño, de estudiante de teología en Francfort, visité la austera lápida que cubre la tumba de Shopenhauer. Somos instantes, pensé, en un ecosistema de millones de años de frontera. ¡Pero qué instantes! Polvo que mide el arco de cada paso por la materia que da Dios, que escudriña las inmensidades del espacio y las relatividades de lo más diminuto al interno del átomo, que se sale de su nicho biológico y planta su huella sobre la luna, que alarga en el tiempo sus esperanzas y elimina con precisión quirúrgica sus taras congénitas, que diseña parrillas aerodinámicas en las que vivir y por las que fluir, que pinta y esculpe sus emociones o las envía con trazos en un papel a las generaciones de otros tiempos y otros lugares, y que deja bien avergonzado al cosmos porque supera con su creación sinfónica de sonidos los ruidos de la naturaleza inerte y aun de la meramente animal. Sí, este polvo ha logrado vestirse más esplendorosamente que los lirios del campo.

De sentirlo así, no se angustie por las injustas omisiones de este atrevido. Habrá otras embestidas mejor logradas. Entretanto, ¡que acuda en su socorro algún piadoso Sancho Panza y le restañe las heridas!

El medio es el mensaje: El impacto de la invención de la imprenta

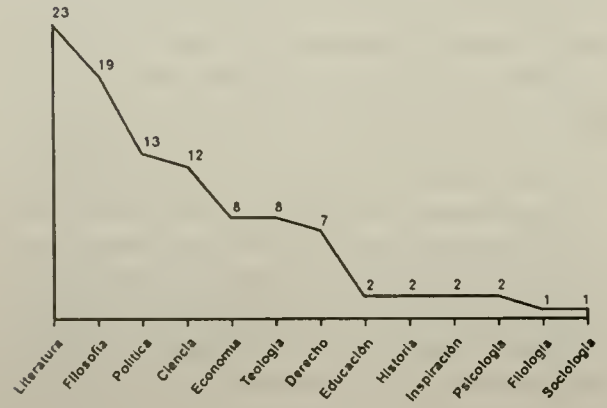


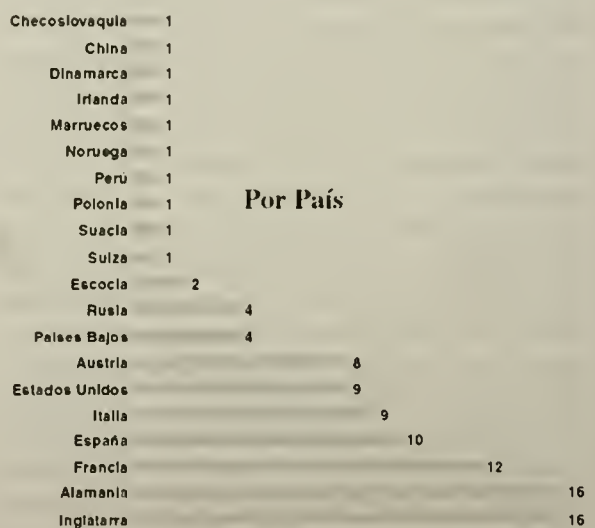
Listado de obras seleccionadas por siglo y por nacionalidad de los autores

Siglo

Area	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX
Teología	1	1	1			2	1		1	1
Literatura		1		3		3	3	1	7	5
Filosofía		1					4	6	5	3
			Inspiración		1	1				
			Filología		1					
					Política	1		4	3	5
					Educación	1		1		
					Historia	1		1		
					Ciencia	2	3	1	4	2
						Derecho	2	3	1	1
							Economía	2	2	4
									Psicología	2
									Sociología	1

Las cien obras del milenio por área de pensamiento





GABRIEL J. ZANOTTI[1]

La ley natural, la cooperación social y el orden espontáneo[2]

Sumario

1- Algunas aclaraciones sobre la ley natural
2- La cooperación social
3- El orden espontáneo
Conclusión
Bibliografía

1- Algunas aclaraciones sobre la ley natural

Vamos a recordar algunas cuestiones sobre la ley natural. Decimos 'recordar' porque lejos de mí el querer repetir otra vez lo que habitualmente se sabe sobre este tema, que se puede encontrar perfectamente tratado en cualquier texto tomista sobre la ley natural. Simplemente, opinamos que hay algunos mal entendidos respecto a este tema que luego dificultan su análisis.

En primer lugar, hay un tema habitualmente olvidado, de consecuencias importantísimas. Santo Tomás no habla sólo de ley natural, sino también de ley humana. Es muy sabido que esta última no debe oponerse a la ley natural,[3] y no negamos la importancia de esto último; al contrario, es el fundamento iusnaturalista para declarar ilegítimo, ipso facto, todo acto legislativo humano que atente contra los derechos individuales que emanan de la ley natural. Sin embargo, hay muchos debates que transcurren por otro lado. ¿Qué hace un defensor de los derechos individuales frente a acciones humanas que son inmorales según la ley natural? He aquí cuando concepciones más autoritarias parecen encontrar una debilidad en los liberales que decimos basarnos en la ley natural. Esta última no autoriza a *no* buscar la verdad sobre Dios, por ejemplo. Un liberal con otros fundamentos no tendría problema: que todos hagan lo que quieran mientras no molesten la autonomía individual del vecino. Pero esa no es la posición del liberal que tiene una cosmovisión cristiana. ¿Luego?

Se olvida en esos casos que la ley humana no pena todo lo que la ley natural sí, porque está promulgada para una sociedad en la cual los seres humanos no son en general ni santos ni criminales absolutos. Y el caso es que esto fue dicho explícitamente por Santo Tomás, y no de modo marginal: 'La ley humana se establece para una multitud de hombres, en la cual la mayor parte no son hombres perfectos en la virtud. Y así la ley natural no prohíbe todos los vicios, de los que se abstiene un hombre virtuoso; sino solo se prohíben los más graves, de los cuales es más posible abstenerse a la mayor parte de los hombres, especialmente aquellas cosas que son para el perjuicio de los demás, sin cuya prohibición la sociedad no se podría conservar, como son los homicidios, hurtos, y otros vicios semejantes'.[4]

Como vemos, hay en la ley humana un margen de tolerancia que resulta de la conciencia de la natura

1 Doctor en Filosofía. Profesor visitante en la Universidad Francisco Marroquín.

2 Este ensayo es la ponencia que para estudiantes de Derecho dimos el 4-8-1999 en la Universidad Francisco Marroquín. La hemos modificado muy levemente para adecuarla a las exigencias de una revista académica. Agradecemos enormemente al Dr. Eduardo Mayora la oportunidad de escribir en tan prestigioso Journal.

3 Sobre el famoso debate de si una ley humana contraria a la ley natural puede llamarse ley, ver Sto. Tomas, II-II, 57°, 1, ad 1: 'se llama finalmente también derecho aquello que se da aquel cuyo oficio es hacer justicia, aunque el resultado le sea inicuo' (en G.J. Bidart Campos, 1983:155). Bidart Campos interpreta esa expresión de Tomás como una alusión a la sentencia injusta.

4 ST, I-II, Q. 96, a. 2c.

leza humana, que Tomás sabía caída por el pecado original, y la escuela escocesa posterior también lo sabía pero por una simple empatía de la naturaleza humana.[5] Esto es importantísimo porque es fuente de un derecho humano fundamental, olvidado por muchos: la intimidad. Toda persona tiene derecho a la ausencia de coacción sobre aquellas acciones privadas que no violen derechos de terceros ni el orden y/o moral pública.[6] El liberal cristiano no tiene por qué recurrir al indiferentismo moral para respetar la intimidad de las personas. Al contrario, tiene conciencia de su deber de respetar la conciencia del otro, de lo cual se deriva el derecho a la intimidad. Este es un punto fundamental que permite superar la antinomia entre un autoritarismo que, fundado en la moral, tema a la libertad; y un liberalismo fundado en el indiferentismo moral. El liberal cristiano no tiene esa disyuntiva. Y la base es Santo Tomás de Aquino.

En segundo lugar, alguien puede preguntar por el alcance de esa tolerancia. ¿Es universal, definible de una vez y para siempre? No. En todo acto humano de promulgación de la ley hay un acto de prudencia, esto es, una adecuación de las normas universales al caso concreto y particular. Esto, en la tradición de Santo Tomás, es esencial.[7] No sólo su filosofía del derecho no se entiende sin este elemento, sino nada de su filosofía moral. En el caso de la ley humana, es el hábito de la prudencia el que determina hasta dónde debe alcanzar el acto de tolerancia, en función de circunstancias diversas de lugar y tiempo. Es por esto que no puede haber legislaciones humanas iguales para todo lugar y tiempo, y Popper es el liberal que ha advertido contra el racionalismo latente en algún liberalismo que pretenda lo contrario.[8] Volviendo a Tomás, él contesta claramente a la objeción de que no todas las leyes humanas son iguales cuando, sin embargo, se derivan de una misma, la ley natural: '[...] no todos los principios comunes de la ley natural pueden aplicarse de igual manera a todos los hombres, por la gran variedad de circunstancias. Y de ahí provienen las diversas leyes positivas según los diversos pueblos'.[9] Esto es importantísimo, como veremos, para una concepción evolutiva de la ley. No hay en Tomás una deducción racionalista de la ley natural, y menos de la ley humana, sin este acto de prudencia. Retomaremos más adelante esta cuestión.

2- La cooperación social

Ya hemos visto que la tolerancia y su aplicación prudencial no sólo nada tiene de contradictorio, sino que está incluido en el análisis de Tomás de la ley natural y ello permite afirmar los derechos individuales más el derecho fundamental a la intimidad sin necesidad de ningún agnosticismo moral. Ahora bien, muchos afirman que la ley natural nada tiene que ver con la noción de cooperación social y utilidad social que aparece en Mises, pues éste la contrapone con la ley natural.

Hay una norma fenomenológica básica: una cosa es lo que los autores dicen, y otra cosa es cómo son las cosas en sí. Independientemente de lo afirmado por Mises,[10] su noción de cooperación social está incluida dentro de la ley natural de Tomás. En efecto: Mises sostiene que la cooperación social se da cuando se abandona la competencia biológica y se pasa a la cooperación social,[11] donde según la ley de división del trabajo todos intercambian sus bienes y

5 Sobre la escuela escocesa, ver E. Gallo, 1987. Este aspecto de la naturaleza humana ha sido destacado por Juan Pablo II en Centesimus annus, Nº 25.

6 Así estaba establecido en la Constitución Argentina de 1853 en su art. 19. Habitualmente, el tema de la 'moral pública' es un problema para ciertas tradiciones liberales. No para la nuestra, por lo que expondremos a continuación.

7 Sin prudencia no hay acto moralmente bueno en Tomás de Aquino. Todo acto bueno, para ser tal, debe cualificado por el hábito de la prudencia, que adapta las normas generales al caso particular.

8 Una Utopía Liberal -esto es, un estado racionalmente planeado a partir de una tabula rasa sin tradiciones- es una imposibilidad. Pues el principio liberal exige que las limitaciones a la libertad de cada uno que la vida social hace necesarias deben ser reducidas a un mínimo e igualadas todo lo posible (Kant). Pero, ¿cómo podemos aplicar a la vida real un principio a priori semejante? Debemos impedir a un pianista que estudie o debemos privar a su vecino de una siesta tranquila? Esos problemas sólo pueden ser resueltos en la práctica apelando a las tradiciones y costumbres existentes y a un tradicional sentido de justicia; a la ley común, como se la llama en Gran Bretaña, y a la apreciación equitativa de un juez imparcial' (Karl Popper, 1983).

9 ST, I-II, Q. 95, a. 2 ad 3.

10 Ludwig von Mises, 1968: cap. 27, punto 3.

11 Ludwig von Mises, 1968: cap. VIII.

servicios en paz, pues la presencia de uno más implica, en un mercado libre, una mayor productividad.[12] Por supuesto que hay diferencias con Tomás dados siete siglos de distancia más la mediación de la ciencia económica que manejaba Mises, pero la idea central se encuentra explícita en Tomás. Primero, que lo que es conveniente para la sociedad es conveniente para la naturaleza humana y, por ende, conforme a la ley natural: 'Si algo es natural a alguno, debe también serle natural aquello sin lo cual ese algo no puede tenerse; pues la naturaleza no falla en las cosas necesarias. Mas es natural al hombre el que sea animal social; lo cual lo demuestra el hecho de que un sólo hombre no basta para todas las cosas que son necesarias a la vida humana. Por lo tanto aquellas cosas sin las cuales no puede conservarse la sociedad humana son naturalmente convenientes al hombre'.[13] Esto es importantísimo para la elaboración de derechos naturales secundarios donde la deducción pase por la utilidad social.

Segundo, está presente, en Tomás, la relación entre escasez de recursos y sociabilidad natural del hombre:

> '[...] El hombre es por naturaleza un animal político o social; cosa que ciertamente se pone de manifiesto en que un sólo hombre no se bastaría a sí mismo, si viviese solo, en razón de que la naturaleza en muy pocas cosas ha provisto al hombre suficientemente, dándole una razón por la cual pueda procurarse las cosas necesarias para la vida, como ser el alimento, el vestido y otras semejantes, para obrar todas las cuales no basta un sólo hombre; por lo cual ha sido naturalmente dispuesto que el hombre viva en sociedad'.[14]

La conclusión es clara: la ley natural no excluye, sino que incluye, la fundamentación de ciertos derechos en la cooperación social y lo que es útil, con 'necesidad de medio', para ello. Por supuesto, el estado de las ciencias sociales en las diversas épocas producirá una evolución 'per accidentes' en la toma de conciencia de ciertas cosas.[15] Pero lo esencial es de algún modo perenne. Y lo esencial es que ley natural y cooperación social se incluyen (la primera a la segunda); no se excluyen.

3- El orden espontáneo

Como ya hemos dicho en otras oportunidades,[16] la noción de orden espontáneo de Hayek incluye -aun-

12 Esto que acabamos de decir tiene especial relevancia para nuestro tema. Los católicos que rechazan todo diálogo con la economía de mercado y pregonan el socialismo se enfrentan con un delicado problema cuando analizan el tema de la superpoblación. Es obvio que no pueden recomendar políticas anti-natalidad como las recomendadas por las Naciones Unidas (unidas para el estatismo, como dice Alberto Benegas Lynch [h]). Entonces, como creen que a mayor población, menor riqueza para repartir, entonces pregonan virtudes heroicas como la solidaridad para quien va a competir con puestos de trabajo y el pan cotidiano. A lo cual muchos asienten, pero luego niegan en su vida concreta, como siempre pasa cuando un sistema social intenta basarse en virtudes heroicas ('supererogatorias', como dice Mariano Grondona, en Hacia una teoría del desarrollo: las condiciones culturales del desarrollo económico, 1999). Pero ni Mises, ni Hayek, ni ningún economista de la escuela austriaca vieron en el aumento de la población un problema, sino todo lo contrario. Es claro que el aumento de la población implicara una baja en los salarios reales si la productividad está estancada por impuestos confiscatorios, inflación y regulaciones de todo tipo. Pero 'basta con' eliminar la mayor parte de los impuestos, sobre todo el impuesto a las ganancias; suspender todo tipo de regulaciones a priori en las relaciones comerciales; eliminar absolutamente todo tipo de aranceles y todo tipo de pasaportes, visas, aduanas y todo lo que dificulte la libre circulación de capitales y personas; privatizar realmente a todas las empresas de bienes y servicios sin privilegios (protecciones legales) ni prebendas de ningún tipo; liberar la moneda eliminando el curso forzoso (Hayek), y entonces, cada nuevo integrante de la población implicará un aumento en la productividad. De ese modo, todos los refugiados, víctimas de guerras y odios, podrían ingresar a ese mercado desregulado y lo primero que harían (no necesariamente, desde luego, pero menos aun con millones de regulaciones e intervenciones) sería ponerse a trabajar, sin trabas, sin protecciones, en libertad. Y formarían así parte de ese proceso de acumulación de capital que sólo creciendo a un ritmo mayor que la población puede implicar un aumento generalizado en los salarios reales (Mises). Para lo cual hay que liberar el mercado, precisamente. Muchos católicos no entienden esto (y no por católicos), y eso repercute directamente sobre mucha gente, que sin analogías, lloran en la impotencia de sus hijos muertos por la desnutrición y las enfermedades, en lo que era la puerta de sus hogares destrozados por la guerra. Por eso pues basta con entre comillas entre las condiciones culturales de las que habla Grondona está que todo esto se entienda. Esto es, que nuestra concepción, nuestra hermenéutica del mundo, cambie. Y, nunca mejor dicho, roguemos a Dios para que ello suceda.

13 SCG, III, 129. Versión castellana de María Mercedes Bergada, en la edición del Club de Lectores, Buenos Aires, 1951.

14 SCG, III, 85. Idem versión castellana.

15 La imposibilidad de cálculo económico sin propiedad privada de los medios de producción (Mises) es un ejemplo.

16 Gabriel Zanotti, 1993, 1996 y 1997.

que él lo haya negado[17] la noción de Providencia tal como la explica Sto. Tomás. Si hay un orden tal que los seres humanos, con conocimiento disperso, tienden a un resultado global que ninguno de ellos podría haberlo planeado, quien planifica ese proceso es Dios, que sostiene a todas las causas segundas en su ser y en su operar.[18]

Ahora bien, se han discutido mucho las opiniones de Hayek con respecto a la evolución de la ley (el common law) y las instituciones humanas. No podemos en tan poco espacio dirimir esos debates,[19] aunque adelantamos que la misma epistemología de Hayek[20] prohíbe que *a priori de circunstancias históricas* se establezca una preferencia *in concreto* por sistemas codificados o no, aunque se pueda establecer in abstracto; y también prohíbe, esa misma espistemología, que se prediga que las mismas instituciones evolucionarán en todas partes y siempre bien. Eso impide al menos algunos malentendidos graves. Pero lo que ahora nos interesa es destacar el punto de unión entre Tomás y el orden espontáneo.

No se trata sólo de decir que, *si* la ley (*law*)[21] surge espontáneamente, entonces ello no será contradictorio con una noción de ley natural que tenga su base en la naturaleza humana. La relación es más profunda. Se trata de afirmar, in abstracto, que la relación entre la ley como orden espontáneo y Tomás es mucho mayor que su relación con un sistema codificado y con un constructivismo en las instituciones humanas.

Esa afirmación se basa, en gran parte, en elementos que hemos visto en el primer punto. Si la ley humana se basa en actos de prudencia; si estos actos de prudencia jurídica implican delimitaciones diversas para el grado de tolerancia de la ley, ello choca con una concepción racionalista de ley natural,[22] en la cual no sólo habría una contraposición con la ley eterna (problema que tiene también Hayek, pero no por racionalista constructivista,[23] sino por su neokantismo)[24] sino sobre todo una pretensión de legislar deductivamente, a priori de circunstancias de lugar y tiempo, sobre ciertas áreas. Lo cual lleva a una mentalidad intervencionista.[25] ¿En qué sentido? *En el sentido de pretender hacer una especie de reglamento a priori del surgimiento de los conflictos, y no confiar en la resolución de los mismos vía judicial una vez que éstos se han planteado.*[26] Como decía Popper: 'Debemos impedir a un pianista que estudie o debemos

17 Afortunadamente, no puso en eso su insistencia, pero lo hizo en una de sus principales obras (Hayek, 1979-II: cap. VIII).

18 SCG, III, caps. 71 a 94; ST, I, Q. 44, 45 y 46, y I, Q. 104 y 105.

19 Ver E. Zimmermann, 1987. Con respecto al diálogo entre la tradición iusnaturalista y la hayekiana, poco después de presentar esta ponencia tuvimos la oportunidad de leer el libro Iusnaturalismo y órdenes espontáneos, de Eduardo Mayora (1998).

20 Ver, al respecto, Hayek 1979b y 1967.

21 Ponemos 'law' entre paréntesis porque con esa palabra Hayek se está refiriendo al Derecho, esto es, normas generales de conducta justa donde se encuentran los derechos individuales, que no debe ser confundido con 'legislación', que son las reglamentaciones que emergen de los poderes legislativos. En los países latinos damos en general este último sentido al término 'ley'.

22 Al respecto, ver Nicola Abbagnano, 1978-II.

23 Si hay algo que está diseminado en todas las obras de Hayek, es su crítica al racionalismo constructivista. Conjeturo que muchos amigos míos tomistas me dirían: 'sí, pero él también incurrió en errores del racionalismo iluminista'. Sí, claro, todos estos pensadores son fruto de una modernidad mezclada con el iluminismo, y a pesar de ello han criticado lo peor del iluminismo (la pretensión de construir una sociedad a priori de sus tradiciones, por ejemplo). ¿Qué pretenden? ¿Qué más pretenden? Un certificado de pureza metafísica tomista firmado por Cornelio Fabro?

24 Que se observa sobre todo en su ensayo 'La primacía de lo abstracto' (1981).

25 Al respecto ver R. Rojas, 1990.

26 En la Argentina, tan llena de reglamentos a priori, que los juristas llaman códigos, esta mentalidad está tan extendida, que a las personas les resulta inconcebible una determinada actividad sin una 'ley', código o reglamento que la estructure previamente. Supongamos que en general, en los comercios minoristas, surgiera la costumbre de instalar determinadas luces para embellecer al lugar. Si las luces en cuestión son muchas, o su instalación causa tales o cuales problemas, el clamor general será un reglamento municipal para los mismos. No se concibe otra cosa. Cuando, en realidad, si la instalación en cuestión es conflictiva con algún derecho, lo 'natural' sería ir a un juez para que éste dictamine. Esto es esencial para la progresiva internalización de externalidades negativas en una sociedad libre. In abstracto, una sociedad libre sólo necesita una constitución federal y, tal vez, un código penal federal, como mucho. Dadas esas pautas generales, por qué o para qué un código civil, comercial, de industria, de minería, etc? In concreto, la dificultad de lo que estamos diciendo es que la mentalidad contraria está tan arraigada que la sola propuesta de esto sería considerada la de un lunático total. Uno no se enfrentaría sólo con la dirigencia política, sino con toda la población en general.

privar a un vecino de una siesta tranquila? Estos problemas sólo pueden ser resueltos en la práctica apelando a las tradiciones y costumbres existentes [...]'[27]

Pues bien: in abstracto, esa mentalidad apriorista en el orden jurídico deja de lado la prudencia, las infinitas circunstancias que sólo una acumulación paulatina de sentencias judiciales puede limitadamente tratar. Y si se deja de lado la prudencia, se deja de lado un aspecto esencial de la filosofía del derecho de Santo Tomás. Decimos in abstracto porque, en lo concreto de la historia, en lo concreto de las circunstancias y las costumbres, los sistemas codificados pueden funcionar, a pesar de ellos mismos.

Con respecto al constructivismo en las instituciones humanas, la tentación común a todos ellos -aún en el caso de lo que se quiera 'construir' sea una sociedad liberal- es que una sola mente humana puede planear una sociedad ideal. Ese es el punto. Hayek no se opone a propuestas concretas para mejorar el orden social; no hay en él un tradicionalismo irracionalista.[28] Lo que hay es la conciencia de que las mejores propuestas no son sino ríos que conducen a mares desconocidos para cualquier ser humano en particular, y sólo conocidos -agregamos nosotros- por Dios. Y eso está basado en la limitación del conocimiento humano. Esa limitación del conocimiento es perfectamente compatible con las bases del realismo moderado de Santo Tomás, donde sólo Dios conoce absolutamente las esencias y el orden del universo. La evolución progresiva de las instituciones humanas es perfectamente coherente con una armonía razón/fe como la de Santo Tomás, en la cual la inteligencia humana, mediante su prudencia, es fuente de esperanza para un mejoramiento progresivo de este mundo; pero, a su vez, lo limitado de su conocimiento, junto con la herida del pecado, implica una advertencia para cualquier grupo de autoiluminados que en nombre de las mejores intenciones diseñen a priori una sociedad perfecta, e intenten borrar por la fuerza a todo lo que no encaja con su esquema. Actitud tan fuertemente idealista no encuentra fundamento alguno en la gnoseología de Santo Tomás de Aquino.[29]

Conclusión

La ley natural de Santo Tomás nada tiene que ver con un racionalismo constructivista. Incluye en sí tanto la noción de la cooperación social como la noción de una evolución progresiva del orden social, fundado en la prudencia y en la tolerancia. Lo cual tiene mucho que ver con el diálogo entre tradiciones que a veces padecen de graves malentendidos.

Bibliografía

Abbagnano, Nicola
1978 *Historia de la Filosofía*. 2 tomos. Barcelona: Montaner y Simón.

Bidart Campos, G.J.
1983 *Valor justicia y derecho natural*. Buenos Aires: Ediar.

Gallo, E.
1987 'La tradición del orden social espontáneo'. *Libertas* 6.

Grondona, Mariano
1999 *Hacia una teoría del desarrollo: las condiciones culturales del desarrollo económico*. Buenos Aires: Ariel.

Hayek, Friedrich A.
1979a *Derecho, Legislación y Libertad*. Madrid: Unión Editorial.
1979b 'Scientism and the Study of Society' [1942] *The Counter-Revolution of Science*. Indianapolis: Liberty Press
1967 'The Theory of Complex Phenomena' [1964] *Studies in Philosophy, Politics and Economics* Chicago: University of Chicago Press.
1981 'La primacía de lo abstracto' [1969]. *Nuevos estudios en filosofía, política, economía e historia de las ideas*. Buenos Aires. Eudeba

Mayora, Eduardo
1998 *Insnaturalismo y ordenes espontaneos*. Guate

27 Ver nota 5.

28 El mismo propuso una reforma institucional importante, en el tomo III de Derecho, Legislacion y Libertad. No importa debatir ahora si la propuesta fue acertada o no: lo importante es ver que no hay contradiccion entre proponer reformas mientras estas no sean utopías de la sociedad perfecta.

29 Al respecto es importante el libro de Spaemann, Crítica de las utopías políticas.

mala: Facultad de Derecho, Universidad Francisco Marroquín.

Popper, Karl

1954 'La opinión pública y los principios liberales'. *Mont Pelerin Society.*

1983 'La opinión pública y los principios liberales'. *Conjeturas y refutaciones.* Barcelona: Paidós.

Rojas, R.

1990 'El orden jurídico espontáneo'. *Libertas*, Nº 13.

Spaemann

1980 *Crítica de las utopías políticas.* Navarra: Eunsa.

Von Mises, Ludwig

1968 *La acción humana.* Madrid: Sopec.

Zanotti, Gabriel

1993 'Hayek y la filosofía cristiana'. *Estudios Públicos* Nº 50

1996 'Caminos abiertos I'. *Libertas* (25)

1997 *Epistemología da economía.* Porto Alegre: Pontificia Universidade Catolica Do Rio Grande Do Sul.

Zimmermann, E.

1987 'Hayek, la evolución cultural y sus críticos'. *Libertas*, Nº 6.

Ninguna sociedad puede existir, si no impera en algún grado el respeto a las leyes; pero es el caso que lo que da más seguridad para que sean respetadas las leyes, es que sean respetables.

Frédéric Bastiat

RAFAEL TERMES[1]

Etica y mundo de los negocios

Sumario

1- Un poco de historia
2- La ruptura del 'método' en la modernidad
3- La actitud de los empresarios y los moralistas
4- Los códigos éticos
5- Los códigos éticos y la ética
6- La norma moral
7- La ética realista
8- Las éticas de la modernidad
9- El subjetivismo
10- La verdadera razón de la ética empresarial
11- Los postulados de la ética realista
12- Aplicación de los postulados a los objetivos empresariales
13- El valor de ser persona
14- La coherencia entre mensaje y comportamiento
15- La corrupción. Soborno y extorsión
16- Ceder a la extorsión para obtener un derecho
17- La ética no es un ideal inasequible
18- La lucha para el saneamiento del ambiente

En los últimos años la ética se ha puesto de actualidad. De manera especial, aunque no exclusiva, el énfasis de este renacimiento de la inquietud moral se pone en las relaciones entre economía y ética y, de forma más concreta, entre empresa y ética, lo cual es muy lógico no sólo por la importancia de la empresa como célula vital de la sociedad, sino sobre todo porque los dirigentes empresariales son los que, sabiéndolo o sin saberlo, van construyendo el futuro, ya que la realidad así lo exige.

Desde luego que esta eclosión de las relaciones entre economía y ética debe ser recibida con satisfacción, porque las cosas no han sido siempre así o, más exactamente, no han sido así durante un largo período cuyo inicio puede situarse aproximadamente alrededor de 1780.

1- Un poco de historia

Durante siglos, economía y moral anduvieron de pareja y cuando, en el siglo XVI, los doctores de nuestra Escuela de Salamanca, desde el doble conocimiento de moral y economía, sentenciaban, por ejemplo, que el *'precio justo' era el precio de mercado, libremente debatido entre un número suficientemente grande de compradores y vendedores, en ausencia de violencia, fraude o dolo*, todo el mundo lo aceptaba. Porque los comerciantes o negociantes de aquella época podían obrar mal, pero sabían que lo hacían y no pretendían ni justificarse ni excusarse. Era un mundo en el que, al lado de muchas cosas indeseables, afortunadamente arrumbadas, el imperio de la moral, por lo menos conceptualmente, estaba plenamente asentado. En esta concepción, que ensambla economía y moral, vivió y trabajó Adam Smith, príncipe de los economistas clásicos, que fue precisamente profesor de filosofía moral en la Universidad de Glasgow, como lo habían hecho, con anterioridad a él, tanto Aristóteles como Tomás de Aquino.

2- La ruptura del 'método' en la modernidad

Pero en la evolución del pensamiento filosófico, hubo un momento, a finales del siglo XVIII, en el que se

1 Doctor *Honoris causa* de la Universidad Francisco Marroquín. Director del IESE, Universidad de Navarra.

produjo la ruptura. Hasta Adam Smith, la economía era una parte de la filosofía moral; de hecho Smith publica su *Teoría de los Sentimientos Morales* bastante antes de dar a luz *La Riqueza de las Naciones*, aunque ésta sea la obra por la que es universalmente conocido. Después de Adam Smith, especialmente a partir de Ricardo, el cuerpo doctrinal se escinde y el estudio de la economía *prescinde* de la moral.

El resultado de este cambio es que durante más de dos siglos, las relaciones entre economía y moral han sido inexistentes. Mejor dicho, los economistas, con unas pocas excepciones, no consideraban que existiese ninguna relación relevante entre economía y moral.

Esta postura produjo, *en el campo* de las cuestiones sociales, la división entre *economía*, *ciencia positiva* y *moral*, *doctrina normativa*. El *ser* y el *deber ser* no podían mezclarse y, por lo tanto, a la moral se le negaba todo papel. Las reglas de conducta para lo que *debe ser* formuladas por la moral, no entraban en la economía porque estas reglas, se decía, no tenían nada que ver con la *realidad*; eran resultado de juicios de valor, reflejo de *actitudes* ideológicas o sociológicas, pero nunca objeto posible de un *análisis científico*. En resumen, los economistas afirmaban que la moral no tenía nada que aportar a la economía y las recomendaciones que aquélla pudiera hacer eran tenidas, a lo sumo, por bien intencionadas pero, por lo general, inútiles y aun perniciosas para el buen funcionamiento de la economía. Obsérvese que esta actitud puede encontrarse todavía hoy en los que se consideran herederos del *pensamiento moderno*.

3- La actitud de los empresarios y los moralistas

Por otro lado, la actitud de los *directivos de las empresas*, no era, por lo general, más proclive a la moral que la de los estudiosos de la economía. La moral se veía como una teoría edificada de espaldas a la *praxis* diaria del mercado y los negocios. Las recomendaciones de la moral eran muy bonitas, idealmente aceptables por todos, pero, lamentablemente -se pensaba- no se podían poner en práctica, porque resultaban incompatibles con las inexorables leyes de la competencia, de la innovación, eficacia, de la autoridad y del beneficio.

Finalmente, la disposición de los moralistas tampoco se prestaba al entendimiento entre economía y moral. Desgraciadamente, la preparación económica de los estudiosos de la moral, que fue muy alta, en la escolástica tardía, se había degradado enormemente. Por lo general, los moralistas no sólo desconocían prácticamente todo de las leyes económicas y su núcleo invariante, sino que ni siquiera entendían desde el lenguaje de los economistas y, al oírles hablar, llegaban a la conclusión de que el mundo de la economía se basaba en principios *intrínsecamente inmorales*.

Se comprende fácilmente que, en estas condiciones, el diálogo entre las tres partes citadas se convirtiera pronto en un diálogo de sordos, máxime cuando, en la práctica, si un empresario que se encontraba ante una complicada situación de suspensión de pagos, en que se barajan cuestiones como la supervivencia de la empresa, el mantenimiento de su patrimonio familiar, el retraso en el pago de sus deudas, quizás problemas de ocultación fiscal, una posible reducción de plantilla, etc., sentía la preocupación de resolver sus problemas de conformidad con la moral y consultaba a un moralista, lo más probable es que éste, totalmente desconocedor de las realidades económicas y empresariales, le defraudara totalmente si el empresario esperaba, como es de suponer, algo más que vagas declaraciones.

Hoy vemos que las posturas de los economistas, empresarios y moralistas, sentados a los lados de una imaginaria mesa triangular, han *cambiado radicalmente* y todos los concernidos declaran que es necesario la *cooperación* entre economía y ética. Indagar en las causas de un tal cambio, nos llevaría demasiado tiempo. Más vale que aquél de que disponemos lo empleemos en ver en qué debe consistir esta reclamada relación entre economía y ética.

4- Los códigos éticos

Lo primero que cabe decir es que muchos empresarios, preocupados por la proliferación de escándalos financieros y por las conductas inmorales de ejecutivos de distintos niveles, han decidido implantar códigos de comportamiento ético, con el propósito de atajar estos desmanes, por lo menos, en el ámbito de la empresa cuya responsabilidad les incumbe.

Un código ético, tal vez convenga precisarlo, es, o debe ser, un documento en el que la empresa establece unos objetivos de carácter ético, en relación con los aportantes de capital de riesgo o accionistas, los trabajadores y los directivos, es decir, la interioridad de la empresa; así como en relación con los clientes, proveedores, instituciones financieras, comunidad local y entorno ecológico en que la empresa se ubica, administraciones públicas y economía nacional en su conjunto. Para formular los objetivos enumerados, un código ético debe empezar por definir: primero, la misión de la empresa que, si bien no forma parte del código, lo predetermina; segundo, los principios éticos en que los objetivos se fundamentan; y finalmente, la concreción -a título aclarativo pero no exhaustivo- de aquella misión y de esos objetivos en las áreas específicas de principal interés. Es normal, por otra parte, que un código ético se dote de algunas reglas de procedimiento, para canalizar reclamaciones, admoniciones y resolución de conflictos.

5- Los códigos éticos y la ética

Ahora bien, ¿cuál es el resultado de estos códigos? Su implantación ¿equivale a la implantación de la ética en la empresa?

Por cierto, ahora me doy cuenta de que hace rato que estamos hablando de ética, comportamientos éticos y códigos éticos, sin que nos hayamos parado a definir qué es la ética y qué hay que entender por comportamientos éticos. Y malo sería que los que dicen tener preocupación por la ética y sus códigos, no supieran realmente ni qué es la ética empresarial, ni la ética *tout court*. Cosa que, por lo que se me alcanza, es desgraciadamente muy fácil que suceda en no pocos casos.

Yo, por ejemplo, no puedo estar de acuerdo, y pienso que muchos otros tampoco, en aquella postura que pretende que la *ética empresarial es la ley, toda la ley, nada más que la ley*. La ley es necesaria para la convivencia, pero, desde el punto de vista ético, no es suficiente. Todos sabemos que, hoy más que nunca, grandes estafas pueden ser legalmente irreprochables. Tampoco puedo aceptar, sin muchas aclaraciones, la postura de los que opinan que *la ética empresarial pertenece a un campo distinto de la moral personal, ya que ésta*, dicen, *pertenece y opera en el ámbito restringido de la conciencia individual*. Para fundamentar estos dos desacuerdos que afectan, el uno, al contenido de la ética y, el otro, a su ámbito, pienso que no hay más remedio que asentar aceptable definición de 'ética', que, con ciertas precisiones en las que ahora no puedo entrar, es sinónimo de 'moral'.

6- La norma moral

La ética -en eso todos parecen estar de acuerdo- es la ciencia que se refiere al estudio filosófico de la conducta humana, considerada en su conformidad o disconformidad con una norma. La ética califica lo que 'se hace' a la luz de lo que 'se debe hacer'; juzga al hombre como 'es' a la luz del hombre como 'debe ser'. Es más; dice cómo pasar del 'ser' al 'deber ser': este 'cómo pasar' es precisamente el papel de la norma, la ley, la regla de comportamiento para alcanzar el fin. Ahora bien, todos los fines implican una referencia al bien. Sin embargo, sobradamente sabemos que el hombre, en la apreciación de lo que apetece como bueno, puede errar y, de hecho, yerra frecuentemente.

A pesar de esta posibilidad de mala elección por parte de la libre voluntad del hombre, todos también parecen estar de acuerdo en que la conciencia del individuo -que constituye su más inviolable intimidad- es la norma próxima para formular un juicio práctico sobre lo que el hombre debe hacer o no hacer, o para valorar una acción ya realizada. Por esto decimos que el hombre está obligado a actuar en conciencia, aunque esta conciencia fuera errónea; invenciblemente errónea, se entiende.

Con lo que acabamos de decir, no hemos simplificado las cosas, sino todo lo contrario, ya que lo que hemos hecho ha sido ni más ni menos que suscitar el problema sobre la norma que es donde, precisamente, empiezan las discrepancias. ¿Debe ser la norma *autónoma* o *heteronoma*? Es decir, ¿se da el sujeto su propia ley o le viene dada desde fuera? En el primer supuesto, la calificación moral viene transferida a la voluntad, y no primariamente a los actos, de manera que la ética autónoma deriva en el imperativo formal.

El segundo supuesto, la heteronomía, plantea un subsiguiente problema, a saber, quien da la ley al

sujeto. Aunque los que tenemos la suerte de haber recibido el don de la fe cristiana, sabemos que la norma moral procede de Dios, creador de la naturaleza, si queremos dialogar con los ateos, los agnósticos o los simplemente deístas, que piensan que Dios no se mete en la historia y nosotros no tenemos derecho a meterle en ella, habrá que decir que el imperativo moral, lejos de ser el resultado arbitrario o caprichoso de la voluntad, deriva de los principios universales e inmutables que el hombre observa en su propia naturaleza -lo cual no está ni puede estar en contra de la fe- y que estos principios constituyen la regla remota del comportamiento moral.

7- La ética realista

Esta ética, así fundada, es la 'ética realista' que Antonio Millán-Puelles, en su obra *La libre afirmación de nuestro ser*, define como *la ética donde la realidad de lo que somos (es decir, lo que somos independientemente de lo que queramos ser, o hacer, o tal vez tener) sirve de fundamento general e inmediato del contenido de nuestros deberes*. A esta ética, dice Millán-Puelles, le cuadra además el significado vulgar del vocablo 'realista', precisamente porque al no tratarse de una pura teoría, una reflexión filosófica, sino precisamente de una ética normativa, esta ética y únicamente ella, es efectivamente practicable. Esta es la razón por la que, en mi opinión, solamente en una ética realista cabe asentar las condiciones de convivencia en la sociedad y las reglas de funcionamiento correcto del mundo de los negocios. Pero no adelantemos las conclusiones.

8- Las éticas de la modernidad

La ética realista, estuvo generalizadamente vigente, *grosso modo*, desde Aristóteles hasta la llegada de Descartes, siglo XVII, momento a partir del cual aparecen sucesivamente filosofías como el racionalismo, el empirismo, el idealismo y el positivismo. De estas filosofías derivan, en el plano práctico, las éticas *relativistas, subjetivistas, conseecuencialistas, proporcionalistas*, que, en el panorama contemporáneo, disputan el campo a la ética realista. En estas éticas las cosas no son como son, sino como las ve o las piensa el sujeto, y, en ellas, la norma del obrar no se deduce, como sucede en la ética realista, de aquellos principios generales y estables, que, precisamente por asentarse en la específica naturaleza del yo humano, determinan que nuestro comportamiento sea éticamente correcto; en estas éticas relativistas y subjetivistas -que precisamente por esto se vanaglorian de ser autónomas- la norma la establece arbitrariamente el sujeto, en un incorrecto ejercicio de la libertad de elección, decidiendo lo que quiere hacer -o no hacer- en unas concretas circunstancias de lugar y tiempo; habida cuenta de la intención que le mueve; y ponderadas, en el mejor de los supuestos, las consecuencias favorables y adversas de la acción. De esta forma, la calificación moral que deriva de la naturaleza propia del acto -lo que en la moral tradicional se llama el *finis operis*- ha quedado expulsada de estas clases de ética, que, en nombre de la libertad y el pluralismo, algunos nos predican, con exclusión de toda referencia a la verdad; la verdad del hombre, en primer lugar.

9- El subjetivismo

Para estas éticas, no hay acciones intrínsecamente malas o buenas: matar, robar, mentir, violentar, defraudar, prevaricar, extorsionar, corromper ni es bueno ni es malo; depende de la *intención* que yo tenga al hacerlo y de las *consecuencias* que se deriven de mi acción. Se me dirá, naturalmente, que pretendo demostrar algo por reducción al absurdo y que nadie, en su sano juicio, puede pretender avalar las acciones enumeradas; que para esto está la ley y que, en el mundo de los negocios, en las empresas, para esto están los códigos éticos, o las normas de comportamiento. Pero no se olvide que en la ética *subjetivista* y *relativista* que estamos analizando, al no existir el referente de los principios universales e inmutables, la norma para la convivencia es el resultado del consenso o de la opinión mayoritaria, que, por su propia naturaleza, es provisional, en la misma medida que el consenso y la mayoría son cambiantes.

Y esta *inestabilidad* de la ética subjetivista es la que puede hacer que una empresa con código ético no sea de verdad ética, si la ética escogida para la elaboración del código es una ética relativista. Quiero decir que, aún en el supuesto de que el código originalmente prohíba las acciones intrínsecamente incorrectas, como, por ejemplo, faltar a la veracidad en la

información sobre la situación financiera de la empresa, si la ética de los altos ejecutivos no pasa de la relativista, puede llegar un momento en el que, por haber cambiado las circunstancias -la competencia no lo hace- o las posibles consecuencias -bajaría la cotización de las acciones- la dirección decida modificar el código de forma que la información mentirosa deje de estar prohibida. Pueden darse, ciertamente, circunstancias en las que la 'responsabilidad' aconseje, y hasta exija, no decir la verdad o toda la verdad; pero ninguna circunstancia puede derribar la 'convicción' -si se tiene- de que no hay que mentir.

10- La verdadera razón de la ética empresarial

La primera consecuencia de lo dicho es que la actuación en el mundo de los negocios y, singularmente, la gestión de las empresas, ha de ser éticamente correcta no precisamente porque, como muchos dicen, la ética sea rentable para la entidad, sino pura y llanamente porque los negocios tienen lugar entre personas humanas y los hombres, en todas las situaciones y circunstancias, deben comportarse éticamente, con independencia de las consecuencias que se deriven de tal comportamiento. Es sin duda cierto que ser ético es rentable, por lo menos a largo plazo, pero esto no es la razón para ser éticos; esto no es más que una propiedad de las decisiones éticamente correctas.

11- Los postulados de la ética realista

Adoptar la ética realista significa muchas cosas:

La *primera* es que no hay una ética de empresa esencialmente distinta; no hay más que una ética que no varía según lugares, tiempos y ámbitos de actuación. La razón es que es éticamente correcto, y sólo lo es, aquel obrar que resulta conforme con la naturaleza que tenemos, y esta naturaleza no cambia por el hecho de que actuemos en el ámbito privado, familiar, social, empresarial o político. Lo cual no impide afirmar que, siendo la exigencia ética sustancialmente la misma en todos estos campos, tal exigencia se especifique en formas concretas en cada uno de ellos, de acuerdo con las características que le son propias.

La *segunda* es que el sujeto de la ética es la persona, no la empresa. La empresa no tiene responsabilidad ética, aunque puede tener responsabilidad jurídica.

La *tercera* es que la ética no siempre coincide con la legalidad. Ni todo lo ético es legal, ni todo lo legal es ético.

La *cuarta* es que la ética es una ciencia de carácter normativo. La ética nos dice, en términos generales, lo que hay que hacer y lo que hay que evitar, pero una vez conocido el criterio, hay que saber aplicarlo a casos concretos que, a menudo, son complejos.

La *quinta* es que la ética, salvadas las exigencias del bien común -que comprende, entre otras cosas, el respeto a los derechos de los demás y el orden público- no puede imponerse coactivamente ni en la vida privada, ni en la pública, ni en la empresarial. Sin embargo, una empresa puede tener definida su propia axiología, su sistema ético-cultural, al que, por el camino del ejemplo y la vivencia, se adhieran todas las personas que integran la empresa; así como tener definidas ciertas reglas de comportamiento que pueden ser exigidas y deben ser observadas por todos los que, habiéndolas conocido previamente, libremente las han aceptado.

La *sexta* y, para mí, la más importante, es que la ética realista es una ética de fines y medios. El fin último es la vida buena, es decir, la vida conforme al ser del hombre; a la dignidad que deriva de ser persona. Los medios para alcanzar este fin son las virtudes. Como es bien evidente, el enunciado del fin, en este caso la autorrealización como persona, no constituye una guía práctica para la acción. En cambio, sí lo es, por ejemplo, decir la verdad, explicar claramente lo que se hace y por qué se hace, mantener la palabra dada, cumplir el compromiso adquirido sobre el importe y la fecha de pago, desempeñar fiel y eficazmente el cometido profesional, remunerar justamente el trabajo, exigir el cumplimiento de los subordinados y ser leal con ellos, servir la calidad anunciada, sin disimular los defectos, y tantas otras cosas que son manifestaciones de las distintas *virtudes*. Hacerlo así siempre, tanto cuando es fácil como cuando es difícil, cuando todos lo hacen y cuando los demás no lo hacen, es poner en juego los medios para el fin. Porque las virtudes son *hábitos* que desarrollan las potencias operativas del hombre, es decir, que le llevan a *hacer* y a *hacer bien* lo que *hay que hacer*; y los *hábitos* se adquieren por *aprendizaje*, por la reiteración de los actos.

12- Aplicación de los postulados a los objetivos empresariales

La aplicación de estos postulados a los objetivos éticos elegidos por una empresa, formulados o no en un código de comportamiento, nos servirán para enjuiciar la calidad de estos objetivos. Voy a poner tres ejemplos que corresponden a tres niveles de exigencia ética.

Objetivo de la empresa A. Que exista *una honda preocupación, positiva y arraigada* para lograr que las acciones de todas las personas de la empresa, empezando por los directivos de mayor nivel, en todos los ámbitos, dentro y fuera de la empresa, en todas las circunstancias, sean siempre excelentes desde el punto de vista moral.

Objetivo de la empresa B. Que todas las personas de la empresa estén dispuestas a comportarse éticamente en las acciones que conciernen a la empresa.

Objetivo de la empresa C. Que en la empresa no se lleven a cabo acciones claramente inmorales y escandalosas.

Fácilmente se ve que solamente el objetivo de la empresa A está plenamente de acuerdo con las exigencias de la ética realista, ya que todas nuestras acciones tienen una dimensión ética. Tanto si estas acciones corresponden a la vida privada, a la pública o a la empresarial. Es evidente que el objetivo de la empresa A, como todos los objetivos, es eso: un objetivo; algo a lo que se tiende. Que se logre o no, forma parte de las contingencias de la vida; lo importante es que, sin desanimarse por los resultados cosechados, se tienda consistentemente al objetivo.

Los objetivos de la empresa B y de la empresa C son objetivos, a todas luces, no congruentes con la ética realista y denotan niveles crecientemente más bajos de sensibilidad ética, porque estas empresas no pretenden, en serio, ser plenamente éticas; les basta con serlo en ciertas cosas, hasta un cierto límite y en determinadas circunstancias. Los que formularon el objetivo de la empresa B, opinan, sin duda, que el comportamiento fuera de la empresa de sus empleados, incluidos los directivos, es algo que sólo a ellos les concierne y no tiene nada que ver con la empresa; lo que la empresa pretende es que sean éticos dentro de ella. Naturalmente, no estoy de acuerdo con esta postura. Se podrá o no podrá lograr que el comportamiento privado de los directivos y, en general, de todas las personas de la empresa sea moralmente correcto; pero una cosa es no lograrlo y otra es considerar que es irrelevante. Cada vez está más claro, a mi entender, que el que no se comporta éticamente en su vida privada, acabará comportándose incorrectamente dentro de la empresa. Esto no es más que un corolario de la tesis de la unidad de las virtudes; ya demostró el viejo filósofo que el intemperante acaba siendo necesariamente injusto.

Poco hay que decir de los redactores de los objetivos éticos de la supuesta empresa C. No les preocupa en absoluto la ética; bajo el pomposo título de código de comportamiento, lo único que quieren evitar es aquello que, en razón del escándalo que provocaría, les puede dañar económicamente. Si la corrupción les resulta rentable, y puede pasar oculta, no tendrán reparo en acudir a ella.

De aquí el poco entusiasmo que, como habréis observado, siento hacia los códigos éticos. Aunque pienso que no son estrictamente necesarios, no digo que no puedan ser útiles; pueden desde luego serlo. Pero lo que sin dudar afirmo es que, por muy acertados y detallados que sean, no lograrán el correcto funcionamiento de la empresa, si en sus gentes está ausente el ejercicio prudencial de todas las virtudes morales. Si los directivos y demás personas de la empresa están decididos a comportarse de forma conducente a valer más como persona, con independencia de que con esta actuación lleguen a tener más o menos cosas, sabrán perfectamente cómo han de actuar en todas las ocasiones y circunstancias, aunque no exista en su empresa ningún código de comportamiento que lo diga.

13- El valor de ser persona

El 'valor de ser persona' viene aumentado o reducido a consecuencia del efecto ético que, con el efecto económico y el efecto psicológico, son los tres efectos que produce todo acto humano. El efecto ético de los actos humanos, que es el que aquí primordialmente nos interesa, consiste, ni más ni menos, en el cambio que tiene lugar en el interior del sujeto a consecuencia del acto. Y este efecto interno es mucho más importante que los que se producen en el exterior. Cualquier cosa que el hombre haga, aunque esta cosa no dañe a sus semejantes, es más, aunque les produzca beneficios, si el acto -de acuerdo con la norma obje-

tiva convertida por la conciencia subjetiva en regla próxima del obrar- ha sido un acto éticamente incorrecto, el hombre se ha degradado, ha envilecido, en poco o en mucho, su dignidad de persona, aunque nada de esto haya traslucido al exterior. Y esta degradación de la persona, esta disminución del valor de ser persona, es mucho más importante que todo lo que el acto humano haya podido provocar exteriormente.

Es cierto que el que roba, miente o falta a la palabra dada causa un daño en el exterior, a terceros, pero antes, en el orden del ser, e incluso aunque el daño exterior por alguna razón no llegue a producirse, se causa un daño a sí mismo, al hacerse ladrón, mentiroso o desleal; y este daño es más importante que el daño material que ha causado, o podido causar, a los otros. Es posible, repito, que, a consecuencia de esta actuación éticamente incorrecta, el sujeto tenga más; pero valdrá menos, será menos hombre. Lo mismo puede decirse en relación con los otros: si yo, por ejemplo, induzco a mis viajantes a vender mercancías cuya calidad no corresponde a la que se ofrece, y ellos libremente se adhieren a la acción incorrecta, es posible que los beneficios de la empresa aumenten, pero no solamente habré deteriorado un poco o un mucho el valor de mi persona, sino que habré provocado el deterioro del valor de la persona de los otros.

De hecho, hay empresas que nunca han puesto por escrito sus compromisos éticos y, sin embargo, son éticamente excelentes. Lo cual no quiere decir que no sea bueno que tanto las reglas de comportamiento, para materias y situaciones concretas, como el sistema de sanciones, se formulen, de alguna manera, por escrito; será sin duda una ayuda. Ahora bien; si hay código, su formulación, su aplicación y, sobre todo, el comportamiento permanente de la empresa deben ser coherentes con el mensaje transmitido.

14- La coherencia entre mensaje y comportamiento

Veamos algunos ejemplos. Si el código ético de una empresa recoge su compromiso de vender sólo productos de calidad que respeten el medio ambiente, y luego se ponen a la venta productos en mal estado u obtenidos por procedimientos que perjudican a la naturaleza, se hace un daño al cliente, pero, sobre todo, se hace un daño a la ética, el código queda desacreditado y la reputación ética de la empresa en entredicho. Y también se hace un daño al personal de la empresa, que recibe un mensaje bien distinto del contenido en el código ético, a saber: para ganar dinero es admisible vender productos en mal estado, engañar al cliente, perjudicar al medio ambiente, incumplir los deberes de solidaridad, etc. Voluntaria o involuntariamente, el personal coopera en esta conducta inmoral.

Otro ejemplo. El director de una sucursal bancaria es remunerado graciosamente por un cliente que, de esta forma, espera recibir trato de favor en la cuantía de los créditos que recibe del banco. La operación se descubre, pero al mismo tiempo se comprueba que, si bien es cierto que los créditos otorgados al cliente rebasan los límites establecidos, no se ha causado ningún daño al banco porque los intereses aplicados son incluso superiores a los normales y los créditos han sido reembolsados oportunamente. Si el banco no castiga al director, porque no sólo no ha causado ningún perjuicio sino que hasta ha beneficiado a la empresa, se lanza un mensaje incoherente que dice: si van en beneficio de la empresa, las transgresiones éticas no tienen importancia.

La coherencia entre el comportamiento de la dirección y su mensaje o código ético, en alguna ocasión puede resultar difícil. Supongamos que un directivo ha defraudado, robado, a la empresa. La virtud de la justicia exige que se castigue al directivo, incluso con el despido; pero el respeto a la fama ajena exige que se procure evitar el escándalo. La prudencia conducirá probablemente a proponer al directivo que presente su dimisión, como mejor salida para el, si acepta, en vistas a encontrar nuevo empleo. Si no acepta, habra que buscar la manera de explicar el despido para que no parezca injustificado a los ojos del resto del personal, porque una cosa es no difamar a una persona y otra no dejar claro que en la empresa se vive la virtud de la justicia, no despidiendo sin causa, pero tambien no dejando de castigar las acciones no eticas.

15- La corrupción. Soborno y extorsión

Para terminar quisiera dedicar alguna atencion al 'jaque' a la ética empresarial derivado de la existencia de un ambiente corrupto que insensiblemente lo va invadiendo todo. Cuando el entorno es propicio a la reali-

zación de prácticas corruptas y, mucho más cuando la corrupción se ha adueñado de la sociedad, el directivo empresarial se ve sometido a dos tentaciones: el soborno y la extorsión; figuras éticamente incorrectas que, ambas, tienen una cara activa y una cara pasiva: sobornar y aceptar el soborno; extorsionar y ceder a la extorsión.

El motivo para acudir a alguna de estas prácticas suele ser el deseo de obtener algún beneficio, pero también el de evitar algún quebranto. La 'justificación' alegada para hacerlo, es que, en un ambiente corrupto, 'no hay más remedio' que aceptar las 'reglas del juego sucio', si se quiere sacar adelante la empresa o lograr el nivel de resultados que el mercado exige. Otros pretenden justificar el soborno diciendo que, en definitiva, no es más que una herramienta de marketing, que equivale a un coste comercial o al pago de un servicio, en un mercado feroz en el que 'todo el mundo hace lo que puede'. Finalmente, los que extorsionan o reciben el soborno, dicen que se trata de compensaciones a los bajos sueldos, de gratificaciones inherentes al cargo, o simplemente de una oportunidad que sería ridículo desaprovechar. Como se ve, tanto el motivo, como las justificaciones son de naturaleza económica; pero, si la empresa, es decir, las personas que la integran, pretenden ser éticas, las consideraciones económicas no pueden aislarse de las exigencias morales.

La respuesta a las tentaciones del ambiente corrupto constituye, hoy, una de las pruebas clave para juzgar de la moralidad de los que andan en el mundo de los negocios. Por ello, pienso que puede ser útil recordar brevemente las calificaciones morales atribuibles al soborno y a la extorsión, en sus dobles caras. Son éstas:

Aceptar un soborno para hacer algo en favor de otro, tanto si éste tiene derecho a ello como si no lo tiene, *es siempre una acción éticamente incorrecta* porque supone una *deslealtad* con la empresa o la administración a la que se está vinculado; una *injusticia* por falta de legítimo título de percepción; una *injusticia con los proveedores* en competencia; una *injusticia con la propia empresa* que soporta en el precio el importe del soborno o pierde el descuento que podría obtener; y finalmente un *atentado* al bien común al distorsionar el recto funcionamiento del mercado.

Ofrecer un soborno para obtener algo a lo que se tiene o no derecho, *es siempre una acción éticamente incorrecta* porque el sobornador, al tiempo que se hace un daño moral a sí mismo, induce al sobornado a una actuación *desleal* e *injusta*, y contribuye, por la repetición de actos, al *deterioro* moral de la sociedad.

Extorsionar, es decir, exigir dinero u otra dádiva para dar a cambio un trato de favor a alguien, o simplemente para hacer aquello que se tiene obligación de hacer, *es siempre éticamente incorrecto* porque supone *deslealtad* e *injusticia* con la organización a la que se está vinculado; *injusticia* con el extorsionado; *injusticia* a los terceros perjudicados por el trato de favor al extorsionado; y, finalmente, contribuir, por la vía del *mal ejemplo*, al empeoramiento del clima ético de la sociedad.

Sobornar, aceptar un soborno y extorsionar son *siempre* acciones intrínsecamente malas. En lo que se refiere a *la aceptación de la extorsión* la cosa no es tan simple y hay que proceder a algunos distingos. En primer lugar, en cuanto a la manera de presentarse, la extorsión puede ser *explícita*, cuando se propone claramente, y *tácita*, cuando se insinúa o cuando, por ser de dominio público su existencia, da paso a lo que parece ser un soborno. Es evidente que el hecho de ser explícita o tácita no hace variar la calificación moral del acto. Una segunda distinción es que, sea explícita o tácita, la extorsión puede hacerse para realizar algo a lo que el extorsionado no tiene derecho o algo a lo que el extorsionado sí tiene derecho. En el primer caso, por ejemplo, si un juez ofrece, mediante pago de dinero u otra dádiva, una sentencia injusta, cae por su base que no se puede acceder a la extorsión, puesto que sería aprobar una acción ilícita, cooperando activamente con ella, ya que si no se pagara el precio la acción no se realizaría.

16- Ceder a la extorsión para obtener un derecho

El segundo caso, aceptación de la extorsión para obtener algo a lo que se tiene derecho, pienso que es el que con más frecuencia se da y el que requiere mayores precisiones. Ceder a este tipo de extorsión no es provocar o aprobar una acción inmoral, sino soportarla. Por lo tanto, algunos se sienten inclinados a decir que es lícito aceptar esta clase de extorsión. Es verdad que, mientras la cooperación formal al mal, que supone su aprobación, nunca es lícita, la cooperación material no inmediata al mal puede serlo en casos más o menos extremos; pero no siempre.

Voy a insistir algo en esto porque la opinión que tiende a ser condescendiente se basa en el ya dicho

'no hay más remedio'. Y a veces, a primera vista, parece que es así. Hay situaciones muy lamentables en las que la corrupción está tan arraigada en el entorno empresarial que no es posible entrar en un negocio sin dar una 'comisión' a las personas implicadas en las correspondientes decisiones de compra o contratación y se sabe que todos los competidores lo hacen. Es posible que, en determinadas ocasiones, esto sea efectivamente así y, sin embargo, no se debe justificar fácilmente la condescendencia a la extorsión. En primer lugar, porque es obligación ética de los empresarios contribuir a la mejora del clima ético del país y accediendo a la extorsión porque 'todos lo hacen', no se contribuye más que a la mayor generalización de la corrupción. En segundo lugar, porque, en bastantes casos, la necesidad de acceder no es real, sino fruto de la rutina. De aquí que los empresarios competitivos y honrados, deban esforzarse, con imaginación y con audacia, para encontrar -y de hecho algunos las encuentran- alternativas de acción que compaginen la ética y la eficacia económica, evitando ceder a la extorsión.

En cualquier caso, las reglas éticas referidas a *la extorsión para obtener algo a lo que se tiene derecho* son:

a- No se debe ceder a una extorsión, ni siquiera para obtener un derecho, si existen alternativas viables que permiten evitarlo. Antes de decidir hay que explorar activamente la existencia de tales alternativas.

b- Comprobada la inviabilidad de otras alternativas, en algunas circunstancias, más o menos extremas, puede ser lícito someterse a una extorsión explícita o tácita para *obtener un derecho*. Para ello se requiere:

1- Que la contraprestación de la extorsión sea un acto intrínsecamente bueno o indiferente. En ninguna circunstancia puede ponerse en obra un acto intrínsecamente malo. Un ejemplo extremo lo aclara: si el precio pedido al extorsionado consistiera en matar a un enemigo del extorsionador, evidentemente no se puede ceder a la extorsión, aunque ésta fuera la única manera de evitar la segura quiebra de la empresa.

2- Que no haya posibilidad práctica de cambiar la situación, para impedir la actuación del extorsionador.

3- Que realmente exista extorsión explícita, o al menos tácita. En la extorsión tácita hay que tener pruebas razonables de que se trata de una situación generalizada en todo el sector, o conocer de fuentes fidedignas que el extorsionador realmente negará el derecho si no se paga la extorsión -aunque no lo pida directamente-. Ofrecer pagos 'bajo-mano', sin que exista extorsión tácita, sería un soborno y, por tanto, ilícito.

4- Que se actúe con la recta intención de querer conseguir un legítimo derecho. Por ejemplo, no ser discriminado por un funcionario o participar lealmente en la competición comercial.

5- Que existan razones morales objetivas (por ejemplo, continuidad de los puestos de trabajo), proporcionadas a los efectos malos indirectos, ocasionados por la acción del extorsionador: enriquecimiento ilícito del agente de compras, aumento de la corrupción en el ambiente, etc.

6- Que no se perjudique directamente a terceros, lo cual ocurre, por ejemplo, si la 'comisión' sirve para obtener el pedido sin ser la mejor oferta y no sólo para evitar una injusta marginación.

7- Que se evite la inducción a otros a actuar mal, al conocer que la empresa da 'comisiones' ilegítimas. Para ello conviene: primero, manifestar al extorsionador, en la medida de lo posible, el desagrado de verse obligado a actuar así; segundo, explicar a los colaboradores próximos y a las otras personas que conozcan o puedan conocer el asunto, las razones de necesidad por las que se ha dado 'comisión', la repugnancia a este tipo de operaciones y la falta de alternativas viables; y tercero, ante la posible difusión del hecho, prever los medios de defensa a que se podrá recurrir para defender la honorabilidad de las personas involucradas, a su pesar, en la operación.

17- La ética no es un ideal inasequible

Se podrá pensar que todo lo que he dicho hasta ahora, aparte de resultar muy complicado, sólo puede proponerse a un personaje ideal, ya que actuar de esta

forma supone un nivel heroico de comportamiento ético que no es exigible en términos generales. No es así. En primer lugar, porque no es complicado. Las reglas sobre el soborno y la extorsión que acabo de recordar no son reglas artificiales; su formulación se hace inmediatamente evidente al espíritu recto. Todos los que no están deformados por una conducta incoherente con su ser humano, o no pretenden acallar la voz de la conciencia para satisfacer sus desordenadas ambiciones, saben perfectamente lo que se debe hacer y lo que se debe omitir, así como lo que se puede hacer y lo que se puede no hacer, sin tener que acudir a un prontuario de soluciones éticas. En segundo lugar, la ética realista no es un ideal teórico, porque una persona es ética cuando intenta vivir de acuerdo con el modelo descrito, aunque no siempre lo logre; mas, aunque esté lejos de conseguirlo, si no abandona, sino que sigue luchando para aproximarse al modelo. Y esto es asequible a todos. Pienso que, muchas veces, no hacerlo así, pone de manifiesto un grado de frivolidad y comodidad que el empresario consciente no puede permitirse.

18- La lucha para el saneamiento del ambiente

La ética realista, la ética de las virtudes que estoy defendiendo no se refiere sólo a lo que no se debe hacer, sino que apunta hacia la excelencia. Los directivos empresariales que quieran de verdad ser éticos no pueden conformarse con resistir al entorno corrupto; deben luchar por cambiarlo y para ello hay varios caminos: primero, denunciando las actuaciones inmorales conocidas y probadas, cuando hay razonables esperanzas de que se actúe contra ellas; segundo, fomentando comportamientos éticos en la profesión o en el sector, sobre todo por la vía de la ejemplaridad; y tercero, actuando, junto con otros, para lograr un cambio cultural e, incluso, legislativo, mediante la promulgación y aplicación de leyes que ayuden a erradicar la corrupción.

Recurrir al 'no hay más remedio porque todos lo hacen' es en muchos casos una manera de cubrir la comodidad o la ineficiencia. Así como hay empresas que por sus deficientes características técnicas o financieras son candidatas natas al soborno y a la extorsión, si quieren sobrevivir, hay compañías, con alta calificación tecnológica y de gestión, que no tienen dificultades para vencer la extorsión y algunas de ellas se han podido permitir el lujo de no operar en países cuya presión para obtener la 'mordida' es muy fuerte.

Una vez más se comprueba que, si la dimensión ética debe formar parte de la cultura empresarial, con no menos razón la eficiencia profesional debe ser un indispensable componente de la preocupación ética del empresario. El directivo de empresa que no se esfuerza por adquirir la excelencia profesional, no es un directivo ético, por muy buenos sentimientos que piense tener.

Si bien sólo unos pocos son capaces de dar origen a una política, todos nosotros somos capaces de juzgarla.

Pericles de Atenas

Sección Estudiantil

ANA CRISTINA RODRÍGUEZ[1]

Contradicciones al Artículo 4º de la Constitución contenidas en los *Acuerdos de Paz*[*]

Sumario

Introducción
1- Antecedentes históricos
2- Análisis jurídico constitucional a los Acuerdos Sustantivos de Paz
3- Acuerdo Marco para la reanudación del proceso de negociación entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
4- Acuerdo Global sobre Derechos Humanos
5- Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado
6- Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca
7- El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas
8- Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria
9- Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática
10- Acuerdo sobre el definitivo cese al fuego
11- Acuerdo de las reformas constitucionales y el régimen electoral
12- Acuerdo sobre bases para la incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la legalidad
Conclusiones

Introducción

El tema de los Acuerdos de Paz nos ha presentado una serie de controversias en cuanto a su validez jurídica y posible cumplimiento. Finalizado el conflicto armado que dio origen a una infinidad de contravenciones, resulta necesario y prudente reflexionar acerca de los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz así como conocer los obstáculos que han impedido su cumplimiento y realización. La historia nos ha mostrado que la guerra[2] es una característica siempre presente de la vida humana. La Firma de la Paz, y los compromisos resultantes de ella, constituyen otra etapa, que a partir de 1997 presentó nuevos retos, y una oportunidad para fortalecer la democracia y el desarrollo sostenible en Guatemala. Estos Acuerdos han tenido y siguen teniendo sobre el comportamiento de las partes, la sociedad y la comunidad internacional repercusiones trascendentales. El alcance y finalidad de este ensayo consiste en hacer un análisis jurídico-constitucional al contenido de los Acuerdos de Paz y las posibles contradicciones al Artículo 4º de la Constitución.

En el momento en que el hombre accedió a vivir en compañía de otros hombres, debió ceder parte de su libertad primitiva para constituir una sociedad debidamente organizada. En otras palabras es como pagar una cuota para ingresar a formar parte de esta sociedad. Todas estas fracciones de libertad individual cedidas por cada uno de los miembros al ingresar en la sociedad, se unificaron y se transformaron en poder, el cual es ejercido por los dirigentes del grupo, porque estos son depositarios de aquel. Todo lo anterior nos conduce a lo que en tiempos modernos conocemos como Estado propiamente dicho. El Estado entre sus múltiples funciones tiene a su cargo salvaguardar nues

* Premio Herculano Aguirre, al mejor ensayo de Derecho.

1 Estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín

2 El Estado de guerra se da entre dos países. Internamente, entre dos facciones se da guerra civil. En el caso nuestro, se dio un enfrentamiento entre un grupo subversivo y el Gobierno establecido.

tros derechos fundamentales.[3] No será sino más adelante que se proporcionará un concepto de tales derechos fundamentales debido a la concepción errónea que mucha gente tiene acerca de ellos, siendo ésta la razón principal de su mal empleo. La libertad e igualdad mantienen una estrecha relación con la paz. La paz o sea la ausencia de una perpetua lucha de todos contra todos sólo es asequible si se establece un orden en el que haya un ente que monopolice la violencia y disponga de una organización de mando y coerción, la cual, sin embargo solo debe intervenir cuando lo autoricen las leyes debidamente promulgadas. El derecho se caracteriza no sólo por su fuerza coactiva sino por ser fuente generadora de derechos y obligaciones.[4] Todas estas relaciones se encuentran reguladas en un cuerpo escrito que todos conocemos como Constitución. Esta Ley Fundamental dentro de la jerarquía de nuestro ordenamiento jurídico, contempla en su primer capítulo varios derechos que el Estado garantiza, y además una serie de obligaciones que el Estado tiene frente al particular. Este trabajo no tiene por objeto discutir el deber del Estado de garantizar estos derechos. El problema jurídico-constitucional que pretende darse a relucir en este trabajo consiste en el análisis y consideración de los medios que la propia Constitución estatuye a efecto de hacer operante ese deber de garantizar los derechos fundamentales. No es la existencia ni la justificación del deber estatal la que se somete a argumentación, sino la forma o los medios para su cumplimiento. La comprensión de las incertidumbres que ahora nos ocupan se concreta en ocasiones a examinar el contraste entre legislación y política. Si el término política se comprende correctamente, podríamos empezar por expresar que el apremio sólo se admite cuando se sujeta a normas y no cuando constituye un medio para lograr objetivos particulares. El instrumento principal de la política debe ser la legislación, de forma que al aplicar la ley se pone en práctica una política que fue determinada con anterioridad. Razón por la cual en ninguna parte de la Constitución encontramos el deber de garantizar la libertad e igualdad por cualquier medio. Aquí el fin no justifica los medios ya que el cumplimiento de estos deberes sólo puede realizarse conforme a la ley.

1- Antecedentes históricos

Ahora entraré a dar una breve reseña de los hechos que llevaron a la firma del *Acuerdo de la Paz Firme y Duradera*. Es preciso analizar la legalidad de los actos para reconocer la legalidad de los acuerdos.

En 1960 se inicia en Guatemala como resultado de una guerra fría, una temprana lucha insurgente con distintos niveles de violencia política e intensidad en los enfrentamientos armados. Treinta y seis años de guerra provocaron un profundo daño en la sociedad guatemalteca.[5] A mediados de la década de los ochenta, en un período en que Centro América atravesaba por problemas en sus economías y estructuras sociales, surgieron los primeros pasos para buscar una solución negociada a los conflictos armados del área. En busca por un equilibrio político del istmo se inician las cumbres de 'Esquipulas' que retornan los esfuerzos de pacificación.[6] En 1987 'El Acuerdo de Esquipulas II' contiene el procedimiento para establecer una paz firme y duradera en Centroamérica, firmado por los Presidentes de los cinco países de América Central. En el apartado que se refiere a la Reconciliación Nacional el acuerdo manifestaba que los gobiernos se obligarían a realizar urgentemente, en aquellos casos en donde se habían producido divisiones sociales, acciones de reconciliación nacional. Se pactó expresamente que para cumplir dicho fin los gobiernos iniciarían el diálogo con todos los grupos desarmados de oposición política interna y con aquellos que se habían acogido a la amnistía. En otro apartado concerniendo la Reconciliación Nacional se convino la creación de una Comisión Nacional de Reconciliación (CNR) para la verificación del cumplimiento de los compromisos que los cinco gobiernos centroamericanos contrajeron por la firma de dicho documento, en materia de amnis-

3 En este caso nos limitaremos a hacer énfasis en los derechos fundamentales de libertad e igualdad, sin excluir la existencia de otros derechos fundamentales como los son el derecho a la vida y la propiedad entre otros.

4 El derecho se caracteriza por su fuerza coactiva y por su carácter represivo cuando la ley se viola. Sin esta característica no existiría compulsión por obedecer la ley.

5 150,000 muertos, 50,000 desaparecidos, 250,000 huérfanos, 100,000 viudas, 420 aldeas arrasadas, datos de la Oficina de Derechos Humanos.

6 Así se inicia el proceso de paz el 25 de mayo de 1986 con la 'Declaración de Esquipulas'.

tía, cese al fuego, democratización y elecciones libres, así como el respeto irrestricto de todos los derechos civiles y políticos de los ciudadanos centroamericanos. También se convino la creación de una Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento, conformada por los Secretarios Generales y representantes de la Organización de Estados Americanos(OEA) y las Naciones Unidas (ONU), así como por los Cancilleres de América Central. Esta Comisión tendría las funciones de verificación y seguimiento del cumplimiento de los compromisos contenidos en el 'Acuerdo de Esquipulas II'. De igual manera los gobiernos centroamericanos se obligaron a emitir declaraciones de respaldo a la labor de esta Comisión Internacional y a brindarle todas las facilidades necesarias para el cumplimiento de sus funciones de verificación y seguimiento. Por lo tanto el 'Acuerdo de Esquipulas II' se trató de un convenio o arreglo internacional en que se delegaron y confirieron competencias a organismos, instituciones o mecanismos creados dentro de un ordenamiento jurídico comunitario concentrado para realizar objetivos regionales y comunes en el ámbito centroamericano. En cuanto a la legitimidad para actuar, el Presidente de la República, sí tenía facultad para comparecer a la firma de semejante convenio, por delegación constitucional.[7] Pero tal arreglo internacional debió haber sido sometido a la aprobación del Congreso, ya que no existen acuerdos de gobierno, que el Presidente pueda celebrar con otros países sin que sean convenios de Estado. El 'Acuerdo de Esquipulas II' jamás fue sometido para su aprobación al Congreso, de la República, ni ratificado, es decir nunca llegó a tener la categoría de ley en el territorio nacional. A pesar de no gozar de validez jurídica dentro del país el 11 de septiembre de 1987 el Organismo Ejecutivo emite el Acuerdo Gubernativo que crea la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR), en el cual su primer considerando expresa que tiene su fundamento en el 'Procedimiento para establecer la Paz Firme y Duradera en Centroamérica' (o Esquipulas II) suscrito por los Presidentes de los Países Centroamericanos. Debido a la ausencia de un respaldo legal en el derecho interno que pudiera fundamentar la emisión del Acuerdo Gubernativo se basaron en el Acuerdo para darle cumplimiento a los fines y funciones que establecía dicho convenio. Y a pesar de su falta de fundamento legal para constituirse, de igual manera se creó la CNR en Guatemala para el cumplimiento de las funciones delegadas en el 'Acuerdo de Esquipulas II'. Si bien es cierto que el 'Acuerdo de Esquipulas II' constituye el inicio del proceso de paz en Centro América, nunca existió formalidad alguna que permitiera efectivamente dicho origen en Guatemala.

El nombramiento de dicha Comisión, fue delegada por el Presidente, sin embargo el Artículo 171 (m) de la Constitución[8] afirma que le corresponde al Congreso. Es evidente que los hechos relatados muestran un exceso de facultades por parte del Presidente. Nadie discute que el gobierno deba ejercitar un alto grado discrecional para hacer eficiente uso de los medios que dispone, pero cualquier decisión debe ser deducible de las normas jurídicas y de aquellas circunstancias a las que se refiere la ley.

Luego que el 'Acuerdo de Esquipulas II' fue dado a conocer, la URNG propone públicamente al Gobierno de Guatemala el inicio y desarrollo de un diálogo público. Esta propuesta causó inmediatamente gran revuelo y dio fomento a las más variadas posturas. Eventualmente el Gobierno aceptó iniciar pláticas con la URNG. Teniendo algunos encuentros preliminares y otros más formales donde discutieron la situación centroamericana, condenando las acciones violentas desarrolladas por grupos irregulares y reiterando sus compromisos en materia de diálogo y respeto a los derechos humanos. Estas condiciones fueron las que prevalecieron antes de la reunion en Oslo, Noruega.

En marzo de 1990 se firma en Oslo, el 'Acuerdo Básico para la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos', en este acuerdo se establece la voluntad del Gobierno y la URNG de buscar el fin de la guerra a través de la negociación y el diálogo. Reiterando lo establecido en el 'Acuerdo de Esquipulas II', las negociaciones debían ser entre los *gobiernos* y los grupos *desarmados* de oposición política interna. Sin embargo este acuerdo fue firmado por la CNR que

7 Arto. 183 (o) Dirigir la política y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución.

8 Arto. 171 m de la Constitución: 'Nombrar comisiones de investigación en asuntos específicos de la administración pública, que planteen problemas de interés nacional'.

manifestaba actuar con pleno respaldo del Gobierno de Guatemala. Esta Comisión ejerció la función reconciliadora que decía tener fundamento legal en el 'Acuerdo de Esquipulas II'. Como ya vimos la validez jurídica de la CNR para ejercer dichas funciones es cuestionable ya que aunque hubiera sido legal la creación de dicha Comisión, igual hubiera estado violando las disposiciones del 'Acuerdo de Esquipulas II' por estarse excediendo de las facultades que le fueron atribuidas en dicho documento. Pero la CNR celebró un convenio con la Unidad Revolucionaria Guatemalteca (URNG) en donde tuvo discusiones con un grupo armado que se encontraba al margen de la ley, y todo en secreto. Nada puede justificar las negociaciones que el Gobierno realizó con los grupos insurgentes armados URNG (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca).

Para agravar la situación, correspondía al Ministro de Relaciones Exteriores sostener cualquier tipo de conversación con las fuerzas (desarmadas, pero armadas en este caso) en Noruega. En tal acuerdo, la URNG propuso y obtuvo el nombramiento de Monseñor Rodolfo Quezada Toruño como conciliador a quien le delegaron las siguientes funciones: 'proponer iniciativas a todas las partes, gestionar y mantener acciones de diálogo y negociación, dinamizando este proceso y resumiendo las posiciones convergentes y divergentes que entre las partes puedan darse, teniendo la facultad de proponer iniciativas y soluciones con el objeto de que puedan ser discutidas y acordadas y todas aquellas otras funciones para el correcto cumplimiento de su cometido'. Acuerda también la CNR, en representación del Gobierno de Guatemala y la URNG, solicitar al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, que se convierta en observador y garante de los compromisos que adquirieron en ese documento. La función pública se caracteriza por ser indelegable.[9] El gobierno le reconoce el poder de actuar abusivamente a un grupo armado y todo esto viola la soberanía nacional. En una democracia los votos reflejan la manifestación de voluntad de la mayoría. Pero en este caso no sólo se viola la soberanía nacional, sino que se pretende dar legitimidad a estas negociaciones que fueron hechas sin tomar en cuenta la voz del pueblo por haber sido formuladas en secreto y por lo tanto se considera ilegal la realización del proceso. La democracia es el diálogo permanente y abierto entre gobernantes y gobernados y las instituciones democráticas son las instancias encargadas de canalizar ese diálogo.[10]

Seguido a este acuerdo y en cumplimiento de los acuerdos de Oslo, extralimitándose totalmente de las facultades que correspondían a la CNR y con la aprobación y respaldo del Gobierno, la CNR celebra las reuniones en El Escorial (España 1990) con los partidos políticos y la URNG en la que tales partidos acordaron ratificar en su totalidad el Acuerdo de Oslo. En este caso se antepone lo político a lo jurídico, ya que le correspondía al Congreso darle valor jurídico o no a dicho acuerdo, y no a los políticos. Esto evidencia la carencia de democracia representativa funcional y participativa que existe en nuestro país. No obstante la cantidad acumulada de faltas cometidas por parte del gobierno, la CNR continuó actuando, con pleno respaldo del Gobierno. Este realiza reuniones y convenios con la URNG en Ottawa, Canadá con el CACIF, en Quito, Ecuador con el sector religioso del país, y en Atlixco, México con los supuestos académicos, cooperativistas, empresariales y pobladores guatemaltecos; en todos ellos se pretende dar a los acuerdos de Oslo validez. Estos últimos acuerdos tienen únicamente validez política dependiendo también su cumplimiento de la voluntad política de los signatarios y de los sectores civiles ahí mencionados. El acuerdo por si sólo no permite constreñir judicialmente a los signatarios al cumplimiento de lo acordado.

En 1991 se llega a la declaración de la 'Iniciativa para la Paz Total de la Nación', hecha por el Presidente Jorge Serrano Elías. Él reconoce ilegalmente la validez de los acuerdos de Oslo. Las negociaciones se reinician y una vez más se reúnen adquiriendo el compromiso de negociar la paz con grupos armados, en manifiesta violación de los postulados contenidos en el 'Convenio de Esquipulas II'.

9 Arto. 154 de la Constitución: 'Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella'.

10 Como afirma Edmundo Vásquez Martínez (1988:17), en una sociedad democrática donde el diálogo se canalice adecuadamente, los diálogos dejan de ser necesarios. Entendiendo por diálogos cualquiera que no se canalice por las instituciones democráticas. El mismo proceso de paz devendría innecesario si concurriera dicha condición. Sin embargo, tal canalización en Guatemala ha sido inadecuada y a veces inexistente.

Con el propósito de darle marcha a los objetivos alcanzados en los 'Acuerdos de Esquipulas' y de conformidad con el Acuerdo de Oslo se constituye el 'Acuerdo de Querétaro' que viene a ser el acuerdo marco sobre democratización para la búsqueda de paz por medios políticos. Este fue firmado en México y aquí básicamente se pacta el reconocimiento de diferentes derechos ya consagrados en la Constitución.

En mayo de 1992 la URNG emite el 'Planteamiento Global de la URNG' en donde propone las reformas constitucionales que el Presidente debería aceptar y compartiendo su iniciativa de ley con ellos, en las cuales afirman que la Constitución y el ordenamiento jurídico sólo benefician intereses minoritarios y que no tienen objeto ni funcionalidad, y que las reformas constitucionales deben expresar los acuerdos políticos que se tomen en la negociación los cuales se explicarán más adelante. Por lo visto la URNG al hacer su análisis de la Constitución, no le dio mucha importancia la Artículo 4º contemplado en la Constitución donde explícitamente indica que todos somos libres e iguales en dignidad y derechos. En este caso podríamos citar a Aristóteles: 'tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales'. La URNG siempre estuvo al margen de la ley. Ahora que ya forma parte de la sociedad civil, se ha demostrado que lo político prevalece sobre la justicia, y en muchos aspectos los Acuerdos de Paz representan una investidura de amnistía.

Es conocido por todos que sin paz no puede haber desarrollo y que sin desarrollo no puede haber paz. En el sentido más amplio de estos dos conceptos. La democracia es indispensable para lograrlo. Por lo tanto es imprescindible apegarse a la ley para seguir los lineamientos que un Estado de Derecho exige. El debate es cómo articular la paz, el desarrollo y la democracia sin salirse del marco legal que nuestro ordenamiento jurídico nos proporciona. En la 'Respuesta al Planteamiento Global de la URNG'[11] se determinó que los acuerdos políticos a que se llegaren deberían de apegarse al marco constitucional vigente de Guatemala. A pesar de dicha argumentación legal se decidió continuar negociando con los grupos armados, en violación flagrante de la Constitución y la ley y contrario a lo pactado en el 'Acuerdo de Esquipulas II'. También se continuaron haciendo las negociaciones en privado al declararse expresamente que 'para el éxito de tales reuniones se requiere de un ambiente de privacidad [...]'[12]

El 25 de mayo de 1993 el auto golpe promovido por el Presidente Jorge Serrano Elías, determina la suspensión indefinida del diálogo de paz. El nuevo Presidente Ramiro De León Carpio reanudó el proceso de Negociación entre el Gobierno de Guatemala y la URNG, e integró nuevamente la Comisión de Reconciliación denominada Comisión de la Paz (COPAZ). En el acuerdo marco para la reanudación del proceso de negociación entre el Gobierno de Guatemala y la URNG se negoció con el fin de asumir acuerdos políticos acordes al marco Constitucional sin limitar su facultad de llegar a acuerdos sobre reformas institucionales y constitucionales. El efecto fue que el Presidente acordó compartir su iniciativa de ley con las fuerzas armadas en caso de alguna reforma al ordenamiento jurídico ordinario o constitucional. También intervinieron los países amigos,[13] consistentes algunos gobiernos entre ellos los que dan financiamiento y ayuda logística a los guerrilleros para que integraran un grupo de amigos del proceso de paz. Esta es una de las explicaciones por las que tanto país extranjero presionó a Guatemala durante todo el proceso de paz para llegar a su culminación.

2- Análisis jurídico constitucional a los Acuerdos Sustantivos de Paz

A continuación se presentará un análisis jurídico-constitucional de los acuerdos de paz empezando desde el

11 Gobierno de la República de Guatemala. Respuesta al Planteamiento Global de la URNG de Mayo 1992. Guatemala 30 junio 1992. pg. 6.

12 A pesar de haber anunciado que se empezarían a hacer públicas las negociaciones, México 26 de abril 1991 DF].

13 Las partes solicitan a los Gobiernos de Colombia, España, Estados Unidos, México, Noruega y Venezuela que integren un grupo de Amigos del Proceso de Paz guatemalteco. Estos tendrán las funciones de apoyar con sus gestiones al Representante del Secretario General de las Naciones Unidas para agilizar el proceso de negociacion, y dar mayor seguridad y firmeza a los compromisos adquiridos por Las Partes en su calidad de testigos de honor de los Acuerdos a los que se llegue dentro del proceso de negociaciones, cuando Las Partes lo soliciten, Acuerdo Marco para la reanudacion del proceso de negociacion entre el gobierno de Guatemala y la URNG, numeral IV México D.F. 10/1/94.

'Acuerdo Marco para la Reanudación del Proceso de Negociación entre el Gobierno y la URNG' hasta el último tratado que finalizó con la firma del Acuerdo de la Paz Firme y Duradera. Retornando a las definiciones de libertad e igualdad esbozadas en la introducción diremos que es indispensable determinar para el propósito de esta exposición el contenido del artículo que será la piedra angular del trabajo.

> *Artículo 4º* ***Libertad e igualdad.*** *En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí.*

3- Acuerdo Marco para la reanudación del proceso de negociación entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca

Las delegaciones del Gobierno de Guatemala y la URNG se reunieron en la ciudad de México del 6 al 9 de enero de 1994 para reanudar el proceso de negociación para alcanzar la culminación de la firma de la paz. Las Partes pactaron sobre las bases para las negociaciones de los procesos de paz donde acordaron en no limitar su facultad de llegar a acuerdos sobre reformas institucionales y constitucionales. En realidad este acuerdo, no presenta mayor problema en cuanto a alguna contradicción expresa al Artículo 4 de la Constitución. Es importante tomar en cuenta que la superlegalidad de las normas constitucionales hace más difícil su reforma.

4- Acuerdo Global sobre Derechos Humanos

En 1994 se firma en México el 'Acuerdo Global Sobre Derechos Humanos'. El contenido de este acuerdo recoge aspectos que reflejan derechos y garantías ya establecidas en la Constitución Política de Guatemala y en la normativa internacional sobre derechos humanos. Todo lo suscrito en este acuerdo no viene a ser más que una manifestación de los mandatos constitucionales a los que se deben apegar los funcionarios. Las partes entienden por derechos humanos: '*los que se encuentran reconocidos en el ordenamiento jurídico guatemalteco, incluidos los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales*' En este documento también se establece la mecánica para combatir la impunidad. La impunidad es uno de los problemas que impiden la plena vigencia de los derechos humanos. Pero a la vez debe entenderse que el Gobierno Guatemalteco es el único responsable de cualquier acción cometida contra los derechos fundamentales, ya sea por estar cometidos por los funcionarios del Estado, o por la falta de castigo a dichas acciones. Por otro lado no debemos olvidar las violaciones cometidas por parte de la URNG, quien siempre actuó al margen de la ley. MINUGUA[14] es el encargado de revisar y verificar que no se atente más en contra de los derechos humanos. Hasta ahora la impunidad ha sido la regla general. La práctica de la impunidad en Guatemala ha resultado en una ola de violencia que ha cobrado la vida de miles de personas. La reconciliación nacional en Guatemala no puede garantizar el respeto de los derechos humanos sin que ésta signifique que la impunidad debe terminar. La impunidad viola groseramente la igualdad de todos ante la ley.

5- Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado[15]

En 1994 las partes se reúnen en Oslo y firman el 'Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado' Con el fin de hacer énfasis en el compromiso de las partes de poner fin al enfrentamiento armado mediante el proceso de negociación.

En este acuerdo se busca brindar todas las garantías a los refugiados en México y los desplazados internos.

Este acuerdo comienza definiendo población desarraigada y reasentamiento. Lo cual para materia del tema es bastante conveniente ya que deja clara la

14 Misión de verificación de los derechos humanos de las Naciones Unidas en Guatemala.

15 Población desarraigada: conjunto de las personas que, desarraigadas por motivos vinculados con el enfrentamiento armado,

extensión de dichos términos. Este acuerdo persigue brindar igualdad pero como se mencionó anteriormente se debe tener mucho cuidado con el empleo de ese término. La agitación igualitaria tiende a concentrarse en las desigualdades que originan las diferencias de situación atribuidas a la naturaleza. El Artículo 4º de la Constitución no se refiere a una igualdad en que se otorgará igualdad de condiciones, sino a una igualdad en que la observancia de la ley será pareja e igual para todos. Uno no escoge en qué situación o bajo qué condiciones nace, y estando bajo la guardia y custodia de los padres, uno tampoco elige donde vivir. Sin embargo en este acuerdo para la conciliación de intereses y la integración de las partes se determinaron ciertos principios pertinentes para realizar dichos objetivos. Entre los cuales cabe mencionar:

> *Las poblaciones desarraigadas merecen una atención especial por las consecuencias que el desarraigo tuvo en ellos, mediante la ejecución de una estrategia global de carácter excepcional que asegure, en el plazo más breve, su ubicación en condiciones de seguridad y de dignidad y su libre y plena integración a la vida social, económica y política del país.*

El Artículo 4º en su última oración expresa en forma imperativa 'el guardar conducta fraternal entre si', que parece ser la única explicación en la que se pueda considerarse darle prioridad a los desarraigados. La igualdad del ordenamiento jurídico basado en preceptos legales generales es la única clase de igualdad que conduce a la libertad y que cabe implantar sin restringir la libertad. Como ya vimos libertad es el otro principio importante que prevalece en el Artículo 4º. Algo que no queda claro es cual va a ser la estrategia global que *asegure* su ubicación en condiciones de seguridad y de dignidad y su libre y plena integración a la vida social, económica y política del país. Si analizamos libertad e igualdad conjuntamente vemos que desde tiempos inmemoriales ha constituido el gran objetivo de la lucha por la libertad conseguir la implantación de la igualdad de todos los seres humanos ante la ley. Y como también se ha visto, muchas veces la gente ha preferido renunciar a su libertad con tal de alcanzar igualdad. Una ley puede ser perfectamente general refiriéndose solamente a las características formales de las personas afectadas e incluso haciendo previsiones diferentes para las distintas clases de personas.[16]

Nuestra legislación sólo reconoce como legítimo dueño a aquel que posea la documentación legal para probarlo, pero en el caso de las personas que tuvieron que abandonar sus tierras, se encuentran en un conflicto en que no todos poseen las pruebas suficientes o necesarias para atribuirse el título de legítimos propietarios. Ahora que regresaron surgen los problemas y los conflictos de intereses. El Gobierno busca ratificar *la imprescriptibilidad de los derechos de tenencia de la tierra en estos casos.* El derecho de propiedad debe protegerse, pero resultarían muchas violaciones a los derechos de propiedad si se hiciera sin base o fundamento legal. No cabe duda que el Estado está facultado para hacer uso discrecional de sus funciones, pero en el momento en que interfiera en la esfera del ciudadano privado y sus bienes, ahí terminan los poderes discrecionales de la administración. Cada vez que mencionan las poblaciones arraigadas, hablan de favorecer a las mismas debido a sus experiencias fuertes. En ningún momento se esta negando la situación traumática que atravesaron todos los afectados del conflicto armado, pero la pregunta a hacer ahora es: ¿Caben las preferencias en un Estado de Derecho? A veces se afirma que la ley, además de general e igual, dentro del Estado de Derecho, también debe ser justa. Pero en este caso a quién se está protegiendo, ya que la norma general dice que en la posesión corre la prescripción. El caso de las tierras es algo frágil donde va a ser muy difícil encontrar la mala fe, especialmente si la ley protege la posesión asumiendo que el que posee es el dueño.[17] Se esta buscando proteger a los que se fueron, pero tienen igual, si no es que mayor mérito los que se quedaron.

viven en Guatemala o en el exterior e incluyen, en particular, los refugiados, los retornados y los desplazados internos, tanto dispersos como agrupados. Reasentamiento: proceso legal de retorno, ubicacion e integracion de las poblaciones y personas desarraigadas en su lugar de origen u otro de su elección en el territorio guatemalteco, de conformidad con la Constitucion.

16 F. A. Hayek, *Fundamentos de la Libertad*. Pág. 265.

17 Arto. 617 Código Civil: 'La posesión da al que la tiene, la presunción de propietario, mientras no se pruebe lo contrario'.

El Gobierno habla no sólo de su reasentamiento inmediato sino de su devolución de todos los derechos que les fueron restringidos. Un resarcimiento por el daño ocasionado. Pero lo que no se está reconociendo es que las leyes generales e iguales proporcionan la más efectiva protección contra la infracción de la libertad individual o desigualdades como derechos inherentes. Ya fue mencionado el proceso que llevó al nacimiento de los acuerdos sustantivos contraídos entre las partes. Así como sus pretensiones de regir en la vida jurídica a pesar de haber nacido fuera de la ley. En un Estado de Derecho las leyes se aplican por igual a todos. El hecho de que las leyes se apliquen igualmente a todos, gobernantes incluidos, es lo que hace imposible la adopción de reglas opresivas. Adquirir compromisos donde lo que se está negociando es tierra, es una situación delicada que debe resolverse bajo el estricto cumplimiento de la ley.

Este acuerdo regula una parte que se refiere a la integración productiva de las poblaciones desarraigadas y desarrollo de las áreas de reasentamiento. Se persigue que no sólo haya desarrollo en estas áreas, sino que el desarrollo de estas áreas sea en condiciones de justicia, equidad, sostenibilidad y sustentabilidad. Lo cual para el desarrollo del país sería algo positivo. Pero lo que esto implica basándome en el numeral III inciso (4) es que además de las actividades agrícolas, se requiere la generación de empleos y de ingresos provenientes de la agroindustria, la industria y los servicios, conforme a esquemas apropiados al medio rural y a la preservación de los recursos naturales. Pero el enfatizar en que la inversión pública se deberá orientar prioritariamente con ese propósito ya es argüir algo incierto ya que el problema de la no descentralización del la industria y servicios públicos es un problema de toda la nación, no es algo nuevo sólo para las comunidades desarraigadas. Si lo que buscan es establecer un marco de incentivos a la inversión para el desarrollo rural en estas áreas, no debe el Estado olvidarse del resto de los sectores escasos del país. La única ruta para consolidar la paz en Guatemala es lograr trazar planos estratégicos cuyos objetivos maticen con los más profundos significados políticos y económicos que den la certeza de que no serán excluyentes las grandes mayorías, que permitan enfrentar a Guatemala a los desafíos de la globalización económica del conocimiento y que se dé oportunidad a los guatemaltecos en condiciones de igualdad a tener acceso a las fuentes de trabajo que demandan urgentemente que será el mejor medio para alcanzar el tan ansiado bienestar social. Así que este proceso no consiste solo en dar, en cuanto a proporcionar los medios para mejorar su calidad de vida y adecuarlos para el mejor desarrollo rural, es imperativo que se trabaje en conjunto y que estas personas que se encuentran en situaciones vulnerables, hagan lo posible para recuperarse y comiencen a generar capital para la Nación. De esta manera encontraremos estabilidad en el país. No sólo debe considerarse a los desarraigados, ya que este acuerdo debe aplicarse, (en caso de llegar a aplicarse), de manera integral para beneficiar a todos los guatemaltecos. Si no cabría plantear la interrogante de: ¿Qué pasa con los otros millones de habitantes que se encuentran en situaciones semejantes y que sólo por no ser desarraigados no pueden gozar de los mismos privilegios, y tener las mismas oportunidades? De lo que no debemos olvidarnos es de las responsabilidades que corresponden a los desarraigados. La palabra 'responsabilidad' parece ser una de la que muchos guatemaltecos se desentienden. Si bien es cierto que el alcance y variedad de la acción son considerables también hay un amplio campo para la experimentación y la mejoría dentro de estos acuerdos que permiten el funcionamiento de la sociedad libre dentro de la máxima eficacia pero nunca apartándose de la ley. Dentro de una sociedad intervenida observamos una transferencia de responsabilidades, no obstante el hecho que las responsabilidades son adquiridas por las personas que quedan obligadas a ellas y que por eso mismo deben ser cumplidas por ellas. Hoy por hoy se sostiene con frecuencia que las necesidades y muchas responsabilidades que los particulares no pueden cumplir son consideradas como funciones propias del Estado, y que no podrían llevarse a cabo adecuadamente si las autoridades administrativas no contaran con amplias facultades discrecionales. En este caso se busca otorgar ciertas garantías a los desarraigados al otorgarles todo aquello que les fue privado durante el enfrentamiento armado.

No es mi intención juzgar ni menospreciar las circunstancias por las que atravesaron las personas desarraigadas, pero debido a la amplitud del concepto 'desarraigado' podríamos deducir que la definición

también incluye a aquellas personas que tuvieron que abandonar su hogar (debido al conflicto armado), pero que pasaron a formar parte de los revolucionarios. Ambos fueron afectados y la URNG tiene una manera muy particular de decir que por muchos años fue afectada y marginada de tal manera que eso justifica sus actuaciones. Al actuar en representación legítima del pueblo. Pero sin entrar a buscar justificaciones, es evidente el conflicto de intereses en el que entramos al buscar beneficiar a personas que por muchos años dañaron a la sociedad.

Otro aspecto peligroso se refiere en cuanto a la asignación de los fondos financieros para la realización de estos proyectos. No podemos esperar que se asignen en proporción a la pobreza existente, como lo manifiesta este documento. Todos podemos ser pobres y ricos, a la vez respecto de otros. Por lo tanto se debe tener cuidado en cuanto a la distribución del presupuesto y suministro de los bienes ya que nuestro gobierno no es precisamente de los más ricos respecto a otros. De igual manera no puede considerarse sólo determinados sectores porque si lo que se busca es resarcir a los afectados por la lucha interna, entonces se tendría que tomar en cuenta a todos los habitantes que fueron y serán igualmente afectados social, cultural y económicamente por los resultados de la guerra. Muchas generaciones venideras todavía se tropezarán con los vestigios de la guerra.

6- Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca

Primero que todo vemos que el mismo título de este acuerdo abarca mucho, sin separarse del famoso tema de los derechos humanos que han cobrado hoy en día tal importancia después de todas sus violaciones. Un panorama de terror y violencia pasiva fue por años el motivo para señalar al país como violador de los más elementales derechos del hombre. El fin de este acuerdo radica en dar a conocer todas aquellos delitos cometidos contra personas que les fueron violados sus derechos humanos o restringidos de alguna manera. Se pretende conocer la verdad mediante la Comisión del Esclarecimiento Histórico. Esta Comisión sólo puede hacer posible el conocimiento o reconocimiento de la verdad histórica acerca del período del enfrentamiento armado interno, pero no tiene ninguna autoridad para la persecución penal de dichos delitos. Hablan de una entidad estatal que tenga a su cargo una política pública de resarcimiento y asistencia a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, como que fuera la acción compensatoria contra algún daño para que no se queden sin nada. Pero si por algo se caracteriza el derecho es por generar derechos y obligaciones, y parece justo resarcir los daños causados y que las víctimas tengan ese derecho, pero los causantes también tienen la obligación de pagar o de actuar conforme a ley, si lo que desean es incorporarse a la vida de legalidad.

Como ya se mencionó anteriormente se debe luchar fuertemente en contra de la impunidad y ver de qué manera se puede garantizar los derechos fundamentales que como todos ya sabemos gozan de cierta prioridad por ser inherentes al hombre. La Comisión encargada del esclarecimiento histórico deberá dar a conocer públicamente al pueblo todos aquellos delitos de los que se entere. En cuanto a esto último se presentan algunos inconvenientes para la actividad eficiente de dicha Comisión. Primero parece difícil que una entidad extrajudicial vaya a ser la que categorice y califique las acciones u omisiones que se le notifiquen como delitos y violaciones de derechos humanos. Y segundo, la importancia de conocer la verdad acerca de un delito consiste en poder, enderezar, resarcir y cumplir con las consecuencias y responsabilidades que produjo. Esta Comisión, carece de fuerza legal para perseguir los delitos de manera que se haga justicia. Es necesario que las personas culpables de delitos, respondan por ello, pero, sin ninguna base legal, o un debido proceso, no tiene sentido esclarecer delitos, que como el mismo título lo dice son 'históricos'.

Sin embargo en este contexto de buscar justicia y que prevalezca la verdad lo que sí valdría la pena es ubicar la situación de los torturados y los desaparecidos. El caso de los desaparecidos es, sin duda alguna, paradigmático. Esto es porque el desaparecido no es un caso del pasado, para la memoria. Es siempre víctima de un delito actual, del presente, insoslayable. Es un delito 'constante y permanente'. El desaparecido es considerado como un no-ser, por lo tanto el

Estado que garantiza la impunidad no quiere reconocerle su carácter de humano. Y se le niega su derecho de ser libre. El derecho a no ser sometido a ninguna circunstancia que menoscabe su dignidad. Se debe escuchar a las personas que fueron dañadas ya que el sufrimiento no se justifica ni debe transformarse en resignación. Bajo ninguna circunstancia debe admitirse que estos acuerdos impliquen amnistía. El mero transcurso del tiempo nunca es suficiente para sanar a una sociedad de la impunidad. El problema queda fijado en la conciencia nacional mientras no se le dé el remedio adecuado. Además de tener el Estado la obligación de castigar a todos aquellos que actuaron en contra de la ley. El olvido es signo de debilidad y es miedo al futuro. No puede existir reconciliación y es por medio de la reconciliación que obtendremos la paz como episodio final de este largo acontecimiento.

7- El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas

La versión final del Acuerdo fue formulada únicamente por las partes negociadoras, sin la efectiva participación indígena (por lo menos se les consultó). Parece difícil determinar qué es lo mejor para un grupo sin tomar en cuenta prioritariamente lo que ese grupo quiere o necesita, en este caso los pueblos indígenas. La democracia es un proceso, pero debe nacer sobre las ideas democráticas y el respeto a la voluntad de la mayoría, no lo que una minoría cree. Este acuerdo fue evaluado como un resultado de las luchas indígenas para hacerse reconocer por parte del gobierno y la URNG. Este acuerdo básicamente quiere desarraigar la opresión y la discriminación, a pesar de existir una disposición constitucional que prohíbe ambas. Se busca reconocer en todos sus aspectos la identidad y los derechos de los pueblos que han habitado y habitan la República, formando parte de su realidad actual y desarrollo.

Es importante recordar que este reconocimiento de identidad no significa bajo ninguna circunstancia que los integrantes de los pueblos indígenas son diferentes o que deben ser tratados con mayor preferencia por no ser iguales o que por ser tratados sin preferencia tampoco son iguales. Es muy clara nuestra ley fundamental cuando enuncia que 'todos somos libres e iguales en dignidades y derechos [...]' Agregando que '[...] tanto la mujer como el hombre cualquiera que sea su estado civil tiene iguales oportunidades y responsabilidades [...]'

Si nuestra misma Constitución establece la prohibición de cualquier tipo de discriminación de conformidad con el derecho vigente ¿por qué querer promover ante el Congreso de la República la tipificación de la discriminación étnica como delito? Y si en todo caso existiera cualquier ley en el derecho interno que muestre alguna forma o implicación discriminatoria hacia los pueblos indígenas, ésta sería *nula ipso iure*, por estar contraviniendo las disposiciones constitucionales. También cabe recordar que en Guatemala nunca se dio una discriminación severa y violenta contra razas, como ha sido el caso de otros países como Estados Unidos. Es obvio que no deseamos que la posición del individuo en sociedad esté determinada por decisión arbitraria o por privilegios conferidos por la voluntad humana a determinadas personas. Es difícil comprender, sin embargo en qué sentido puede ser legítimo sostener que cualquier persona se halla demasiado por encima de los restantes o que los grandes progresos de algunos con respecto a los demás han de resultar en daño para la sociedad.

En la lucha contra la discriminación se pretende crear *defensorías indígenas* y la instalación de *bufetes populares de asistencia jurídica gratuita para personas de bajos recursos en las municipalidades donde predominan las comunidades indígenas.* Si todos somos vistos iguales ante la ley y tratados bajo la misma ley, ¿cuál es la necesidad de crear defensorías indígenas que sólo crearían una mayor disparidad en la forma de administrar justicia? Si bien es cierto que ellos se encuentran limitados en cuanto a su capacidad de manifestarse debido al factor del idioma, la emisión de todas las leyes a los idiomas mayas sí ayudaría al cumplimiento de la ley, pero todavía no justifica el tratamiento especial o excluyente de los demás tribunales. Ya que la creación de estos tribunales especiales también lleva aparejado la conservación y vigencia de *normas consuetudinarias* (además del enorme gasto y tiempo que estos tribunales exclusivos y únicos tomarían). De aquí podemos considerar un caso hipotético que no queda claramente establecido cómo se resolvería en el supuesto de que una persona no indígena se encuentre en un municipio

donde por ser la mayoría indígena no exista ningún otro tipo de tribunal. ¿Quién juzga? ¿Qué lengua predomina en el juicio? Quieren preservar el derecho consuetudinario ya que en varios aspectos podría aportar a la legislación vigente, pero de conformidad con lo establecido en la Ley del Organismo Judicial sólo la ley es considerada como fuente formal,[18] y dicha ley es clara al enunciar que la costumbre sólo ayudará cuando la ley se ausente. Querer manejar sus asuntos internos de acuerdo con sus normas consuetudinarias implicaría caos. Y si este derecho consuetudinario predomina en alguna área, ¿Qué ley es mayor o qué categoría, validez, o importancia va a tener? Algo que es importante y que nunca se debe olvidar es que el derecho es uno, que se manifieste en diferentes maneras, no quiere decir que en algún momento va a ser personal, al contrario, se caracteriza por ser general y abstracto, y es así como debe permanecer. Dicen que este derecho consuetudinario no debe contravenir disposiciones vigentes, pero muchos casos ya están reguladas, así que muchas veces el problema no son las leyes sino la eficacia de las mismas. Es importante resaltar no la cantidad de leyes sino su contenido. Entre menos leyes existan, habrá mas libertad sin negar que incluso las normas generales y abstractas, igualmente aplicables a todos, pueden constituir, posiblemente severas restricciones de la libertad. La principal salvaguarda proviene de que tales reglas deben aplicarse tanto a quienes las promulgan como a quienes se ven compelidos a cumplirlas. Así que parece muy difícil que normas basadas en costumbre y creencias que no sean congruentes con la sociedad moderna, se traten de conservar y de hacer operantes. Ya que si bien es cierto que ayudaría a los pueblos indígenas, a la vez generaría restricciones a aquellos que no vivan bajo ellas, y sus efectos serían nefastos. La afirmación de que la ley nos hace libres tan sólo es cierta si por ley se entiende la norma general.

En el apartado acerca de la protección jurídica de los derechos de las comunidades indígenas encuentran necesario tomar la medida de promover el aumento del número de juzgados para atender los asuntos de tierras y agilizar procedimientos para la resolución de dichos asuntos, pero en nuestro país la justicia no sólo es ciega sino tardía, queriendo decir que nuestros procesos son muy largos. De manera que no se puede pretender agilizar sólo un sector, es necesario agilizar el sistema judicial en general. El Organismo judicial es una herramienta de la ley que hace posible su cumplimiento.

Un tema delicado que trata este acuerdo es la discriminación específica hacia la mujer. Se habla acerca de la vulnerabilidad e indefensión de la mujer indígena. El requisito para que los preceptos de la ley sean generales no obsta para que a veces se apliquen reglas especiales a diferentes clases de individuos siempre que se refieran a propiedades que solamente ciertos hombres poseen. Existen normas que pueden aplicarse sólo a las mujeres o a los inválidos o a personas de determinada edad. En la mayoría de tales casos ni siquiera será necesario nombrar la clase de gentes a las que se aplica la norma en cuestión. El hecho de que la legislación vigente considera que sólo las mujeres pueden ser violadas o quedar embarazadas no es una distinción arbitraria ni sujeta a determinados grupos a la voluntad de otros, siempre que sea igualmente reconocida como justa por los que está dentro y fuera del mismo. Cualquier mujer que es violada obviamente se encuentra indefensa por consiguiente es vulnerable debido a la fuerza empleada sobre ella. Para que rija tal norma es necesario que los puntos de vista individuales no dependan de si la persona pertenece al grupo o no. Siempre que la distinción sea favorecida por la mayoría tanto dentro como fuera del grupo existe una fuerte presunción de que sirve a los fines de ambos. Pero en el caso de la mujer indígena se habla de una doble discriminación: como mujer y como indígena con el agravante de una situación social de particular pobreza y explotación. Esto contradice el artículo 4º de la Constitución en la parte donde dice que todos tanto mujer como hombre son iguales, y yo entiendo que en este caso no cabría lugar a que alguna situación probara lo contrario. Sin embargo el gobierno se *compromete a promover una legislación que tipifique el acoso sexual como delito y considere como un agravante en la definición de la sanción de los delitos*

18 Arto. 2 LOJ: 'La ley es la fuente del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia lo complementara y la costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden publico y que resulte probada'

sexuales el que haya sido cometido contra mujer indígena. Ciertamente esto no es la igualdad a la que nos faculta el Artículo 4º ya que de por si el acto de violación es un acto de aprovechamiento hacia la mujer por ser mujer, pero no se puede decir que a algunas mujeres se les va a considerar más que a otras ya que en el momento en que se creen ese tipo de desigualdades donde se busque proteger a una clase de mujeres se estará afectando a otras. Cuando sólo aquellas que están dentro favorecen la distinción, nos encontramos claramente ante el privilegio y si solamente los que están fuera la favorecen, nos hallamos ante la discriminación. Lo que para algunos es privilegio para el resto es discriminación. En un Estado de Derecho no caben ninguno de los dos. Nuestra ley protege al género femenino, pero si se hiciera eficaz esta propuesta estaría dándole prioridad a la mujer indígena sobre la mujer ladina. Queriendo decir que se estarían contrariando a las disposiciones constitucionales. No se puede tipificar para unas y seguir perjudicando a otras, lo único que crearía esta sanción contra los delitos sexuales hacia la mujer indígena es un incentivo o una luz verde que indica que se puede seguir violando a la mujer no indígena sin que se agrave la pena. Lo único que podemos deducir de este apartado es el reconocimiento de la ignorancia de los indígenas y la incivilización de los hombres, como resultado de la falta de educación. Además ¿dónde se expresa claramente quién es indígena y quién no? Qué condición nos atribuye tal denominación. No es el Estado el que va a decidir la etnicidad de cada persona. No es posible que las leyes se hagan para beneficiar a algunos, el fin de este acuerdo es proteger a los indígenas de las discriminaciones cometidos contra ellos, donde ellos alegan del trato inicuo que han recibido por parte de la sociedad, pero en el caso de delitos sexuales vemos que no desean ser tratados iguales, omitiendo ellos mismos su derecho constitucional de igualdad y libertad. Es importante comprender que la igualdad ante la ley no modifica la realidad ni suprime las desigualdades naturales, más bien trata de equipararlas, pero tiene limites. Lo que distingue a las leyes constitucionales de las ordinarias es su carácter de superlegalidad y su difícil modificación. Este acuerdo en su parte referente al marco constitucional habla sobre una reforma a la Constitución para que defina y caracterice a la nación guatemalteca como de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe. Ya estando esto reconocido en el Artículo 66 de la Constitución, además de ser claro el respeto que se le debe tener a las diversas culturas que integran el país. Una vez más quiero recordar que a pesar de la existencia de una diversidad cultural, la ley nos mira iguales a todos, no pudiendo menoscabar nuestras creencias y prácticas, solo respetarlas.

Una vez más encontramos el problema de la tierra el cual se vuelve la causa principal de las limitaciones a los derechos constitucionales. En el apartado que habla de: *La restitución de tierras comunales y compensación de derechos el gobierno adoptará la medida de suspender las titulaciones supletorias para propiedades sobre las cuales hay reclamos de derechos por las comunidades indígenas.* El reconocimiento de la propiedad constituye evidentemente el primer paso en la delimitación de la esfera privada que nos protege contra el poder arbitrario y que por lo tanto nos garantiza libertad. Se ha dicho desde tiempo inmemorial que un pueblo contrario a la institución de la propiedad privada carece del primer elemento de la libertad.[19] Esta disposición nos coloca ante una situación muy delicada debido a que por querer compensar a gente que se le violó su derecho de propiedad a la vez se está perjudicando a la gente que lo único que hizo fue hacer valer su derecho de usucapión o prescripción por medio de la posesión. Y como nuestro Código Civil lo indica el título supletorio sólo se obtiene cumpliendo con requisitos específicos determinados en la ley, que requiere como uno de ellos la buena fe, entre otros.[20] Nuestra legislación siempre ha buscado proteger la posesión pero ahora vemos que la institución de la posesión es debilitada al tratar de resarcir derechos que no tienen fundamento legítimo para reclamarse, ya que muchas personas que claman tener derecho sobre ciertos terrenos carecen de documentos para probarlo. En este caso ya no se está protegiendo la posesión, sino a las comunidades indígenas, que en una forma u

19 Henry Main, 1880:230.

20 Arto. 634 Código Civil: 'Las diligencias de titulación supletoria deberán sujetarse al procedimiento que señala la ley respectiva y la resolución aprobatoria de las mismas es título para adquirir propiedad'.

otra debido al tiempo han perdido su derecho. Ante todo debe prevalecer nuestro derecho de libertad en donde podemos seguir disfrutando de él sin la necesidad de poseer nada. Pero en este caso se está partiendo del supuesto de que existe gente que no posee propiedad (en cuanto tierras) y se les está beneficiando a costa de gente que tiene derecho sobre ella. La ley nos manda a actuar dentro de un marco de libertad y permite hacer todo lo que no está prohibido, pero parece ser que cada vez se limita más debido a la incertidumbre en que se cae por la falta de coacción y protección por parte del Estado. Al suspender los plazos de prescripción para cualquier acción de despojo a las comunidades indígenas caemos en una inseguridad al ver que nuestros derechos serán alterados para beneficiar a otros debido a su situación que en cualquier caso debería ser visto igual por la ley. Ahora sus derechos son demasiado claros o poseen el debido título entonces ahí la ley resuelve, no *las partes*. Porque nuestro sistema legal exige que todo sea fundamentado en ley. Y si las leyes son iguales para todos, serán menos las expectativas de derecho que se verán alterados y escasas las situaciones de violaciones de derechos adquiridos.

Por último otro punto que parece importante cubrir es el numeral donde se pide que se ratifique el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) referente a los Pueblos Indígenas y Tribales. El inconveniente más grande de este acuerdo es su contenido y materia a regular, en cuanto que todo lo estipulado en ese documento no parece adecuado para aplicarse a un país en donde más de la mitad de la población es indígena. No es compatible que una norma internacional, obligue al derecho interno que ni siquiera consideró que países como Guatemala son un caso especial en donde los pueblos indígenas conforman la mayoría de la población.

8- Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria[21]

Con este acuerdo se pretende que a través de la Paz Firme y Duradera se puedan superar las situaciones de pobreza, extrema pobreza, discriminación, marginación social y política que han obstaculizado y distorsionado el desarrollo social, económico, cultural y político del país. 'La pobreza -decía Bentham- no es consecuencia de las leyes, sino de la condición primitiva de la raza humana'[22] Es irónico que consideren en el preámbulo de este acuerdo que el Estado debe democratizarse para ampliar las posibilidades de participación del pueblo, cuando fue el mismo Estado el que no consideró dicha participación indispensable para la realización de dichos acuerdos. El pueblo no ha firmado nada. No se trata de considerar ahora la forma en que se llevaron a cabo estos acuerdos sino si éstos suprimen de alguna manera la libertad o afecta la igualdad.

Son muchas las situaciones que se contemplan en este acuerdo. Entre ellas el financiamiento de la actividad gubernamental, el mantenimiento de los tribunales, de la policía, del sistema penitenciario, de las fuerzas armadas y la inversión será de enormes sumas. Pero ésta inversión lleva aparejado el acto de imponer a tal objetivo contribuciones fiscales que de modo alguno supone para muchos una supresión a la libertad. No es necesario advertir que esta necesidad en ningún caso puede aducirse como justificación de esa tributación expoliatoria y discriminatoria a la que recurre tanto nuestro gobierno en forma excesiva. Conviene insistir sobre esto, ya que este acuerdo hace mención acerca del aumento de impuestos. Como ejemplo podemos mencionar que el 1.5% de los impuestos recaudados a partir de 1997 serán dedicados a la política de fomento de la vivienda, con prioridad al subsidio de la demanda de soluciones habitacionales de tipo popular. (¿Dónde? se establece en la Constitución que entre las funciones del Estado esta darnos vivienda, cuando en muchos casos libertad e igualdad bastarían.) De igual manera se eximirá de impuestos a las propiedades de pequeña superficie, lo cual una vez más viene a constituir un privilegio que les den tierra y que además se decida que se les liberará de impuestos, siendo el Congreso el unico que podrá decidir esto, la falta de coordinacion entre los órganos no facilita ni la validez ni facilitara el cumplimiento de estos acuerdos. Estos acuerdos son meras manifestaciones unilaterales del Gobierno de conformidad con lo resuelto en sus discusiones con la

21 Este acuerdo habla de distintos reordenamientos y reorganizaciones sin identificar a que se refieren. Un acuerdo debe ser claro.
22 Jeremy Bentham, I:309.

URNG. Montesquieu decía: 'sólo el poder es capaz de frenar el poder'. Como ya sabemos la división de poderes es una doctrina integrante al Estado de Derecho, en el que nos encontramos (supuestamente).

Otros impuestos son propuestos en este acuerdo, unos para realizarse a largo plazo (1996 al año 2000, eso es largo plazo [...] Y otros inmediatos como el caso del impuesto territorial y el impuesto sobre tierras ociosas propuestos en este acuerdo. Vemos que cualquier impuesto que se insinúe o proponga en estos acuerdos son para el logro del bien común o el bienestar social. Si vemos siempre es la mayoría la que impone impuestos sobre la minoría, por el simple hecho de ser la mayoría, pero la democracia no tiene ese fin, de manera que la mayoría que es la que rige en una democracia no debe aprovecharse de serlo. Porque como ya hemos mencionado las clasificaciones utilizadas por la ley no han de implicar privilegios ni discriminaciones sino deben ampararse en diferencias que tanto los comprendidos en un grupo como los excluidos consideren importantes. No debemos olvidar que las necesidades fiscales han constituido siempre una de las causas principales de la actividad inflacionaria, es por eso que se debe tener cuidado con la imposición de tributos que pueden tener consecuencias negativas en la economía del Estado. El Estado piensa mucho en ingresos pero no parece tomar en cuenta que los egresos también son importantes y esos sólo se pueden generar a través de una economía de libre mercado, no intervenida. El rápido progreso económico parece ser en gran medida el resultado de la aludida desigualdad (base de la división del trabajo).

En cuanto a la estrategia para darle acceso a tierra y recursos productivos a los campesinos. *El mecanismo para realizar dicho supuesto será por medio de la creación de un fondo fideicomiso de Tierras dentro de una institución bancaria. Este Fondo de Tierras concentrará la potestad del financiamiento público de adquisición de tierras y propiciará el establecimiento de un mercado transparente de tierras facilitando el desarrollo de planes de reordenamiento territorial.* Dicho fondo se conformará por las siguientes tierras: tierra de baldíos nacionales y de fincas registradas a nombre de la nación. Tierras nacionales entregadas en forma irregular en zonas de colonización especialmente en el Petén y la Franja Transversal del Norte, que el Gobierno se compromete a recuperar mediante acciones legales, tierras adquiridas por instituciones ad hoc, las adquiridas con donativos de gobiernos amigos y organizaciones internacionales, las adquiridas con préstamos de organismos internacionales, las tierras ociosas que se expropien de acuerdo con el Artículo 40 del Decreto 1551. Objetivamente esto constituye una desigualdad al tratar de propiciar la creación de todos los mecanismos posibles para desarrollar un mercado activo de tierras que permita la adquisición de ellas para los campesinos que no la poseen o la poseen en cantidad insuficiente. Además vale la pena mencionar que estas transacciones se harían a largo plazo o con tasas de interés comerciales menores mencionando al final de este apartado [...] *con un mínimo o sin enganche.* No se puede pretender desarrollar económicamente si sólo se tiene en mente ayudar y subsidiar a todos los que no pueden por sí solos. El concepto de fraternidad es muy amplio y subjetivo, no pudiendo la ley obligarnos a actos y obligaciones específicas de fraternidad. El gobierno no tiene los fondos para constituir tales compromisos (en nombre del pueblo).

9- Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática

Este acuerdo persigue *fortalecer el poder civil en tanto expresión de la voluntad ciudadana a través del ejercicio de los derechos políticos. Afianzar la función legislativa, reformar la administración de justicia y garantizar la seguridad ciudadana.*

Primero que todo para fortalecer el poder civil, es necesario proteger los derechos constitucionales y que todos podamos vivir y actuar en condiciones de libertad e igualdad. Muchas veces la gente no se percata del valor que tienen tales derechos individuales, no entendiendo plenamente su significado, debido al concepto equívoco que se tiene de tales derechos y es por eso que encontramos controversias en las normas y por ende en los intereses. Básicamente se vuelve a mencionar la estructura de los órganos administrativos y la importancia de su mejoramiento y modernización. Se indica que se formará una instancia multipartidaria que tendrá a su cargo entre otros las reformas legales, tema que se tratará en el acuerdo de Reformas Constitucionales.

Entre las funciones esenciales, ni subsidiarias ni complementarias, sino esenciales encontramos la de la seguridad pública. A este punto, parece obligado examinar la cuestión de si la conscripción militar supone o no limitación de la libertad del hombre. Tema que se trata en este acuerdo. En nuestro país es obligatorio, por una sencilla razón: la realidad de nuestro mundo. Lo que se refiere con esto es que no parece violatorio de libertad que se obligue a todos a contribuir al esfuerzo común de defensa de la patria. El Estado impone el servicio militar a cuantos gozan de las necesarias fuerzas físicas, por igual a todos los que alcanzan la mayoría de edad. Si bien es cierto que es obligatorio, no significa que debe ser forzado a tal punto que viole o ponga en peligro los derechos fundamentales del hombre. Tampoco pudiendo los integrantes del ejército abusar de su poder de defensa como se evidenció en varias ocasiones durante la guerra. La conscripción militar constituye un deber cívico que en ningún momento debe ser discriminatorio sino conforme a la ley. Y si en algún momento ha sido, no ha sido causado por nadie más que no sea el Estado mismo, ya que es el único que puede obligar a hacer servicio militar. Cuestión que sí vendría a contravenir la libertad e igualdad.

10- Acuerdo sobre el definitivo cese al fuego

El cese al fuego definitivo es el producto de la conclusión de los acuerdos sustantivos del proceso de paz. La URNG considera este acuerdo como el pase para su incorporación a la vida política del país. Indispensablemente esta incorporación debe ser bajo condiciones de seguridad y dignidad, pero ante todo igualdad. Y sólo en ese momento se podrá considerar de interés nacional su incorporación, de otra manera no podrá ser objetivo de conciliación dentro de sistema democrático las excepciones a la justicia.

El análisis de este acuerdo es bastante complejo considerando que el cese al fuego *atestigua la decisión de la organización político militar de la URNG de incorporarse como fuerza política a la legalidad. Así como copartícipe, conjuntamente con el Gobierno y la sociedad civil en la construcción de la paz, del desarrollo y del bien común.*

En un principio la URNG cuestionó la legitimidad del gobierno guatemalteco al afirmar que su accionar se encontraba enmarcado dentro del derecho de legítima rebelión de los pueblos. Y por esa misma razón, no aceptaban acogerse a la amnistía, pues eso hubiera sido reconocer la ilegitimidad de su movimiento.[23] Razón por la cual la URNG se negó a bajar las armas en el transcurso de los diálogos, lo cual iba en contra de lo establecido en el 'Acuerdo de Esquipulas II'.

El cese al fuego consiste en la suspensión de todas las acciones insurgentes de parte de las unidades de la URNG y el cese de todas las acciones de contrainsurgencia por parte del Ejército de Guatemala. Durante muchos años esta lucha fue emisora de varios delitos, y ahora que ha cesado al fuego, ellos se pueden integrar a la sociedad, con derecho a todo. La ley no es flexible, claro que establece un aspecto positivo el cese al fuego, pero también es importante sancionar todo aquellos actos dañinos que fueron causados por las fuerzas revolucionarias. Así que no sólo consiste en cesar al fuego, y que ya tengan derecho a integrar la sociedad con derecho a todo, porque así como tienen derechos, tienen obligaciones, y la primordial va a ser responder por todas sus faltas.

La URNG siempre estuvo al margen de la ley, sin embargo parece ser que ahora forma parte de todo a lo que siempre se opuso. No sólo la URNG fue la que cometió acriminaciones sino también el Ejército, pero más grave aún es pensar que éstas actuaban como legítimos mandatarios del Estado. Por lo tanto el Ejército y patrulleros civiles también deben ser sometidos a organismos de control judiciales. Si bien es cierto que estos delitos fueron cometidos por militares, no deben ser las cortes militares las que hagan justicia sino las cortes civiles, siendo que las víctimas eran civiles. Las cortes militares son necesarias y fundamentales para mantener la disciplina de las fuerzas armadas, pero en este caso serán las cortes civiles las que tengan como finalidad impartir justicia.

11- Acuerdo de las reformas constitucionales y el régimen electoral

Como ya fue mencionado las partes asumieron el compromiso de que los acuerdos políticos reflejarían las legi

23 URNG, 1992:60; CNR:31-40.

timas aspiraciones de todos los guatemaltecos. Se establecerían con apego al marco constitucional vigente y de conformidad con lo pactado en el Escorial, España donde la URNG y los políticos del país se comprometieron a promover las reformas de la Constitución que fueren necesarias par la reconciliación de todos.

Hasta este punto podemos decir que los acuerdos ni reflejan los deseos de los guatemaltecos ni se han establecido con apego al marco constitucional. La Constitución sirve para limitar los poderes del Estado y a la vez reconoce nuestros derechos fundamentales y los protege. La razón de su supremacía radica en que todas las normas contenidas en ella pueden ser desarrolladas por otras normas y otras leyes, pero nunca pueden ser contrariadas o tergiversadas. Toda nación y toda sociedad para poder vivir y desarrollar sus actividades y para poder convivir unos con otros en armonía necesitan de una organización jurídica y política y de unas reglas de conducta humana que tienen que ser cumplidas por todos y en caso de no hacer hay sanciones por ello. Si bien es cierto que Guatemala esta formada por diferentes tipos de culturas, todas ellas tienen algo en común: todos son iguales ante la ley. La Constitución sirve de base y cimiento sólido para una auténtica democracia, o sea para que exista un Estado de Derecho. La Constitución está conformada por normas bajo las cuales actúan los ciudadanos ya que constituyen una adaptación de toda la sociedad al medio en que aquéllos se desenvuelven y a las características generales de los miembros que integran tal sociedad. Sin embargo las partes encuentran la necesidad de adecuar la legislación ordinaria a lo acordado en los Acuerdos de Paz, llegando a expresar que *si es necesario recurrirían a reformas constitucionales.* Estas reformas no tocan la parte dogmática de la Constitución, ya que de esa manera se tendría que integrar una Asamblea Nacional Constituyente para cualquier reforma, pero sí encontramos varias propuestas de reformar la parte orgánica.

Dentro de las propuestas a las Reformas Constitucionales Se busca reconocer específicamente la identidad de los pueblos Maya, Garífuna y Xinca, además de definir y caracterizar al Estado guatemalteco como de unidad nacional, multiétnico, pluricultural y multilingüe. En un Estado democrático, la igualdad y la libertad van implícitas. La verdad es que parece un exceso tener que mencionar en cada ley que se debe respetar el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe del país, el derecho implica un precepto moral, que no debe recordarle a cada ciudadano que está bien o mal moralmente. Las reglas están, se acatan o se incumplen. La Paz como solución presenta más problemas que soluciones en el cual se busca un equilibrio entre las exigencias de la paz, la justicia, la verdad y la reconciliación nacional.

Respecto al idioma parece prudente mencionar en este punto del ensayo su papel, y sus efectos. Tema que también se toca en el Acuerdo 169 acerca de los Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT. En este Convenio entre otras cosas se pide que se reconozcan los idiomas mayas como oficiales, ya que la Constitución reconoce solamente el español como lengua oficial.[24] Parece difícil oficializar idiomas que carecen de reglas ortográficas y que sólo se basan en la tradición oral. Además vemos que un idioma siempre enriquece la cultura, pero sería más fácil que el español se usara como moderador. Es más fácil para fines prácticos que los pueblos indígenas se metan a aprender español en vez de que todo el resto trate de aprender los demás idiomas.

Además hablando todos el mismo idioma no nos entendemos, qué objeto tendría integrar más idiomas que ni siquiera todas las comunidades indígenas entienden entre sí. No se les está prohibiendo hablar, al contrario, se respeta, pero lo que ellos piden vendría a afectar de manera controversial a toda la nación. La evolución que han llevado los pueblos indígenas ha sido más lenta, pero no podemos caminar a diferentes pasos en una sociedad que está destinada al progreso y que se encuentra en constante evolución, ya que si unos esperan a otros el único resultado sería un progreso petrificado.

En cuanto al tema del sistema de justicia, es importante mencionar que una de las grandes debilidades estructurales del Estado reside en el sistema de administración de justicia que es uno de los servicios públicos esenciales. Este sistema y dentro de él, la marcha de los procesos judiciales adolecen de fallas y deficiencias. La obsolescencia de los procedimientos legales, la lentitud de los trámites, la ausencia de los sistemas

24 Arto. 143 Constitución: 'El idioma oficial de Guatemala, es el español, las lenguas vernáculas forman parte del patrimonio cultural de la Nación' Este artículo que es uno de los que se quiere reformar.

modernos para la administración de los despachos y la falta de control sobre los funcionarios y empleados, propician la corrupción e ineficiencia. Motivo por el cual no podemos adaptar las normas de derecho consuetudinario para que rijan nuestra sociedad, ya que sería regresar y quedarnos sin la posibilidad de avanzar. Vemos hoy que muchas situaciones nuevas que han surgido, no coinciden con las normas vigentes, ya que no han sido previstas, haciendo alusión a la teoría Hayekiana.[25] El derecho consuetudinario debe ser compatible con la sociedad moderna.

En cuanto a la legislación interna se propone una reforma al Código Penal de manera que *se dé prioridad a la persecución penal de aquellos delitos que causan mayor daño social, tomando en cuenta las diferencias culturales propias del país y sus costumbres, que garantice plenamente los derechos humanos y tipifique como actos de especial gravedad las amenazas y coacciones ejercidas sobre funcionarios judiciales, el cohecho, soborno y corrupción, los cuales deberán ser severamente penalizados.* El Derecho penal no puede establecer una escala de valores para seguir y hacer justicia. El Derecho penal debe responder a las necesidades diarias que surgen, con la obligación de perseguir todos los delitos cometidos en territorio guatemalteco o contra guatemaltecos. Una vez más esto contradice la disposición constitucional del Artículo 4º A todos se les va a aplicar la misma ley y todos somos iguales ante la ley. Por qué se le va a dar más prioridad a sancionar ciertas acriminaciones sobre otras tomando como base los delitos que causan mayor daño social. Todos tenemos el mismo derecho de que se nos resuelva con rapidez y categorizando con igual importancia cualquier infracción penal no importando su grado de daño. Existen leyes que ya regulan los casos excepcionales, y nuestra Constitución tutela los derechos fundamentales del hombre.

12- Acuerdo sobre bases para la incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la legalidad

Incorporación de URNG a la legalidad: *proceso mediante el cual sus miembros se integran a la vida política, económica, social y cultural en un marco de dignidad, seguridad, garantías jurídicas y pleno ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos.*

Uno de los medios de incorporación de la URNG a la legalidad consiste en convertir sus fuerzas político militares en un partido político acreditado y cuya acción se enmarque dentro del ordenamiento jurídico nacional. La base fundamental de este Acuerdo es la Ley de Reconciliación Nacional. Esta ley dejará sin castigo a los autores de delitos y perpetraciones violentas por parte de la URNG y del Ejército. Ya fue interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley, debido a la cantidad de divorcios legales que presenta respecto a la Constitución sobre la cual la Corte de Constitucionalidad no ha emitido fallo alguno.

El primer considerando de la Ley de Reconciliación Nacional comienza enunciando que la paz constituye un interés nacional y prioritario, pero no podemos obtener todo lo que deseamos a cuesta de extinguir responsabilidades penales. Aristóteles decía: 'libramos la guerra para obtener la paz'. Frase con la cual justificaba la guerra. Meses después de la firma de la paz, lo único que hemos obtenido es conciencia de lo que se necesita para obtener la paz, y no es reconciliación, sino hacer que se cumpla la ley. Los autores de tales delitos, no sólo son responsables hacia la víctima y sus familiares, sino con todo el pueblo por haber mantenido al país en una inestabilidad constante. Omiten la norma constitucional de libertad e igualdad, al crear otra que estipula injusticias como las siguientes:

Extinción de responsabilidad penal: Con miras a favorecer la reconciliación nacional, sin desatender la necesidad de combatir la impunidad, la Ley de Reconciliación Nacional incluirá una figura legal que permita la incorporación de los miembros de URNG a la legalidad.

Parece un poco contradictorio, pero como dicen ellos todo por la paz [...]

Delitos políticos: la Ley de Reconciliación Nacional declarará la extinción de la responsabilidad penal por los delitos políticos cometido en el enfrenta-

25 Teoría que indica que la civilización fue el resultado acumulativo costosamente logrado tras ensayos y errores, que la civilización fue la suma de experiencias transmitidos de generación en generación. Y que las instituciones que integran nuestra sociedad las descubrimos.

miento armado interno hasta la fecha de entrada en vigencia de la Ley, y comprenderá a los autores, cómplices y encubridores de los delitos contra la seguridad del Estado, orden institucional y la administración pública.

Qué suerte tienen aquellos que cometieron delitos durante 36 años y no reciben castigo.

Declarar igualmente la extinción de la responsabilidad penal por los delitos comunes conexos cometidos en el enfrentamiento armado, entendiéndose por tales aquellos que directa, objetiva, intencional y causalmente tengan relación con la comisión de los delitos políticos y respecto de los cuales no se demuestre que tuvieron como móvil un fin personal.[26]

Ahora que ha cesado el enfrentamiento armado y se integren a la vida civil, tanto los revolucionarios como los patrulleros civiles, vemos que lo único que cambia es que no poseen armas, pero ideológicamente siguen militarizados. El único fin que miran en la paz es la realización de sus propias acciones. La consolidación de la Paz Firme y Duradera es muy frágil por varias razones, entre las cuales cabe mencionar la negligencia del gobierno de propiciar los espacios de participación de ciudadanos, como ocurre en una democracia. El Estado de derecho no debe quitarle a las víctimas lo único que les quedó, y esto es el derecho a que se haga justicia. Para una verdadera reconciliación nacional será necesario en algún momento pasar por acto del perdón. Pero la palabra perdón corre el peligro siempre de evocar imágenes que desfiguran su sentido y que empobrecen el profundo significado del gesto. El perdón no significa olvido, ya que no es esa la manera de salvaguardar la paz. El perdón es un acto admirable. Pero sólo puede perdonar el que fue víctima, no sólo se está concediendo la impunidad sino el Estado la está otorgando en nombre de todos los afectados. Estas personas no sólo quedan sin castigo, sino pasarán a adquirir posiciones de poder y se verán en el pleno goce de sus derechos como civiles [...]

Constituyendo esto el mayor trato de desigualdad que se puede dar en un Estado de Derecho al librar a culpables de sus responsabilidades y festejar su incorporación a la sociedad. Y esta falta de coacción que sí es necesaria, viola la libertad de los demás al permitir que estas personas la hayan limitado, restringido o en algunos casos hasta quitado. Para que todos seamos libres es imperativo que se sancione a los que no la respetan, sin embargo ahora parecen ser inmunes en nuestra sociedad y ante la justicia. Nunca había sido tan obvia la injusticia en nuestro medio, teniendo encima de todo este trato de desigualdad un fundamento legal para respaldarlo, como es la Ley de Reconciliación contraviniendo directamente las disposiciones de la Constitución

El 29 de diciembre de 1996 se firmó el último acuerdo denominado *Acuerdo sobre cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz.* Este acuerdo es básicamente un calendario con las fechas en que debe cumplirse los acuerdos y los plazos para su funcionalidad. Pero se podría decir que este acuerdo está demás si todos los otros acuerdos no gozan de validez jurídica, ni están reconocidos como derecho interno. No obstante su carencia de legitimidad, ya empiezan a cumplirse ciertas disposiciones. El presupuesto nacional se está adaptando a lo que establecen los acuerdos. Y así existen varios hechos que en un gobierno de leyes no tendrían lugar.

Es indispensable la divulgación de dichos acuerdos, debido a que el pueblo debe estar al tanto de los compromisos adquiridos en los acuerdos y preparado para sus repercusiones.

Conclusiones

Después del análisis realizado a lo largo de este trabajo se puede concluir primeramente que los acuerdos de paz carecen de validez jurídica debido a la ausencia de los elementos jurídicos necesarios para que puedan surtir los efectos legales que les corresponden. El proceso de paz ha sido en Guatemala un proceso político generador de efectos jurídicos. Existen disposiciones en los Acuerdos de Paz que contravienen la disposición constitucional de libertad e igualdad Artículo 4º. La firma de la paz ha sido a un costo muy alto, el 29 de diciembre de 1996 culminó el proceso de paz. Pero lamentablemente la firma de un documento no nos

26 Apartado III. Area Jurídica, Numerales: 17, 18,19, 20

llevará a la paz. La Paz sólo puede garantizarla el Estado respetando los derechos que cada persona tiene y obligando a las personas a que se respeten mutuamente sus propios derechos. Y esto se logra por medio del respeto a la libertad entendiendo ésta como la facultad de poder hacer todo lo que no está prohibido sin violar la libertad de otro. La democracia implica libertad e igualdad. El poder radica en el pueblo, pero éste lo ejercita a través de las personas que eligen libremente para ello con el fin de que los gobernantes cumplan estrictamente con el sistema elegido y administren y dirijan al país, de tal forma que se defiendan los intereses del pueblo.

La discreción que el Gobierno de Guatemala ha utilizado para dirigir las negociaciones de la paz, ha dado origen a controversia. Es muy difícil predecir con exactitud los efectos que tendrá la plena vigencia de estos acuerdos. Lo que no es difícil predecir es lo que podemos esperar de ellos. Al contrario es muy fácil asumir que en ausencia de libertad e igualdad lo único que queda es injusticia, arbitrariedad, violencia y poco a poco un distanciamiento de lo que hoy por hoy conocemos como Estado de Derecho. Es importante preservarlo, protegerlo, y que sea la manifestación de un gobierno de leyes. Este trabajo no ha pretendido resolver todas las dudas e incertidumbres que han surgido respecto a los Acuerdos de Paz, pero sí pretende sacar a relucir aquellos derechos sobre los cuales nacen todas las relaciones eminentes de una Democracia como lo son la libertad y la igualdad. Estos dos principios van de la mano, ninguno va antes que el otro, al contrario, la existencia de uno presume la existencia del otro. Principios que no sólo se nos atribuyen por el hecho de ser persona al vivir en sociedad, sino que el propio Estado no los reconoce de la manera más expresa y amplia, consagrados en la Constitución y concebidos en cada una de nuestras conciencias. Por lo tanto, después de este largo y profundo estudio, no resta más que concluir que existen contradicciones al artículo cuarto de la Constitución en los Acuerdos de Paz, la libertad y la igualdad sí son esenciales para la convivencia en sociedad, pero más que lo que está escrito, pactado o acordado, hay que distinguir que todo lo que va en contra de la naturaleza del hombre no puede perdurar ni ser impuesto de manera permanente. Han sido demasiadas las luchas a través de la historia por obtener libertad e igualdad en una misma frase, hoy en día los encontramos garantizado por el propio Estado, no dejemos que sea el mismo Estado el que nos lo quite o restrinja de alguna manera. No es hasta que las personas ven amenazados sus derechos de libertad e igualdad, o hasta que los pierden, que comprenden la importancia y naturaleza de tales derechos. La ley nos garantiza libertad e igualdad, dejemos que la ley regule, ya que la ley no es más que el reflejo de la voluntad común, de una determinada sociedad que impera en un determinado momento.

Bibliografía

Bentham, Jeremy

s.f. 'Principles of the Civil Code'. *Works.*

Código Civil

1996 *Código Civil de Guatemala.* Decreto-Ley Número 106. Guatemala: Ediciones Alenro.

Gobierno

1992 *Respuesta al Planteamiento Global de la URNG.*

Hayek, Friederich A.

1975 *Los fundamentos de la libertad.* Héroes S.A.

Main, Henry

1880 *Village Communities.* Nueva York.

URNG

1992 *Planteamiento global.*

Vásquez Martínez, Edmundo

1988 'El diálogo nacional'. *Revista Crónica*, 15. Guatemala.

Las leyes se encuentran siempre con las pasiones y los prejuicios del legislador: unas veces pasan a través de ellos y toman cierta tintura; otras veces, detenidas por las preocupaciones y por las pasiones, se incorporan a ellos.

Montesquieu

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
REVISTAS

Indice

Indice

A
Acido desixorribonucleico (ADN) 67
Acoso sexual 145
Actividad registral 21
Acto
  fedatario notarial 21, 22
  nulo 37
  registral 21, 34, 36, 38
Acuerdos
  169 147, 150
  de Oslo 138, 139
  de Paz 135, 139, 150, 152, 153
  de Querétaro 139
  Global sobre Derechos Humanos 135, 140
  Marco 135, 139, 140
  sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas 144
Agentes diplomáticos 26, 28, 29
Agnosticismo moral 118
Agracetus Inc. de Middleton, Wisconsin 81
Aguilar Castro, Luis Alfonso 55
Aguirre Godoy, Mario 28, 31, 32, 37, 38
Allgemeine Elektricitaets Gesellschaft 44
Alvarez, Francisco 42
Amadís de Gaula 114
American Telegraph & Telephone Company 43
Amicis, Edmundo de 115
Amnistía 136, 137, 139, 144, 149
Antigua 42
Aquino, Tomás de 117, 118, 119, 120, 121, 123
Arbenz Guzmán, Jacobo 42
Ariosto 114
Aristóteles 123, 126, 139, 151
Arzú, Alvaro
  Programa de Gobierno 1996-2000 53
Asiento registral 34, 37
Association of Licensed Automobile Manufacturers (ALAM) 80
Ateos 126
Autonomía individual 117
Axiología 127

B
Balzac, Honorato 115
Barlow, John Perry 75, 82
Barrios, Justo Rufino 42
Baudelaire, Charles 115
Beneficios marginales 78
Benegas Lynch, Alberto 119
Bennet, George 45
Bentham, Jeremy 147, 153
Bergson, Henry 114
Best sellers 113
Bidart Campos, Germán J. 62, 66
Bien común 8, 67, 68, 127, 130
Biotecnologías agropecuarias 68
Bocaccio 115
Borges, Jorge Luis 115
Borndholdt, Erika de 113
Braudel, ferdinand 114
Buchanan, James 109, 112
  déspota benevolente 110
Buchanan, James M.
  Doctorado Honoris Causa 7
Byron, George 115

C
Caballero de la Triste Figura 114
Cairncross, Frances 51, 52, 59
Calderón de la Barca, Pedro 115
Cámara de Hacienda 28
Carga
  fiscal 15, 16, 18, 19, 20
  impositiva 18, 19
  tributaria 15, 16, 17, 18, 19
Carlyle, Thomas 114
Carta de las Naciones Unidas 62
Castán Tobeñas, José 67
Castillo Armas, Carlos 42
CATO 19
Católicos 119
Cédula
  de notificación 32
  de vecindad 27
Centesimus annus 118
Centro de Opción Pública del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales 7
Centros de Información de Redes 87, 94, 95
Cerezo Arévalo, Marco Vinicio 47
Chamorro, Violeta 99, 111
Chateaubriand, Francois 115
Chaucer, Geffrey 115
Chiang Kai Chek 115
Chile
  Ley General de Telecomunicaciones 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59
Cibernauta 94
Clase pequeño burguesa 103, 111
Clonacion 67, 68, 69, 70
Cobos, Salvador 42
Código
  Civil 11, 14
  de Enjuiciamiento 30, 37
  de Notariado 26, 27, 29, 31, 32, 37, 38
  ético 125, 126, 129
  Tributario 13, 14
Código Postal de la Republica de Guatemala 43
Código Telegráfico y Telefonico de la República de Guatemala 43
Códigos de operador 59
Cole, Julio 113
Colegio de Abogados de Guatemala 26
Collodi, Carlos 115
Comisión de la Paz (COPAZ) 139
Comisión Nacional de Reconciliación (CNR) 136, 137
Comisión para el Esclarecimiento Historico 135, 143
Common law 120
Compañía de Telefonos de Guatemala 42, 44
Compraventa 25, 33
Comunidades indígenas 144, 145, 146, 147, 150
Conducta humana 125
Condueño 11, 13
Congreso de la Republica
  atribuciones 16
Constitucion Politica 15, 16, 20
Constructivismo 120, 121
Consules 26, 29, 30
Contrato
  de donacion 24, 37
  solemne 23, 24
Contribuyente 12, 13, 14
Convencion de Viena sobre Asuntos Consulares 29
Convenio de Munich 27
Convivencia social 67
Cooperacion social 117, 118, 119, 121
Cooperativas 103, 106, 108
Copropiedad 11, 12, 13, 14
Copyright 75, 76, 77, 82, 83, 84, 85, 86
Corte de Constitucionalidad 21, 22, 27, 33, 34, 35
Corte Suprema de Justicia

Sección de estadigrafía 65
Cosmovisión cristiana 117
Crecimiento económico 78
Crédito fiscal 14
Croce, Benedicto 114
Cruzadas 114
Curtiss, Glenn 80
Cyber-squatter 90

D
Darío, Rubén 115
De León Carpio, Ramio 139
Debido proceso 32, 33, 35, 39, 64
Declaración Americana de los Derechos del Hombre 62
Defensorías indígenas 144
Degenkolb 24
Deístas 126
Denison, Edward 78, 83
Derecho
consuetudinario 145, 151
de marcas 87, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96
de propiedad 11
de propiedad intelectual 87, 89, 95, 96
humanos 135, 136, 137, 140, 143, 151
privado 12, 14
público 14
real 33, 35
registral inmobiliario 35
tributario 11, 13, 14
tributario internacional 28
Derecho de patentes 67
Derechos
defensa 64
del hombre 62
individuales 62, 63
Derechos de interconexión 54, 59
Derechos humanos
teoría 62
Derechos individuales 117, 118, 120
Desarraigado 141, 142
Descartes 126
Descartes, Renato 101
Descentralización 8
Desempleo 19
Deuda nacional 17
Deudor 14
Dewey, Joh 114
Diario de Centroamérica 46
Díaz Castillo, Roberto 63, 66
Dickens, Charles 115
Dickenson, Emily 115
Dirección General de Correos y Telégrafos 45
Dirección General de Teléfonos 45, 46
Dirección General de Telégrafos 43, 45
Directorio telefónico 56
Discriminación 144- 147
Documento
legalización 28, 29
notarial 22, 27, 36, 37, 38, 39
público 21, 28, 30, 31, 34, 36, 37
Dollymanía 67
Dostoiesvski, Fiodor 115
Du Teil, Oscar 42

E
Eastman Kodak 81
Economía 123, 124, 125
capitalista 76
de Mercado 16
nacional 18
Economía mixta 108
Einstein, Albert 115
Ejemplaridad 132
Ejército
conscripción militar 149
patrulleros civiles 149
servicio militar 149
El Cristo de Palacagüina 99
El Escorial 138, 150
El Origen de las Especies 114
El Príncipe 114
El Principito 115
Empirismo 126
Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones Internacionales
véase GUATEL
Empresarios 123, 124, 131
Escribanía de Gobierno 29
Escribano de Cámara y de Gobierno 28
Escuela de la opción pública 110
Escuela de Salamanca 123
Escuela de Telegrafía y Capacitación 42
Escuela de Telegrafía, Telefonía, Radiotelegrafía y Radiotelefonía 42
Escuela escocesa 118
Espacio cibernético 87, 90, 92, 96
Espectro radioeléctrico 52, 53, 54, 58
Esquipulas II 136, 137, 138, 139, 149
Estado
de Derecho 16, 139, 141, 142, 146, 148, 150, 152, 153
funciones 15, 16
Estados Unidos
Constitución de 1787 77
Ley formal sobre patentes 77
Estatismo 119
Estrada Cabrera, Manuel 42, 43
Etica
empresarial 123, 125, 127, 129
realista 123, 126, 127, 128, 132
relativista 126
subjetivista 126
Exhibición personal
análisis sustantivo y procesal 61, 63
véase también hábeas corpus
Extorsión 123, 129, 130, 131, 132

F
Fabro, Cormelio 120
Facismo 101
Factor 13, 14
Falacias intencionalistas 100
Fausto 114
Fe cristiana 126
Fichte, Johann 114
Fideicomiso 24, 33, 148
Fiduciario 33
Figuras delictivas
abuso contra particulares 65
abuso de autoridad 65
detención irregular 65
Filosofía del derecho 118, 121
Filosofía moral 123
Flaubert, Gustave 115
Flores, Nidya de 113
Fondo de Tierras 148
Ford, Henry 80, 83
Franja Transversal del Norte 148
Franklin, Benjamin 77, 83
Fratti, Giovanni 113
Freud, Sigmund 115
Friedman, Milton 7
Capitalism and Freedom 81, 83

G
Garantía hipotecaria 23
Garantías
constitucionales 61, 62, 64, 65
procesales 61–64, 65
Gentile, Giovanni 114
Giuliani Fonrouge, Carlos M. 28, 39
Globalización 70
Gnoseología 121
Gosplan 109
Graham Bell, Alexander 80
Gran Marcha 115
Griliches, Zvi 78, 84
Grondona, Mariano 119, 121
Guatel
desmonopolización 41, 47, 48

H
Hábeas corpus
véase también Exhibición Personal
Hanckel, Lissa 113
Hayek, Friedrich A. 7, 61, 62, 66, 77, 84, 100, 101, 102, 104, 105, 107, 111, 112, 119, 120, 121, 122
Hermanos Grimm 115
Herzog, Werner 108
Hitler, Adolf
Mi lucha 115
Hoerdelin 115
Homo economicus 110
Hugo, Víctor 115
Hume, David 76
Husserl, Edmund 114

I
Ibsen, Henrik 115
Idealismo 126
Identificación tributaria 12, 13
Idioma 144, 150
Iluminismo 120
Imperativo moral 126
Impuestos
reducción 15, 17, 18, 19, 20
Impunidad 64, 140, 143, 144, 151, 152
Incentivos 79, 80, 81
Indefensión 145
Industria automovilística 80
Ingresos fiscales 17
Instituto Roslin 67, 69, 70
Internet
motores de búsqueda 93
Internet Assigned Numbers Authority (IANA) 89, 94
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) 89, 94
Invenciones biotecnológicas 67
Inventario 32
Iusnaturalismo 120, 121

J
Jarach, Dino 12, 14
Jaspers, Karl 114
Juan Pablo II 118
Juárez-Paz, Rigoberto 99

Juicio arbitral de equidad 69
Juzgado Privativo de Tierras 29

K
Kafka, Franz 115
Kant, Emmanuel 118
Know how 69, 70
Kublai Kan 114

L
La Divina Comedia 114
La piñata 111
Lange, Oscar 109
Legalidad 127
Ley de Contrataciones del Estado 53
Ley de Inversión Extranjera 52
Ley de Migración 27
Ley de Radiocomunicaciones 51, 52
Ley del Impuesto Sobre la Renta 12, 14
Ley del Organismo Judicial 26, 27, 28, 29, 30, 145
Ley General de Telecomunicaciones 47
  Antecedentes 51, 53
  Derechos de Interconexión 54, 59
  Fundamentos 51, 53
  Operador de red 54, 57
  Recursos esenciales 54, 56, 59
Ley natural 117, 118, 119, 120, 121
Ley reguladora del uso y captación de señales vía satélite y su distribución por cable 52
Leyes de la oferta y la demanda 100, 102
Libertad 15, 16, 18, 20, 68, 135, 136, 140, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153
  defensores 62
  individual 62, 63, 66
Licencia de uso 68, 69, 70
Lope de Vega, Félix 115
López de Soler, Edith 65
Loterías 32, 33
Lutero, Martín 115

M
Macnider, Stanley 42
Magna Carta inglesa 115
Mann, Thomas 115
Mao 115
Máquina de vapor 81
Marca
  comercial 75, 76, 77
  registrada 76, 77
Marco Polo 114
Marcuse, Herbert 114
Marginación social 147
Matrimonio 22, 23, 30
May, Karl 115
Mazariegos Fernández, Luis Antonio 63, 66
McLuhan, Marshall 114
Medios de prueba 30, 31, 32, 36, 37
Mercado de telecomunicaciones
  liberalización 51, 54, 58
Michelet, Jules 114
Michigan State University 68
Mil y una Noches 114
Millán-Puelles, Antonio 126
Miller, Roger LeRoy 105, 106, 112
Ministerio de Finanzas 14
Ministerio Público 37
Minugua 140
Mises, Ludwig von 109, 118, 119, 122
Monterroso, Marialys de 113
Moral 18, 123, 124, 125, 126, 130
Mujer indígena 145, 146

N
National Science Fundation (NSF) 94
Naturaleza humana 117, 118, 119, 120
Nazismo 101
Neokantismo 120
Network Solutions Inc. (NSI) 94
Newton, Isaac 115
Nietzsche, Friederich 114
Nombres de Dominio
  Administradores 87
  Sistema 87, 88, 89, 90, 93, 94, 96
Norma moral 126
Normas consuetudinarias 144, 145
North, Douglass 78, 79, 85
Notariado 21, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 38
Notario
  responsabilidad civil 37
Nueva Zelandia 19

O
Obligación
  fiscal 12
  tributaria 12, 13, 14, 27, 28
Ocupación de bienes 32
Olivero, Lucía 113
Opción Pública 7, 8
Operadores 54, 55, 56, 58, 59
Orden
  espontáneo 111
  social 101, 102, 104
Orden espontáneo 117, 119, 120
Organización de Estados Americanos 137
Organización Internacional del Trabajo (OIT) 147
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
  Centro de Arbitraje y Conciliación 92
Orlando el Furioso 114
Ortega, Daniel 103, 109
Oveja Dolly 67

P
Palme, Olof 109, 111
Panavision International 91
Patente
  costo 75, 80, 82
  de comercio 13, 14
  monopolio 76, 77
  propiedad 75, 77
  y progreso técnico 75, 78
Pecado original 118
Peirce, Charles 114
Peralta Azurdia, Enrique 44, 45
Pérez de Antón, Francisco 113
Persona 129, 132
  física 12
  jurídica 12, 13, 14, 24
Pinocho 115
Piratería 79
Plagio 63, 64
Planificación económica 109
Plant, Arnold 76, 83
Poder adquisitivo 17
Poder público 15, 16
Política económica 16, 18, 19
Políticas anti-natalidad 119
Popper, Karl 118, 120, 122
Posadas, Dinora 113
Positivismo 126
  jurídico 15
Precio justo 123
Precios topes 101, 104
Presidentes
  De León Carpio, Ramiro 139
  Serrano Elías, Jorge 138, 139
Presunción de inocencia 64
Primera Guerra Mundial 80
Principio a priori 118
Principios
  territorialidad 28
Privatizacion 8
Privilegios monopólicos 75, 76, 80
Procesos judiciales 21
producción 70
Producción ganadera 67, 68, 69, 70
Propiedad 18
  derecho 76, 77, 79, 81, 82, 83
  intelectual 69, 70, 71, 75, 76, 82, 83, 85, 86
  privada 75, 76, 146
Propiedad privada 103, 106, 112
Protestos 32
Protocolo TCP/IP 88
Protocolos 26, 27, 30, 31
Publicidad del proceso 64

Q
Quetzaltenango 42, 44
Quezada Toruño, Rodolfo 138
Quiñones Solórzano, Edmundo 22

R
Racionalismo 126
  constructivista 101, 107, 108, 112
  crítico 107
Racionalismo iluminista 120
Ramírez, Sergio 99, 100, 101, 103, 107, 108, 109, 111, 112
  Adiós muchachos 100
Rand, Ayn 115
Ranke, Leopold von 114
Reagan, Ronald 17
Reconciliación nacional 136, 140, 150, 151, 152
Red de telefonía 57
Redes de fibra óptica 52
Reforma agraria sandinista 103
Registro
  Civil 30, 35
  de la Propiedad 23, 31, 35, 36, 39
  de Poderes 33, 35
  General de la Propiedad 29, 33
  Mercantil 13, 33, 35, 37
  publico 28
Renacimiento 114
Renovatio contractus 24, 25
Resolucion de conflictos 69
Revolución Industrial 78, 79, 81, 82, 114
Revolución Liberal 23, 29
Revolucion sandinista 99, 100, 106, 112

Ricardo 124
Risorgimento italiano 115
Rosales Pichardo, Jorge Edwin 61, 62, 66

S
Sagan, Karl 116
Saint Euxépery, Antoine
El Principito 115
Salario real 17
Salgari, Emilio 115
San Juan de la Cruz 115
Sancho Panza 116
Sandinistas 99, 100, 103, 105, 107, 109, 110, 111
Santa Teresa 115
Schliemann, Heinrich 114
Schopenhauer, Arthur 114
Secretaría de Fomento 44, 45
Sendero Luminoso 115
Sentencia injusta 117
Serra, María Mercedes 63, 66
Serrano Elías, Jorge 138, 139
Servicio de Comunicaciones Radiotelegráficas y Radiotelefónicas de la República 45
Servidumbre 23
Shakespeare, William 115
Shelley, Percy 115
Sistema nacional de comunicaciones eléctricas 44
Smith, Adam
La Riqueza de las Naciones 124
Teoría de los Sentimientos Morales 124
Soborno 123, 129, 130, 132
Socialismo 100, 102, 106, 108, 109, 112, 119
Sociedad 12
Sociedad abierta 102, 104, 105, 106
Software 82, 83
Solow, Robert 78, 86
Solzhenitsyn 115
Somoza Debayle, Anastasio 99, 111
Sosa, Claudia 113
Spengler, Oswald 114
Stillman, Charles L. 99
Subastas 32, 33
Subjetivismo 123, 126
Sujeto pasivo 12, 13, 14
Suma Teológica 114
Superintendencia de Telecomunicaciones 55, 57, 58, 59
Superpoblación 119

T
Tecnología apropiada 69
Telecomunicaciones de Guatemala 54, 59
Telefonaktitiebolaget L. M. Ericsson 44
Telefonía
distancia internacional 47
local 47
rural 47
Televisión por cable 52, 53
Teoría del Conocimiento 101
Termes, Rafael 68, 71
Territorialidad 28
Testimonios 29, 30-33, 36
Tierras
comunales 146
Titulaciones supletorias 146
Toeppen, Dennis 92
Toledo Ordóñez, José 55, 58
Toledo, Roderico 42, 48
Tolstoi, Alekséi 115
Toynbee, Arnold 114
Tradicionalismo irracionalista 121
Transferencia de biotecnología agropecuarias 68
Tribu 99, 102, 103, 104, 109
Tributos 28, 33
Tropical Radio 45
Turgot 114

U
Ubico, Jorge 42
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) 135, 138, 140, 151
Unión de hecho 22
Unión Internacional de Telecomunicaciones 53
Universidad de Glasgow 123
Urcuyo, Francisco 99
Utopía Liberal 118

V
Valencia, Jaime A. 26
Vargas Llosa, Mario
comadreja 62
Vásquez Martínez, Edmundo 138, 153
Velarde, Caridad 105-106, 112
Verne, Julio 115
Vico, Juan Bautista 114
Viteri, Ernesto 24, 39
Vivienda 147

W
Watt, James 80, 81
Wheelock, Jaime 108
Winckelmann 114
Wright, Orville 80
Wyld, Andrés 113

X
Xerox 81
Xorostiaga, Javier 104

Se terminó de imprimir en los talleres
de *Editorial Amigos del País*, el 5 de marzo
de 2001. El tiraje fue de
750 ejemplares.

UFM-BIBLIO
091994

UNIVERSIDAD FRANCISCO MARROQUÍN
FACULTAD DE DERECHO
APARTADO POSTAL 632-A, 01910 GUATEMALA, C.A.
TEL.: (502) 361-2411, FAX: (502) 361-2421